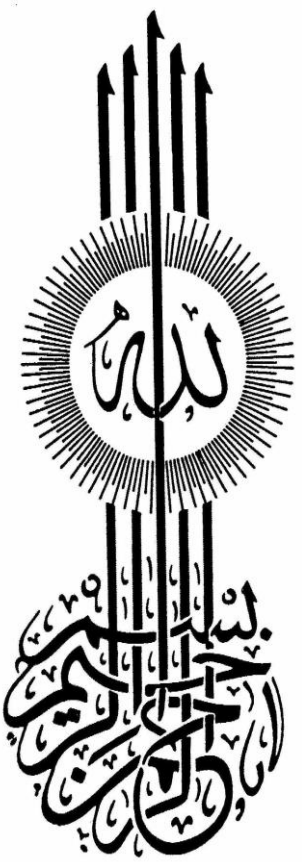
جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون

# النظرية العامة للالتزامات

## القسم الأول

# مصادر الالتزام

تأليف
الأستاذ الدكتور
إسماعيل عبد النبي شاهين
أستاذ القانون المدني المتفرغ
بكلية الشريعة والقانون بطنطا
ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق



## المقدمة

**مصدر الالتزام:** يقصد به الواقعة القانونية المنشئة له Fair juridique، فعقد البيع هو مصدر لالتزام المشتري بدفع الثمن؛ والعمل غير المشروع، كإتلاف مال الغير هو مصدر الالتزام بالتعويض الذي يلزم به من تسبب في هذا الضرر .

والتقسيم التقليدي الذي أخذ به القانون المدني الفرنسي ومعه أكثر القوانين اللاتينية يحصر مصادر الالتزام في خمسة هي: العقد، وشبه العقد، والجريمة، وشبه الجريمة، والقانون .

**فالعقد contrat:** هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو أكثر في ذمة كل من المتعاقدين أو أحدهما؛ كعقد البيع: ينشئ التزاما على عاتق البائع بتسليم البيع، والتزاما على عاتق المشتري بدفع الثمن والوديعة ينشئ التزاما في ذمة المودع لديه فقط، ولا ينشئ التزاما في ذمة المودع .

**وشبه العمد quasi:** عرفته المادة ١٣٧١ مدني فرنسي بقولها " أشباه العقود: هي الإعمال الإرادية البحتة الصادرة من الإنسان والتي ينشأ عنها التزام قبل شخصي آخر؛ وأحيانا التزامات متبادلة بين الطرفين"، فهو إذن عمل اختياري يترتب عليه نشوء التزام نحو الغير، مثل الفضولي؛ فهو يقوم بعمل اختياري نحو الغير، فيترتب عليه التزامه بأن يكمل العمل الذي بدأه، وأن يقدم عنه حسابا للغير.

**والجريمة délit:** فعل ضار يقوم به فاعله بقصد الإضرار بالغير؛ فيلتزم بالتعويض؛ كإتلاف الشخص مال الغير عمدا .

**وشبه الجريمة quasi delit:** عمل ضار ولكن ليس بقصد الإضرار بالغير؛ فهو يصدر عن إهمال ورعونة وعدم تبصر؛ وهو كالجريمة يلتزم فاعله بالتعويض عن الضرر . والقانون: La loi مصدر مباشر للالتزام – بمقتضى النص – في

حالات معينة كالالتزام بالنفقة، والتزامات الجوار، فهي التزامات تترتب على واقعة لا تدخل في الحالات السابقة [١].

وهذا التقسيم التقليدي لمصادر الالتزام الذي يرجع إلى القانون الروماني ظل سائدا حتى بداية القرن العشرين، حيث تعرض لنقد شديد أدى إلى رفض الفقه له لانعدام الأساس المنطقي الذي يقوم عليه هذا التقسيم[٢]، وترتب على هذا النقد أن عدل عنه كثير من الفقهاء، وعدلت عنه كثير من التشريعات، ويأخذ معظم الفقهاء في الوقت الحاضر، ومعظم التشريعات كالتقنين الألماني والتقنين السويسري، والمشروع الفرنسي الإيطالي، والتقنين الإيطالي الجديد، والتقنين المدني المصري الحالي – يأخذون بتقسيم مصادر الالتزام إلى خمسة هي: العقد؛ والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب، والقانون .

**فالعقد:** هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني؛ كعقد البيع، وعقد الإيجار، وعقد التأمين.. الخ.

والإرادة المنفردة: اتجاه إرادة الشخص إلى إلزام نفسه دون حاجة الإرادة أخرى لنشوء هذا الالتزام، مثل الوعد بجائزة لمن يقوم بعمل معين .

**والعمل غير المشروع أو الفعل الضار:** هو خطأ من الشخص يسبب ضررا للغير يلزم من تسبب فيه بالتعويض. كإتلاف مال الغير عمدا.

---

(١) د/ عبد المنعم الصدة: مصادر الالتزام ط ١٩٩٢م. ص ٣٤ – ٣٥ ، د/ عبد الودود يحيى – النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزامات ط ١٩٨٧م ص٣، د / السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ص١٥١ – ١٥٢.

(٢) د/ عبد الودود يحيى . المصدر السابق . الموضع السابق .

**والإثراء بلا سبب أو الفعل النافع:** هو واقعة تؤدي إلى إثراء شخص على حساب آخر، فينشأ عنها التزام المثرى بتعويض المفتقر بقدر افتقاره . ولكن في حدود الإثراء .

**والقانون:** هو مصدر مباشر للالتزام في الحالات التي لا يمكن فيها رد الالتزام إلى مصدر من المصادر الأربعة السابقة [١].

وهذا الترتيب الحديث المصادر الالتزام هو الذي أخذ به القانون المدني المصري، ويطلق على المصدرين الأولين: المصادر الإرادية، ويطلق على المصدرين الثالث والرابع: المصادر غير الإرادية، بينما الالتزامات الناشئة مباشرة عن القانون، تخرج عن نطاق النظرية العامة للالتزامات لأنها لا تخضع الضوابط مشتركة، وتدرس في المواضع المتفرقة التي وردت فيها .

**- خطة الدراسة:**

وفقا للترتيب السابق لمصادر الالتزام؛ فإننا سنتناول دراسة كل مصدر من هذه المصادر في باب مستقل، وبذلك تكون خطة الدراسة على النحو التالي :

الباب الأول: العقد

الباب الثاني: الإرادة المنفردة

الباب الثالث: العمل غير المشروع .

الباب الرابع: الإثراء بلا سبب .

الباب الخامس: القانون .

---

(١) د/ عبد الودود يحيى . المصدر السابق. د/ لبيب شنب – موجز مصادر الالتزام – المصادر الإرادية ط ١٩٨٠م ، ط بيروت ص ٣ .

# الباب الأول
# العقد وأحكامه

**تمهيد وتقسيم:** جاء القانون المدني المصري الحالي خلوا من تعريف للعقد ويجمع الفقه المصري على أن المقنن المصري بهذا قد أحسن صنعاً لأن وضع التعريفات عموماً من عمل الفقه، وذلك خلافاً لبعض التقنينات العربية، والأجنبية التي أبت إلا تنص على تعريف العقد وهو مسلك محل نقد، وقد عرف بعض الفقه العقد بأنه: " توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.

ففي عقد البيع يرتبط كل من البائع والمشتري بما اتفقت عليه إرادتهم من الآثار القانونية، كتسليم المبيع ودفع الثمن، والأثر القانوني للعقد، قد يكون إنشاء التزام كما في عقد البيع، حيث ينشيئ التزاماً على عاتق البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، والتزام الأأخير بدفع الثمن، وقد يكون هذا الأثر: نقل الالتزام كما في الحوالة، أو تعديله كما في الاتفاق على اقتران أجل الالتزام، أو إنهائه كما في الوفاء الذي ينقضي بالدين[1].

**وعليه سوف نقسم هذا الباب إلى أربعة فصول، على النحو التالي:**

(١) السنهوري، السابق، ص: ١٣٩، د/ حشمت أبو ستيت، السابق، ص: ٣٩، د/ عبد الفتاح عبد الباقي، ص: ٢٤، د/ الصدة، ص: ٥٠، د/، عبد الرازق فرج، السابق، ص: ٢٥.

## الفصل الأول

## انعقاد العقد (أركان العقد)

سبق أن ذكرنا أن العقد في فقه القانون المدني هو عبارة عن " توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، ومن ثم فإن تكوين العقد يحتاج إلى:

أ – وجود إرادتين أو أكثر متوافقتين وهو ما يعبر عنه بالرضا .

ب – اتجاه الإرادتين إلى إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو إنهائه؛ وهو ما يعبر عنه بالمحل.

ج– أن يكون الباعث على إنشاء الالتزامات المقصودة من العقد باعثا مشروعا؛ وهو ما يعبر عنه بالسبب .

د – إفراغ التراضي في الشكل الذي حدده القانون إذا كان العقد شكليا؛ كعقد الهبة؛ أو تسليم الشيء الواجب التسليم إذا كان العقد عينيا .

وتأسيسا على ما تقدم فإن جمهور الفقه[1] القانوني على أن أركان العقد هي: الرضا والمحل والسبب ومراعاة الشكلية إذا كان العقد شكليا؛ وأن شروط صحة العقد هي: توافر أهلية العاقدين؛ وسلامة الإرادة من العيوب وهي الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال .

ودراسة تكوين العقد تقتضي أن نعرض لأركانه في ثلاثة مباحث ثم نعرض

---

(١) انظر في ذلك: د . حشمت أبو سنيت – المرجع السابق ص ٧٠ ، د غانم – المرجع السابق ص ٧٧ ، د. أنور سلطان – المرجع السابق ص ٥٦ ، د. عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٨٥ ، مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٢ ص ٥ – ٧ ، ص ٢٠٥ – ٢٣٣، وانظر في فقه القانون الفرنسي بلانيول وريبير وبولا نجيه– المصدر السابق ف ١٧٣ ، ١٧٢، كولان وكابيتان – السابق جب) ف ٨٠.

الجزاء التي يترتب على تخلف أي من أركان أو شروط صحة العقد في مبحث رابع .

## المبحث الأول

## التراضي Le concentement

### تمهيد: وجود التراضي وصحته:

التراضي يوجد بوجود إرادتين متوافقتين، ووجود أو توافر شروط المحل والسبب؛ إلا أن التراضي وحده وإن كان يكفي لوجود العقد؛ إلا أنه لا يكفي لصحته، ولكي يكون العقد صحيحا ينبغي أن تكون الإرادتان المتوافقتان صحيحتين، ومن ثم فإننا سنعرض أولا لوجود التراضي في مطلب أول؛ ثم نعرض لصحة التراضي في مطلب ثان .

### المطلب الأول

### وجود التراضي

التراضي: هو توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث الأثر المقصود من العقد، ويتحقق هذا التوافق بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين[١] وعلى هذا نصت المادة ٨٩ من التقنين المدني المصري بقولها: "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير على إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"[٢].

(١) د. عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٨٧ ، وانظر د . السنهوري – السابق ص ٢١٢

(٢) يقابل هذا النص في التقينيات العربية: التقنين السوري م ٩٢) مطابق – التقنين المدني الليبي ٨٩ ) مطابق ( التقنين اللبناني – م ١٦٥ ، ١٧٨ ( موافق ) التقنين الأردني م ٩٧ ( موافق ) ، و التقنين العراقي م ٧٣ .

والمقصود بالإرادة هنا هي الإرادة التي يعتد بها القانون، وهي التي تتجه لإحداث أثر قانوني معين، والقانون لا يعتد بالإرادة إلا إذا كانت صادرة ممن له القدرة على معرفة ما يترتب عليها من آثار، ومن ثم لا عبرة بالإرادة إذا كانت صادرة ممن ليست لديه القدرة على التمييز كالطفل غير المميز، والمجنون؛ ومن فقد الوعي السكر أو مرض، ومن انعدمت إرادته الذاتية تحت تأثير الإيحاء ونحو ذلك(١)، ولا عبرة – أيضا – بالإرادة التي لم تتجه لإحداث أثر قانوني؛ كما في المجاملات الاجتماعية، وفي التبرع بتقديم خدمات مجانية كما لا عبرة بإرادة الهازل؛ ولا بالإرادة الصورية، ولا بالإرادة المعلقة على محض المشيئة، ولا بالإرادة المقترنة بتحفظ ذهني، لأن الإرادة في كل هذه الأحوال لا تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين(٢).

ويجب التنويه إلى أن الإرادة مسألة نفسيه؛ فلا يكفي وجودها فقط، بل ينبغي أن يعبر عنها، وأن تتطابق الإرادتين، ومن ثم فإن سنعرض لهاتين المسألتين كل في فرع مستقل؛ ثم نعرض في فرع ثالث لبعض صور التراضي العربون، والوعد بالتعاقد، والعقد الابتدائي ] .

## الفرع الأول

## التعبير عن الإرادة

### طرق ( وسائل) التعبير عن الإرادة :

الإرادة عمل نفسي لا يهتم القانون بها طالما بقيت كامنة في نفس صاحبها، فإذا

---

(١) د/ عبد الرزاق السنهوري–المصدر السابق ص٢١٣، د. إسماعيل غانم – المرجع السابق ص٧٩ ، د. لبيب شنب– المرجع السابق ص ٩٨، د. عبد الودود يحيي–المرجع السابق ص٢٨ .

(٢) انظر: د – عبد الودود يحيى السابق – الموضع السابق – د . عبد الفتاح عبد الباقي ص ٦١ ، والصدة – السابق ص ٨٨ ، والبدراوي – المصدر السابق ص ١٧١ ، د لبيب شنب – المصدر السابق ص ٦٩.

أفصح عنها صاحبها: كان هذا الإفصاح هو " التعبير عنها " أي أن الإرادة قد أخذت مظهرا خارجيا يدل عليها، فأي وسيلة تكفي للإفصاح عن الإرادة تعتبر تعبيرا عنها، ويستوي أن تكون هذه الوسيلة: الألفاظ، أو الكتابة أو الإشارة؛ أو مجر اتخاذ موقف يدل عليها[1]، وفي هذا تنص المادة ٩٠/١ من القانون المدني على أن: "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود".

**دلالة التعبير عن الإرادة ( التعبير الصريح والتعبير الضمني ) :**

يكون التعبير عن الإرادة صريحا إذا كان المظهر الذي اتخذه –سواء كان كلاما أو كناية . مظهرا موضوعا في ذاته للكشف عن هذه الإرادة حسب المألوف بين الناس، مثل استعمال لفظ البيع أو الشراء أو كتابتهما وسواء كانت الكتابة عرفية أم رسمية، في شكل سند، أو كتاب، أو إعلان.

وقد يكون التعبير الصريح عن الإرادة بالإشارة المتداولة عرفا، فإشارة الأخرس غير المبهمة تعبير صريح عن إرادته، وهز الرأس – حتى من غير الأخرس – عموديا دلالة على القبول، وهزها أفقيا دلالة على الرفض .

وقد يكون التعبير الصريح باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، مثل عرض التاجر لبضائعه على الجمهور مع بيان أثمانها، ومثل وقوف سيارات الأجرة في الأماكن المخصصة لذلك، فهذا يعد بمثابة

(١) د. عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٢٩ ، د . عبد الرازق حسن –المرجع السابق ص ٦٦ ، د . حسام الدين الأهواني – المرجع السابق ص ٥٩ ، انظر في ذلك نقض مدني في ٢٤/١/ ١٩٦٧م – مجموعة أحكام النقض السنة ١٨ رقم ٣٠ ص ١٩٠ .

إيجاب صريح موجه إلى كل الناس.[١]

**أما التعبير الضمني للإرادة:** فهو الذي ينبئ عن الإرادة بطريقة غير مباشرة، أي بوسيلة لا تتفق والمألوف بين الناس في الكشف عن هذه الإرادة، وإنما يمكن استنباطها من ظروف الحال[٢]، ومثال ذلك بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار وعلم المستأجر بذلك، إذ يعتبر هذا عقد إيجار جديد تم بينهما بإرادتين ضمنتين ( م ٥٩٩ مدني )، وقيام الوكيل بتنفيذ وكالة لم يقبلها صراحة، إذ يعتبر التنفيذ حينئذ قبولا ضمنيا.

## الفرق بين التعبير الصريح والتعبير الضمني عن الإرادة

الأصل أنه لا فرق بين التعبير الصريح والتعبير الضمني، فكل منهما يكفي للتعبير عن الإرادة، إلا أن هذه القاعدة ترد عليها عدة استثناءات نوجزها فيما يلي:

(أ) إذا اشترط القانون شكلا خاصا لإبرام عقد معين كاشتراطه الرسمية في الرهن مثلا، فلابد من مراعاة هذا الشكل كوسيلة وحيدة للتعبير عن الإرادة .

(ب) يشترط القانون في بعض الأحيان أن يكون التعبير عن الإرادة صريحا: مثل ما تقضى به المادة ٨٤٤/٢ مدني مصري من ضرورة وجود اتفاق صريح على الإعفاء من الضمان في القسمة بين المتقاسمين لتحقق هذا الإعفاء.[٣]

---

(١) السنهوري: المرجع السابق ص ٢١٨، د. عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٨٩، وانظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ج ٢ ص ٢٩ .

(٢) د . إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٨١ ، د . جميل الشرقاوي – المرجع السابق ص ٧٨ ، د . محمود جمال الدين زكي – المرجع السابق ص ٦٣ ، د . عبد الفتاح عبد الباقي – المرجع السابق ص ٦٤.

(٣) انظر أيضا ما تقصى به المادة ٥٩٧ مدني مصري في حالة التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ، من أن تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن .

(ج) إذا اتفق المتعاقدان على وجوب أن يكون التعبير عن الإرادة صريحا، ومثال ذلك اشتراط المؤجر على المستأجر ضرورة إخطاره كناية برغبته في إنهاء عقد الإيجار، وفي ذلك تنص المادة: ٩٠ / ٢ من التقنين المدني المصري على أنه: يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون، أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا . .

**عدم مطابقة العبارة للإرادة ( الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة ):**

الإرادة كظاهرة نفسية تمر بعدة مراحل: هي مرحلة التصور، ثم مرحلة التدبر، ثم مرحلة الحسم، وأخيرا مرحلة التعبير، فإذا وصلت الإرادة إلى هذه المرحلة فإنها تصبح ظاهرة اجتماعية بعد أن كانت ظاهرة نفسية. (١)

وإذا صدر التعبير مطابقا للإرادة: فلا صعوبة في الأمر، أما إذا اختلف التعبير عن الإرادة، فإن البحث يثور فيما إذا كان يجب أن نتحرى ونأخذ بالإرادة الحقيقية (الإرادة الباطنة)، أم أنه يتعين أن تلتزم حدود التعبير عن الإرادة ونأخذ بالإرادة الظاهرة ؟ ومثال ذلك: لو أخطأ تاجر ووضع سعر سلعة معينة على سلعة أخرى؟ أو إذا ذهب شخص لشراء ماكينة تصوير معينة، فأخطأ وأشار إلى ماكينة أخرى، في هذه الصور وأمثالها هل نأخذ بالإرادة الحقيقية للشخص ( الإرادة الباطنة) أم نأخذ بالإرادة الظاهرة ؟

**هناك في هذا الشأن نظريتان**:

**إحداهما: نظرية الإرادة الباطنة volonté interne:** وهذه تأخذ بها القوانين اللاتينية وخاصة القانون الفرنسي.

**ومضمون هذه النظرية:** أنه يجب البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين حتى يمكن تحديد التزاماتهما، لأنها الإرادة التي اتجهت لإحداث أثر قانوني، أما التعبير

(١) د . سمير تناغو – المرجع السابق ص ٣٤ – ٣٥ .

فليس سوى المظهر المادي للإرادة؛ فإذا اختلف هذا المظهر المادي عن الإرادة الباطنة – فالعبرة بهذه لا بذلك، وإذا تعذر الوصول إلى الإرادة النفسية ( الباطنة ) فما على القاضي إلا أن يتعرفها عن طريق الاقتراض.[1] أي يبحث عن الإرادة التي يفترض أنها حقيقية.

**ثانيهما: نظرية الإرادة الظاهرة volonté exterm:** وهذه تأخذ بها القوانين الجرمانية، وخاصة القانون الألماني.

**ومضمون هذه النظرية:** أن الإرادة شيء كامن في النفس ولا يمكن الاعتداد بها إلا إذا ظهرت في العالم الخارجي، فالقانون يرتب أثرا على الإرادة في مظهرها الاجتماعي؛ لا الإرادة المنطوية في أعماق النفس، والإرادة لا تأخذ مظهرا اجتماعيا، إلا بالتعبير عنها؛ لأن التعبير عن الإرادة هو الشيء المادي الذي يستطيع القانون أن يحيط به وأن يرتب عليه أثره، دون حاجة إلى تحسس ما تنطوي عليه النفس من نيات؛ فالعبرة عندهم بالتعبير عن الإرادة، ويستوي بعد ذلك أن يكون التعبير عن هذه الإرادة صريحا أم ضمنيا، كما لا أهمية لوسيلة هذا التعبير – إشارة أم كتابة .... الخ، كما قد يكون السكوت في أحوال خاصة مظهرا من مظاهر التعبير عن الإرادة: والأخذ بهذه النظرية هو الذي يؤدي إلى استقرار المعاملات، وطمأنة المتعاقد الذي يعقد بالمظهر الخارجي لا إرادة المتعاقد الآخر.

غير أن أنصار هذه النظرية لا يكتفون باعتبار المظهر الخارجي للإرادة دليلا عليها؛ يقبل إثبات العكس إذا تبين من الظروف أنه لا يتفق مع الإرادة الحقيقي، ولكنهم يعتبرون هذا المظهر الخارجي هو العنصر الأساسي للإرادة؛ وهو الذي يجب الوقوف عنده؛ وإذا صح اعتباره دليلا على الإرادة؛ فهو دليل لا يقبل إثبات العكس؛

(١) د. عبد الرزاق السنهوري – المرجع السابق ص ٢٢٢ ، د ، عبد الودود يحيى. المرجع السابق ص٣٠، والصدة – السابق ص٩٤، د. عبد الناصر العطار المرجع السابق ص٢٣.

فلا يمكن أن يسمح للمتعاقد أن يثبت أنه قصد شيئا آخر غير الذي صدر به التعبير.[١]

**تقدير النظريتين:**

يستبين من عرض مضمون النظريتين أنهما تختلفان اختلافا واضحا من حيث الأساس النظري لكل منهما، بيد أن أثر هذا الاختلاف ليس كبيرا سواء من الناحية العملية أو القانونية:

**فمن الناحية العملية:** لا يظهر الفارق بين النظريتين إلا إذا قام الدليل على ما يخالف التعبير، وإقامة مثل هذا الدليل أمر بالغ الصعوبة في كثير من الأحيان.[٢]

**ومن الناحية القانونية:** لا نجد تشريعا يأخذ بإحدى النظريتين بصورة مطلقة، إذ أن السياسة التشريعية تقوم دائما على ترجيح إحدى النظريتين فحسب.

ومن أجل ذلك نجد أن كثيرا من التقينيات الحديثة تأخذ بكل من النظريتين بالقدر الذي يقتضيه استقرار المعاملات، فالقانون الألماني يغلب الأخذ بالإرادة الظاهرة والقانون الفرنسي يغلب الأخذ بالإرادة الباطنة، أما القانون المصري فيأخذ بالإرادة الباطنة التي يمكن التعرف عليها[٣]، ولهذا لا يعتد فيه بتعبير الهازل؛ ولا بالتعبير الصوري، ولا بالتعبير المقترن بتحفظ ذهني، ولا يؤخذ بعبارة من كان سكرانا؛ ويجوز

---

(١) د . عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٣١ ، د . عبد المنعم البدراوي –المصدر السابق ص ٩٥ ، د . سمير تناغو – المرجع السابق ص ٣٥ ، د . حسام الدين الأهوائي – المرجع السابق ص ٦٦ – ٦٧ .

(٢) د. عبد الرزاق السنهوري – السابق – هامش ص ٢٢٥، وانظر د . إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٩٢ ، د . حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٨٨ ، د . سليمان مرقس – السابق ص ٦٥ – ٦٦ ، د جمال زكي – السابق من ٦٦.

(٣) د . عبد الناصر توفيق المطار – المرجع السابق ص ٢٤ ، د . عبد الحي حجازي المرجع السابق بند ١٦٠ ، والبدراوي – السابق ص ٨٥ .

إبطال العقد إذا شاب الإرادة: غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، وهذا هو منطق الإرادة الباطنة .

هذا ويستطيع القابل – أيضا – أن يرجع عن قبوله مادام لم يتصل بعلم الموجب، ومن ثم لا ينعقد العقد في هذه الحالة أما إذا اتصل بعلم الموجب فلا عبرة برجوع القابل؛ لأن العقد يكون قد انعقد ولا يستطيع أحد الطرفين أن يرجع عنه بإرادته المنفردة[١]، إذا كان من العقود التي لا يجوز الرجوع فيها بالإرادة المنفردة.[٢]

**أثر الموت أو فقد الأهلية فى التعبير عن الإرادة:**

تنص المادة ٩٢ من التقنين المدنى المصرى على أنه: " إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل".

ويستبين من هذا النص أن التعبير عن الإرادة إذا كان قبولا لإيجاب ومات القابل قبل أن يصل القبول إلى علم الموجب، فإن ذلك لا يمنع من إتمام العقد،[٣] إلا إذا

---

(١) د / عبد الرازق فرج – المصدر السابق ص ٨٨ ، ود/ الصدة – السابق – الموضع السابق ، والبدراوى – السابق ص ١٨١ ، د إسماعيل غانم –المصدر السابق – ص ١٠٠ ، د عبد الفتاح عبد الباقي – ص ٧٦ – ٧٧ .

(٢) انظر: رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه – سابق الإشارة إليها

(٣) ويضرب الأستاذ الدكتور / السنهورى مثالا لذلك بقوله: "شخص في مصر كتب لآخر في فرنسا يعرض عليه صفقة، فقبلها الآخر، ولكنه مات قبل أن يصل القبول إلى علم الموجب ، ولم يكن هذا عند وصول القبول إليه بعلم بموت صاحبه العقد في هذه الحالة يتم وفقا للتقنين الجديد ويجب على ورثة القابل في هذه الحالة (وعلى القيم فى حالة فقد الأهلية) وقد تم العقد أن يقوموا بتنفيذه في الحدود التي يلتزم بها الورثة بعقود مورثهم". السنهوري – السابق ص ٠٢٣٢.

تبين من التعبير ذاته أو من طبيعة التعامل أن شخصية القابل محل اعتبار أساسي في العقد.

**متى ينتج التعبير عن الإرادة أثره :**

التعبير عن الإرادة يوجد وجودا ماديا بمجرد صدوره عن صاحبه، ولكنه لا يوجد وجودا قانونيا، ولا ينتج أثره القانوني إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه، فإذا كان التعبير عن الإرادة إيجابا، فإنه لا ينتج أثره القانوني إلا إذا علم من وجه إليه الإيجاب، والأثر هنا صلاحية الإيجاب لأن يقترن به القبول.

وإذا كان التعبير قبولا، فلا ينتج أثره كذلك إلا إذا وصل إلى علم الموجب والأثر هنا اقتران القبول بالإيجاب وإتمام العقد، وقد نصت على هذا الحكم المادة ٩١ من التقنين المدني المصري بقولها: "ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك".

فهذه المادة تقرر أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره إذا اتصل بعلم من وجه إليه، ويكون لمن وجه إليه الإيجاب وعلم به أن يصدر قبولا ينعقد به العقد، أما قبل ذلك فليس للإيجاب وجود قانوني، ويستطيع الموجب أن يعدل عنه.

ونظرا لأن العلم مسألة يتعذر إثباتها فى كثير من الحالات، فقد أقام المشرع قرينة على العلم، هى وصول التعبير إلى من وجه إليه، لأنه بحسب المألوف من الحياة، فإن من وصل إليه تعبير عن الإرادة يكون قد علم به، مع مراعاة أن هذه القرينة القانونية قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس،[1] وهذا ما تقرره المادة ٩١ سابق الإشارة إليها.

---

(١) د. سمير نتاغو – السابق ص ٣٦. د. عبد الودود يحيى – السابق ص ٣٢ . د . عبد المنعم الصدة – السابق ص ١٠٠ . د . حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٨٨ ، د. عبد الحى

## الفرع الثاني
## تطابق الإرادتين في القانون المدني

### تمهيد: عناصر الرضا (الإيجاب والقبول):

ينعقد العقد بصدور إيجاب من أحد الطرفين، واقترانه بقبول من الطرف الآخر، ويجب أن تكون إرادة الطرفين متطابقتين.(١)

فتوافق أو تطابق الإرادتين يعنى: اقتران الإيجاب بقبول مطابق له، والإرادة الأولى تسمى "الإيجاب"، والإرادة الثانية تسمى "القبول"، وقد يحدث ذلك في مجلس واحد هو مجلس العقد، وقد يحدث ذلك في أكثر من مجلس واحد، كما يحدث في التعاقد بين الغائبين أو بالمراسلة، ونعرض في هذا الفرع لمعالجة هذه المسائل:

**أولا: الإيجاب:**

**ماهية الإيجاب وخصائصه:**

الإيجاب كما عرفته محكمة النقض: "هو العرض الصادر من شخص يعبر به على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين، بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد".(٢)

**ويستبين من هذا التعريف أن خصائص الإيجاب(٣) هي:**

أ – **يجب أن يكون الإيجاب جازما:** أى يكون صادرا عن نية باتة في التعاقد، فإذا كان من وجه إليه العرض لم يعقد عزمه نهائيا على التعاقد، فلا تكون بصدد

---

حجازى – المرجع السابق ص ١٥٦ ، د: سليمان مرقس – السابق ص ٦٩ .

(١)انظر المادة ٨٩ من التقنين المدنى المصرى .

(٢)نقض مدنى في ١٩/٦/١٩٦٩ – مجموعة المكتب الفني – طعن رقم ٣٢٣ – السنة ٣٥ ق ص١٥١٧.

(٣) أي الخصائص التي تميزه عن الدعوة للتعاقد أو المفاوضة .

إيجاب بل تجاه دعوة إلى المفاوضة بشأن التعاقد[١] لا يترتب عليها بذاتها أثر قانوني، وكل من المتفاوضين له الحق في قطعها دون تثريب عليه، إلا إذا كان ثمة ضرر لحق بالطرف الآخر، حينئذ قد تترتب المسئولية التقصيرية ويقع عبء الإثبات على من وقع عليه الضرر[٢] كأن يثبت مثلا أنه فاتته صفقة أخرى رابحة ما كان يرفضها لولا هذه المفاوضات.

ويلاحظ أن توافر نية التعاقد على وجه جازم أو عدم توافرها إنما هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض وفقا لكل حالة على حدة.

كما يلاحظ أن خصيصة الجزم فى الإيجاب لا تتعارض مع اقترانه بتحفظ صريح أو ضمني، وهو ما يسمى بـ "الإيجاب المعلق" كأن يعرض شخص بيع سلعة معينة بثمن معين مع احتفاظه بالحق في تعديل ثمن السلعة وفقا لتغير سعر السوق، فهذا يكون إيجابا معلقاً على شرط عدم ارتفاع الأسعار قبل القبول، بحيث إذا تم القبول قبل تغير الأسعار، فإن العقد ينعقد باقترانه بهذا الإيجاب.[٣]

**ب – يجب أن يكون الإيجاب كاملا:** ويقصد بذلك أنه يجب أن يكون الإيجاب شاملا لجميع العناصر الأساسية اللازمة لإبرام العقد، بحيث ينعقد العقد إذا اقترن به القبول، ففى البيع مثلا لا يعتبر العرض إيجابا إلا إذا عين فيه على الأقل الشيء المبيع والثمن تعيينا كافيا، ولكن لا يلزم تحديد مكان التسليم، أو من يتحمل نفقات

---

(١) د / لبيب شنب – المرجع السابق ص ١٠٤ ، د / عبد الرازق فرج – المرجع السابق – ص ٩٣ ، د / عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ٢٨

(٢) د / عبد الرازق السنهورى – السابق ص ٢٠٧ ، د / جميل الشرقاوى – المرجع السابق ص ٢٦٦ ، د / سمير تناغو – السابق ص ٣٧ .

(٣) د/ إسماعيل غانم: مرجع سابق، ص١٠٦، د/ السنهوري: مرجع سابق، ص٢٠٧

التسليم؛ لأن ذلك ليس من العناصر الرئيسية اللازمة للعقد، ومن ثم تحكمها القواعد التشريعية المكملة أو العادات الجارية.

كما لا يلزم لكمال العرض واعتباره إيجابا أن يكون موجها إلى شخص معين بالذات، فيمكن أن يكون العرض موجها للجمهور،(١) ويكون إيجابا صحيحا ينطوى على نية التعاقد مع أى شخص يبدى إرادته في قبوله،(٢) على أن يستثنى من ذلك العقود التي تكون شخصية المتعاقد فيها محل اعتبار كعقود العمل، والشركة، والإيجار، القرض ... الخ.

ويراعى أن العرض الموجه للجمهور هو مجرد دعوة للتعاقد، والاستجابة لهذه الدعوة هي الإيجاب (وليست هي القبول كما يظن البعض) ومن ثم يتعين أن يقترن به قبول الداعى حتى ينعقد العقد، وللداعى حرية رفض الإيجاب كما يشاء، إلا أن رفضه للإيجاب هنا يتقيد بمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق.(٣)

**أثر الإيجاب – القوة الملزمة للإيجاب:**

لا يترتب على صدور الإيجاب ذاته أي التزام على الموجب طالما لم يتصل بعلم من وجه إليه(٤)، فالأصل أن للموجب أن يرجع(٥) عن إيجابه طالما لم يقترن هذا

---

(١) Roger Nerson: La volonté de contracter, mélanges secrétsn, ١٩٦٤، P.٢٠٩ et suiv.

(٢) ومثال ذلك: الإيجاب الذي يوجهه التاجر متضمنا رغبته في بيع سلع أو سلعة معينة لدية ، فهو إيجاب موجه إلى الجمهور، أو إلى أي شخص يرغب في شراء السلعة المعروضة بالسعر المحدد لها في الإيجاب . انظر: د / لبيب شنب . المرجع السابق ص ١٠٦ .

(٣) د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٠٧ ، وانظر د / لبيب شنب – المرجع السابق – الموضع السابق .

(٤) د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٠٧ ، وانظر د / لبيب شنب – المرجع السابق – الموضع السابق .

(٥) م ٩١ مدنى مصرى .

الإيجاب بالقبول، ومثال ذلك أن يسترد الموجب رسالته من البريد قبل أن تصل إلى علم من وجهت إليه.

أما إذا وصل الإيجاب إلى علم من وجه إليه فإنه لا يجوز العدول عنه إذا كان قد اقترن بتحديد ميعاد للقبول، والإيجاب هنا يعتبر إيجابا ملزما، وعلى هذا الحكم نصت المادة ٩٣ مدنى مصرى بقولها:

"١- إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد.

٢- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة".

ويستبين من هذا النص أن الإيجاب يكون ملزما إذا عين ميعاد صريح للقبول، ويلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه حتى انقضاء هذا الميعاد، ويمكن أن يكون تحديد ميعاد القبول ضمنيا، كأن يستخلص من ظروف التعاقد أو من طبيعة المعاملة، كما لو عرض شخص على آخر أن يبيع له شيئا تحت التجربة، فهذا إيجاب يستفاد منه ضمنا أن صاحبه قصد الارتباط بإيجابه طوال المدة اللازمة للتجربة.(١)

وفي التعاقد بالمراسلة: يعتبر الموجب ملزما بالبقاء على إيجابه الفترة اللازمة لوصول خطابه مضافا إليها الفترة اللازمة لدراسة هذا الإيجاب والبت فيه، والفترة التي يستغرقها الخطاب الذي يحمل القبول.(٢)

**وخلاصة القول:** أنه إذا حدد ميعاد للقبول صراحة أو ضمنا التزام الموجب

---

(١) راجع فيما سبق د / عبد الرازق حسن فرج – المرجع السابق ص ٩٥ . د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٣٥ . د / لبيب شنب – المرجع السابق ص ١١٠

(٢) د / عبد الرازق السنهورى – المرجع السابق ص ٢٠٩ ، د . عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١١٣ ، د / عبد الحي حجازي – المرجع السابق جـ ٢ ص١٢٩ ، د / جميل الشرقاوى – المرجع السابق ص ٢٦٩ .

بالبقاء على إيجابه حتى انقضاء هذا الميعاد، وأساس التزام الموجب هو الإرادة المنفردة،[١] لاسيما أن القانون المصرى يعترف بهذه الإرادة مصدرا للالتزام، أما إذا لم يحدد في الإيجاب ميعادا للقبول على النحو السابق: جاز للموجب أن يرجع عن إيجابه في أي وقت يشاء.[٢]

**سقوط الإيجاب**:

للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل أن يصل إلى علم من وجه إليه، ومع ذلك يسقط الإيجاب بعد استكماله كيانه القانوني باتصاله بعلم من وجه إليه ويزول كل أثر له في الأحوال الآتية:

أ – برفضه ممن وجه إليه: سواء كان إيجابا ملزمًا[٣] أو غير ملزم[٤] حتى لو صدر الرفض قبل انقضاء الميعاد المحدد للقبول، ويعتبر رفضًا: القبول الذى يتضمن تعديلًا في الإيجاب.

ب – يسقط الإيجاب إذا كان معلقا على شرط وتخلف هذا الشرط سواء كان الإيجاب ملزمًا أم غير ملزم.[٥]

---

(١) د / عبد المنعم الصدة السابق ص ١١٣ ، د / عبد الودود يحيى – المرجع ( السابق ص ٧٦ ، د . السنهورى – السابق ف ١٠٤ ، د / حشمت أبو ستيت . المرجع السابق في ٩٩ ، وقارن: سليمان مرقس – السابق في ٧٩ ، د / عبد الحي حجازي – السابق ف٣٢٩.

(٢) د / عبد الودود يحيى – السابق ص ٧٦ ، والبدراوى – السابق ص ١١٤

(٣) الإيجاب الملزم بوجه عام: هو ما حدد فيه ميعاد للقبول ولم تنته بعد المهلة التي التزم فيها الموجب بالبقاء على إيجابه.

(٤) الإيجاب غير الملزم بوجه عام: هو الإيجاب الذى لم يصل إلى علم من وجه إليه (م ٩١ مدنى مصرى ).

(٥) د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١١٢ ، د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق – ص ٣٦ ، د / عبد الرازق فرج – المرجع السابق ص ٩٦ . د / حسام الدين الأهواني – مصادر الالتزام ط ١٩٩٥ م ص ٩٣ – ٩٤

ج – يسقط الإيجاب الملزم كذلك بانقضاء المدة المحددة لقبول الإيجاب قبل أن يقترن به القبول.

د – يسقط الإيجاب غير الملزم بانفضاض مجلس العقد[١] قبل أن يقترن به القبول، وسواء بعد ذلك أكان انقضاض المجلس حقيقة، كما إذا اقترن الراغبان في التعاقد – أم حكما – كما لو انصرفا عن موضوع التعاقد بأمر آخر.

هـ – يسقط الإيجاب غير الملزم إذا رجع فيه الموجب قبل أن يقترن به القبول، حتى ولو تم الرجوع قبل انفضاض مجلس العقد.[٢]

و – بتقدم عطاء يزيد عليه: فإذا جاء الإيجاب فى صورة عطاء تقدم به شخص في مزايدة علنية، فإن هذا العطاء يسقط إذا تقدم شخص آخر بعطاء أكبر، حتى ولو كان العطاء الأول باطلًا [٣] أو قابلا للإبطال[٤]، وذلك تأسيسا على أن عدم قبول العطاء الأول فورا يعتبر – فضالة.[٥]

---

(١) ويراعى أن انفضاض مجلس العقد يستوجب القول بأن الإيجاب يكون هنا غير ملزم ويكون في حالتي التعاقد بين حاضرين، أو في التعاقد بالمراسلة

(٢) د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٣٧ ، د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١١٣. د / لبيب شنب – المرجع السابق ص ١١١.

(٣) كمحام أو قاض يتقدم بعطاء فى مزاد لبيع شيء متنازع عليه إذا كان نظر النزاع يدخل في دائرة اختصاص المحكمة التي يباشر أي منهما عمله في دائرتها (م ٤٧١ مدنى) أو كان الذي تقدم بالعطاء الأكبر مجنونا مثلا

(٤) كما لو كان من تقدم بالعطاء الأكبر ناقص الأهلية أو كان رضاه معيبا فنقص الأهلية أو أي عيب من عيوب الإرادة التى تجعل العقد قابلا للإبطال

(٥) د / إسماعيل غانم: مرجع سابق، ص١٣٠، د/ لبيب شنب: المرجع السابق ص١١٣ .

## ثانياً: القبول:

### ماهية القبول وشرطه:

القبول acception هو: تعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب يفيد موافقته على الإيجاب، وهذا القبول يؤدى إلى انعقاد العقد متى وصل إلى علم الموجب وكان الإيجاب لا يزال قائما.(١)

فالقبول هو الإرادة الثانية في العقد فلا يتحقق توافق الإرادتين وبالتالي لا ينعقد العقد إلا بقبول الإيجاب ممن وجه إليه.

والأصل أن لمن وجه إليه الإيجاب حرية قبوله أو رفضه، إلا أن هذه الحرية قد يحد منها في بعض الأحوال تطبيق مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق.

### ويشترط في القبول حتى ينعقد به العقد الشروط الآتية:

أ – لما كان القبول هو الإرادة الثانية في العقد: وجب كما هو الحال في الإيجاب – أن تتوافر فيه الشروط التي تتعلق بوجود الإرادة الصحيحة واتجاهها إلى إحداث أثر قانوني معين، والتعبير عنها بأي صورة من صور التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا بين الناس، كما يجوز أن يكون التعبير عن القبول ضمنيًا كما لو تصرف شخص في بضاعة عرضت عليه بسعر محدد، فهذا التصرف من هذا الشخص يعتبر قبولا لشراء البضاعة بهذا السعر.

كما يجب أن يكون القبول صادرا من شخص ذى أهلية صحيحة وخالية من العيوب المؤثرة في صحة الرضا.(٢)

---

(١) د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٣٧ ، وانظر: د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١١٣ . د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١١٦.

(٢) انظر فيما سبق د/لاشين الغياتي – مصادر الالتزام ط ٢٠٠٣ ص ٧٢ – ٧٦.

ب – يجب أن يظل الإيجاب قائما حتى وقت القبول: فبهذا وحده يتحقق التلاقي بين الإيجاب والقبول، فإذا كان الإيجاب قد سقط لأي سبب، فإن القبول لا يؤدى إلى انعقاد العقد، إلا أنه قد يعتبر إيجابا جديدا يكون للموجب الأصلى (الذي أصبح موجبا له) حرية قبوله أو رفضه بشرط أن يتضمن كافة شروط قيام الإيجاب السابق بيانها، ومن ثم يجب أن يصل القبول إلى علم الموجب قبل سقوط الإيجاب.(١)

ج – يجب أن يكون القبول مطابقا للإيجاب: يجب لكي يتم العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب مطابقة تامة فى جميع المسائل التي تناولها الإيجاب وسواء أكانت مسائل جوهرية أو ثانوية، فإذا لم يكن القبول مطابقا للإيجاب بأن كان يتضمن إضافة أو نقصا أو تعديلا للإيجاب، فإن العقد لا ينعقد، ويعتبر هذا القبول رفضا للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا،(٢) لا ينعقد العقد إلا بقبوله ممن وجه إليه الإيجاب الأول. (٣)

فإذا عرض البائع بيع شيء يملكه بألف، فقبل المشترى شراء الشيء بخمسمائة، أو بألف مؤجلة، فإن البيع لا يتم، ويعتبر هذا القبول من المشترى إيجابا جديدا إذا قبله البائع انعقد العقد، وإلا فلا، وقد نصت على هذا الحكم المادة ٩٦ مدنى مصرى بقولها: "إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدًا".

**ويراعى أن عدم ذكر المسائل التفصيلية لا يمنع من انعقاد العقد،** ويكفى الإبرام

---

(١) د / حسام الأهواني – المرجع السابق ص ٥٥، د / لبيب شنب – المرجع السابق ص ١١٦ ، د / عبد الرازق فرج – المرجع السابق ص ٩٨ ، د / سمير تناغو –السابق ص٣٩.

(٢) د/ عبد الودود يحيى: السابق ص٣٨، د / إسماعيل غانم: المرجع السابق ص١١٥.

(٣) ٩٦ م مدنى مصرى، وانظر نقض مدنى فى ١٦/٢/ ١٩٦٧ طعن رقم ٦١ م ٣٣ ق – السنة ١٨ ص ٣٩٤ .

العقد أن يتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية، فيكفي – في عقد الإيجار مثلا – الاتفاق على الأجرة والعين المؤجرة والمدة، ومن ثم إذا لم يذكرا من يتحمل نفقات الحراسة أو أجرة المياه، انعقد العقد، وخضعت هذه المسائل الثانوية للعرف الجارى وطبيعة المعاملة[١].

بيد أن المتعاقدين إذا تعرضا للمسائل التفصيلية ولم يتفقا بشأنها، ولم يشترطا أن العقد لا يتم إلا بعد الاتفاق على هذه المسائل، فإن العقد ينعقد، ويقضى القاضي فيما يثار من نزاعات بشأن هذه المسائل وفقا لطبيعة المعاملة وأحكام القانون والعرف وقواعد العدالة وفقا للمادة ٩٥ مدنى مصرى[٢]، ولولا نص هذه المادة لما كان من المستطاع إعطاء القاضي سلطة إكمال ما نقص من إرادة المتعاقدين فى ضوء القواعد العامة، لأنه بذلك يخرج عن حدود مهمته العادية التى تقتصر على تفسير العقد.[٣]

ولكن إذا جعل المتعاقدان الاتفاق على هذه المسائل شرطا لتمام انعقاد فإن العقد لا ينعقد إلا إذا تم الاتفاق على هذه المسائل وفقا للمادة ٩٥ مدنى مصرى.

---

(١)انظر: د/عبد الودود يحيى– المرجع السابق ص٣٩ ، د/إسماعيل غانم–المرجع السابق ص ١١٦ ، د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١١٧ . د / لبيب شنب – السابق ص ١١٧ .

(٢) وتنص المادة ٩٥ مدنى على أنه: "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة".

(٣) د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١١٨ . وقارن د / عبد الرزاق السنهوري – الوسيط جـ ١ ط ١٩٥٢ ، ص ٢١٩ ، وانظر: مجموعة الأعمال التحضيرية جـ ٢ ص٤٦.

**التعاقد بين حاضرين في مجلس واحد [مجلس العقد]**:

سبق أن ذكرنا أن الإيجاب المقترن بأجل للقبول صريح أو ضمني يظل قائما طوال مدة الأجل، سواء كان التعاقد بين حاضرين أو غائبين.

أما إذا كان التعاقد بين حاضرين في مجلس واحد، ولم يقترن الإيجاب بأجل للقبول فإن الإيجاب يبقى قائما مادام مجلس العقد لم ينقض، وهذا المجلس يسمى بـ "مجلس العقد" وقد أشار القانون المدنى المصرى إلى مجلس العقد في المادة ٩٤ منه بقوله:

"١- إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل.

٢ – ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فورا إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينقض مجلس العقد".

ويستبين من هذا النص أن مجلس العقد إذا اتحد حقيقة أو حكما (كما في التعاقد بالتليفون أو الفاكس) فإن القبول يجب – كمبدأ عام – أن يصدر فور الإيجاب والعلم به.

وواضح أن هذا الحكم فيه كثير من العنت؛ لأن من وجه إليه الإيجاب قد يحتاج إلى وقت ليتدبر أمره قبل أن يصدر القبول، لذلك فإن التقنينات المدنية العربية – ومن بينها القانون المصرى – خففت من هذا العنت باللجوء إلى حكم الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، لأنه حكم منطقى يتفق مع مقتضيات التعامل،[1] ومن ثم لم تعد الفورية في القبول لازمة بل يجوز في القبول أن يتراخى عن الإيجاب في

(١) د / عبد الودود يحيى – السابق ص ٣٨ .

مجلس العقد مدة معقولة وبشرط ألا ينشغل فيها المتعاقدان بغير موضوع العقد ويبقى فيها الموجب باقيا على إيجابه.[١]

**التعاقد فيما بين الغائبين [ التعاقد بالمراسلة ]:**

التعاقد بين غائبين هو ذلك التعاقد الذى لا يجمع المتعاقدين فيه مجلس واحد يجعل بينهما اتصالا مباشرا، بحيث تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به[٢]، والتعاقد بين غائبين يتم بإحدى وسائل المراسلة كالبريد أو البرق أو برسول غير نائب، والذي يميز التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين أنه: في التعاقد بين حاضرين تنمحى هذه الفترة من الزمن ويعلم الموجب بالقبول في الوقت الذي يصدر فيه، أما في التعاقد ما بين غائبين فإن القبول يصدر ثم تمضى فترة من الزمن هي المدة اللازمة لوصول القبول إلى علم الموجب، ومن ثم يختلف وقت صدور القبول عن وقت العلم بة:[٣]

**تحديد زمان ومكان انعقاد العقد وأهمية ذلك التحديد:**

لا يثور البحث في تحديد زمان ومكان انعقاد العقد إلا في التعاقد بالمراسلة، أما فى التعاقد بين حاضرين فإن التعبير الذي يصدر من أحدهما يعلم به الآخر في ذات الوقت وفى نفس المكان، وفي التعاقد بالتليفون أو الفاكسميلي لا يثور البحث إلا في تحديد مكان التعاقد، هل هو المكان الذي يتواجد فيه الموجب أو الذي يتواجد فيه القابل، أما فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد، فالتعاقد بالتليفون يكون كالتعاقد بين حاضرين حيث لا يوجد فاصل زمني بين صدور القبول والعلم به.[٤]

---

(١) د/ السنهورى: المرجع السابق ص٢١٠ ، د/ إسماعيل غانم: المرجع السابق ص١١٩.

(٢) د . عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٣٤ ، د / عبد الناصر العطار المرجع السابق ص ٣٧ ، وانظر د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١١٨

(٣) د / عبد الرزاق السنهورى – المرجع السابق ص ٢٤٧ .

(٤) د / إسماعيل غانم – المصدر السابق ص ١٢٠ ، وانظر: د / لبيب شنب –المرجع السابق ص ١٢٠ – ١٢٣ ، د / حسام الدين الأهواني – المرجع السابق – ص ١٢٩ .

**وتظهر أهمية تحديد زمان انعقاد العقد فيما يلى:**

أ – في تحديد الوقت الذي تترتب فيه آثار العقد كانتقال الملكية في بيع منقول معين بالذات، وقيام حق المشترى في الثمار.

ب – إذا عدل الموجب عن إيجابه فإن العقد ينعقد إذا لم يعلم القابل بهذا العدول إلا بعد صدور القبول منه، وذلك في حالة القول بأن العقد يتم بإعلان القبول، ولا يتم العقد إذا أخذ بالقول القائل أنه لا يتم إلا إذا علم الموجب بالقبول.

ج – القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري وقت إبرام العقد، فإذا صدر بعد إبرام العقد قانون جديد يعدل من شروط التعاقد فإنه لا يسرى على أي عقد أبرم قبل العمل بأحكام القانون الجديد.

د – في تحديد بدء سريان تقادم الالتزام المترتب على العقد، فإذا كان هذا الالتزام منجزا فإن ميعاد التقادم يبدأ من وقت تمام العقد، لأن الدين يكون مستحق الأداء في ذلك الوقت.

هـ – إذ تم شهر إفلاس المدين التاجر فإن العقود التي يبرمها بعد شهر الإفلاس لا تسرى في حق الدائنين.

و – لا يستطيع الدائن في الدعوى البوليصية الطعن في العقد الصادر من مدينه إلا إذا كان دينه سابقا على هذا العقد.[١]

ز – يرجع في تقدير قيمة العقد فى دعوى تكملة الثمن إلى وقت البيع[٢] وقد تتغير هذه القيمة فى الفترة ما بين إعلان القبول والعلم به.

---

(١) مادة ٤٢٥ مدنى مصرى .

(٢) انظر د / عبد الرازق فرج – المرجع السابق ص ١٠٥ – ١٠٦ ، د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٣٤ .

ح – تختلف آثار استحالة التنفيذ تبعا لما إذا كانت هذه الاستحالة تمت بعد انعقاد العقد أو قبل الانعقاد، فإذا هلك المبيع – مثلا – قبل انعقاد العقد فإن محل الالتزام يصبح مستحيلا استحالة تحول دون إبرام العقد. (١)

**أما أهمية تحديد مكان انعقاد العقد فتظهر فيما يلى:**

أ – في تحديد مكان المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن العقد، إذ قد يتحدد الاختصاص على أساس مكان انعقاد العقد .

ب – فى تطبيق قواعد القانون الدولى الخاص، ذلك أن القاعدة عند عدم وجود اتفاق خاص بالنسبة للعقود التي يدخل فيها عنصر أجنبي أنها تخضع في شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه (م ٢٠ مدنى مصرى) وتخضع في آثارها عند اختلاف موطن المتعاقدين لقانون الدولة التي تم فيها العقد (م ١٩ مدنى).

**النظريات المختلفة في تحديد زمان انعقاد العقد** :

لقد آثار التعاقد بين الغائبين خلافا كبيرا بين فقهاء القانون المدنى حول تحديد زمان انعقاده، وظهرت بصدد ذلك أربع نظريات:

**النظرية الأولى: نظرية إعلان القبول: système de déclaration:**

ويرى أنصار هذه النظرية أن العقد: توافق إرادتين، فمتى أعلن الطرف الآخر قبوله للإيجاب المعروض عليه؛ توافقت الإرادتان وتم العقد، ومن ثم يعتبر التعاقد بين غائبين قد تم بمجرد إعلان القبول، وهذه النظرية تتفق ومقتضيات الحياة التجارية من وجوب السرعة في التعامل .

ولكن يؤخذ عليها خروج منطقها عن القواعد العامة: ليس من الضروري أن تكون الإرادتان متوافقتين باعلان القبول، إذ يجوز أن يعدل الموجب عن إيجابه ولا يصل

(١) انظر فيما سبق: د / عبد الرزاق السنهوري – المرجع السابق ص ٢٤٣ – ٢٤٤ د / عبد الرازق حسن فرج – المرجع السابق ص ١٠٦ – ١٠٧

عدوله إلى القابل إلا بعد صدور القبول، كما أنه ليس صحيحا أن القبول ينتج أثره بمجرد صدوره، فالقبول إرادة، والإرادة لا تنتج أثرها إلا من وقت العلم بها.[١]

**النظرية الثانية: نظرية تصدير القبول: systeme d'expédition**

ومضمون هذه النظرية: أنه يجب تصدير القبول زيادة على إعلان القبول حتى يكون الإعلان نهائيا لا يمكن الرجوع فيه ولا يمكن أن يسترده، وبهذا يصح إثبات القبول سهلا[٢]، ويتحقق التصدير بإرسال القبول بالبريد أو بالبرق أو ما شابه ذلك.

ولكن هذه النظرية هي الأخرى لم تسلم من النقد، إذ أن تصدير القبول لا يحول دون إمكان استرداده، فيمكن استرداد القبول من مصلحة البريد، أو العدول عن القبول ببرقية تصل قبل وصول الخطاب المتضمن القبول، ومن ثم فإن التصدير لن يزيد في قيمة القبول شيئا.

**النظرية الثالثة: نظرية استلام القبول: systeme de réception**

ومضمون هذه النظرية: أن العقد يتم حين يصل القبول للموجب ويتسلمه، أي يتسلم الرسالة أو البرقية المتضمنة للقبول، إذ أن القبول بذلك يصبح نهائيا لا يمكن استرداده.[٣]

ولكن يؤخذ على هذه النظرية – أيضا – أن مجرد تسليم القبول للموجب لا يعني بالضرورة علمه به حتى ينتج أثره؛ لأن من المسلم به أن التعبير عن الإرادة – كما

---

(١) انظر: د / عبد الرزاق السنهورى – المرجع السابق ص ٢٤١ ، د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٣٦ ، د / عبد المنعم البدراوى – المرجع السابق ص ٢٠٧ .

(٢) د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٣٦ ، د / عبد الرازق فرج – المرجع السابق – الموضع السابق .

(٣) وسواء بعد ذلك أن يعلم الموجب بالقبول أو لا يعلم به، لأن توافق الإرادتين يتم بوجود القبول

سبق بيانه – لا ينتج أثره إلا من وقت العلم به. [١]

**النظرية الرابعة: نظرية العلم بالقبول: Sysléme d'unformation**

وتعنى هذه النظرية أن العقد لا ينعقد إلا إذا وصل القبول إلى علم الموجب، إذ أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه، وأنصار هذه النظرية يرون أن وصول القبول قرينة على العلم به، وهي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس. [٢]

**موقف القانون المصرى من النظريات السابقة**:

أخذ القانون المدنى المصرى الحالي بنظرية " العلم بالقبول" وهذه النظرية تتفق مع المبدأ الذى أخذ به المشرع الوضعى المصرى في المادة ٩١ من القانون المدنى التي تنص على أنه: "ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك". وطبق المشرع هذا المبدأ على التعاقد فيما بين الغائبين حين نص في المادة ٩٧ من القانون المدنى على أنه:

"١– يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضى بغير ذلك.

٢ – ويفترض إن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول".

---

(١) انظر فيما سبق: د / عبد الرزاق السنهورى – المرجع السابق ص ٢٤٢ ، د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٢٥ – ١٢٦ ، د / حشمت أبو ستيت –نظرية الالتزام – الطبعة الأولى ص ٨٩ ، د / جميل الشرقاوى – المرجع السابق – ص ٢٨١ .

(٢) د / حشمت أبو ستيت – المرجع السابق – الموضع السابق ، وانظر: السنهوري " السابق ص ٢٤٣ ، ذ / جميل الشرقاوى – السابق ص ٢٨١ .

فهذا النص واضح في الأخذ بنظرية " العلم بالقبول " حين ترك تحديد وقت انعقاد العقد ومكانه لاتفاق المتعاقدين، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق ولم يقض القانون بحكم آخر في عقد خاص: كان الوقت الذي يتم فيه العقد هو وقت علم الموجب بقبول إيجابه وكان مكان انعقاد العقد هو المكان الذي يكون فيه الموجب وقت علمه بالقبول، ويعتبر وصول القبول قرينة على العلم به، ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس، كأن يثبت الموجب أنه لم يعلم بالقبول رغم وصوله إليه – لمرضه أو لسفره .... الخ، والأخذ بهذا المذهب يكفل – بحق – حماية كاملة للموجب، حيث يجعله غير مرتبط بالعقد إلا من وقت علمه بأن إيجابه قد قبل ممن وجه إليه.[1]

## مدى صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة؟

من المسلم به فقها وقضاء وتشريعا أن السكوت لا يصلح أن يكون تعبيرا عن الإيجاب، لأن الإيجاب ينطوى على عرض موجه من أحد الطرفين إلى الآخر، ولا يتصور أن يستخلص هذا العرض من مجرد السكوت، ومن ثم فإن البحث ينحصر في مدى صلاحية السكوت للتعبير عن القبول؟ والقاعدة العامة فى هذا الشأن أن السكوت في ذاته مجردا عن أية ظروف ملابسة له لا يكون تعبيرا عن الإرادة أو قبولا، لأن الإرادة عمل إيجابي والسكوت شيء سلبى[2]، ومن هنا كانت القاعدة

(١) د / جميل الشرقاوى – السابق ص ٢٨٢ ، وانظر – السنهوري – السابق ص٢٤٣ ، د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٢٦ ، د / عبد المنعم الصدة –المرجع السابق ص ١٣٩ – ١٤٠ ، د / عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ٠٣٨.

(٢) د / عبد الرزاق السنهوري – المرجع السابق ص ٢٢١ ، د / حسام الدين الأهواني المرجع السابق ص ٩٨ ، وانظر في الفقه الأجنبي: ديموج في الالتزامات جا ف ١٨٥ – ١٩٠ ، وانظر: مارية جوزيه ليتمان – رسالة عام ١٩٦٩م من ) ) جامعة ستراسبورج ... دور السكوت في التصرفات القانونية ..

الفقهية الشرعية التي تقول " لا ينسب لساكت قول " ولا يعتبر السكوت – أيضا – إرادة ضمنية لأن الإرادة الضمنية تستخلص من ظروف إيجابية تدل عليها[١]، أما السكوت فهو عدم، وأولى بالعدم أن تكون دلالته الرفض لا القبول، وهذا هو المبدأ العام [٢] الذي يقول به الفقه والقضاء فى مصر ومعظم التقنينات المعاصرة. [٣]

على أنه إذا كان مجرد السكوت لا يعتبر قبولا على النحو سالف البيان فإن هناك حالات استثنائية يعتبر فيها السكوت قبولا، وذلك إذا كان السكوت موصوفا أو ملابسا:

**أولا: السكوت الموصوف:**

هو السكوت الذى يصفه واضع القانون أو الاتفاق أو العرف بأنه قبول[٤] كما في الأحوال الآتية :

أ- إذا كان هناك نص في القانون يعتبر السكوت رضا: ومن هذا ما تقضى به المادة ٤٢١ من القانون المدنى: وهي تعالج البيع بشرط التجربة – من أنه يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه خلال المدة المتفق عليها، وإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا .

ب- إذا كان هناك اتفاق بين المتعاقدين على اعتبار السكوت رضا: كما لو اتفق صاحب العمل مع العامل على أن العقد بينهما يتجدد تلقائيا إذا لم يخطر أحدهما

---

(١)انظر: مجموعة الأعمال التحضيرية جـ ٢ ص ٥٧ .

(٢) د / عبد الرازق حسن فرج – المرجع السابق ص ٠٦٨

(٣) د / السنهوري – السابق – الموضع السابق

(٤) د / عبد الناصر العطار – السابق ص ٣٠ .

الآخر بعدم رغبته فى التجديد قبل إنهاء العقد بمدة معينة؛ فالسكوت عن الإخطار يعتبر قبولا بالتجديد.[١]

ج- إذا كان هناك عرف يقضى بذلك: كما لو أرسل مصرف إلى عميله بيانا بالحساب الجارى للعميل، وذكر أن عدم الرد على هذا الحساب في مدة معينة يعتبر إقراراً له، فسكت العميل عن الاعتراض عن الرد في وقت مناسب، فإن العرف وطبيعة المعاملة تقضى باعتبار سكوت العميل اعتمادا لهذا الحساب[٢]

**ثانيا: السكوت الملابس: silance circonctamcie**

وهو السكوت الذى يدل على القبول فى ظل الظروف التي لا بسته، وقد دلت عليه بوضوح القاعدة الفقهية الشهيرة بقولها "السكوت في معرض الحاجة بيان"، أى أن السكوت إذا صاحبته ظروف تخلع عليه دلالة الرضا، فإنه حينئذ يعتبر قبولا، وقد نصت على هذا النوع من السكوت المادة ٩٨ من القانون المدنى المصرى ويستفاد منها أن الحالات التي يعتبر السكوت فيها قبولا هي:

١- إذا كان العرف التجارى الذى جرى عليه العمل يقضى بأن السكوت يدل على الرضا[٣]، أو كانت طبيعة المعاملة تقضى بذلك كما إذا أرسل المتاجر البضاعة لمن طلبها وأضاف في الفاتورة ظروفا مستجدة، كاشتراط الوفاء بطريقة معينة سكت عنها المشترى ولم يبادر إلى رفضها فإن سكوته يعتبر قبولا لهذه الشروط [٤] .

---

(١) انظر د / إسماعيل غانم – السابق ص ٨٤ ، د/ عبد الرازق فرج – السابق ص٧١.

(٢) د / عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ٢٠ ، وانظر د / عبد الودود يحيى ٧١. د / ستيت ص ٩٠ . السابق ص ٣٩ ، د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٨٥

(٣) انظر: مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٢ ص ٥٩ .

(٤) السنهورى – السابق ص ٢٢٣ ، د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٩٣ د / عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ٣١ ، د / حسام الأهواني – المرجع السابق ص ١٠٠ . د / عبد الودود يحيى – السابق ص ٤١ ، وانظر مازو: السابق – فقرة ١٣٧ .

٢- إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل كما إذا اعتاد عميل استيراد البضائع التي يريدها من تاجر بالكتابة إليه فيرسل له التاجر ما يريد دون أن يطلب منه ضرورة القبول الصريح، فإذا طلب العميل شيئا وظل التاجر ساكتا كعادته ولم يطلب الرد، كان للعميل أن يعتبر هذا السكوت قبولا[١] .

٣- إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه، ثم سكت من وجه إليه هذا الإيجاب، فسكوته هذا يعد قبولا، كالهبة التي لا تشترط فيها الرسمية، تعرض على الموهوب له فيسكت، وكأن يعرض المؤجر على المستأجر تخفيض الأجرة فسيسكت الأخير، وكأن يعرض التاجر على العميل تخفيض ثمن السلعة فيسكت العميل[٢] .... الخ .

وننوه أخيرا إلى أن الحالات المذكورة، التي يعد السكوت الملابس فيها قبولا لا تعدو أن تكون أمثلة فقط، ولم ترد على سبيل الحصر، ومن ثم فكل سكوت تلازمه ملابسات تدل على الرضا فهو "سكوت ملابس" كما لو علم الموكل بتجاوز الوكيل حدود وكالته وسكت، فإن سكوته يعتبر إقرارا لعمل الوكيل. وكالمالك الحقيقي إذا علم أن الغير باع ملكه وسكت دون عذر، كان سكوته اقرارا للبيع وقبولاً له .

---

(١) السنهورى – السابق – الموضع السابق، د/عبد الرازق فرج – المرجع السابق ص ٧٢ ، د / عبد المنعم الصدة – السابق ص ٩٣ .

(٢)انظر فيما سبق: د / عبد الرازق حسن فرج – المرجع السابق ص ٧٢ – ١٧٣ د / عبد الناصر العطار–المرجع السابق ص٣١، د/إسماعيل غانم– المرجع السابق ص ٨٥ – ٨٩ .

## المطلب الثاني

## صور خاصة من التراضي

نقسم هذا المطلب إلى خمسة فروع وذلك على النحو التالي:

### الفرع الأول

### التعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة

**مضمون التعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة:**

قد يتم العقد في بعض الأحيان لا عن طريق الممارسة[١]، أي بعد التفاوض بين طرفيه – وهذا هو الغالب – وإنما يتم – أحيانا – بطريق المزايدة .

فيعرض موضوع العقد فى مزاد عام بغية إبرامه مع من يتقدم بأكبر عطاء، أو بطريق المناقصة بغية إبرام العقد مع من يتقدم بأقل عطاء، كما في بيع أموال المدين جبرا عن طريق القضاء، وقد يكون البيع اختيارا عن طريق المزاد، كتاجر يريد تصفية متجرة، أو بيع منقول أو عقار مملوك لشخص خاص عن طريق المزاد لمن يتقدم بأكبر عطاء، ومثال العقود التي تتم بطريق المناقصة "عقد المقاولة"، فتطرح العملية المراد إتمامها في مناقصة عامة للاهتداء إلى المقاول الذى يقبل إتمامها بأقل أجر، وكثيرا ما تلجأ الجهات الحكومية والشركات الكبيرة إلى طريق المناقصة للحصول على الأشياء المطلوب توريدها بأقل الأثمان.[٢]

**الإيجاب والقبول في عقود المزاد والمناقصة :**

طرح الصفقة فى المزاد أو المناقصة لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد حتى

---

(١) السنهوري – السابق ص ٢٢٦ .

(٢) د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٢٩ ، د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص٤٢ ، د / جميل الشرقاوى – المرجع السابق ص ٣٠٦.

ولو كان الإعلان عن المزاد مصحوباً بتحديد ثمن أساسي.[١] فطرح الصفقة في المزاد عبارة عن دعوة إلى التعاقد عن طريق التقدم بعطاء.

والتقدم بعطاء – استجابة لهذه الدعوة – هو الإيجاب، أما القبول: فلا يتم إلا بإرساء المزاد على مقدم العطاء، وقد عبرت عن هذه المادة ٩٩ من التقنين المدنى المصرى بقولها: "لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا". [٢]

**نوع الإيجاب في عقود المزايدة والمناقصة :**

الإيجاب الذى يتمثل بالعطاء فى عقود المزايدة: هو إيجاب ملزم – كما هو واضح في المادة ٩٩ مدنى مصرى، إذ هو قد اقترن بمهلة ضمنية تستخلص من ظروف الحال، ففى حالة المزايدة أو المناقصة التي تتم في مظاريف مغلقة، يلتزم كل من تقدم بعطاء بالبقاء على إيجابه خلال المدة اللازمة لتجميع العطاءات وفض المظاريف وفحص العطاءات المقدمة لإرساء المزايدة أو المناقصة على أحدها، ويسقط العطاء بانقضاء المهلة المعقولة إذا لم يقترن به قبول، وفى المزاد العلنى يلتزم صاحب العطاء بالبقاء على إيجابه الفترة المعقولة لكى يعطى الفرصة لغيره بالتقدم بعطاء أكبر، وإذا حدث ذلك سقط العطاء الأول حتى ولو كان العطاء الثانى (الأخير) باطلا[٣] أو قابلا للأبطال[١] وحكم بإبطاله.[٢]

---

(١) انظر نقض مدنى في ٩ / ١ / ١٩٦٤ – مجموعة أحكام النقض – السنة ١ ص ٦٨ – رقم ١٣ ، وانظر – فى المناقصة – نقض مدني في ٢٨/٣/ ١٩٦٦ المجموعة السابقة – السنة ١٧ ص ٧٣٠ رقم ٩٩ .

(٢) السنهورى – السابق ص ٢٢٦ ، د/ سمير تناغو – السابق ص ٤٢ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص١٠٩ ، د / جميل الشرقاوى – المرجع السابق ص ٣٠٧ .

(٣) العطاء الثاني يكون باطلا إذا صدر من شخص يحرم عليه القانون التعاقد في الصفقة المعروضة – كقاض أو محام يتقدم بعطاء فى مزاد لبيع عين متنازع عليها إذا كان نظر النزاع

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه إذا اشترط من دعا إلى المزاد أن له الحق في قبول أو رفض أى عطاء، فلا يتم إرساء المزاد إلا بعد أن يستعمل من دعا إلى المزاد هذا الحق.[٣]

## الفرع الثاني
## عقود الإذعان

**تعريف عقد الإذعان وخصائصه**:

عقد الإذعان contrat d'adhesion هو: العقد الذي يسلم فيه القابل بالشروط التي يضعها الموجب لإتمام التعاقد ولا يقبل مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضرورى تكون محل احتكار قانوني أو فعلى أو تكون المنافسة محدودة النطاق في شأنها [٤].

فالقبول في عقد الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط الموجب، فيقلبها أو يرفضها دون مناقشة؛ ومن ثم تكون إرادة أحد الطرفين – في عقد الإذعان – هى الإرادة المهيمنة في العقد وتفرض مشيئتها على جماعة من الأشخاص كما يرى بعض الفقه[٥]، وإن كنا نرى أن عقد الإذعان يمكن أن يقوم بين شخص وآخر كمن يحتكر سلعة ويبيعها لأحاد الناس بالشروط التي يفرضها.

---

يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر عمله في دائرتها ( م ٤٧١) مدنى مصر ( أو كان الذي تقدم بالعطاء الأكبر مجنونا .

(١)العطاء يكون قابلا للإبطال إذا كان من تقدم بالعطاء الأكبر ناقص الأهلية أو كان رضاه معيبا بعيب من عيوب الإرادة: الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال .

(٢) انظر: د/إسماعيل غانم– المرجع السابق ص ١٣٠ ، د / جميل الشرقاوي . السابق ص ٣٠٧ .

(٣) د/ عبد الودود يحيى: المرجع السابق، ص٤٣، ود/ الصدة – المرجع السابق ص١١٠.

(٤) د / عبد المنعم الصدة – المصدر السابق ص ١١٩ .

(٥) د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٣٢ .

**وقد تولت محكمة النقض المصرية[١] بمباركة من جمهور الفقه – [٢] تحديد خصائص عقد الإذعان فيما يلى :**

أ– أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين .

ب– احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا، أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة بشأنها منافسة محدودة.

ج– أن يكون الإيجاب موجها إلى الجمهور كافة وبشروط متماثلة وعلى نحو مستمر، والغالب أن تكون هذه الشروط في صيغة مطبوعة، ويقصد بها مصلحة الموجب.

**ومن أمثلة عقود الإذعان:** عقد الاشتراك فى المياه، والنور، والغاز، والتليفونات، وعقد النقل بالسكك الحديدية والطائرات والبواخر، والسيارات العامة، وعقد التأمين بأنواعه المتعددة وعقد العمل في المشروعات الكبيرة... الخ.

**والقبول في هذه العقود:** هو إذعان بالمعنى الدقيق، فالموجب يعرض إيجابه وشروطه بشكل نهائى ولا يقبل فيه مناقشة، وليس أمام الطرف الآخر إلا التسليم بهذه الشروط، لأنه فى حاجة إلى السلعة التي يعرضها الموجب، لذلك يكون مضطرا للقبول الذى يتمثل فى صورة إذعان للشروط المقدمة من الموجب.[٣]

---

(١) نقض مدنى في ١٢ / ٣ / ١٩٧٤ – مجموعة أحكام النقض – السنة ٢٥ – ص ٤٩٢ ، ونقض مدنى في ٣/٦ / ١٩٦٩ – المجموعة السابقة ص ٨٥١ .

(٢) د / عبد الرزاق السنهورى – المرجع السابق ص ٢٣٠ ، د / إسماعيل غانم –السابق ص ١٣٢–الصدة السابق ص١٢٠ ، د / حسام الدين الأهواني –المرجع السابق ص ١٢١ . د / عبد الودود يحيى – السابق ص ٤٤ ، د / لبيب شنب – المرجع السابق .

(٣) انظر: الصدة ص ١٢٣ ، د/ إسماعيل غانم ص ١٣٢ ، د / عبد الودود يحيى . ص ٤٥ ، د / سمير تناغو – السابق ص ٤٢ ، وانظر: مجموعة الأعمال التحضيرية جـ ٢ ص ٦٨ – ٦٩ ،

وقد عبرت المادة ١٠٠ من التقنين المدنى المصرى عن ذلك بقولها: "القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها".

**طبيعة عقود الإذعان:**

كانت طبيعة عقود الإذعان محل خلاف بين الفقهاء، حيث انقسم الفقهاء في شأن تحديد هذه الطبيعة إلى فريقين :

**الفريق الأول:** ذهب إلى إنكار وصف " العقود على عقود الإذعان، ويرى أن عقد الإذعان عبارة عن مركز قانوني منظم institution تنشئه إرادة منفردة يصدرها الموجب، فتكون بمثابة قانون أو لائحة تسيطر على تفسير العملية وتطبيقها، ويجب أن يعنى فى تطبيقه بمراعاة مقتضيات العدالة وحسن النية، ويرى أنصار هذا الرأى [١] أن عقد الإذعان لا يتوافر فيه الإرادة التعاقدية، وهى الإرادة المشتركة، أو لا توجد فيه المساواة التي تفرضها فكرة العقد، ومن ثم فهو أقرب إلى أن يكون قانونا يفرضه الطرف الأقوى اقتصاديا على جماعة المتعاملين معه، ويقتصر دور إرادة الطرف الآخر على مجرد الانضمام إلى هذه الجماعة، فيسرى عليه قانونها .

---

وانظر نقض فرنسي في٢١/١١/ ١٩١١ سيرى ١٩١٢ – ١ – ٧٢ ، ونقض فرنسي في ١٩/٢ / ١٩٢٣ ، داللوز – ١ –١٢٩ ، ومحكمة استئناف باريس فى ٢ / ١١ / ١٩٢١ جازيت دى باليه ١٩٢١ ٢ – ٤٦٢ ٠ –

(١) سالى – إعلان الإرادة – ف ٨٩ ، وهو ريو – مبادئ القانون العام – الطبعة الثانية ص ٢٠٦ وما بعدها ، ودولا: عقود الإذعان – رسالة ص ١٣٣ وما بعدها ديجي: الدولة والقانون الوضعى ص ٢٩٨ ، وانظر في هذا الشأن بوجه خاص رسالة الدكتور / عبد المنعم الصدة في عقد الإذعان ص ٨٩ – ١٣١ .

**وذهب الفريق الثاني:** وهم جمهور الفقه القانوني المصري والفرنسي[1] إلى أن عقود الإذعان: عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين، ويخضع لجميع القواعد التى تحكم سائر العقود؛ وذلك لأن إرادة الموجب لا تنتج أي أثر إلا بعد انضمام إرادة القبل لها، وبذلك تساهم الإرادتان فى إنشاء عقد الإذعان والمساواة القانونية – فقط – هي المطلوبة فى العقد، أما المساواة الاقتصادية فليست لازمة .

وقد حسم المشرع المصري هذا الخلاف واعتبر عقود الإذعان عقوداً قانونية تتم بتوافق الإرادتين وفقاً للمادة ١٠٠ مدني مصري السابق الإشارة إليها .

**الأحكام الخاصة بحماية الطرف المذعن في عقود الإذعان** :

الواقع أن التفاوت الاقتصادي فى مركز طرفي عقد الإذعان أمر ليس فى الوسع تجاهله، وتقتضي العدالة أن يهيئ القانون الوسائل التى تكفل حماية الطرف الضعيف حتى لا يكون ضحية جور الطرف القوي، ومن ثم فقد عملت التقنينات على حماية الطرف الضعيف بوسيلتين:

**الأولى:** خاصة بسلطة القاضي إزاء ما يمكن أن يتضمنه العقد من شروط تعسفية. **والثانية**: خاصة بتفسير العقد.

**أ – ففيما يتعلق بما يمكن أن يتضمنه العقد من شروط تعسفية:**

جاء القانون المدنى المصرى بنصوص عامة لتنظيم عقود الإذعان بوجه عام[2]،

---

(١) انظر: د / السنهوري – السابق ص ٢٣١، ٢٣٢ ، د / الصدة ص ١٢٥ وما بعدها ورسالته المشار إليها سابقاً، د / اسماعيل غانم المرجع السابق ص١٣٢–١٣٣ ، د/ سمير تناغو – السابق ص ٤٣ د / حسام الدين الأهواني – المرجع السابق ص ١٢٤ – ١٢٥، وانظر: ديموج ج ٢ ص ٦١٦ ،/ وجونو: رسالة في مبدأ سلطان الإرادة ص ٢٢٧ – ٣٠٣ . ولويس لوكا: الإرادة والسبب ط ١٩١٨ ص ٢٥٠ وما بعدها ديريه: الطبيعة القانونية لعقد الإذعان في مجلة القانون المدني ربع السنوية ١٩١٠ ص ٥٢٦.

(٢) وجاء بنصوص خاصة لحماية الطرف الضعيف في بعض العقود ، كما في عقد التزام المرافق العامة ، وعقد العمل ، وعقد التأمين.

فنص في المادة ١٤٩ منه على أنه "إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".

فقد جاءت هذه المادة بحكم استثنائى من القاعدة الأصلية التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، أي ليس من سلطة القاضي أن يعدل من شروط العقد أو يلغيها، إلا أن القانون المدني خرج على هذا الأصل وأعطى للقاضي سلطه استثنائية يحمى بها المستهلك من الشروط التعسفية التي تفرضها عليه شركات الاحتكار، والقاضي هو الذي يملك تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا أم لا، ولا معقب لمحكمة النقض على تقديره ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به، كما أن كل اتفاق يقيد من السلطة التي منحها المشرع للقاضي في هذا الشأن يكون باطلا. (١)

**ب – وفيما يتعلق بتفسير العقد:**

نصت المادة ١٥١ مدنى مصرى على: "١– يفسر الشك المصلحة المدين

٢– ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن".

**ويستبين من هذا النص:** أن الأصل هو أن الشك يفسر لمصلحة المدين، وقد استثنى المشرع من حكم هذا الأصل "عقود الإذعان" فقرر أنه عند غموض شرط من شروط العقد: يفسر الشك لمصلحة الطرف المذعن دائنا كان أو مدينا، لأن الطرف القوى هو الذى وضع شروط التعاقد، وكان بإمكانه أن يفرض على المذعن شروطا

(١) د / عبد الرزاق السنهورى – السابق ص ٢٣٤ ، د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٤٦ ، د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٢٧

واضحة لا غموض فيها، فإذا لم يفعل ذلك، فإنه يؤاخذ بخطئه وتقصيره ويتحمل تبعه عمله. [١]

## الفرع الثالث
## الوعد بالتعاقد

**تعريف الوعد بالتعاقد وأنواعه :**

الوعد بالتعاقد promesse de contrat هو: الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل إذا أظهر الموعود له رغبته في إبرام التعاقد خلال المدة المتفق عليها[٢]، فالوعد بالتعاقد: عقد لابد فيه من توافق إرادتين، ولكنه عقد تمهيدي، فهو يمهد لإبرام عقد آخر هو العقد الموعود به [٣].

والمادة ١٠١ من التقنين المدنى صريحة في أن الوعد بالتعاقد قد يكن ملزما لجانب واحد؛ أي ملزما للواعد، وقد يكون ملزما للجانبين:

**ومن أمثلة الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد:** مستأجر يقوم بإصلاحات هامة فى العين المؤجرة، ويحصل قبل قيامه بها على وعد من المالك ببيع العين إذا رغب في شرائها خلال مدة معينة، فيكون هذا وعدا بالبيع يلتزم به صاحب العين، وقد يكون الوعد وعدا بالشراء كأن يطلب مستأجر من المالك إجراء تعديلات جوهرية في العين المؤجرة، فيشترط المالك على المستأجر أن يشترى العين إذا هو رغب في بيعها إليه.[٤]

---

(١) انظر: د / عبد الودود يحيى – السابق – الموضع السابق ، د / إسماعيل غانم . المرجع السابق ص ١٣٥ ، د / سمير تناغو – السابق ص ٤٣.

(٢) انظر المادة ١٠١ من التقنين المدنى المصرى .

(٣) انظر: د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٣٧ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٤١

(٤) د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٣٧ ، د / جميل الشرقاوى – المرجع السابق ص ٢٨٦ ، د / محمد لبيب شنب – المرجع السابق ص ١٣٢

**ومن أمثلة الوعد بالتعاقد الملزم للجانبين:** كما لو وعد مالك عقار أن يبيعه لشخص وعده بشرائه، فيكون كل من طرفي الاتفاق واعدا وموعودا له في نفس الوقت.

ويستبين مما سبق أن الوعد بالتعاقد مرحلة وسط بين الإيجاب والعقد النهائي، فهو يزيد على الإيجاب لأنه عقد يتم بإيجاب وقبول، وهو دون العقد. النهائي لأن الإيجاب والقبول ينصان على مجرد الوعد بالتعاقد لا على عقد نهانى[١]

وتجدر الإشارة إلى أن الوعد بالتعاقد لا يقتصر على عقد البيع فقط، وإنما يتصور فى جميع العقود، فأى عقد قد يسبقه وعد بإبرامه قبل ذلك، وقد يكون العقد الموعود به عقد شركة أو أي عقد الوعد كعقد القرض ).

**شروط الوعد بالتعاقد:**

تنص المادة ١٠١ مدنى مصرى على: "١ – الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها .

٢ – وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد".

ويستبين من هذا النص أنه يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد الشروط الآتية :

١– أن يتم الاتفاق فى الوعد بالتعاقد على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه: فإذا كان العقد الموعود به بيعا وجب الاتفاق على المبيع والثمن، وإذا كان

(١) انظر: د / عبد المنعم الصدة – السابق – الموضع السابق ، د / جميل الشرقاوي – السابق – الموضع السابق .

قرضا وجب الاتفاق على مبلغ القرض، وإذا كان إيجارا وجب الاتفاق على العين المؤجرة والأجرة ومدة الإيجار.[١]

٢ – يجب تعيين المدة التي يلتزم فيها الواعد بالبقاء على وعده، ويلتزم الموعود له أن يظهر خلالها خياره بين قبول العقد ورفضه: وهذا الشرط لا تقضى به القواعد العامة، ولولا النص عليه صراحة في المادة ١٠١ ما سقط حق الموعود له في إبرام العقد النهائي إلا بالتقادم طبقا للقواعد العامة على أنه لا يشترط أن تعين هذه المدة صراحة، بل يمكن استخلاصها ضمنا من ظروف الحال، كما إذا كان العقد الموعود به لا يجدى تنفيذه بعد فوات ميعاد معين، فيكون هذا الميعاد هو المدة التي يجب خلالها إظهار الرغبة في التعاقد ويجوز أن يتفق الطرفان على أن مدة الوعد هي " المدة المعقولة "، وفي هذه الحالة تستخلص المدة من عناصر الاتفاق وظروفه، وعند الاختلاف على تحديدها يتولى القاضي أمر هذا التحديد.[٢]

**٣**– إذا كان العقد الموعود به عقد شكليا كعقدى الهبة والرهن الرسمي: وجب أن تتوافر الشكلية أيضا في الوعد بالتعاقد.

٤– يجب أن يكون الواعد أهلا لإبرام العقد الموعود به وأن تكون إرادته سليمة من العيوب وقت الوعد بالعقد، فإذا كان الوعد ملزما للجانبين على ما سبق بيانه – وجب أن تتوافر هذه الأهلية فيهما معا، أما إذا كان الوعد ملزما لجانب واحد فلا تشترط وقت الوعد الأهلية اللازمة للعقد النهائي إلا فى الواعد، أما الموعود له فلا

---

(١) د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٤١ ، د / جميل الشرقاوى – ص ٢٨٩ د / عبد الرازق فرج – المرجع السابق ص ١١٢ ، د / سمير تناغو – المرجع السابق ص ٤٦.

(٢)د / عبد الرزاق السنهوري – المرجع السابق ص ٢٥٤ ، د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٤٣ ، د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٥٢ ، د /جميل الشرقاوى – المرجع السابق ص ٢٨٩ ، ذ / أنور سلطان – المرجع السابق ص ١٣٨ .

يشترط فيه سوى التمييز وقت الوعد. [١]

**آثار الوعد بالتعاقد:**

إذا تم الوعد بالتعاقد صحيحا: ترتبت عليه آثار معينة، وتجب التفرقة في شأن هذه الآثار بين مرحلتين:

**الأولى: آثار الوعد قبل ظهور الرغبة أو حلول الميعاد** :

لما كان الوعد بالتعاقد عقداً غير تبادلي في الغالب الأعم، فهو بذلك لا يلزم الموعود له بشيء، أما الواعد فيلتزم بالبقاء على وعده حتى حلول الميعاد أو ظهور الرغبة فى التعاقد، فقبل أن يظهر الموعود له رغبته في التعاقد النهائي، لا ينشىء الوعد إلا التزاما على عاتق الواعد بإبرام العقد الموعود به، وهذا يقتضى ألا يقوم بأى عمل من شأنه أن يحول دون إبرام العقد النهائي، فإذا كنا بصدد وعد بالبيع التزم الواعد ألا يبيع تلك العين الموعود ببيعها إلى غير الموعود له قبل انقضاء المدة المحددة لإظهار الرغبة في التعاقد من عدمه[٢]، ويلتزم فوق ذلك بالمحافظة على هذا الشيء، فلا يجوز أن يتلفه، أو أن يغير من طبيعته أو شكله، كما لا يجوز له أن يرتب عليه أى حق للغير كرهته أو هبته للغير مثلا، وإذا أخل الواعد بالتزامه هذا كان مسئولا مسئولية عقدية عن الضرر الذي أصاب الموعود له وفقا لقواعد هذه المسئولية .

---

(١)د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٤٠ ، د / عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ٤٥ ، د / لبيب شنب – المرجع السابق ص ١٣٢ ، وانظر مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٢ ص ٧٢ – ٧٥ .

(٢) د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٥٣ ، د / عبد الرازق فرج – المرجع السابق ص ١١٤ ، د / جميل الشرقاوى – المرجع السابق ص ٢٩١.

فالوعد بالتعاقد لا يرتب أى أثر من آثار العقد الموعود به قبل إظهار الرغبة في التعاقد، فلا يكون الواعد ملتزما بنقل الملكية أو التسليم، كما أن الموعود له لا يكون ملتزما بدفع الثمن لأن كلا من الملكية ودفع الثمن إنما هما أثران لعقد بات تم انعقاده بصفة نهائية. (١)

**الثانية: آثار الوعد بعد ظهور الرغبة أو حلول الميعاد** :

إذا أظهر الموعود له رغبته في إبرام العقد الموعود به خلال المدة المحددة: انعقد العقد النهائي منذ ذلك الوقت دون حاجة إلى رضاء جديد من الواعد، لأنه سبق وأن أعلن رضاءه باتا منذ البداية عند الوعد بالتعاقد وأصبح كل من طرفيه ملتزما بما يرتبه هذا العقد من آثار. (٢)

وإذا توفى الموعود له قبل إظهار رغبته في إبرام العقد، فإن حقه في ذلك ينتقل إلى ورثته ما لم يتبين من بنود الاتفاق أو طبيعته أن شخصية الموعود له كانت محل اعتبار في التعاقد (٣)

ولا يكون لانعقاد العقد الموعود به أثر رجعي يستند إلى وقت العقد، فالعقد لا يعتبر منعقدا إلا من وقت ظهور الرغبة أو حلول الميعاد فحسب .

ويترتب على انعقاد العقد بإظهار الموعود له رغبته في التعاقد جميع الآثار التي يرتبها العقد الموعود به، ويلتزم الواعد بتنفيذ التزامه وإذا لم يقم بتنفيذ التزامه، كان

---

(١) د / عبد الرازق حسن فرج – المرجع السابق ص ١١٤ ، وانظر د / لبيب شنب –المرجع السابق ص ١٣٨ ، د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٤٨

(٢) د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٥٣ ، د / إسماعيل غانم – المرجع السابق – ص ١٤٥ ، د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٤٨ . د / عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ٤٦

(٣) د / لبيب شنب – المرجع السابق ص ١٣٩ .

للموعود له أن يجبره على تنفيذ التزامه عينا، عن طريق استصدار الموعود له حكما يلزم الممتنع بتنفيذ التزامه عينا إذا كان ذلك ممكنا.

وإذا كان التنفيذ يتطلب تدخل الواعد شخصيا، كما لو كان العقد الموعود به عقدا رسميا لابد أن يشترك الواعد في إبرامه: قام حكم القاضي مقام التنفيذ [١] على أن حكم المحكمة بوجود العقد هو حكم مقرر وليس حكما منشئا، لأن العقد الموعود به قد انعقد بمجرد إظهار الرغبة في التعاقد من قبل الموعود له إلا في الأحوال التي يجب إفراغ العقد في ورقة رسمية يجب على الطرفين الاشتراك في إعدادها [٢] فيكون الحكم هنا منشئا وليس مقررا .

## الفرع الرابع

## التعاقد بالعربون

### التعريف بالعربون ودلالته:

العربون: هو مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين عند إبرام العقد.

والغرض من العربون إما أن يكون حفظ الحق لكل من المتعاقدين في العدول عن العقد مقابل خسارة هذا العربون، وإما تأكيد العقد والبت فيه باعتبار دفع العربون بدءا في تنفيذه. [٣]

---

(١) د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٥٣ ، د / عبد الفتاح عبد الباقي –المرجع السابق ص ١١٤ ، د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٢٦ ،
د / لبيب شنب – المرجع السابق ص ١٣٩ .

(٢)انظر فيما سبق: د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٤٦ ، د / لبيب شنب المرجع السابق ص ١٣٩ ، وقارن د / عبد الحى حجازى في المصادر الإدارية ف ٢٩٢ حيث يرى أن حكم القاضي يكون منشئا في جميع الأحوال .

(٣) د / السنهوري – السابق ص ٢٦٠ ، د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٥، د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٥٤ ، والبدراوى – السابق ص ٢٤٠.

فالعربون وفقا للمفهوم السابق – ووفقا لما تقصده الإرادة المشتركة للمتعاقدين له دلالتين:

**دلالة العدول:** أى أن العربون يفيد الاحتفاظ بالحق في العدول عن العقد، وتأخذ القوانين اللاتينية القديمة وعلى الأخص القانون الفرنسي بهذه الدلالة.

**دلالة البت:** أي تأكيد العقد والبت فيه[١] بالبدء فى تنفيذ الالتزام عن طريق تعجيل جزء من المقابل الذي يلتزم أحد المتعاقدين بدفعه، كالأجرة في عقد الإيجار، والثمن في عقد البيع وهكذا، وتأخذ القوانين الجرمانية وبعض القوانين الحديثة كالقانون لسويسرى.[٢] علما بأن كلا الدلالتين قابلة لإثبات العكس، لأن المرجع في ذلك إرادة الطرفين.

وقد حسم المشرع الوضعى المصرى هذا الخلاف وأخذ بدلالة العدول، فنصت المادة ١٠٣ من التقنين المدني المصري على أنه:

"١– دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

٢– فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر".

**أحكام العربون:**

يستبين من النص السابق أن دفع العربون يعطى الحق لكل من المتعاقدين في العدول عن العقد خلال المدة التي يجوز له فيها ذلك، ما لم يقض الاتفاق بينهما

---

(١) انظر: د / عبد الرازق فرج – المرجع السابق ص ١١٧ ، د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٤٨ ، د / لبيب شنب – المرجع السابق ص ١٢٥ ) د / عبد الناصر العطار المرجع السابق ص ٤٨ ، وانظر نقض مدني في ١١/٥/١٩٨٨ طعن رقم ٧٢ س ٥٥ ق ..

(٢) مادة ١٥٨ التزامات .

بغير ذلك صراحة أو ضمنا، فإذا مضت مدة " خيار العدول " دون أن يعدل أحدهما " صار العقد باتا لا يجوز العدول عنه، وحينئذ يصبح العربون تنفيذا جزئيا للعقد، وإذا استعمل أحدهما حقه في العدول خلال مدة [ خيار العدول ] وجب عليه أن يدفع للمتعاقد الآخر قدر العربون(١)، فإذا كان هو الذي دفع العربون فقده، وأضحى العربون حقا لمن قبضه، وإذا كان هو الذي قبض العربون التزم برده ووجب عليه – فضلا عن ذلك – رد مثله، ويستوى في ذلك عقد البيع وعقد الإيجار وأي عقد آخر.(٢)

وتجدر الملاحظة – أخيرا – إلى أن خسارة العربون – أو رده ومثله – هي مقابل الحق في العدول عن العقد، إذ يلتزم به الطرف الذي عدل حتى ولو لم يترتب على العدول أي ضرر أو كان الضرر أقل من قيمة العربون ومن ثم فهو لا يعتبر تعويضا، ولا يعتبر شرطا جزائيا، لأن طبيعة العربون تختلف عن طبيعة الشرط الجزائي؛ لأن الأخير تعويض اتفاقي عن الضرر التي يتوقع المتعاقدان حدوثه عند الإخلال بالعقد، فالدائن لا يستحق أي تعويض إذا لم يلحقه ضرر، وللقاضي سلطة تخفيض الشرط الجزائي إذا كان ينطوى على تقدير مبالغ فيه لدرجة كبيرة، بينما أحكام رد العربون ومثله – أو فقده – لا تخضع لأى من هذه الأحكام الخاصة بالشرط الجزائي .

(١) د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٥١ ، وانظر: السنهوري – السابق ص٢٦٣ ، د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٥٥.

(٢) السنهوري – المرجع السابق – الموضع السابق .

## الفرع الخامس
## النيابة في التعاقد

### أولاً: التعريف بالنيابة في التعاقد:

النيابة Representation هى: قيام شخص يسمى "النائب" بإبرام تصرف قانوني باسم شخص آخر ولحسابه يقال له "الأصيل"، بحيث ينتج التصرف آثاره مباشرة فى ذمة الأصيل.(١)

ومثالها أن يتعاقد شخص باعتباره نائبا عن شخص آخر فى بيع عقار مملوك لهذا الأخير، فإن العقد يبرمه النائب مع المشترى، إلا أن ما يترتب على العقد من حقوق والتزامات ينصرف بصفة أساسية إلى شخص الأصيل لا إلى شخص النائب الذي قام بإبرام العقد.(٢)

وللنيابة دور هام في تنظيم علاقات الأفراد في المجتمع، فهي لا غنى عنها بالنسبة للأشخاص الذى لا تتوافر لهم أهلية التعاقد ولا يستطيعون إبرام العقود لحسابهم الخاص كالقاصر والمجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة والغائب ومن يلحق بهؤلاء، وهذه هي حالات النيابة القانونية كما أن النيابة فوائد كبيرة في تسهيل التعامل بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون بعيدا عن المكان الذي يجب إبرام التصرف فيه، أو لا تسمح لهم ظروفهم ومشاغلهم بإبرام التصرف بأن كانوا في سفر أو مرض مثلا أو لا يكونون على خبرة بموضوع التصرف، إذ يستطيع هؤلاء أن ينيبوا عنهم أشخاصا

---

(١) د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٥٢ ، وانظر في هذا المعنى د /عبد الرزاق السنهوري – المرجع السابق ص ٢٣٤ وما بعدها ط ١٩٨١ . د / عبد الفتاح عبد الباقي – المرجع السابق ص ١١٨.

(٢) د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٥٦ ، د / عبد الناصر العطار –المرجع السابق ص ٥٢ ، د / سمير تناغو – السابق ص ٢١.

يقومون بالعمل.[١]

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة جائزة فى كل التصرفات القانونية، ويستثنى من ذلك التصرفات التي أوجب القانون فيها أن تصدر من صاحب الشأن شخصيا ولا تجوز فيها النيابة كحلف اليمين.[٢]

**ثانياً: أنواع النيابة:**

من المسلم به أن النيابة لا تجوز إلا في الأعمال القانونية، وتنقسم بالنسبة إلى المصدر الذي يحدد نطاق سلطة النائب إلى: نيابة قانونية، ونيابة اتفاقية:

١- **فالنيابة القانونية:** هى التى يقرر القانون وجودها ويتولى تحديد سلطات النائب فيها، كما في نيابة الولى والوصي والقيم والحارس القضائي.

٢- **أما النيابة الاتفاقية:** فهى التى تتم بالاتفاق بين النائب والأصيل، ويحدد الاتفاق سلطات النائب، وأهم مثال لها: الوكالة .

وللنيابة تقسيم آخر من حيث المصدر الذي يعين شخص النائب: فقد تكون نيابة قانونية كما في نيابة الولى عن الصغير، وقد تكون نيابة قضائية كما في نيابة الوصى والحارس، وقد تكون نيابة اتفاقية كما في الوكالة، حيث يتم تعيين الوكيل باتفاق بينه وبين الموكل.[٣]

---

(١) د/ عبد المنعم الصدة المرجع السابق من ٥٠١٥٢ / لبيب شنب – المرجع السابق ص ٧٠، وانظر فى هذا المعنى بوجه خاص: مؤلفنا: مسئولية الوكيل في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة بالقانون الوضعي من الكويت ١٩٩٩م

(٢) انظر في موضوع النيابة فى التعاقد بوجه خاص رسالة الدكتور/ جمال مرسى النيابة في التصرفات القانونية – طبيعتها وأحكامها – رسالة دكتوراه من جامعة الإسكندرية ١٩٠١م.

(٣) انظر فيما سبق مؤلفنا مسئولية الوكيل – السابق ص ٦٥ – ٧٢ ، وانظر د / عبد الرزاق السنهوري – المرجع السابق ص ١٩٠ ، د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ٧٥ ، د / لبيب شنب – المرجع السابق ص ٧٠ .

**ثالثا**: **شروط النيابة**:

**الشرط الأول**: **حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل**:

إذا كان هناك تعاقد بالنيابة، فإن العقد ينعقد بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل، أي يعبر عن إرادته هو ولا يعبر عن إرادة الأصيل، وهذا هو ما يفرق بين التعاقد بنائب والتعاقد برسول[١]، والرسول على عكس النائب لا دخل لإرادته في إبرام العقد، وإنما يقتصر دوره على مجرد نقل إرادة أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حاملا رسالة مكتوبة يقوم بتسليمها، أو حاملا رسالة شفوية يقتصر على مجرد تبليغها، والعبرة في العقد الذى يتم بواسطة رسول بإرادة المرسل وحده، ولا ينظر إلى إرادة الرسول، ومن ثم لا يشترط أن تتوافر في إرادة الرسول المقومات اللازمة للإرادة والتعبير عنها، فيصح أن يكون الرسول صبيا غير مميز مادام قادرا على نقل إرادة المرسل إلى الطرف الآخر[٢] وعيوب الرضا لا ينظر فيها إلا إلى إرادة المرسل.

أما بالنسبة للنيابة فإن عيوب الرضا ينظر فيها إلى إرادة النائب لا الأصيل؛ فإذا وقع النائب في غلط أو تدليس أو إكراه، كان العقد قابلا للإبطال دون حاجة إلى البحث في إرادة الأصيل.[٣]

كما أن حسن النية وسوءها يتلمسان عند النائب لا عند الأصيل، وذلك في الأحوال التي يرتب فيها القانون أثرا على ذلك، فإذا تعاقد النائب مع مدين معسر

---

(١)انظر: د / عبد الرزاق السنهوري – المصدر السابق ص ٢٤٠ ، د / جميل الشرقاوى – المرجع السابق ص ٩٠ ، د / لبيب شنب – المرجع السابق ص ٧١ .

(٢) راجع: د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٥٦ . د / عبد الرازق حسن فرج المرجع السابق ص ١٢١ ، د / سمير تناغو – المرجع السابق ص ٢٣ .

(٣) د/ السنهوري: مرجع سابق، ص٢٤١.

جاز للدائنين الطعن في العقد بالدعوى البوليصية طبقا للمادة ٢٣٨ متى أثبتوا تواطؤ النائب ولو كان الأصيل حسن النية ... وهكذا.

غير أنه يلاحظ أنه في بعض الفروض يجب النظر بعين الاعتبار إلى نية الأصيل، ويتحقق ذلك فى النيابة الاتفاقية كما لو أثبت النائب أنه كان يتصرف وفقا لتعليمات محددة صدرت له من الأصيل راعاها النائب في إبرام العقد، فإذا وكل شخص شخصا آخر فى شراء شيء معين بالذات، وكان الموكل يعلم بما فيه من العيب والوكيل يجهل ذلك، فليس للموكل أن يرجع في هذه الحالة – على البائع بدعوى العيب بحجة أن الوكيل كان يجهل ذلك[1] إذا العبرة هنا بإرادة الأصيل، وقد عبرت عن ذلك المادة ١٠٤ من التقنين المدنى المصرى، فبعد أن نصت فى فقرتها الأولى على قاعدة الاعتداد بشخص النائب، عادت في فقرتها الثانية إلى النص على ما يأتي: "ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها".

**أما فيما يتعلق بأهلية التعاقد:** فإنه يفرق في هذا الشأن بين النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية.

**ففي النيابة الاتفاقية:** العبرة بإرادة الأصيل لا بإرادة النائب، ومن ثم وجب أن تتوافر في الأصيل الأهلية اللازمة لإبرام التصرف موضوع النيابة وقت إبرام النائب للعقد، أما النائب فلا تشترط فيه الأهلية الكاملة، وإنما يكفى أن يكون مميزا حتى تكون له إرادة يعتد بها .

---

(١) د / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٥٨ . د / عبد المنعم البدراوى – المرجع السابق ص ١٠٣ . د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٥٧ . د / محمد لبيب شنب – المرجع السابق ص ٧٢. د / جميل الشرقاوى – المرجع السابق ص ٩١

**أما في النيابة القانونية:** فيجب أن تتوافر الأهلية الكاملة في النائب حتى يمكنه أن يتولى رعاية مصالح الأصيل الذي قد يكون عديم التمييز أو ناقص الأهلية.[١]

**الشرط الثاني: إبرام التعاقد أو التصرف باسم الأصيل:**

المقصود بهذا الشرط أن تتوافر لدى كل من النائب والمتعاقد معه نية توجيه آثار العقد مباشرة إلى الأصيل، والصورة المثلى لذلك هي أن يعلن النائب وقت التعاقد أنه يتعاقد بصفته نائبا عن الأصيل.[٢]

ولكن لا يلزم أن يعلن النائب عن صفته صراحة؛ إذ يمكن أن يفهم ذلك من ظروف التعاقد، كما إذا باع مستخدم بضاعة مخدومه فى محل هذا المخدوم، وكقبطان السفينة يتعاقد عن صاحبها.

أما إذا لم يصرح النائب عند التعاقد بأنه يبرم العقد لحساب غيره، ولم يكن من تعاقد معه عالما بصفته كنائب، فإننا لا نكون بصدد نيابة، ولا تضاف آثار العقد إلى شخص الأصيل، بل تضاف إلى شخص النائب دائنا أو مدينا باعتباره أصيلا، أى متعاقداً لحساب نفسه،[٣] وفي هذه الحالة يطلق على النائب "الوكيل المسخر، أو "الاسم المستعار"، ويكون على النائب بعد أن يكسب الحقوق الناشئة من العقد أن ينقلها إلى الأصيل.[٤]

---

(١) السنهوري – المرجع السابق ص ٢٥٣ وما بعدها ، الصدة – المرجع السابق من ١٦٠ – ١٦١، د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٥٨ ، د / إسماعيل غانم – المرجع السابق – ص ١٥٩ ، د/ جميل الشرقاوى – المرجع السابق ص ٩٢.

(٢) د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٦١ ، وانظر نقض مدنى في ٢٩/١٢/ ١٩٦٠ مجموعة أحكام النقض – السنة ١٧ – رقم ٣٩٢

(٣) انظر في ذلك نقض مدنى في ٢٩/١٢/ ١٩٦٦ – مجموعة أحكام النقض المدنى –السنة ١٧ – رقم ٢٩٢ ص ١٩ – ٢٠ ، وانظر: لبيب شنب – السابق ص ٧٥ .

(٤) د / عبد الرازق حسن فرج – المرجع السابق ص ١٢٣ ، د / إسماعيل غانم –المرجع السابق ص ١١١، والبدراوى – السابق ص ١٠٥

**على أنه استثناءً مما تقدم:** تضاف آثار العقد الذي يبرمه النائب مباشرة إلى الأصيل، رغم أن النائب لم يعلن وقت إبرام العقد عن صفته كنائب والمتعاقد معه لم يعلم بصفته كنائب، وذلك في حالتين نصت عليهما المادة ١٠٦ مدنى:

**الأولى: إذا كان من تعاقد مع النائب من المفرض أن يعلم حتما بوجود النيابة:** كما في العقود التي يبرمها العاملون في المحلات التجارية دون أن يعلن هؤلاء العاملون عن صفتهم، وكما في التعاقد مع الوصى بالنسبة لأموال القاصر، فالمفروض أن من يتعاقد مع هؤلاء لابد أن يكون عالما بوجود النيابة.

**الثانية: أن يستوى لدى من يتعامل مع النائب أن يكون التعامل مع النائب أو الأصيل:** كما لو اشترى إنسان سلعة من متجر معين، فهو لا يعينه إن كان البائع له أصيلا أو وكيلا، ولا يعنى البائع أن يكون المشترى مشتريا لنفسه أو وكيلا مسخرا ( نائبا عن غيره).[١]

ففى هذا المثال وأمثاله تضاف آثار العقد إلى الأصيل مباشرة، حتى ولو كان صاحب المحل لا يعلم بوجود النيابة.

**الشرط الثالث: أن يكون تصرف النائب في الحدود المرسومة لنيابته:**

يشترط لانصراف آثار العقد إلى شخص الأصيل أن يكون النائب قد تعاقد داخل الحدود المرسومة لنيابته، وهذه الحدود يبينها القانون، كنيابة الولى أو الوصى، أو يبينها الاتفاق كما في الوكالة وقد نصت المادة ١٠٥ من التقنين المدنى المصرى على ذلك بقولها: "إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل".

(١) انظر مؤلفنا – مسئولية الوكيل – السابق ص ٢٣٧ ، د / عبد الرازق فرج – السابق ص ١٢٣، د. لبيب شنب – السابق ص ٧٦ ، د / إسماعيل غانم – السائل ص ١٦٣ .

كما نصت المادة ٢/١٠٧ من التقنين المدنى المصرى على أن " الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها".

**وتأسيسا على ما تقدم:** فإن النائب إذا تجاوز حدود وكالته فلن ينتج العقد أثره بالنسبة للأصيل سواء كان الوكيل حسن النية أو سيء النية، [١] ما لم يقره، فإذا أقره الأصيل كان الإقرار ذا أثر رجعى سواء كان الإقرار صريحا أو ضمنيا، كقيام الأصيل بتنفيذ تصرف النائب، وقد يستفاد الإقرار من السكوت، فينتج العقد آثاره في حق الأصيل من وقت إبرامه لا من وقت الإقرار، وإذا لم يقره فلن يكون لمن تعاقد مع النائب إلا الرجوع بالتعويض على النائب إذا كان له مقتض.[٢]

**واستثناء من ذلك تنصرف آثار العقد إلى الأصيل رغم مجاوزة النائب الحدود نيابتة في الحالات الآتية:**

أ – إذا كان النائب ومن تعاقد معه حسنى النية، وكان هذا الأخير يعتقد أن النائب يتعاقد في حدود السلطات الممنوحة له، مثال ذلك أن تنقضى النيابة بموت الأصيل أو عزل النائب، ويتم التعاقد دون علم النائب ومن تعاقد معه بذلك – وهذا ما يحدث في حالة النيابة الظاهرة – فهنا ينصرف أثر العقد الذي يبرمه النائب إلى الأصيل أو إلى خلفائه فى حالة وفاته[٣]، وقد عبرت عن هذا المعنى المادة ١٠٧

---

(١) كما لا ينصرف أثر التصرف إلى النائب لأن الفرض أنه يتعامل باسم الأصيل ولذلك يكون التصرف موقوفا.

(٢)راجع في هذا المعنى تفصيلا باستفاضة مؤلفنا – مسئولية الوكيل – السابق ص ١٢٥ – ٦٢٧ ، والمراجع المشار إليها فيه .

(٣) د/ عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٦٢ ، د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ١٦٥ ، د / أنور سلطان – السابق ف ٤٨ ، د / عبد الحي حجازي – السابق ج ٢ ص ٢٣٢ مورد / إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٦٧ ، د /حشمت أبو ستيت – ف ١٣٠ ، وانظر:

مدنى مصرى بقولها: "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه، حقا كان أو التزامًا يضاف إلى الأصيل أو خلفائه".

ب- إذا أثبت الوكيل أنه كان من المستحيل عليه أن يخطر الموكل سلفا باضطراره للخروج عن الحدود المرسومة للوكالة، وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف، كما لو وكل شخص شخصا آخر في بيع أرض زراعية فعرض المشترى على الوكيل أن يشترى كذلك المواشي والآلات الزراعية الموجودة بالأرض، وإلا لن يشترى الأرض خالية من ذلك: جاز للوكيل أن يفعل ما عرضه المشترى بشرط أن تدل الظروف على أن الموكل ما كان إلا ليوافق على تصرف الوكيل لو أنه علم به قبل نفاذه،[1] وفى هذه الحالة على الوكيل أن يبادر إلى إبلاغ الموكل بخروجه عن حدود الوكالة وإحاطته علما بسبب ذلك [ انظر م ٧٠٣ مدنى مصرى ] .

**رابعاً: آثار النيابة:**

التعاقد الذي يتم بطريق النيابة يرتب آثارا معينه في عدة علاقات قانونية وهى: العلاقة بين النائب ومن تعاقد معه (الغير) والعلاقة بين الأصيل والغير، والعلاقة بين النائب والأصيل النائب:

---

نقض مدنى في ٢٨/٢/ ١٩٧٦ طعن رقم ٤٠٠ ص ٤٧ ق ، نقض مدني في ٣٠/٥ / ١٩٦٣ مجموعة المكتب الفني – السنة ١٤ – ص ٧٥٩

(١)السنهوري – الوسيط ج١ ص ٢٥٢ ط ١٩٨١ ، د / عبد الرازق فرج – المال ص ١٢٥ ، د/ عبد الودود يحيى – السابق ص ٦٣ ، وانظر مؤلفنا السابق مسئولية الوكيل – ص ١٣٢ والمراجع المشار إليها فيه .

**أولا: أحكام العلاقة بين النائب ومن تعاقد معه:**

لما كان النائب يتعاقد باسم الأصيل ولحسابه – كما قدمنا – فإن أثر العقد الذي يبرمه النائب ينصرف إلى الأصيل، ويترتب على ذلك أن النائب لا يستطيع أن يطالب الغير بحق من الحقوق التى أنشأها العقد إلا إذا كانت النيابة شاملة لتنفيذ العقد بالإضافة إلى إبرامه، وفى هذه الحالة يوجه المطالبة باسم الأصيل لا باسمه شخصيا، كما لا يستطيع الغير أن يطالب النائب شخصيا بأي التزام ترتب على العقد، بل يرجع على الأصيل إلا إذا كانت النيابة – أيضًا – شاملة تنفيذ العقد، وإذا كان النائب لا يلتزم بالعقد – أساسا – فإن هذا لا يمنع من التزامه بخطأه، ويكون مسئولا عن تقصيره في أداء مهمته نحو الغير أو نحو الأصيل أو نحو الاثنين معا بحسب الأحوال.(١)

**ثانيا: أحكام العلاقة بين الأصيل والغير :**

في العلاقة بين الأصيل والغير تنشأ علاقة مباشرة لأنهما هما المتعاقدان وتنصرف إليهما آثار التصرف، فيكتسب الأصيل الحقوق التي تولدت له عن العقد، ويرجع بها مباشرة على الغير المتعاقد مع النائب دون وساطة النائب كما يرجع الغير على الأصيل مباشرة بما رتبه له العقد من حقوق.

وقد نصت المادة ١٠٥ مدنى مصرى على ذلك بقولها: "إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل".

---

(١) د / عبد الرزاق السنهورى – المرجع السابق ص ٢٥٤ ، د / عبد الودود يحيى السابق ص ٦٣ ، د / إسماعيل غانم – السابق ص ١٦٦ ، د / سمير تناغو السابق ص ٢٦ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ٩٨ ، لبيب شنب – السابق ص ٧٦ – ٧٧

**ثالثا: أحكام العلاقة بين النائب والأصيل:**

هذه العلاقة يحكمها المصدر الذي أنشأ النيابة، فإذا كانت النيابة اتفاقية فإن العقد المبرم بين النائب والأصيل (عقد الوكالة أو عقد العمل) هو الذي يحدد الالتزامات وحقوق كل منهما قبل الآخر، وإذا كانت النيابة قانونية أو قضائية تولى القانون تحديد هذه الحقوق [١] .

**خامساً: تعاقد الشخص مع نفسه:**

التعاقد مع النفس هو العقد الذي يتم عن طريق الجمع بين صفتين فى شخص واحد، بحيث يقوم هذا الشخص (النائب) بدور الطرفين (النائب والأصيل) فيصدر تعبيرين عن الإرادة متقابلين فى شأن مصالحهما المتعارضة،[٢] مثل أن يوكل شخص فى بيع شئ فيشتريه هو لنفسه، ومثل أن يكون وكيلا عن البائع فى البيع ونائبا عن المشترى وهكذا، ففى المثال الأول نجد أن الشخص الواحد يكون نائبا عن غيره وأصيلا عن نفسه، وفى المثال الثاني نجده نائبا عن كل من المتعاقدين.

وقد اختلفت التشريعات فى هذه المسألة فمنها ما ذهب إلى تحريم تعاقد الشخص مع نفسه، كالقانون الألماني والمشروع الفرنسي الإيطالي والقانون الأنجليزي والقانون المدنى المصرى الحالى، ومنها ما يبيحه بوجه عام كالقانون الفرنسي والقانون السويسرى والقانون المصرى القديم، ولكن لا يوجد تشريع أطلق التحريم أو الإباحة بصورة مطلقة، فالتي حرمت تعاقد الشخص مع نفسه أباحته في فروض معينه،

(١) د / إسماعيل غانم – السابق ص ١٧٠ ، عبد الفتاح عبد الباقي – السابق ص ١٢٨ وما بعدها ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ١٦٨ جميل الشرقاوي – السابق ص ٩٩ ، لبيب شنب – السابق ص ٧٧ ، سمير تناغو – السابق ص ٢٦.

(٢) د / الصدة – السابق ص ١٦٨ ، وانظر: بلاينول وريبير وبلانجي جـ ٢ فـ ١٤٥ .

والشرائع التي أباحته حرمته في ظروف استثنائية نزولا على مقتضيات الحياة العملية.[١]

وقد حسم القانون المدنى المصرى الحالى هذه المسألة؛ حيث أورد نصا عاما يحرم تعاقد الشخص مع نفسه إلا فى بعض الحالات، إذ نصت المادة ١٠٨ بأنه: "لا يجوز الشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة".

ويتضح من هذا النص أن الأصل فى القانون المصري أن تعاقد الشخص مع نفسه لا يجوز يستوي فى ذلك أن يكون أصيلا عن نفسه ونائباً عن غيره أو يكون نائباً عن الطرفين كما سبق بيانه.

وقد طبق الشارع المصري هذا الأصل فى نصوص كثيرة فى باب البيع[٢]، وأحكام الولاية على المال.[٣]

ويرجع تحريم الشارع للتعاقد مع النفس إلى أن النائب ينفرد وحده بالتوفيق بين مصلحتين متعارضتين، وهذا وضع لا تتوافر فيه الحماية الواجبة لمصلحة الأصيل أو مصلحة أحد الموكلين للنائب.[٤]

---

(١) السنهورى – مصادر الالتزام ط ١٩٥٢ ص ٢٠٢ .

(٢) انظر المادتين ٤٧٩ ، ٤٨٠ اللتين تحرمان على النائب أن يشتري ما ينط به بيعه ولا يجوز للسماسرة والخبراء أن يشتروا ما عهد إليهم بيعه .

(٣) انظر المواد ٦ ، ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ التي ترحم على الولي أن يؤجر مال القاصر لنفسه أو لمن يكون الوصي نائباً عنه إلا بإذن من المحكمة .

(٤) السنهوري – السابق ص ٢٠٤ . الصدة – السابق ص ١٧٢ ، سليمان مرقس – السابق ص ١١٥ ، عبد المنعم البدرواي – السابق ص ١١٤ ، اسماعيل غانم – السابق ص ١٧١ ، محمود جمال الدين

فإذا تعاقد الشخص مع نفسه كان تصرفه غير نافذ فى حق الأصيل تأسيساً على أن النائب هنا يعتبر متجاوزاً الحدود المرسومة لنيابته ومع ذلك هناك حالات استثنائية ذكرتها المادة ١٠٨ يجوز للشخص فيها أن يتعاقد مع نفسه على خلاف الأصل:

**أ- إذا رخص الأصيل للنائب بذلك سلفا، أو أجاز تصرفه بعد إبرامه:** ففي حالة الترخيص هذه يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه، ويكون تصرفه نافذا في حق الأصيل، لأن النائب حينئذ يعمل في حدود نيابته، كما يستطيع الأصيل أن يقر تعاقد الشخص مع نفسه، وهذا الإقرار هو إجازة لتصرف النائب، فإذا صدر هذا الإقرار أصبح نافذا في حق الأصيل من وقت إبرام التعاقد لا من وقت الإقرار.

**ب- إذا نص القانون على إجازة تعاقد الشخص مع نفسه:** مثال ذلك ما تنص عليه المادة ١٤ من قانون الولاية على المال من أن للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

**ج- ما يقضى به العرف التجارى من جواز تعاقد الشخص مع نفسه:** كما في حالة الوكيل بالعمولة، وسمسار الأوراق المالية في البورصات[١] .

---

زكي – السابق ص ١٠٥ ، جميل الشرقاوي – السابق ص ١٠٠.

(١) السنهوري – السابق ص ٢٠٥ ، والصدة – السابق ص ١٧٣ ، إسماعيل غانم السابق ص ١٧٢ ، عبد الرازق حسن فرج – السابق ص ١٣٢ ، لبيب شنب " المرجع السابق ص ٨٠ ، سمير تناغو – السابق ص ٢٨ ، جميل الشرقاوى السابق ص ١٠١ – ١٠٢ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ٦٤ .

## المطلب الثاني

## صحة التراضي

### نقص الأهلية وعيوب الرضى ( بيان وتوضيح ):

حين يوجد التراضي – على ما سبق ذكره – والمحل والسبب، وتواجد الشروط التى يوجبها القانون فى كل منها: ينعقد العقد، ويجب فوق ذلك يكون رضا كل من العاقدين رضا صحيحا، ويكون الرضا صحيحا إذا صدر من ذي أهلية وكان خاليًا من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس والإكراء والاستغلال[١] .

وسنقتصر في هذه الدراسة على عيوب الرضا، أما الأهلية فنحيل فيها إلى الكتب المختصة في النظرية العامة للحق[٢] على أنه تجب الإشارة إلى الملاحظات الآتية:

**أولا:** المقصود بالأهلية فى نطاق صحة التراضي هي أهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص للقيام بالأعمال والتصرفات القانونية، أما أهلية الوجوب وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق والواجبات، فإن صلتها بنظرية العقد تقتصر على ركن المحل، ولا صلة لها بركن التراضي .

**ثانيا:** الذي يعنينا فى دارسة صحة التراضي: حالات نقص الأهلية: إذ أن نقص الأهلية لا يعدم الرضى ولكن يجعله غير صحيح، وناقصوا الأهلية في القانون المصرى، هم: الصبي المميز[٣] والسفيه وذى الغفلة .

أما انعدام أهلية الأداء بانعدام التمييز فلا يقتصر أثره على تعبير الإرادة إذ أن

---

(١) انظر نقض مدنى في ٢٢ / ٣ / ١٩٨٠ – طعن رقم ٥٧٦ – السنة ١٠ في مجموع المكتب الفني السنة ٣١ ص ٨٧٨ .

(٢) انظر للمؤلف: المدخل لدراسة القانون – نظرية الحق – ط ٢٠٠٢م .

(٣) سن التمييز في القانون المصرى هو من سن السابعة إلى ما قبل بلوغ من الرشد وهو الحادية والعشرون سنة ميلادية كاملة ( م ٤٤ / ٢ مدنى مصرى ) .

إرادة الصبي غير المميز لا وجود لها في نظر القانون، ومن ثم كانت عقود الصبي غير المميز ( الذي لم بلغ السابعة من عمره ) باطلة بطلانا مطلقا وهذا هو وضع الصبي غير المميز، والمجنون والمعتوه بعد تسجيل قرار الحجر عليهما[١]، أو قبل تسجيل قرار الحجر إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة[٢] أو معروفة للمتعاقدين.

**ثالثا:** نقص الأهلية إذن يعتبر عيبا في الرضى يجعله غير صحيح دون أن يعدمه، ولمن عيبت إرادته أن يطلب هو أو وليه إبطاله إذا توافرت شروط طلب الإبطال الأخرى، وهذا العيب فى الرضا لا شأن لنا بأحكامه لأن محله نظرية العقد.

**أما عيوب الإرادة:** وهى الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال ( الغبن ) فهي محل دراستنا وهي المقصودة هنا، ونعرض لها الآن كل في فرع مستقل.

## الفرع الأول

## الغلط ( L'erreur )

**تعريف الغلط:**

الغلط: وهم يقوم في ذهن شخص فيصور له أمرا على غير حقيقته ويكون هذا الوهم هو الدافع إلى التعاقد.[٣]

---

(١) فيكون تصرف المجنون والمعتوه قبل تسجيل قرار الحجر صحيحا مادامت حالة الجنون والعته غير شائعة وغير معروفة للمتعاقد الآخر أخذا بالإرادة الظاهرة التي يسهل التعرف عليها ( انظر المادة: ١١٤ / ٢ مدنى مصرى ) وانظر كذلك المادة ١١٠ مدنى مصرى

(٢) د . إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٧٣ وانظر كذلك: د / عبد الرزاق السنهورى – الوسيط جـ ١ مصادر الالتزام – المجلد الأول: العقد – الطبعة الثالثة ١٩٨١ ص ٣٦٢ – ٢٦٩.

(٣) انظر في تعريفات الغلط: السنهورى – السابق ص ٣٨٢ – عبد الودود يحيى " السابق ص ٨٧، إسماعيل غانم – السابق ص ١٧٥ ، البدراوي – السابق ص ٢٤٤، د / حسام الدين الأهواني – النظرية العامة للالتزامات جـ ١ – مصادر الالتزام ص ١٣٧ ط ١٩٩٠.

فالغلط تصور كاذب للواقع يؤدى بالشخص إلى إبرام تصرف ما كان ليبرمه لو تبين حقيقة هذا الواقع، كأن يشترى شخص قطعة أثاث معتقدا أنها أثرية بينما هي حديثة الصنع، أو يستأجر شخص شقة يعتقد أنها بحرية، فإذا بها شرقية، أو أن يتعاقد رب عمل مع عامل معتقدا أنه يحمل مؤهلا فنيا معينا، ثم يتبين أن العامل لم يحمل هذا المؤهل.

والغلط بهذا المعنى هو الغلط الذي تقصده في دراستنا لأنه يعيب الإرادة – ولا يمس وجودها – ويؤدى بالتالي إلى أن يكون العقد قابلا للإبطال، ولذا كان لزاما علينا أن نميز بين هذا الغلط المعيب للإرادة وبين أنواع أخرى من الغلط لا يؤثر بعضها في صحة العقد بينما يؤدى بعضها الآخر إلى عدم انعقاد العقد .

**أنواع الغلط**:

**١ – الغلط الذي لا يؤثر في صحة الرضى (الغلط المادي):**

هناك غلط لا يعيب الإرادة وبالتالي لا يؤثر في صحة الرضى، ويظل العقد صحيحا رغم وجوده وهو ما صطلح على تسميته بـ "الغلط المادي". ويقصد به الغلط الذى لم يكن له أي دور في تكوين الإرادة، بل طرأ بعد تكوينها وهو عبارة عن الغلط فى الحساب وغلطات القلم[١]، كأن يتم الاتفاق على سعر الوحدة من وحدات السلعة المبيعة بغير غلط من أحد الطرفين، ثم يحدث الغلط في حساب الثمن الإجمالي أو فى نقل الأرقام من ورقة إلى أخرى، فهذا الغلط لا يؤثر فى انعقاد العقد ولا صحته، بل يجب تصحيح ما وقع فيه الغلط [٢] وهذا ما نصت عليه المادة ١٢٣ مدنى

(١) ويطلق عليه البعض الغلط في النقل أو التفسير ، أى الغلط الذي يقع وقت نقل الإرادة أو يقع في تفسيرها إذا فهمها من توجهت إليه على غير حقيقتها هو ما يسمى بالغلط في التفسير ( السنهوري ص ٣٨٤ ) وهذا المعنى لا يخرج عن المعنى المشار إليه في المتن .

(٢) انظر: إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ١٧٥ ، الصدة – السابق ص ٢٠٠ . عبد الودود يحيى – السابق ص ٨٨ ، سمير تناغو – السابق ص ٥١ . حسام الدين الأهواني – السابق ص١٥٠. د/ عبد

مصرى بقولها: "لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط".

**٢- الغلط الذي يؤدي إلى منع انعقاد العقد (الغلط المانع):**

هناك حالات للغلط يترتب عليه فيها منع انعقاد العقد، وهذا هو ما يسمى بـ "الغلط المانع" وهو يتحقق في حالات أربع:

أ- غلط فى ماهية العقد: كما إذا سلم شخص شخصا آخر شيئا على أنه عارية، فتسلمه الآخر على أنه هبة.

ب- غلط في ذاتيه المحل: كما لو باع شخص أحد منزلين يملكهما، فقبل المشترى أحدهما معتقدا أنه يشترى المنزل الآخر .

ج- غلط في وجود سبب الالتزام: كما لو اتفق الورثة مع الموصى له على إعطائه مالا من أموال التركة تنفيذا لوصية مورثهم ثم يتضح أن الموصى كان قد رجع في وصيته قبل وفاته، أو أن الوصية باطلة.

د- غلط فى محل الالتزام: كما لو اتفق على بيع شيء معين بذاته ثم يتبين أنه كان قد هلك قبل الاتفاق[١].

والغلط المانع على النحو السابق، يعدم الإرادة، ويؤدى إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا؛ لأن ذلك يتعلق بوجود الإرادة ذاتها، ولا يندرج تحت الغلط الذي يعيب الإرادة وهو ما نحن بصدده .

---

الفتاح عبد الباقي – السابق من ١٧٦ ، لبيب شنب – السابق ص ١٥١، وانظر: نقض مدنى ١١/١٢/ ١٩٤٧

(١)د / عبد الودود يحيى – السابق ص ٨٧ ، لبيب شنب – السابق – الموضع السابق اسماعيل غانم – السابق ص ١٧٦ ، والسنهورى – السابق ص ٣٨٣ ، البدراوي السابق ص ٢٤٥ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١١٢ ، وانظر: مازو السابق – ف ١٦١ وما بعدها .

### ٣-الغلط الذي يعيب الإرادة (نظرية الغلط في التقنين المدني الحالي):

أخذ التقنين المدنى المصرى بالنظرية الحديثة للغلط وهي تشترط في الغلط الذي يعيب الإرادة ويجعل العقد قابلاً للابطال: أن يكون جوهرياً ويكون الغلط كذلك إذا كان هو الباعث الدافع إلى التعاقد ومعياره ذاتي يرجع فيه إلى الإرادة المتعاقد الذي وقع في الغلط.

**شروط الغلط الذي يعيب الإرادة وتجعل العقد قابلاً للإبطال**:

يتضح من نص المادتين ١٢٠، ١٢١ من القانون المدني أن شروط الغلط ثلاثة وهي:

**الشرط الأول**: **أن يكون الغلط جوهرياً على غير أركان العقد**:

الغلط الذي يعيب الإرادة ويجعل العقد قابلاً للإبطال هو الغلط الجوهري، والغلط يكون جوهرياً إذا بلغ في نظر المتعاقد الذي وقع فيه حداً من الجسامة بحيث كان يمتنع عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط[١]، ومعياره ذاتي أو شخصي، أى أن اعتبار الغلط جوهرياً يقاس بمدى تأثيره على إرادة الغلط نفسه، فالعبرة إذن لمعرفة ما إذا كان الغلط جوهريا أم لا: هو شخص المتعاقد الذي وقع فيه، ومن ثم لا أهمية لمدى تأثير الغلط فى الشخص العادي، وبهذا المعيار الذاتى أخذ الفقه والقضاء فى مصر منذ عهد التقنين القديم[٢]، وجاء التقنين الجديد مؤيدا للمعيار الذاتي، وصريحا

---

(١) د / عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٩٠ ، وانظر اسماعيل غانم – السابق ص ١٨٠، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٠٥ ، عبد الناصر العطار – السابق ص ٨٧ ، محمود جمال الدين زكي – السابق ص ١٢٠ ، عبد التفاح عبد الباقي – السابق ص ١٧٢ وما بعدها ، أنور سلطان – السابق ص ١٦٥ ، جميل الشرقاوي – السابق ص ١١٥ .

(٢)انظر: د / عبد السلام ذهني – الالتزامات في ١٢٧ – الدكتور محمود هيبة –النظرية العامة في الالتزامات ف ٢٥٥ د / حلمى بهجت بدوى – السابق في ١١٦ أبو ستيت – السابق ٥ ف ١٥٦ .

في وجوب الأخذ به؛ حيث نصت المادة ١٢٠ مدنى مصرى على أنه: "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد...".

ثم وضحت المادة ١٢١ معيار الغلط الجوهري فقالت: "١- يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

٢- ويعتبر الغلط جوهريًا على الأخص:

(أ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.

(ب) إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد".

**على أي شيء يقع الغلط؟**

يستبين من النصوص السابقة أن الغلط الجوهرى الذي يعيب الإرادة قد يكون:

أ- في صفة جوهرية فى الشيء. ب- أو في شخص المتعاقد.

ج- أو في قيمة الشيء. د- أو في الباعث على التعاقد .

وسنعالج الآن معيار الغلط الجوهري على هذه الحالات:

**أولًا: الغلط في صفة جوهرية في الشيء ( محل التصرف ):**

هذه هي إحدى الحالتين اللتين ورد ذكرهما في الفقرة الثانية من المادة ١٢١ مدنى مصرى، والغلط فى صفة الشيء يعيب الإرادة إذا كان جوهريا، بأن وقع فى صفة فى الشيء ترقى فى نظر المتعاقدين إلى المستوى الذي يجعله هو الدافع إلى التعاقد.

وفي القضاء المصرى أمثلة عديدة لبيان هذا النوع من الغلط، فقد قضت محكمة النقض بأن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج لدى الأقباط الأرثوذكس

تأسيسا على أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة.[١] وقضى بجواز طلب الإبطال للغلط الواقع في صفة جوهرية للشيء حالة شراء قماش على أنه قابل لأن يغسل ثم يتضح أنه غير قابل لذلك[٢].

ولما كان المعيار الذاتي يقتضى الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين وهي أمر نفسى يصعب التعرف عليه في بعض الحالات، فقد أضاف المشرع ضابطا موضوعيا يساعد على التعرف على هذه النية، فلا يعتبر الصفة جوهرية فقط إذا كانت كذلك في نظر المتعاقدين، وإنما تكون جوهرية أيضا إذا كانت ظروف التعاقد، وما يجب أن يسود في التعامل من حسن نية يقتضيان اعتبارها جوهرية[٣]، كمن يشترى تحفة على أنها أثرية، ثم يتبين أنها حديثة الصنع.

**ثانياً: الغلط في شخص المتعاقد** :

الغلط الجوهري الذي يعيب الإرادة فى هذه الحالة هو ذلك الذي يقع في ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد طبقا لنص المادة ١٢١ / ٢ مدني، ومثل هذا الغلط إنما يقع في العقود التي تكون فيها شخصية المتعاقد محل اعتبار، كعقود التبرع بوجه عام وبعض عقود المعاوضة.

ومن أمثلة الغلط في ذات المتعاقد: الغلط في شخص الموهوب له أو المزارع أو الشريك أو الوكيل، إذ أن شخصية المتعاقد في هذه العقود محل اعتبار .

---

(١) نقض مدنى فى ١٩/١١/ ١٩٧٥م مجموعة أحكام النقض – السنة ٢٦ رقم ٢٧٢ . ص ١١٤ ، وانظر نقض مدنى في ٢٠/٥/ ١٩٦٥ – المجموعة السابقة – سن ١٦ رقم ٩٨ ص ١٠٣ .

(٢) انظر: استئناف مختلط في ١٨/٣/١٩٤٦ مجموعة التشريع والقضاء المختلط ٥٨ ص ٧٤ .

(٣) عبد الودود يحيى – السابق ص ٩١ ، لبيب شنب – السابق ص ١٤٨ ، والصدة – السابق ص ٢٠٦ ، وعبد الناصر العطار – السابق ص ٨٧ – ٨٨ .

ومن أمثلة الغلط فى صفة جوهرية في شخص المتعاقد: إذا وهب شخص شخصا مالا معتقدا أن هناك رابطة قرابة تربطه به ثم يتضح أن الأمر على غير ذلك، وكأن يؤجر شخص منزلا لإمرأة يعتقد أن سلوكها قويم، فيتضح أنها تحترف الدعارة، حتى ولو لم تكن تباشر مهنتها في المنزل المؤجر، أو أن يتعاقد صاحب عمل مع شخص على أنه يحمل مؤهلا معينا ثم يتبين له غير ذلك.

وتقدير ما إذا كانت شخصية المتعاقد أو صفته كانت هي محل اعتبار أو كانت هي الدافعة إلى التعاقد: مسألة من مسائل الواقع لا القانون تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض(١).

**ثالثاً: الغلط في قيمة الشيء:**

يكون الغلط فى القيمة سببا لإبطال العقد إذا كان جوهريا؛ أي دافعا إلى التعاقد، والنظرية الحديثة أخذت بهذا النوع من الغلط، على عكس النظرية التقليدية (القديمة) التى لم تسلم بالغلط في هذه الحالة.

ومن أمثلة الغلط الجوهرى فى القيمة: أن يبيع شخص سهما بقيمته الفعلية، وكان يجهل أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة، فلمن وقع في هذا الغلط أن يطلب إبطال البيع للغلط في القيمة. (٢)

**رابعاً: الغلط في الباعث على التعاقد:**

المعيار الذاتي ينطبق على هذه الحالة، كما هو الشأن في الحالات السابقة، فإذا وقع الغلط فى الباعث الدافع إلى التعاقد، فإنه يعيب الإرادة، ويجعل العقد قابلا

---

(١) السنهوري – السابق ص ٣٩٧ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١٧٧ ، إسماعيل غانم – السابق ص ١٨٢: لبيب شنب – السابق ص ١٤٩، وانظر نقض مدنى مصري في ٦/٥/ ١٩٥٤ – مجموعة أحكام النقض – س٥ – رقم ١٢٥ ص١٤٠، ونقض مدنى مصري في ١٠/٢٩/ ١٩٥٣ – مجموعة أحكام النقض – س ٥ – رقم ١٣ ص ١٠٨.

(٢) انظر: السنهوري – السابق ص ٣٩٧ وقارن ، إسماعيل غانم – السابق ص ١٨٣ ٠

للإبطال، فإذا استأجر شخص منزلا في مدينة معينة معتقدا أنه نقل إليها، ثم اتضح له بعد ذلك أنه لم ينقل، أو اشترى شخص سيارة معتقدا أن سيارته هلكت في حريق ما، ثم تبين أنها لم تحترق وأنها صالحة للاستعمال، كان واقعا فى غلط فى الباعث يجيز له طلب إبطال العقد بشرط أن يكون المتعاقد الآخر في الحالتين قد اتصل بهذا الغلط (أي يعلم بالباعث على التعاقد) ويجب فوق ذلك أن يعلم المتعاقد الآخر أن من يتعاقد معه واقع في غلط[١] (أي أن الموظف لم ينقل في المثال الأول والسيارة لم تحترق في المثال الثاني).

**الشرط الثاني: أن يتصل المتعاقد الآخر بالغلط:**

لا يكفى لجواز طلب إبطال العقد أن يكون الغلط جوهرياً على النحو السابق، بل يجب – فوق ذلك – أن يكون المتعاقد الآخر قد اتصل بالغلط، وفي هذا المعنى تقول المادة ١٢٠ مدني، إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه .

وقد أراد المشرع الوضعي بهذا الشرط أن يكفل استقرار التعامل فبقى المتعاقد من أن يفاجأ بدعوى يرفعها الطرف الآخر يطلب فيها إبطال العقد لغلط لم يكن يعلم عنه شيئاً، ولم يكن في وسعه العلم به، ولم يكن من السهل عليه أن يتبينه.[٢]

إذ يجب في الغلط الذي يجيز طلب الإبطال أن يكون مشتركاً أو يكون غلطاً فردياً بشرط – في هذه الحالة – أن يكون الطرف الآخر عالماً به وترك من وقع في

---

(١) د . عبد الودود يحيى – السابق ص ٩٣ ، الصدة – السابق ص ٢٠٩ ، عبد الفتاح عبد الباقي – المرجع السابق ص ١٧٦ ، لبيب شنب – المرجع السابق –الموضع السابق ، وقارن إسماعيل غانم – السابق ص ١٨٤ ، ومازو – السابق جـ ٢ ف ١٦٣ .

(٢) د / عبد الودود يحيى – السابق ص ٩٤، وانظر د/ عبد الفتاح عبد الباقي – السابق ص ٣١٨ ، وانظر نقض مدني في ٧ / ٦ / ١٩٧٨ – س ٤٤ ق طعن رقم ٢٦٣

غلط يقع فيه دون أن ينبهه إلى ذلك، أو كان من السهل عليه أن يتبينه وفقاً لظروف التعاقد؛ إذ في الحالة الأولى يكون المتعاقد الآخر (الذى لم يقع فى الغلط) سيئ النية، وفي الحالة الثانية يكون مقصرا، والجزاء في الحالتين هو طلب إبطال العقد، ويمتاز هذا الحل الذي أخذ به المشرع المصرى بأنه وإن كان يجيز طلب الإبطال في الصور الثلاث (الغلط المشترك، الغلط الذي يعلم به الطرف الآخر أو كان من السهل عليه أن يتبينه) فهو في نفس الوقت يعالج كل أحكام هذه الصور، ففى حالة الغلط المشترك يكون الطرف الذي وجه إليه طلب الإبطال حسن النية، فلا يجب عليه التعويض، وفى حالة علم هذا الطرف بالغلط يكون سيئ النية، فيجب عليه التعويض، وفى حالة استطاعته أن يتبين الغلط يكون مقصرا فيجب عليه التعويض كذلك[١]. إلا أن التعويض هنا يكون أصعب منالا من الحالة السابقة.

**وخلاصة القول:** أنه يشترط لكى يكون العقد قابلا للإبطال للغلط: أن يكون الغلط جوهريا على النحو السابق بيانه، وأن يكون المتعاقد الآخر قد اتصل بهذا الغلط، بأن كان هو الآخر واقعا في غلط، أو، أو لم يكن وقعا في غلط ولكن كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه إن كان ذلك واضحا من ظروف التعاقد، كما لو اشترى شخص تحفة من شخص متخصص في بيع الأشياء الأثرية.[٢]

**إثبات الغلط**:

يقع عبء إثبات الغلط على من يدعى وقوعه فيه، إذ يجب على من وقع في غلط أن يثبت أنه كان واقعا فى غلط جوهرى، وأن المتعاقد الآخر قد اتصل بالغلط على النحو السابق بيانه[٣] علما بأن ما يجب إثباته هنا هو عبارة عن وقائع مادية

(١)د / عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٢١١

(٢) د / عبد الودود يحيى – السابق ص ١٥ .

(٣) انظر نقض مدنى في ٢١ / ٦ / ١٩٧٣ – مجموعة المكتب الفني – السنة ٢٤ ص ٩٥٣ .

يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات بما فيها البيئة والقرائن أيا كانت قيمة العقد المطلوب إبطاله.

**لا يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية:**

تنص المادة ١٢٤ من التقنين المدنى المصرى على أنه"١- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية.

٢- ويبقى بالأخص ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد".

يتضح من النص السابق أن أثر الغلط في العقد – إذا توافرت شروط الغلط – هو أنه يجوز لمن وقع في غلط أن يتمسك به ويطلب إبطال العقد.

ولكن لا يجوز التمسك بالغلط إذا كان يتعارض مع مقتضيات حسن النية؛ لأن التمسك بالغلط في هذه الحالة يكون تطبيقًا من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق[١]، فلو أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ العقد على النحو الذي كان يقصده أثناء التعاقد، فلا يجوز لمن وقع في الغلط أن يتمسك – رغم ذلك – بطلب إبطال العقد، مراعاة لمقتضيات حسن النية، وتطبيقا لذلك: لو أن شخصا قبل حوالة حق لم يحل موعد استحقاقه لاعتقاده أنه مضمون برهن ثم تبين له أن المنزل المرهون كان قد احترق، فعرض عليه المحيل أن يرتب رهناً على عقار له ضماناً للوفاء بالحق المحال، فإن هذا الشخص لا يجاب إلى طلب الإبطال، إذ أن هذا الطلب يتعارض حينئذ مع مقتضيات حسن النية[٢] .

(١) السنهوري – السابق ص ٤١٩ ، وانظر: الصدة – السابق ص ٢١٤ ، لبيب شنب، السابق ص ١٥٧ . وجميل الشرقاوى – السابق ص ١٢٨ ، عبد الناصر العطار السابق ص ٩٢.

(٢) عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢١٥ د / عبد الودود يحيى – السابق ص ٩٦ . اسماعيل غانم – السابق ص ٢٠٧ ، سليمان مرقس – السابق ص ١٨٥ ، د / عبد الحي حجازي – السابق ص ٢٦٢ ، وانظر: مجموعة الأعمال التحضيرية جـ ٢ ص ١٦٧.

## الفرع الثاني

## التدليس (Le dol)

**التعريف بالتدليس**:

التدليس هو: استعمال طرق احتيالية توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد؛ أى هو الأفعال التي يتم بها إيهام شخص بغير الحقيقة لحمله على التعاقد.

ويتضح من هذا التعريف أن الصلة وثيقة بين الغلط والتدليس؛ فالتدليس لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد،[1] ويختلف التدليس بهذا التحديد – عن الغش أو التزوير، في أن التدليس إنما يكون أثناء تكوين العقد، أما الغش فقد وقع بعد تكوين العقد أثناء التنفيذ فعلاً – ويقع خارجاً عن دائرة العقد.

وجدير بالذكر أن التدليس وإن كان هو الذي يثير الغلط في نفس المتعاقد فيحمله على التعاقد: إلا أن هذا الغلط يختلف عن الغلط العادي في أن الأول يقوم لدى المتعاقد نتيجة للحيل التي لجأ إليها المدلس، بينهما يقوم الثاني من تلقاء نفسه ومن هنا كان الاختلاف بين الغلط العادي، والغلط الناشئ عن التدليس ومن ثم كانت العلاقة وثيقة بين الغلط والتدليس.

**شروط التدليس**:

تنص المادة ١٢٥ من التقنين المدني المصري على ما يلي: "١- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

٢- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس فيه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة".

---

(١) السنهوري – الوسيط – مصادر الالتزام – المجلد الأول – العقد – الطبعة الثالثة ١٩٨١ ص ٤٢١ ، وانظر: اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٢٠٨.

وتنص المادة ١٢٦ مدني على أنه: "إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس".

**ويتضح من هذا النص أن شروط التدليس ثلاثة هي:**

**الشرط الأول**: **استعمال طرق احتيالية**:

هذا الشرط يحتوى على عنصرين: عنصر مادي: وهو الوسائل المادية التي تستعمل للتأثير في إرادة المتعاقد، وعنصر معنوى: وهو نية التضليل للوصول إلى غرض مشروع.

**أولا: الجانب (العنصر) المادى:** وهو الحيل المستعملة التى توهم المدلس عليه بغير الحقيقة، ويجب أن تكون هذه الحيل كافية للتضليل بحسب حالة المتعاقد، أي أن المعيار هنا معيار شخصى، ومن أمثلة ذلك: تقديم عقود إيجار مزورة لمن يريد شراء عقار لإيهامه أن دخل العقار كبير، وأكبر من الدخل الحقيقي، والشركات والجمعيات التي تتخذ لها من مظاهر الإعلان ما لا يتفق مع حقيقتها لتخدع الناس فى أمرها، ومن يظهر بمظهر اليسار والسعة على غير الحقيقة وينتحل لنفسه صفات يكون من شأنها أن تخدع المتعاقد. (١)

والأصل أن مجرد الكذب لا يكفى لتوافر العنصر المادي في التدليس مادام أن ذلك مألوف في التعامل، كالتاجر الذى يروج لبضاعته فينتحل لها أحسن الصفات، إلا أنه (مجرد الكذب) قد يعتبر كافيا إذا تعلق الأمر بواقعة لها أهميتها في التعاقد، بحيث يمكن القول أن المتعاقد (المدلس عليه) ما كان ليقدم على التعاقد لولا البيانات

(١) انظر: السنهوري – السابق ص ٤٢٥: الصدة – السابق ص ٢١٧ ، ود/ عبد الودود يحيى – السابق ص ٩٧ ، عبد الفتاح عبد الباقي – السابق ص ١٨٩ وما بعدها ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١٢١ ، لبيب شنب – السابق ص ٩٧.

الكاذبة التي أدلى بها المتعاقد الآخر[١]، ومثاله من يعطى شخصا بيانات كاذبة عن كفايته وخدماته السابقة، بقصد التحايل للحصول على عمل، أو يعطى شخص بيانات كاذبة لشركة التأمين ليخفي حقيقة الخطر الذي يتعرض له، أو يعطى شخص بيانات كاذبة عن تاريخ صنع السيارة المؤمن عليها وتاريخ شرائها [٢].

كما أن الكتمان retieence أو السكوت[٣]، قد يعتبر من الطرق الاحتيالية إذا تعلق الأمر بواقعة هامة كان يجب التصريح بها، ولم يكن في وسع المدلس عليه معرفتها من طريق آخر، وما كان المدلس عليه ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة، ومثال ذلك: كتمان البائع على المشترى قرارا يقضى بنزع ملكية العقار المبيع للمنفعة العامة، أو أن يتصالح وارث مع مدين للتركة على ترك جزء من الدين، وهو يجهل أن هناك تأمينا يضمن الدين ويعلم ذلك المدين ويكتمه عن الوارث، ومثل سكوت المؤمن له عند التعاقد مع شركة التأمين وعدم إبلاغها بما أصابه من أمراض قبل إبرام عقد التأمين.[٤]

**ثانيا: العنصر المعنوي:** وهو عبارة عن نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع، فإذا انتفت نية التضليل فلا تدليس، كما في حالة التاجر الذي يمتدح

---

(١) د / عبد الودود يحيى – السابق – الموضع السابق ، وانظر: اسماعيل غانم السابق ص ٢١١ ، وأنور سلطان – السابق ص ١٧٦

(٢) انظر: عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢١٧ ، جميل الشرقاوي – السابق ص ١٢٠ ، حسام الدين الأهواني – السابق ص ١٦٣ ، حشمت أبو ستيت – السابق ص ١٧٢، وانظر: استئناف مختلط في ٢٦/٢/ ١٩٣٠ – مجموعة التشريع والقضاء المختلط – ١١ ص ٣٢٥ ، ونقض مدنى في ١٩٤٣/٢٥/٢ – مجموعة القواعد القانونية جـ ١ ص ٥٩ رقم ٢٩ .

(٣) أي عدم إعطاء توضيحات معينة متعلقة بموضوع التصرف ، وهو مجرد موقف سلبي من المتعامل مع الغالط

(٤) عبد الرازق فرج: السابق، ص ١٥٣، والصدة: السابق، ص٢١٨، والأهواني: السابق، ص١٦٤.

بضاعته بقصد الترويج لها حتى ولو وصل إلى حد الكذب، لأن ذلك مألوف فى التعامل وليس هناك نية للتضليل، لأنه يريد استهواء الناس ليس إلا[١]

كما يجب أن يكون القصد من التضليل: الوصول إلى غرض غير مشروع؛ أي حمل المتعاقد على إبرام تصرف لا يتفق مع مصلحته[٢]، فإذا استعملت الطرق الاحتيالية للوصول إلى غرض مشروع فلا تدليس، كما لو اكتشف المودع أن المودع لديه غير أمين، فاستعمل طرقا احتيالية للحصول من المودع لديه على إقرار بالوديعة.[٣]

**الشرط الثاني: أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد:**

يجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد، وهذا الشرط ليس إلا تطبيقا للمبدأ العام في عيوب الرضى، وقد نصت عليه المادة ١/١٢٥ بقولها: "ويجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل ... من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد".

والعبرة في هذا بشخص المتعاقد المدلس عليه ذاته، لا بمدى تأثير هذه الحيل فى الشخص العادى، ومن ثم يجب مراعاة درجة ثقافة وذكاء وخبرة وسن المدلس عليه، ومن يقصد التدليس إنما يختار وسائله وفقا لحالة ضحيته[٤]، فالمعيار شخصى، وقاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك، ويقدر ما إذا كان التدليس قد

---

(١) السنهوري – السابق ص ٤٢٠ ، لبيب شنب – السابق ص ١٦٣ ، إسماعيل غانم السابق ص٢١٠، وانظر نقض مدنى فى ٢٠/٢/ ١٩٣٦، مجموعة عمر جـ ١ ص ١٠٤٩ رقم ٣٢٧

(٢) الصدة – السابق ص ٢١٨

(٣) السنهوري – السابق ص ٤٣١ ، وعبد الودود يحيى – السابق ص ٩٨ ، الصدة –السابق – الموضع السابق، ونقض مدنى في ٢١/١٢/١٩٧٦ مجموعة المكتب الفني – س ٢٧ ص ١٧٩١

(٤) د . إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٢١٤ ، د ، لبيب شنب – السابق من ١٦٤ ، حسام الأهوانى – السابق ص ١٧٠ وما بعدها ، سمير تناغو – السابق ص ٥٨.

حمل المدلس عليه على التعاقد أم لا؟ وهو يهتدى في ذلك بما تواضع عليه الناس في تعاملهم وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجربة[١]...الخ.

ويميز بعض الفقهاء[٢] بين التدليس الدافع dol principal بالمعنى المتقدم وبين التدليس غير الدافع، أو العارض dol incident كما يسميه البعض[٣] وهو التدليس الذى لم يكن هو الدافع إلى التعاقد، وإنما يؤدى إلى قبول التعاقد بشرط أبهظ، أى يجعل العقد أثقل عبئا فقط، وأنه كان سيبرم العقد على أي حال، حتى ولو لم يقع عليه تدليس، وهذا النوع الأخير لا يعيب الإرادة ولا يجعل العقد قابلا للإبطال، وإنما يقتصر الأمر فيه على تعويض يقتضيه المدلس عليه وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية.

غير أن جمهور الفقه المصرى[٤] ينتقد هذه التفرقة؛ إذ هى تقوم على فصل مصطنع بين إرادة التعاقد في ذاتها، وبين الشروط التى تحركت في دائرتها، فإرادة التعاقد ليست إرادة مجردة بل هي إرادة إبرام عقد معين بشروط معينة[٥].

ومن ثم فنحن نميل إلى الأخذ بهذا الرأى لاتساقه مع المنطق القانوني السليم، ويكون المدلس عليه بالخيار بين أن يطلب إبطال العقد، أو يستبقيه مع طلب التعويض عما أصابه من ضرر بسبب التدليس، وفى هذه الحالة يستطيع الطرف

---

(١) السنهورى – السابق ص ٤٣١ ، وانظر نقض مدنى فى ١٣/٣/ ١٩٧٣ مجموعة أحكام النقض س ٢٤ رقم ٧٠ ص ٣٩٦ .

(٢) عبد الحي حجازي: المصادر الإرادية ف ٤٥٧ ، حشمت أبو ستيت: السابق ف ١٧٧، أنور سلطان: السابق ص ١٨٠ ، الصدة ، السابق ص ٢١٩ . الشرقاوى – السابق ص١٢٣.

(٣) د . إسماعيل غانم السابق ص ٢١٠ ، وانظر: جميل الشرقاوى – السابق – الموضع السابق

(٤) د/ السنهورى – السابق ص ٤٣٢ ، إسماعيل غانم – السابق ص ٢١٥ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ٩٩ ، سليمان مرقس – السابق ص ١٩٠ ، منصور مصطفى منصور ص ٨٢ ، محمود جمال الدين زكى – السابق ص ١٣٩ ، لبيب شنب –السابق ص ١١٦ .

(٥) د / إسماعيل غانم – السابق ص٢١٥.

الآخر أن يتفادى الحكم بالإبطال إذا أظهر استعداده لتعديل شروط التعاقد على النحو الذي يرفع الضرر الذى أصاب المتعاقد الآخر من جراء التدليس، وذلك تطبيقا للمبدأ الذي يقضى بعدم جواز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية[١]، ويسرى هذا إليه على النحو السابق بيانه .

**الشرط الثالث**: **اتصال التدليس بالمتعاقد الآخر**:

تنص المادة ١٢٦ مدنى مصرى على أنه "إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس".

يتضح من هذا النص أن التدليس يجب أن يكون قد اتصل بالعاقد الآخر، وهو يكون كذلك إذا كانت الطرق الاحتيالية قد صدرت من المتعاقد، أو من غير المتعاقدين، ولكن المدلس عليه أثبت أن المتعاقد معه كان يعلم، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بالتدليس، فإذا لم يثبت العلم على هذا النحو، فلا يكون أمام المدلس عليه إلا أن يرجع على المدلس بالتعويض طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية[٢].

ويلاحظ أن التدليس الصادر من النائب عن أحد الطرفين لا يعتبر تدليسا صادرا من الغير (م ١/١٢٥) فلا يشترط لإبطال العقد علم الأصيل أو استطاعته العلم

---

(١) د . عبد الودود يحيى – السابق ص ٩٩ ، انظر: السنهوري – السابق ص ٤٢٣ وقارن د / عبد الرازق فرج – السابق ص ١٥٧ ، عبد الناصر العطار – السابق ص ٩٩ ، وحسام الأهواني – السابق ص١٧٢ ، انظر نقض مدنى في١٩٧٢/٨/٢، مجموعة المكتب الفنى – س ٢٣ ص ١٣٨ .

(٢) د. عبد الودود يحيى – السابق ص ١٠٠ ، إسماعيل غانم – السابق ص ٢١٧ ، وقارن السنهورى – السابق ص ٤٤٠ ، البدراوى – السابق ص ٢٧٤ ، محمود جمال الدين زكى – المرجع السابق ص ١٤١ ، لبيب شنب – السابق ص ١٦٨ .

بالتدليس الصادر من نائبه[١]، فإذا لجأ سمسار إلى التدليس على شخص ليشترى منه بضاعة، دون أن يكون مالكها – البائع – على علم بهذا التدليس، فلا يعتبر البائع مدلسا هنا، ويكون من غير العدل في حقه إبطال العقد، مادام أنه كان حسن النية (أى لا يعلم بالتدليس الحاصل من السمسار، ولم يكن عالما بالغلط الذي وقع فيه المتعاقد الآخر نتيجة لهذا التدليس) ويظل العقد في هذه الحالة صحيحا، ولا يكون للمتعاقد المدلس عليه إلا أن يرجع على السمسار بالتعويض وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية[٢].

**هل تغنى نظرية الغلط عن نظرية التدليس في القانون الوضعي؟**

سبق أن ذكرنا أن التدليس هو استعمال طرق احتيالية توقع المتعاقد في غلط من شأنه أن يدفعه إلى التعاقد، وهذا يعنى أن الذى يجعل العقد قابلا للإبطال هو الغلط الناشئ عن التدليس، ومن ثم ثار التساؤل عما إذا كانت نظرية الغلط تغنى عن نظرية التدليس أم لا؟

**وللإجابة على هذا التساؤل نقول:** إنه وفقا للنظرية التقليدية فى الغلط نجد أن نظرية الغلط لا تغنى عن نظرية التدليس؛ لأن الغلط في النظرية التقليدية لا يعيب الإرادة إذا وقع فى القيمة أو الباعث – على نحو ما ذكرنا في حينه –، بينما يمكن إبطال العقد للتدليس في هاتين الحالتين إذا كان نتيجة للتدليس، ومن ثم يكون لنظرية التدليس فائدتها بجانب نظرية الغلط في ظل النظرية التقليدية.

أما في ظل النظرية الحديثة التي يأخذ بها القانون المصرى فإن الغلط يغنى عن التدليس؛ لأن الغلط الذى يعيب الإرادة ويجعل العقد قابلا للإبطال في هذه

(١) د/ إسماعيل غانم – السابق ص ٢١٧ ، د/ جميل الشرقاوى – السابق ص ١٣٤، ود/ عبد الناصر العطار – السابق ص ١٠٠.

(٢) د/ عبد الرازق حسن فرج – السابق ص ١٥٨ ، وانظر: عبد المنعم البدراوى –السابق ص ٢٧٤ ، والصدة – السابق ص ٢٢٢ ، لبيب شنب – السابق –الموضع السابق.

النظرية هو الغلط الجوهرى، أى الدافع إلى التعاقد، بصرف النظر عن موضوع الغلط، أى حتى ولو كان غلطا في القيمة أو الباعث، فكل عقد يبطل للتدليس يمكن فى ذات الوقت إبطاله للغلط[١] ولكن التدليس لا يفى عن الغلط فى أى حال من الأحوال، وهو ما أخذ به كثير من التقنيات المعاصرة.[٢]

ومع ذلك فهناك فارق عملى بين الغلط المصحوب بالتدليس والغلط غير المصحوب به، ويظهر أثر ذلك في أمرين:

**أولهما:** يتعلق بالإثبات؛ حيث يسهل إثبات الغلط إذا كان نتيجة للتدليس، لأن الطرق الاحتيالية غالبا ما تكون طرقا مادية يسهل إثباتها، بينما الغلط العادي (التلقائي) أمر نفسى ليس من الميسور إثباته.

**ثانيهما:** من حيث الجزاء، فبالإضافة إلى الإبطال الذي يؤدى إليه الغلط في الحالتين، فإن الغلط المصحوب بالتدليس يكون سببا في إلزام المدلس بالتعويض على أساس العمل غير المشروع، أما الغلط العادي: فجزاؤه الإبطال فقط، ولا محل للتعويض إلا إذا ثبت خطأ في جانب المتعاقد الذي علم بالغلط أو كان في استطاعته العلم به.[٣]

---

(١) السنهوري – السابق ص ٤٤١ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ١٠١ ، عبد الحي حجازي – السابق ص ٢٠٠ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٢٣ . سمير تناغو – السابق ص ٥٩ .

(٢) كالتقنين النمساوى (م ٨٧) من التقنين النمساوي القديم م ٥٥ من التقنين النمساوى المعدل (وكذلك التقنين البرتغالي الذي أغفل التدليس كعيب من عيوب الرضا (انظر المادتان ٦٥٧ ، ٦٦٣ من التقنين البرتغالي).

(٣) راجع في ذلك: السنهورى – السابق ص ٤٤٢ ، عبد الودود يحيى – السابق – الموضع السابق ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١٣٥ – ١٣٦ ، سمير تناغو – السابق ص ٦٠ ، حشمت أبو ستيت – السابق ص ١٧٧ ، مجموعة الأعمال التحضيرية جـ ٢ ص ١٧٢ – ١٧٣.

ومن أجل هذه الفوارق العملية بين الغلط والتدليس استبقى القانون المدنى المصرى الحالى نظرية التدليس بجانب نظرية الغلط كعيب من عيوب الرضا يجيز طلب إبطال العقد، جريا على التقاليد التي لا تخلو من كل قيمة[١]، وخاصة إذا اقترنت هذه التقاليد بتلك الفروق العملية السابق بيانها.

## الفرع الثالث

## الإكراه ( La violence )

**التعريف بالإكراه وأنواعه :**

الإكراه: هو ضغط يقع على الشخص فيبعث في نفس رهبه أو خوفاً يحمله على التعاقد، فالذي يفسد الرضا ليس الإكراه في ذاته ولا الوسائل المادية التي تستعمل في الإكراه، بل هي الرهبة التى تقع في نفس المتعاقد، أو الخوف الذي نتج عن الإكراه، ومن ثم تكون الإرادة غير مختارة.

والإكراه الذي يعيب العقد ويجعل العقد قابلاً للإبطال هو الذي يفسد الرضا دون أن يعدمه، حيث تكون إرادة المكره موجودة ولكنها غير حرة، إذ يكون المتعاقد بالخيار بين أن يتحمل الأذى، أو يتعاقد لدرء الأذى عن نفسه أو غيره، فاختار أهون الضررين وتعاقد، وفى هذه الحالة يكون العقد قابلا للإبطال .

أما إذا وصل الإكراه إلى حد إعدام الإرادة، كما لو أمسك المكره بيد المكره وجعله يبصم بأصبعه على ورقة مثبتة لالتزام، ففى هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا لانعدام الرضا –وليس تعييبه– إذ أن الرضا قد انتزع عنوة لا رهبة[٢]، وهذا النوع

---

(١) د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٢٣ .

(٢) وقد يكون من قبيل الإكراه المعدم للرضا، التنويم المغناطيسي ، كما يمكن أن يتعدى هذا النوع من الإكراه إلى أى تصرف قانونى ولو كان بإرادة متفردة ( انظر في ذلك: بيدان الذي يفضل تعبير contrainte بدلا من تعبير violence الوارد في القانون الفرنسي والمصرى جـ ٨ ص ٨٤، وانظر كذلك حشمت أبو ستيت –السابق ١٩٧ .

من الإكراه نادر الوقوع، ولا شأن لنا به لأنه خارج عن نطاق بحثنا.

والإكراه الذى يعيب الرضا ويجعل العقد قابلا للإبطال، قد يكون جثمانيا وهو الذي يقع على جسم المكره بالضرب والتعذيب، فيضطر المكره إلى قبول العقد ليوقف هذا الأذى، وقد يكون الإكراه معنويا، وهو الذي يكون بالتهديد بإيقاع الأذى المادى الذى يقع على الجسم أو المال، أو الأذى النفسي الذي يمس العاطفة أو السمعة أو الشرف، فيضطر المكره – أيضا – إلى قبول العقد ليوقف هذا الأذى الذي هدد به.

وأيا كان نوع الإكراه فإن أثره نفسي بحت، هو تلك الرهبة التي يولدها في نفس المكره، فتنصرف إرادته بتأثير تلك الرهبة إلى إبرام التعاقد.

والإكراه – كالتدليس – له وجهان: فهو فى ذاته عمل غير مشروع يستوجب التعويض، وهو بالنظر إلى ما يولده من رهبة فى نفس المكره عيب في الإرادة [1] يجعل العقد قابلا للإبطال.

**شروط الإكراه:**

نظمت المادتان ١٢٧، ١٢٨ من التقنين المدني المصري الحالي أحكام وشروط الإكراه، فنصت المادة ١٢٧ على أنه: "١- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

(١) إسماعيل غانم – السابق – ص ٢٧ – ٢١٩ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢١٤ ، محمود جمال الدين زكى – السابق ص ١٤٤ ، عبد الفتاح عبد الباقي –السابق ص ١٩٥ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١٤٠ – لبيب شنب – السابق الموضع السابق ، وسمير تناغو – السابق ص ٦١ ، عبد الناصر العطار . – السابق ص ١٠٨ ، وانظر في الفقه الفرنسي: بولائجيه – المرجع السابق بند ٣ . دى باج جا بند ٦٣ . ومازو – السابق جـ ٢ بند ٢٠٠ .

٢- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقة يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

٣- ويراعى فى تقدير الإكراه من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه".

وتنص المادة ١٢٨ على أنه: "إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه".

**ويستبين من هذين النصين أن شروط الإكراه الذي يعيب الإرادة ثلاثة هى:**

**الشرط الأول**: **استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم**:

هذا الشرط يعنى أنه لابد من استعمال وسائل للإكراه تقع على الجسم أو على النفس، فتهدد المتعاقد المكره، أو شخصا عزيزا عليه بخطر جسيم محدق بالنفس أو المال[١]، كما يتوافر هذا الشرط إذا استعمل صاحب الحق المطالبة بحقه لابتزاز فائدة غير مشروعة من المدين، ومن ذلك أيضا أن يستعمل صاحب الشوكة والنفوذ الأدبى شوكته ونفوذه ليحقق غرضا غير مشروع، والإكراه الذي يهدد بخطر جسيم محدق بالنفس أو المال نوعان:

أ- **إكراه حسى violence physique**: وهو الذي يقع فعلا على جسم المكره بالضرب أو التعذيب.

ب- **وإكراه نفسي violence morale**: وهو الذي يكون بالتهديد بإيقاع الأذى

(١) د/ السنهوري: المرجع السابق، ص٤٨٨.

بالجسم أو النفس أو الشرف دون إيقاعه فعلا، [١] كتهديد شخص بخطف ولده، أو حرق ماله، أو تلويث سمعته بإثارة فضيحة له... الخ.

وليس هناك فرق بين الإكراه الحسى والإكراه النفسي، فكلاهما يعيب الإرادة،[٢] ويجعلان العقد قابلا للإبطال إذا توافرت باقى شروط طلبه.

**ونعرض فيما يلى للحالات الثلاث التي يتوافر مع وجودها الشرط الأول للإكراه:**

**الحالة الأولى: يجب أن يكون هناك خطرا جسيما محدقا بالنفس أو المال:**

يجب لكى يتحقق الإكراه: أن يكون الخطر المهدد به جسيما، والعبرة في جسامة الخطر بحالة المكره النفسية، وليست العبرة في الإكراه بالوسيلة المستعملة، ولكن العبرة بما تبعثه هذه الوسيلة من رهبة في النفس تجعل المتعاقد يعتقد أن خطرا جسيما يهدده في نفسه أو جسده أو شرفه أو ماله، فحالة المكره الشخصية هي التي تحدد ما إذا كان الخطر جسيما أم لا، فالمعيار ذاتى كما هو الشأن في عيوب الإرادة كلها، ومثال ذلك أن يهدد شخص أحد القرويين السذج بالقيام بعمل من أعمال السحر والشعوذة يلحق الأذى به أو بأحد أفراد أسرته، [٣] والمرأة في هذا المقام غير الرجل، والشيخ الهرم غير الشاب، والمثقف غير الجاهل، والصحيح غير المريض.[٤]

ولا يكفى أن يكون الخطر جسيما، بل يجب أن يكون محدقا؛ أى وشيك الوقوع، فلو كان التهديد بخطر يتراخي وقوعه إلى أجل يتمكن معه المتعاقد من اتخاذ الحيطة

---

(١) د . إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٢١٨ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ١٠٣.

(٢) د . عبد الودود يحيى – السابق ص ١٠٣ ، لبيب شنب – السابق ص ١٠٧ وما بعدها ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١٤٢ ، سمير تناغو – السابق ص ٦١

(٣) عبد الودود يحيى – السابق – الموضع السابق ، إسماعيل غانم – السابق –الموضع السابق .

(٤) عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٢٩ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١٤٣.

لنفسه لتفادى الخطر المحدق به، أو إبلاغ السلطات العامة، فإن التهديد هنا لا يكون من شأنه عادة أن يوقع في النفس الرهبة التي تفسد الرضا.[١]

فالعبرة إذن بحالة المتعاقد النفسية، فقد لا يكون الخطر وشيك الوقوع، ومع ذلك يولد في نفس المعاقد رهبة حالة، يتصور معها أنه لا سبيل لدفع الخطر إلا بقبول ما هدد به[٢].

والخطر الجسيم الحال قد يهدد المتعاقد في جسمه كالتهديد بالقتل أو التعذيب، وقد يهدده فى ماله كالتهديد بإتلاف مزروعاته أو إحراق منزله، وقد يهدده في شرفه واعتباره بين الناس كالتهديد بإفشاء سر يمس شرفه، أو إثارة فضيحة له.

وليس من الضروري أن يهدد الخطر المتعاقد نفسه، فقد يهدد شخصا آخر عزيزا عليه، كابنه أو زوجته أو أو خطيبته، أو صديق عزيز، بحيث يتاثر المتعاقد بهذا التهديد، فيعتبر الإكراه متحققا بذلك[٣]، والقاضي هو الذي يقدر مدى علاقة المتعاقد بمن يتهدده الخطر، وأثر هذا التهديد على المتعاقد. (انظر المادة ١٢٧ / ٢ السابق ذكرها).

**الحالة الثانية**: **استعمال صاحب الحق حقه للحصول على غرض غير مشروع (العنصر المعنوي في الإكراه)**:

لا يتحقق الإكراه إلا إذا كان المقصود من الضغط الواقع على المتعاقد المكره هو الوصول إلى غرض غير مشروع[٤] ويستوى في هذا أن تكون وسيلة الإكراه مشروعة

---

(١) السنهوري: السابق، ص ٤٥

(٢) د . عبد الودود يحيى – المرجع السابق – الموضع السابق . الصدة – السابق ص ٢٣٠ .

(٣) السنهورى – السابق ص ٤٥٢ ، وانظر: إسماعيل غانم – السابق ص ٢٢٠ . وجميل الشرقاوى – السابق – الموضع السابق ، حشمت أبو ستيت ف ١٨٤ .

(٤) الصدة – السابق ص ٢٣٠ ، عبد الفتاح عبد الفتاح – السابق – بند ١٠٥ ، عبد الرازق حسن فرج – السابق ص ١٢٤ ، عبد الناصر العطار – السابق ص ١٠٩

أم غير مشروعة، فالعبرة بعدم مشروعية الغرض الذي يراد الحصول عليه من المكره، فإذا تبين أن هذا الغرض غير مشروع: تحقق الإكراه حتى ولو كانت وسيلته مشروعه، ومن هنا فإنه يمكننا تصور فروض أربعة:

**الفرض الأول:** إذا استعملت وسيلة غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع، تحقق الإكراه: كمن يهدد آخر بخطف ولده أو بالتشهير به، إذا لم يكتب له سندا بمبلغ من المال، وكمن يهدده آخر بحرق زراعته، إذا لم يبرم تصرفا معينا.

**الفرض الثاني:** إذا كانت الوسيلة مشروعة والغرض غير مشروع تحقق الإكراه أيضا، كما لو فاجأ شخص شخصا آخر بارتكاب جريمة ما، فهدد بالإبلاغ عنه وعن الجرم الذي ارتكبه إذا لم يتعهد له بدفع مبلغ من المال لاحق له فيه، وكما لو هدد الدائن مدينه بأن يشهر إفلاسه إذا لم يكتب بمبلغ آخر أكبر من الحق الذي له، ففى كل هذه الفروض يتحقق الإكراه، ويجعل الرضا معيبا[1]،

لأن العبرة بعدم مشروعية الغرض، ولا يؤثر على هذا أن تكون الوسائل مشروعة[2]

**الفرض الثالث:** إذا كانت الوسيلة مشروعة، وأريد بها الوصول إلى غرض مشروع، فلا يتحقق الإكراه، كما لو هدد الدائن مدينه بشهر إفلاسه إذا لم يقدم له رهنا يضمن له الوفاء بدينه، فالإكراه في هذا المثال وأشباهه لا يعيب الرضا، ولا يكون التصرف قابلا للإبطال؛ لأن الرهبة المتولدة عن هذا التهديد هي رهبة بحق.

**الفرض الرابع:** إذا كانت الوسيلة غير مشروعة، واستخدمت للوصول إلى غرض مشروع، كمن يهدد آخر بالقتل، أو بإفشاء سر يصيبه في سمعته إذا لم يكتب

---

(١) السنهوري – السابق ص ٤٥٤ – ٤٥٩ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ١٠٤ . الصدة – السابق ص ٢٣١ ، لبيب شنب – السابق ص ١٧٢، جميل الشرقاوى – السابق ص ١٤٤ – ١٤٥، وانظر مجموعة الأعمال التحضيرية جـ ٢ ص ١٨٥ – ١٥٦

(٢) نقض مدنى في ١/٢٦/ ١٩٧٦ مجموعة أحكام النقض المدنى – السنة ٢٧ رقم ١٨ ص٣٠١.

له سنداً بمبلغ هو مدين له به فعلا[١]، ولكن يشترط فى هذه الحالة – حتى لا يكون الإكراه متحققا – ألا تكون هذه الوسيلة غير المشروعة جريمة يعاقب عليها القانون، فمثلا إذا هدد الدائن مدينه بالقتل إذا لم يبرم له عقد رهن، كان هذا التهديد إكراها، بخلاف ما إذا هدده بأن يحرض مخطوبته على فسخ خطبته به إذا لم يبرم له عقد رهن، فإن هذا التهديد لا يعد إكراها[٢].

**الحالة الثالثة: الشوكة والنفوذ الأدبي:**

الأصل أن الشوكة والنفوذ الأدبى الذى قد يكون لشخص على آخر كرها في لا يتحقق معه الإكراه، مثل النفوذ الذى يكون للأب على ابنه، والرئيس على مرءوسة، والنفوذ الذي يكون للأستاذ على الطالب، والوصى على القاصر ما لم يكن من ذوى القربى، والزوج على زوجته... إلخ؛ لأن استعمال النفوذ الأدبى والشوكة أمر مشروع مادام الغرض من ذلك الوصول إلى غرض مشروع. [٣]

أما إذا استخدم صاحب النفوذ نفوذه للحصول على غرض غير مشروع بأن أبرم معه عقدا بشروط باهظة، ما كان ليقبلها لولا النفوذ الأدبي الذي للمتعاقد الآخر عليه، فإن الإكراه هنا يعتبر متحققا لأنه يعيب الإرادة ويجعل العقد قابلا للإبطال[٤].

---

(١) راجع في ذلك: السنهوري – السابق ص ٤٥٨ – ٤٥٩ ، عبد المنعم الصدة –السابق ص ٢٣٢ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ١٠٥

(٢) عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ١٠٩ .

(٣) السنهوري – السابق ص ٤٦١ م

(٤) د . عبد الودود يحيى – السابق ص ١٠٥ ، عبد الفتاح عبد الباقى – السابق ص ٢٠٥ ، لبيب شنب – السابق ص ١٧٢ وما – السابق ص بعدها ، سمير تناغو – السابق ص ٦٢ ، حسام الدين الأهواني – ١٨٠ – ١٨١ ، وعبد الرازق فرج – السابق ص ١٦٥ ، والعطار – السابق ص ١١٠ ، وانظر نقض مدنى فى ١٩/٦/ ١٩٧٠ – مجموعة أحكام النقض المدنى من ٢١ ص ١٠٢٢ .

**الشرط الثاني**: **يجب أن تتولد في نفس المكره رهبة تبعث على التعاقد**: (**الإكراه دافع إلى التعاقد**):

سبق أن ذكرنا أن الذي يعيب الإرادة ليست هي وسائل الإكراه المستعملة، وإنما هي الرهبة التي تحدثها هذه الوسائل، وتؤثر هذه الرهبة في نفس المتعاقد – دون وجه حق – تأثيرا يدفعه إلى التعاقد.

والمعيار هنا ذاتي؛ فليست العبرة بمدى تأثير وسائل الإكراه فى الشخص العادي، بل العبرة بتأثيرها في نفس المكره، فيراعى فى التقدير جنس من وقع عليه الإكراه وسنة، وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. [١] (م ١٢٧ / ١).

فالقروى الطيب غير المدنى المتحضر، والضعيف غير القوى، والمريض غير المعافى والجاهل غير المتعلم، والصغير غير الكبير.... وهكذا.

ويعتد أيضا في تقدير الرهبة بظروف الزمان والمكان، فالتهديد ليلا يكون أشد رهبة – غالبا – في نفس المتعاقد من التهديد نهارا، والتهديد في جهة قاصية بعيدة عن الناس يختلف عن التهديد في مكان أهل بالسكان وعلى مقربة من رجال الأمن[٢].... الخ.

ومعرفة ما إذا كانت الرهبة هى التى دفعت إلى التعاقد فعلا هى من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض في

---

(١) د . إسماعيل غانم – السابق ص ٢١٩ ، د . عبد الرازق فرج – السابق ص ١٦٦ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ٢٠٦ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص في هذا المعنى نقض مدنى ٢٩/١/ ١٩٧٩ – المجموعة السابقة السنة ٢٧ ص١٤

(٢) نقض مدنى في ١٥/٢/ ١٩٦٦ مجموعة أحكام النقض – السنة ١٧ ، رقم ٣٨ ص ٢٨٧ ، السنهوري – السابق ص ٤٦٨ ، وانظر: عبد المنعم البدراوى – السابق ص ٢٧٣ ، عبد المنعم الصدة – السابق – الموضع السابق – محمود جمال الدين زكي – السابق ص ١٥٠ .

ذلك إلا من حيث سلامة التسبيب [١].

**الشرط الثالث**: **أن يكون الإكراه صادرا من المتعاقد الآخر أو كان على علم به ( اتصال المتعاقد الآخر بالإكراه )**:

الإكراه يحدث عادة من أحد طرفي العقد للآخر، كما لو هدد شخص آخر بقتله إذا لم يعطه ما معه من النقود، وفى هذه الحالة يفسد الإكراه الرضا ويجعل التصرف – أو العقد – قابلا للإبطال، ولكن الإكراه قد يصدر أيضا من الغير، كما لو هدد شخص جاره بإلحاق الأذى به إذا لم يبع منزله إلى آخر، هنا لا يكون الإكراه سببا لإبطال العقد إلا إذا كان الطرف الآخر (وهو في هذا المثال

من يشترى المنزل) يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه. [٢]

وفى هذا تنص المادة ١٢٨ مدنى مصرى على أنه: "إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه"، فإذا لم يثبت علم المتعاقد الآخر على هذا النحو، فلا يكون العقد قابلا للإبطال، ولا يكون أمام المتعاقد المكره إلا أن يرجع بالتعويض على من وقع منه الإكراه على أساس الفعل الضار[٣].

ويلاحظ أنه في التعاقد بطريق النيابة: يكون العقد قابلا للإبطال إذا صدر الإكراه من الأصيل ولو لم يعلم به النائب، أو صدر من النائب ولو لم يعلم به الأصيل.[٤]

---

(١) نقض مدنى فى ١١ / ١ / ١٩٦٦ – مجموعة أحكام النقض –س ١٧ رقم ٢٨ ص ٢٨٧.

(٢) عبد الودود يحيى – السابق ص ١٠٧ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٣٤ ، عبد الفتاح عبد الباقى – السابق ص ٢٠٤ – ٢٠٥ ، عبد المنعم البدراوي – السابق ص ٢٨٤ ، سمير تناغو – السابق ص ٦٢ ، د ، حسام الدين الأهواني – السابق ص ١٨٣ .

(٣) انظر: السنهوري – السابق ص ٤٧١ ، عبد الودود يحيى – السابق – الموضع السابق ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٣٤ ...

(٤) إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٢٢ .

**الإكراه في حالة الضرورة** :

يقصد بهذا النوع من الإكراه أن ظروفا تهيأت مصادفة لأحد المتعاقدين فولدت رهبة يستغلها للضغط على إرادة الطرف الآخر وحمله على التعاقد.

مثال ذلك: طفل يشرف على الغرق، فيتقدم شخص لإنقاذه، ويحصل من والده في مقابل ذلك – وقبل أن يقوم بعملية الإنقاذ – على تعهد بإعطائه مبلغا كبيرا من المال، أو يصاب شخص بحادثة فيشترط الطبيب لعمل اللازم له طبيا أجرا باهظا، في مثل هذه الحالات يتحقق الإكراه؛ لأن المتعاقد الآخر الذي استغل هذه الظروف كان يعلم بها وقصد استغلالها للحصول على فائدة غير مشروعة من خلال الشروط التي حددها، ومن ثم يتحقق الإكراه الذي يجعل العقد قابلا بالإبطال. (١)

**وعلى العكس:** إذا كان المتعاقد الآخر حسن النية ولم يقصد أن يستغل المتعاقد المهدد بخطر تهيأت ظروفه مصادفة، لا يكون للمتعاقد المكره حق إبطال العقد؛ لأن المتعاقد الآخر كان حسن النية ولم يهدف إلى استغلال الخطر الذي يتهدد المتعاقد معه، ومثال ذلك أن يتفق جراح شهير مع مريض على إجراء عملية خطيرة، وتقاضي نظير ذلك على مبلغ كبير، ولكنه يتناسب مع خطورة العملية، فالعقد – هنا – صحيح حتى ولو تمسك المريض فيما بعد أن إرادته لم تكن حرة وقت التعاقد(٢).

---

(١) انظر: السنهوري – السابق ص ٤٧٤ ، إسماعيل غانم – السابق ص ٢٢١ ، الصدة – السابق ص ٢٣٤ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ١٠٧ ، لبيب شنب – السابق ص١٥٤.

(٢) السنهوري – السابق ص ٤٧٥ هامش ، وانظر في هذا المعنى: حشتمت أبو ستيت – السابق بند ١٨٧ ، عبد الفتاح عبد الباقى – السابق ص ٢٠٦ وما بعدها ، عبد المنعم البدراوى – السابق ص ٢٨٥، أنور سلطان – السابق ص ن ١٩٠ وما بعدها

## الفرع الرابع

## الاستغلال ( الغبن) L`exploitation

**تعريف الاستغلال والغبن:**

الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه الشخص وما يأخذه.

أما الاستغلال فهو انتهاز شخص حالة ضعف شخص آخر لكي يحصل منه على مزايا لا تتعادل مع ما يعطيه فى مقابلها[1]، فيتحقق الغبن المادى، بل قد يصل الاستغلال إلى الحد الذى يجعل من وقع منه الاستغلال يحصل على مزايا لا تقابلها أى منفعة على من وقع عليه هذا الاستغلال.

ويستبين مما سبق أن الغبن هو المظهر المادي للاستغلال، ومن ثم فإن الغبن يتميز عن الاستغلال بأمرين جوهريين:

أ- الغبن لا يتصور إلا في عقود المعاوضة غير الاحتمالية، أما عقود المعاوضة الاحتمالية كعقد التأمين، وعقود التبرع، فلا يتصور فيها الغبن لأن الأولى تقتضى طبيعتها ضرورة وقوع غبن ما على أحد المتعاقدين، ولأن الثانية (عقود التبرع) يعطى فيها أحد المتعاقدين ولا يأخذ[2]، بخلاف الاستغلال الذى قد يقع في العقود الاحتمالية، بل وفي عقود التبرع، كل هذا ومن ثم كان الاستغلال أوسع مدى من الغبن.

---

(١) د . إسماعيل غانم – السابق ص ٢٢٣ ، د . منصور مصطفى منصور – مصادر الالتزام – مذكرات على الآلة الضاربة ص ٨٩ ، جميل الشرقاوى – السابق من ١٥١ ، لبيب شنب – السابق ص ١٧٩ وما بعدها ، سمير تناغو – السابق ص١١.

(٢) السنهوري – السابق ص ٤٧٦ – ٤٧٧ ، وهامش (١) بذات الصحيفة ، وانظر في الموضوع الاستغلال بصفة خاصة رسالة الدكتوراه توفيق حسن فرج – نظرية الاستغلال في القانون المدنى المصرى – رسالة من جامعة الإسكندرية ١٩٥٧م –وانظر إسماعيل غانم – السابق ص ٢٢٤ ، والصدة – السابق ص ٢٣٧ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ١٠٨ .

ب – الغبن يقاس بمعيار مادى؛ إذ ينظر فيه إلى ما بين الآدات المتقابلة من تفاوت في القيمة المادية، أى القيمة بحسب سعر السوق، والعبرة فى تقدير الغبن بوقت تمام العقد، فينظر إلى التعادل في هذا الوقت. ولا عبرة بتغير القيمة بعد ذلك، والغبن بهذا المعنى يعتبر عيبا في العقد يتحقق بمجرد التفاوت المادى، حتى ولو كانت إرادة العاقد المغبون سليمة،[1] وذلك كله عكس الاستغلال الذي يكون المعيار فيه شخصيًا لا ذاتيًا.

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الغبن يصعب الاحتراز منه تماماً فلا بد من التسامح فى الغبن اليسير والوقوف عند الغبن الفاحش أي الذي يجاوز الحد المألوف فى التعامل.

**شروط الاستغلال**:

تضمنت المادة ١٢٩ مدني مصري شروط قيام الاستغلال فقالت: "١– إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بينا أو هوى جامحاً، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المكبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

٢– ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

٣– ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن".

يتبين من هذا النص أن شروط قيام الاستغلال هي:

---

(١)السنهوري السابق ص ٤٧٧ ، وعبد المنعم البدراوى – السابق ص ٢٨٧ جميل الشرقاوى – السابق ص ١٥١ ، لبيب شنب – السابق ص ١٧٩ ، أنور سلطان – السابق ص ١٩٢ .

**الشرط الأول: أن يكون هناك اختلال فادح بين الأدآت المتقابلة فى العقد:**

يجب أن يكون الاختلال فى التعادل بين الالتزامات المتقابلة للمتعاقدين فادحاً بمعنى أن يصل الاختلال إلى الحد الذي يجاوز المألوف بشكل واضح [١]، فلا يكفي مجرد عدم تعادل قيمة بدلين فى معاوضة ليتحقق الغبن إذ من المألوف فى التعامل وجود غبن يسير بين المتعاملين لا يعتد به والغبن يكون فادحاً بالنسبة للمغبون إذا كان ما يلتزم به يزيد بكثير عن قيمة ما يحصل عليه كمقابل لالتزامه.[٢]

وتقدير فداحة الاختلال متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ويقع عبء إثبات هذا الاختلال على المتعاقد المغبون والعبرة فى تقدير قيمة الشئ بقيمته الشخصية بالنسبة للمتعاقد، لا بقيمته المادية في الأسواق، فقد تكون قيمة الشيء في السوق ألفا، ومع ذلك يشتريه المتعاقد بألفين، لأنها تساوى ذلك في نظره لاعتبارات شخصية لديه.[٣]

وغنى عن البيان أن العبرة فى تقدير قيمة الشيء بوقت التعاقد، ومن ثم لا عبرة بما يؤثر فيها أو يطرأ عليها بعد ذلك من ارتفاع أو انخفاض في الأسعار.

والاختلال بين الآدآت المتقابلة بالمعنى الذي ذكرناه يكون في جميع التصرفات[٤]، وأكثر ما يكون في عقود المعاوضات المحددة (غير الاحتمالية) كعقود

---

(١) عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٤١ ، جميل الشرقاوي – السابق ص ١٥٢ لبيب شنب – السابق ص ١٨٠ ، حسام الدين الأهواني – السابق ص١٨٢.

(٢) السنهوري – السابق ص ٤٨٦ – الصدة – السابق ص ٢٤١ ، وقارن – حسام الأهواني – السابق ص ١٨٧ .

(٣) انظر في ذلك تفصيلا: رسالة د / توفيق فرج – سابق الإشارة إليها ص ٢٣٠ وانظر في ذلك أيضا: نقض مدنى فى ٨/٢/١٩٥١ – مجموعة أحكام النقض المدنى س ٢ – رقم ٥٩ ص ٣٠٦

(٤) السنهوري – السابق ص ٤٨٨ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٤٢ ، وقارن جميل الشرقاوى – السابق ص ١٥٥ . حيث يرى سيادته: أن فكرة الغبن لا تتصور في غير المعاوضات.

البيع – والإيجار، والقرض... الخ، كما قد يقع في عقود المعاوضات الاحتمالية، وإن كان هذا غير مألوف[١] كما إذا اشترطت شركة التأمين – في عقد التأمين – أقساطا سنوية مالية باهظة لا تتعادل البتة مع احتمال الخسارة، فإن عنصر الاستغلال المادي (الغبن) يكون متحققا [٢].

كما قد يقع الاستغلال أيضا فى التبرعات سواء كانت عقودا كالهبة، مثل ما لو تبرع شخص بجميع أمواله لزوجته الثانية الشابة ليحرم زوجته وأولادها من أمواله، أو كانت تصرفات انفرادية كالوصية، ففى هذه التبرعات لا يقال أن هناك اختلالا فادحا في التعادل، إذ لا تعادل أصلا، فهو معدوم، لأن العاقد لا يأخذ مقابلا لما يعطى[٣]، ومع ذلك يقوم الاستغلال في مثل هذه التصرفات – استثناءً – على الوجه السابق بيانه

**الشرط الثاني**: **أن يكون هناك استغلال لطيش بين أو هوى جامح في المتعاقد المغبون**:

هذا الشرط هو ما يعبر عنه بـ " العنصر النفسي" في الاستغلال في مقابلة العنصر الموضوعي (الشرط الأول في الاستغلال وهو عدم التعادل بين التزامات المتعاقدين).

ويتحقق هذا الشرط إذا كان اختلال التعادل أو عدم وجود المقابل قد وقع نتيجة استغلال ضعف معين في المتعاقد الآخر ( المغبون ).

---

(١) لأنها تقوم على أساس الكسب والخسارة.

(٢) د/ عبد الرازق حسن فرج: السابق ص١٧٩، وانظر: سليمان مرقس، السابق بند ٢٢٠، لبيب شنب – السابق ص١٨١، وانظر: مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٢ ص ١٩ .

(٣) انظر: السنهوري – السابق ص ٤٨٧ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٤٢ . توفيق فرج – السابق ٩٤ وما بعدها، حسام الدين الأهواني السابق ص ١٨٧ .

وهذا ما عبرت عنه المادة ١٢٩/١٠ مدنى مصرى بقولها "متى تبين أن المستعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر، قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا".

فالقوانين المدنية العربية ومن بينها القانون المصرى – حددت الضعف الذي يتوافر به هذا الشرط (العنصر النفسي) لوجود الاستغلال في حالتين:

الطيش البين، والهوى الجامح، ولذلك لا يجوز تطبيق نظرية الاستغلال إذا كنا بصدد حالة من حالات الضعف غير هاتين الحالتين.[١]

**والطيش البين:** هو الخفة الواضحة التي تؤدى إلى التسرع وسوء التقدير، وقبول التعاقد دون ترو أو تدبر فى النتائج المترتبة على العقد،[٢] وذلك كالشاب الوارث الذي يرغب في الحصول على نقود بأية وسيلة لسد حاجته إلى البذخ والتبذير، فيأخذ فى بيع أمواله بثمن بخس أو الاقتراض بشروط باهظة.

**أما الهوى الجامح:** فهو الرغبة الشديدة تقوم في نفس الشخص، فيتعلق بشخص أخر أو بأمر معين يريد الحصول عليه تعلقا يفقده سلامة الحكم على ما يتصل بموضوع تعلقه[٣]، ومثال ذلك: الرجل الطاعن في السن حين يتزوج امرأة شابة تستغل ولعه بها لكى يبرم لصالحها وأولادها عقودا يؤثرهم بها على زوجته الأولى وأولاده منها، ومثل المرأة المتزوجة التي تكره زوجها كرها شديدا يؤدى بها إلى الرغبة الجامحة في الانفصال عنه، فيحصل منها على مبلغ كبير من المال في مقابل

---

(١) د . إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٢٢٩ ، د . جميل الشرقاوى – السابق ص ١٢٦ ، د . لبيب شنب – السابق ص ١٨٢ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٤٤.

(٢) د . لبيب شنب – السابق ص ١٣٢ ، توفيق فرج – السابق ص ٢٨٧ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١٥٧ ، حسام الأهوانى – السابق ص ١٨٨.

(٣) انظر عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٤٤ ، توفيق فرج – السابق ص ٢٨٩ وما بعدها ، ومنصور مصطفى منصور – السابق ص ١٩٣ .

طلاقها[1]، كما يمكن أن نتصور فتاة (نزقه) يشتد بها الولع بالعمل فى السينما فيأتي من يستغل فيها هذا الهوى الجامح فتعطيه من مالها الكثير حتى يهيء لها فرصة الظهور في أحد الأفلام أو لكي يقدمها لبعض كبار المخرجين والمنتجين.

وهكذا الشأن في أنواع كثيرة من الأعمال كالحب الشديد إلى حد الوله للعمل في الصحافة، أو السلك السياسي أو التدريس بالجامعة ... الخ .

**الشرط الثالث**: **أن يكون الاستغلال هو الذي دفع إلى التعاقد**:

يجب أن يكون الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى إبرام التصرف، أى يجب أن يكون المتعاقد مع المغبون قد أراد استغلال ضعف من به طيش بين أو هوى جامح، وهذا يقتضى بداهة أن يكون المتعاقد مع المغبون قد علم بالضعف المتوفر لديه[2]، أو كان في وضع من الواجب عليه فيه أن يعلم بهذا الضعف عند هذا المتعاقد المغبون، وقيام المغبون بإبرام التصرف تحت تأثير هذا الاستغلال يجعل إرادته معيبة، ويكون العقد قابلا للإبطال، مع مراعاة أن المعيار هنا معيار ذاتى كما هو الشأن في كل عيوب الإرادة.

**إثبات الاستغلال**:

المتعاقد المغبون هو الذي يقع عليه عبء إثبات الاستغلال بشروطه السابق ذكرها، ويجوز له الإثبات بكافة الطرق، لأنه ينصب على وقائع مادية هي الوقائع المكونة للاستغلال، فعليه أن يثبت وجود الاستغلال بوجود الطيش البين والهوى الجامح، وهذا الاستغلال هو الذي دفعه إلى التعاقد.

---

(١) د . إسماعيل غانم السابق ص ٢٣١ ، وانظر عبد الودود يحيى – السابق ص . ١١ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٤٢

(٢) د. توفيق فرج – السابق ص ٢١٣ – ٢١٤ ، وانظر: لبيب شنب – السابق ص١٨٣، وعبد الودود يحيى – السابق ص١١١، محمود جمال الدين زكي – السابق ص١٥٩-١٦٠.

وهذه مسائل موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع، أما الوصف القانوني لهذه الوقائع كالفصل فيما إذا كان الطيش أو الهوى أو غيرهما يصح أن يكون محل استغلال، فتلك مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع الرقابة محكمة النقض.[١]

**جزاء الاستغلال**:

تقضى المادة ١/١٢٩ مدنى مصرى بأنه يجوز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد، ومن ثم فإن شروط الاستغلال إذا توافرت، كان لمن وقع فى الاستغلال أن يطلب إبطال العقد، أو انقاص التزاماته.

أ- **دعوى إبطال العقد:** وهى الدعوى التي يرفعها المغبون طالبا إبطال العقد الذي أبرمه نتيجة لاستغلال المتعاقد الآخر فيه طيشا بينا أو هوى جامحا[٢]، بيد أن القاضي لا يلتزم بأن يجيب المغبون إلى طلبه إبطال العقد، ولكن يجوز له أن يكتفى بـ "انقاص الالتزامات" الباهظة الذي وقع فيها المغبون، إذا رأى أن هذا كافيا لرفع أثر الاستغلال[٣]، وسواء بعد ذلك أكان العقد معاوضة أن تبرعاً، ويسترشد القاضي فى هذا الخيار الممنوح له بملابسات القضية وظروفها، ومن ثم فالأمر بالنسبة لمحكمة

---

(١) د . عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٤٦، لبيب شنب – السابق ص ١٩٤ . محمود جمال الدين زكى – السابق ص ١٦٠ ، عبد الرازق فرج – السابق من ١٨١ ، سمير تناغو – السابق ص ٦٧ .

(٢) د. عبد الرازق فرج–السابق ص١٨١، عبد الودود يحيى– السابق ص١١١ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١٥٨

(٣) انظر نقض مدنى في ١/٤/١٩٦٩م – مجموعة أحكام النقض المدني – س ٢٠ رقم ٨٩ ص ٥٥٦

الموضوع مسألة واقع لا معقب عليها من محكمة النقض[١]، وإذا كان القاضي يملك انقاص التزامات المتعاقد المغبون، فإنه لا يملك أن يزيد فى التزامات المتعاقد الآخر، فإذا كنا بصدد عقد بيع، ورفع البائع المغبون دعوى الإبطال الاستغلال، فإن القاضي قد لا يحكم بالإبطال ويكتفى بانقاص ثمن المبيع إلى الحد الذي يزيل الغبن الفاحش، ولا يستطيع أن يحكم بزيادة الثمن على المشترى، والآخير يستطيع من تلقاء نفسه أن يتوقى دعوى الإبطال التى رفعها البائع، إذا قدم ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن[٢].

**ب- دعوى الإنقاص:** يستطيع المتاقد المغبون رفع دعوى الإنقاص من البداية وفى هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يحكم بالإبطال؛ لأنه لا يجوز له أن يحكم بأكثر مما يطلبه الخصم، ويقضى القاضي فى هذه الدعوى بإنقاض التزامات المتعاقد المغبون إلى الحد الذى يزول معه الغبن الفاحش بحسب تقديره لملابسات وظروف الدعوى[٣].

وجدير بالذكر أن المتعاقد المغبون غالباً ما يلجأ إلى دعوى الإنقاص إذا رأى أن من مصلحته الإبقاء على العقد، لأن طلبه إبطال العقد سيؤدى به إلى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، وهذا يحرمه من المنفعة التي كان ينبغى تحقيقها من وراء التعاقد [٤].

---

(١) السنهوري – السابق ص ٤٩٨ ، الصدة ، السابق ص ٢٤٧ اسماعيل غانم – السابق ص ٢٣٣ . عبد الودود يحيى – السابق ص ١١١ لبيب شنب – السابق – ص ١٩٠ .

(٢) المادة: ٣/١٢٩ مدني مصري .

(٣) د. عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٤٨ ، عبد الودود يحي – السابق ص ١١٢ ، لبيب شنب ص١٩٠، سمير تناغو–السابق ص ٦٧ – ٦٨ . جميل شرقاوي – السابق ص ١٥٩ .

(٤) د . عبد الرازق فرج – السابق ص ١٨٢ .. وانظر: أنور سلطان – السابق ص ١٦٧ ، عبد المنعم البدراوى – السابق ص ٢٩٥ ، عبد الفتاح عبد الباقي – السابق ص ٢١٤ – ٢١٥ .

كما يلاحظ أن الإنقاص كالإبطال يجوز في التبرعات كما في المعاوضات[١] فيستطيع القاضي أن ينقص التزامات المتبرع المغبون إلى الحد الذي يراه مناسبا.

وسواء كنا بصدد دعوى إبطال أو دعوى إنقاص، يجب أن ترفع الدعوى خلال سنة من وقت إبرام العقد المشوب بعيب الاستغلال وإلا كانت الدعوى غير مقبولة[٢]، وهذه المدة مدة سقوط لا مدة تقادم، فلا تقبل الوقف ولا الانقطاع.

وهي بذلك تختلف عن دعاوى طلب إبطال العقد بسبب عيوب الإرادة الأخرى،[٣] فيما يتعلق بالمدة التي يجوز أن ترفع الدعوى خلالها، وهي ثلاث سنوات من وقت اكتشاف العيب، أو خمس عشرة سنة من وقت العقد، والمدة هنا مدة تقادم تقبل الوقف والانقطا، وحكمة جعل المدة قصيرة في الاستغلال، هي الرغبة فى حسم النزاع بشأن العقود التي يشوبها استغلال حتى لا يبقى مصير العقد معلقا لفترة طويلة بشأن عيب التثبت من وجوده ليس بالأمر السهل، وفى هذا حماية للتعاقد واستقرار التعامل[٤] .

---

(١) عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٤٨ .

(٢) م ١٢٩ / ٢ مدنى مصري .

(٣) وهي الغلط أو التدليس أو الإكراه .

(٤) د. عبد الودود يحيى – السابق الموضع السابق – وانظر في هذا المعنى –السنهوري – السابق ص ٢٩٧ ، إسماعيل غانم – السابق ص ٢٣٥ ، سمير تناغو السابق ص ١٨ ، الصدة – السابق ص ٢٤٩ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١١٠ ، وقارن أنور سلطان – السابق ص ١٦٣ ، توفيق فرج –– السابق بند ١٤٥ .

# المبحث الثاني

## المحل: L'oliget

**محل العقد ومحل الالتزام**:

محل الالتزام هو الشيء – أو الأمر – الذى يلتزم المدين القيام به، والمدين يلتزم إما بإعطاء شيء كالتزام بنقل ملكية منزل، وإما بعمل كالتزام المقاول ببناء منزل، وإما بالامتناع عن عمل كالالتزام بعدم المنافسة[1] (أي عدم فتح محل مماثل في نفس المنطقة).

أما محل العقد فهو العملية القانونية التي يراد تحقيقها، كالبيع أو الإيجار، فموضوع العقد هو بيع شقة، أو إيجار عين أو تقديم خدمة.

وتحقيق العملية القانونية التى هى محل العقد تستلزم – غالبا – إنشاء التزامات على عاتق الطرفين أو على عاتق أحدهما، ولذلك فإن محل العقد: يتحدد بمحل الالتزامات الرئيسية التي تتحقق بها العملية القانونية المقصودة، ففي عقد البيع – مثلا – تكون العملية القانونية التى تراضي عليها الطرفان، والتي يتحدد بها محله: هى نقل الملكية فى مقابل ثمن نقدى، ونقل الملكية هو الآداء الذى يلتزم به البائع، ودفع الثمن هو الآداء الذي يلتزم به المشترى.

وعلى ذلك فإن الشروط التى يجب أن تتوافر فى محل العقد هي الشروط التى يجب أن تتوافر فى محل الالتزام والقول بالتفرقة بين محل الالتزام ومحل العقد، وخضوع كل منهما لأحكام غير التى يخضع له الآخر قول يعوزه الدليل الصحيح ويفتقر إلى المقومات القانونية المقبولة.

---

(١) انظر في ذلك: السنهوري – الوسيط جـ ١ ط ١٩٨١ ص ٥٠١ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ١٨٠ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ١١٢ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٥٠ – ٢٥١.

**شروط المحل**: **تعداد**:

يستخلص من نصوص التقنين المدني المصري (م ١٣١ – ١٣٥) أن شروط محل الالتزام (محل العقد) ثلاثة:

١- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود .

٢- أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين .

٣- أن يكون مشروعاً ( قابلاً للتعامل فيه ) .

وإذا تختلف أي شرط من هذه الشروط فلا ينشأ الالتزام ويكون العقد باطلاً، وسنعالج كل شرط من هذه الشروط فى مطلب مستقل على النحو التالي:

## المطلب الأول

## المحل موجود أو ممكن الوجود

**أولا**: **معنى الوجود** ( **وجود المحل** ):

إذا كان محل الالتزام نقل حق عينى على شيء فيجب أن يكون الشيء موجودا وقت نشوء الالتزام، أو أن يكون محتمل الوجود بعد ذلك وفقا لقصد المتعاقدين، فإذا قصد المتعاقدان أن يقع الالتزام على شيء موجود فعلا – وقت التعاقد –، ثم تبين أنه غير موجود، فإن الالتزام لا يقوم حتى ولو أمكن وجوده في المستقبل، ويكون العقد باطلا بطلانا مطلقا، مثل قيام شخص ببيع سيارة موجودة عنده، ثم يتبين أن السيارة سرقت أو هلكت قبل إبرام العقد.

ويستوى أن يكون الشيء غير موجود أصلا أو كان موجودا، ثم هلك قبل نشوء الالتزام، أما إذا كان الشيء موجودا وقت إبرام العقد، ثم هلك بعد ذلك فإن الالتزام يكون قد نشأ صحيحا، إلا أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه لعدم استطاعة أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه[١] إذ لا التزام بمستحيل.

(١) د/ عبد المنعم الصدة السابق ص ٢٥٤ ، عبد الرازق فرج – السابق ص ١٩١ . محمود جمال الدين

**التعامل على شيء سيوجد في المستقبل**:

تنص المادة ١/١٣١ مدنى مصرى على أنه: "يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا".

ويستبين من هذا النص أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا بشرط أن يكون هذا الشيء ممكن الوجود في المستقبل تحقيقا أو احتمالاً، مادام المتعاقدان لم يقصدا أن يرد التعاقد على شيء موجود فعلا وقت العقد.

**ومن أمثلة ذلك**: بيع شخص لآخر منزلا لم يبدأ بناؤه بعد، على أن تنتقل ملكية المنزل للمشترى عند تمام البناء، فهذا بيع شيء مستقبل محقق الوجود، وقد يكون الشيء المستقبل محتمل الوجود، كما إذا باع شخص نتاج ماشية قبل وجودها[1]، إذا النتاج هنا قد يوجد وقد لا يوجد، ومن ثم يكون البيع هنا معلقا على شرط يتحقق إذا وجد النتاج، ومن ذلك أيضا بيع مزارع المحصولات أرضه قبل ظهورها، وبيع صاحب المصنع قدراً من مصنوعات مصنعه قبل تمام صنعها.

وهكذا نجد أن المشرع الوضعى أجاز التعامل في الأشياء المستقبلة على النحو السابق، وأنه يحدث كثيرا فى حياتنا العملية، وهو بذلك أتى بحكم يتفق مع ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين – كابن القيم – الذي يرى جواز التعامل في الشيء المستقبل إذا امتنع الغرر، وهو ما لا يتفق ورأى جمهور فقهاء المسلمين الذي يرى أنه لا يجوز التعامل – كقاعدة عامة – إلا في شيء موجود، ويستثنى من ذلك السلم، والإيجار الذي أجيز على خلاف القياس لضرورات اجتماعية واقتصادية.

وبناء على ما سبق فإن الشيء إذا لم يكن قابلا للوجود في المستقبل كما لو

---

زكى – السابق ص ١٦٩ ، أنور سلطان– السابق ص٢٠٨.

(١) انظر: د / عبد الرزاق السنهورى – السابق ص ٥٠٥ ، عبد المنعم الصدة السابق ص ٢٥٥ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ١٣ ، لبيب شنب – السابق ص ١٩٩.

اتفق على تأجير شقة فى طابق علوى من المنزل المزمع بناؤه، وكان قانون تنظيم المباني لا يجيز الارتفاع بالبناء إلى الطابق الذي اتفق على أن تكون فيه الشقة المؤجرة، فإن الالتزام هنا لا ينشأ لاستحالة المحل،[1] وينفسخ العقد بعد أن كان قد انعقد فعلا.[2]

**استثناءات من قاعدة جواز التعامل على شيء سيوجد في المستقبل**:

إذا كانت القاعدة هى جواز التعامل على الأشياء المستقبلة، إلا أن القانون قد يحرمه في بعض الأحوال لاعتبارات خاصة، ومن هذا القبيل: النص على بطلان هبة المال المستقبل (م ٤٩٢)، والنص على بطلان رهن المال المستقبل، سوءا كان رهنا رسميا (م ١٠٣٣) أو رهنا حيازيا (م ١٠٩٨ ) .

وقد يحرم القانون جميع أنواع التعامل فى نوع خاص من المال المستقبل كما فعل عند ما حرم التعامل في التركة المستقبلة، وهو ما سنعالجه تفصيلا في البند التالي:

**التعامل في التركة المستقبلة**:

بعد أن قررت الفقرة الأولى من المادة ١٣١ مدنى مصرى جواز التعامل في الشيء المستقبل إذا كان قابلا للوجود، نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على حكم التعامل في التركة المستقبلة، فقالت: "غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون".

وترجع هذه القاعدة فى أصلها الأول إلى القانون الروماني، حيث كان يعتبر التعامل في التركات المستقبلة مخالفا للنظام العام والآداب، فهو يخالف الآداب لأن من يتعامل فى تركة شخص لا يزال حيا، إنما يضارب على موته. ويخالف النظام

(١) د.إسماعيل غانم–السابق ص ٢٤٣ ، وانظر السنهوري – السابق ص ٥٠٦ تناغو – السابق ص ٧٠ .

(٢) د . عبد الرازق فرج – السابق ص ١٩٢ ، سمير تناغو – السابق – الموضع السابق – قارن: لبيب شنب – السابق ص ١٩٩ ، حسام الدين الأهواني – السابق ص ٢٠٣ .

العام، لأنه يغرى صاحب المصلحة بالتعجيل بموت المورث. إلا أن الرومان كانوا يعتدون في هذا التحريم بمصلحة المورث فقط، ولذلك كانوا يجيزون هذا التعامل إذا رضى به المورث واشترك في العقد.

بينما نجد القوانين الحديثة تحرم هذا التعامل لا لمصلحة المورث فقط، بل لمصلحته ومصلحة الوارث معا، فنصت هذه القوانين على تحريم التعامل في التركة المستقبلة، ولو كان ذلك برضاء المورث، فإذا وقع مثل هذا التعامل كان باطلا بطلانا مطلقا[١] مع ما يترتب على هذا البطلان من آثار.

فالمادة ١٣١ / ٢ مدنى مصرى – شأنها شأن معظم القوانين الحديثة تحرم التعامل في التركة المستقبلة.

ويراد بالتركة المستقبلة مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من ديون وقت موته، والتعامل المحظور هو الذي يرد على التركة في مجموعها، أو على جزء منها، أو على مال معين باعتبار أنه سيدخل ضمن أموال الشركة المستقبلة سواء أكان التعامل من المورث نفسه، أو من الوارث المستقبل وأيا كانت صورة التعامل، فإذا باع شخص ما سيئول إليه من تركة مورثه أو جزءا منه، أو مالا معينا باعتبار أنه سيئول إليه بالميراث، وقع البيع باطلا ويستوى مع الوارث فى الحكم الموصى له، فلا يجوز له أن يتصرف في المال الموصى به قبل وفاة الموصى، ويقع التصرف باطلا، حتى ولو أجازه المورث [٢]، لأن هذا التصرف مخالف للآداب العامة، على أساس أنه يتضمن مضاربة على حياة المورث، وتعجلا لموته.

---

(١) السنهوري – السابق ص ٥٠٩ ، وانظر: د / عبد المنعم الصدة – السابق من ٢٥٧، د. سمير تناغو – السابق ص ٧١ ، حسام الدين الأهواني – السابق من ٢٠٢.

(٢) انظر في ذلك: د / عبد الودود يحيى – السابق ص ١١٤ ، سليمان مرفس –السابق ص ١٢٩ – ١٣٠ ، عبد الفتاح عبد الباقى – السابق ص ٢٢٢ – ٢٢٣

وتحريم التصرف فى التركة المستقبلة عام، لا فرق فيه بين تصرف صادر من الوارث وتصرف صادر من المورث، فإذا اتفق مورث مع أحد الورثة على أن يختص بنصيب أكبر من نصيبه الشرعي، أو إذا اتفق مع أجنبي على أن يكون له حظ ونصيب في التركة، فهذه الاتفاقات باطلة، لأن المورث لا يمكنه التصرف فى تركته إلا عن طريق الوصية التي تختلف أحكامها عن هذه الاتفاقات، حيث يجوز للوصى أن يرجع في وصيته إلى ما قبل الموت، كما أن الوصية مقيدة بعدم تجاوز الحد الجائز الإيصاء به، وعلة بطلان التصرفات الصادرة من المورث ترجع إلى أن هذه التصرفات تخل بأحكام الميراث التي هي من النظام العام [١]، والتي لا يجوز الخروج عليها إلا عن طريق الوصية.[٢]

**وخلاصة القول**: أن كل أنواع التعامل في التركة المستقبلة غير جائز قانونا، فلا يجوز للوارث أن يبيع ميراثه المستقبل، أو يهبه، أو يقايض به . أو يقدمه نصيبا في شركة أو يصالح عليه، ولا يجوز لاثنين من الورثة أن يتفقا على قسمة ما سيقع فى نصيب كل منهما من الميراث أو أن يشترى أحدهما ميراث الآخر الذى سيئول إليه ..... الخ .

وأخيرا يجب التنوية إلى أنه يستثنى من تحريم التعامل في التركة المستقبلة أحوال نص عليها القانون، من ذلك: ما نص عليه القانون في المادة ٩١٥ مدنى مصرى فى شأن جواز الوصية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها، ومن ذلك أيضا: ما نص عليه القانون في المواد ٩٠٨ – ٩١٣ مدنى مصرى من جواز الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بشروط مخصوصة...الخ.

---

(١) انظر: السنهورى – السابق ص ٥١١ ، عبد الودود يحيى– السابق ص ١١٥ . سليمان مرقس – السابق ص ١٣٠ .

(٢) عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٥٢ ، د . إسماعيل غانم – السابق ص ٢٣٨ . جميل الشرقاوى – السابق ص ١٩٢ .

**ثانياً: إمكان وجود المحل**:

إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل: وجب أن يكون ممكنا والإمكان هنا يقابل شرط الوجود – السابق بيانه – إذا كان محل الالتزام إعطاء شيء، فالوجود ليس إلا صورة للإمكان، فهما شيء واحد يعبر عنه بالإمكان في حالة ما إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل[1] ويعبر عنه بالوجود إذا كان محل الالتزام إعطاء شيء .

وتأسيسا على ما تقدم فإن محل الالتزام إذا كان غير ممكن، بأن كان مستحيلا، فإن الالتزام لا يقوم، ويكون العقد باطلا إذ لا التزام بمستحيل، وقد نصت على هذا الحكم المادة ١٣٢ من التقنين المدنى المصرى بقوله: "إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا".

**والمقصود بالاستحالة هنا: الاستحالة المطلقة:** وهي التي تقوم بالنسبة لجميع الناس، وذلك حتى تكون الاستحالة موضوعية ترجع إلى الالتزام في ذاته، فتقوم بالنسبة إلى الناس جميعا، لا أن تكون شخصية تقوم بالنسبة إلى البعض (المدين مثلا) دون البعض الآخر[2]، وهذه الاستحالة المطلقة تمنع قيام الالتزام ويترتب عليها بطلان العقد بطلانا مطلقا.

ويشترط أن تكون هذه الاستحالة موجودة وقت العقد، أما الاستحالة، اللاحقة لانعقاد العقد فهي لا تمنع من قيام الالتزام وانعقاد العقد، إلا أنها تؤدى إلى انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه، متى كانت الاستحالة راجعة لسبب أجنبي لايد للمدين فيه، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه بقوة القانون، أما إذا كان للمدين يد في هذه الاستحالة –بأن ثبت تقصيره– فإنه يكون مسئولا ويلتزم بتعويض الدائن عما أصابه من ضرر.

---

(١) انظر نقض مدنى في ١١/١١/ ١٩٧٥ – مجموعة المكتب الفني – السنة ٢٦ عن ١٣٦٤ .

(٢) عبد الودود يحيى – السابق – الموضع السابق ، حسام الدين الأهواني – السابق ص ٢٠٦.

ويستوى في الاستحالة المطلقة أن تكون استحالة طبيعية، وهي الاستحالة التي ترجع إلى طبيعة المحل، كما لو التزم شخص بأن يبعث الروح في ميت، أو التزام شخص بعدم القيام بعمل قد قام به فعلا، أو أن تكون استحالة قانونية، وهى الاستحالة التى ترجع إلى حكم القانون، كما لو تعهد محام بالطعن بالاستئناف في حكم قضائي، ثم اتضح أن ميعاد الاستئناف قد فات[١] .

**أما الاستحالة النسبية:** فهى التى يكون محل الالتزام فيها مستحيلا بالنسبة لبعض الأشخاص دون البعض الآخر، فقد تقوم الاستحالة بالنسبة إلى المدين، ولا تقوم بالنسبة إلى غيره، مثل أن يلتزم شخص بعمل فني (رسم لوحة مثلا) لا يستطيع القيام به، ولكن يستطيع القيام به غيره، وهذه الاستحالة لا تمنع من قيام الالتزام، وبالتالى ينعقد العقد، سواء كانت سابقة أو لاحقة على انعقاد العقد، ولكن نظرا لأن القيام بالعمل مستحيل على المدين فإن الدائن يستطيع التنفيذ العينى على نفقة المدين، أو يطلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان له محل[٢].

وتطبيقا لهذه التفرقة بين نوعى الاستحالة نجد أن بيع ملك الغير: الاستحالة فيه استحالة نسبية، وإذا كان الالتزام بنقل الملكية في هذا البيع مستحيلا على البائع، فليس هو بالأمر المستحيل فى ذاته، ويستطيع المالك الحقيقى – أو البائع نفسه إذا أصبح مالكا – أن يقوم بتنفيذ هذا الالتزام، ولولا ورود نص المادة ٤٤٦ من التقنين المدنى الذي يجعل بيع ملك الغير قابلا للإبطال، لكان هذا البيع صحيحا قابلا للفسخ[٣] .

---

(١) عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٥٣ .

(٢) د. عبد الودود يحيى – السابق ص ١١٦ .

(٣) السنهورى – السابق – هامش ص ٥١٥ ، وانظر حشمت أبو ستيت – السابق ص ١٩٢ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٥٤ ، أنور سلطان – السابق ص ٢١٦ .

## المطلب الثاني
## شرط التعيين (المحل معين أو قابل للتعيين)

**كيفية تعيين المحل:**

تنص المادة ١٣٣ من التقنين المدنى المصرى على أنه: "١- إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا. ٢- ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى طرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط".

وتنص المادة ١٣٤ على أنه: "إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر".

ويستبين من هذه النصوص أنه يجب الانعقاد العقد أن يتفق على تعيين محل الالتزام، أو على الأقل أن يتم الاتفاق على الأسس التي تمكن من تعيينه:

**أ- فإنا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل:** وجب أن يكون العمل الواجب القيام به أو الامتناع عنه معينا أو قابلا للتعيين، فإذا تعهد مقاول ببناء منزل، وجب أن يتحدد هذا المنزل بتحديد طوابقه وعدد حجراته وغير ذلك من البيانات التى تعينه تعيينا كافيا، ومع ذلك قد لا يعين هذا المنزل تعيينا كافيا على النحو السابق، ولكنه يكون قابلا للتعيين، وقابليته للتعيين ترجع إلى الظروف التى تستخلص منها نية طرفي الالتزام[1]، فإذا التزم المقاول ببناء مستشفى أو مدرسة، أو

(١) السنهورى – السابق ص ٥١٩ ، وانظر: عبد الودود يحيى – السابق ص ١١٧ ) جميل الشرقاوى – السابق ص ١١٩ ، لبيب شنب – السابق ص ١٩٦.

منزلا سكنيا، أو منزلا للاستغلال التجاري أو الصناعي، فإن ظروف التعاقد هى التى يستخلص منها العناصر اللازمة لتعيين البناء المطلوب. [١]

أما إذا التزام مقاول بإقامة بناء دون أن يعين أي نوع من البناء هو، فإن المحل يكون غير معين ولا قابل للتعيين، ويكون في حكم المعدوم، ولا ينشأ التزام

**ب- وإذا كان محل الالتزام إعطاء شيء:** كما لو كان الالتزام محله نقل حق عينى على شيء، فإن الشيء الذى يرد عليه يجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيين:

**فإذا ورد الالتزام على شيء معين بالذات:**[٢] وجب بيان ذاتية الشيء؛ إذ يجب أن يعين الشيء تعيينا يميزه عن غيره بأن يوصف وصفا نافيا للجهالة، وتختلف طريقة التعيين باختلاف الشيء، فالمنزل يعين بموقعه ومساحته وعدد طوابقه، وأوصافه الأساسية التى تميزه عن غيره، والأرض تعين بذكر مساحتها وموقعها وحدودها، والسيارة تعين بذكر ماركتها وسنة صنعها والأرقام المميزة لها.[٣]

**أما إذا كان الشيء غير معين بالذات، بأن كان من المثليات**[٤]: وجب أن يعين بذكر جنسه ونوعه ومقداره، كأن يذكر مثلا أن المبيع مائة أردب من القمح الهندى، أو عشرين قنطارا من القطن الأشموني[٥] .

---

(١) نقض مدنى فى ٨/ ١١ / ١٩٥١ – مجموعة أحكام النقط من ؟ رقم ٥ ص ٤٦ .

(٢) الأشياء المعينة بالذات هى الأشياء القيمية الذى يغلب أن تتفاوت أحادها تفاوتا يعتد به ، ولا يقوم بعضها مقام بعض فى الوفاء ( كالمنازل والسيارات ، والأراضي ... الخ ).

(٣) نقض مدنى في ٩/٢ / ١٩٤٨ – مجموعة أحكام النقض في ٢٥ عاما ص٣٤٦.

(٤) الأشياء المثلية هي التي يغلب ألا تتفاوت أحادها تفاوتا يعتد به معنوية ، فيقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ( م ٨٥ مدنى ) .

(٥) انظر: السنهوري – السابق ص ٥٢٠ . د . عبد الحي حجازي – السابق ف عبد الفتاح عبد الباقى – السابق ص ٢٢٥ ، أنور سلطان ١٢٢ – ١٢٥ السابق ص ٢١٩.

وقد يكتفى المتعاقدان بذكر الجنس والنوع دون ذكر المقدار، وهنا يجب أن يتضمن العقد ما يستطاع به تحديد مقدار محل الالتزام، كمن يتعهد بتوريد القمح اللازم لمطحن لمدة شهر، أو الأغذية اللازمة لمستشفى أو مدرسة لمدة عام .

وفي كثير من الأحيان يترك المتعاقدان تعيين المحل للعرف، كما إذا قام تاجر بتوريد سلعة لعميل دون أن يبين الثمن.

ويلاحظ أنه إذا كان الشيء من الأشياء المثلية التي تتفاوت درجة جودتها، فلا يشترط – لتحقق شرط التعيين – أن تعين في العقد درجة الجودة أو حتى أن يتضمن العقد أسس تعيينها، إذ يتولى القانون تحديدها بإلزام المدين أن يسلم شيئا من صنف متوسط[١]، فلا يكون ممتازا حتى لا يغين المدين ولا يكون رديئا حتى لا يغبن الدائن.

**ج- وإذا كان محل الالتزام نقودا:** فإنها تعين بذكر نوعها ومقدارها كألف جنيه مثلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدين بالوفاء بالقدر المتفق عليه وقت الوفاء، ولا يتأثر هذا القدر بارتفاع أو انخفاض قيمة النقود[٢] .

وهذه القاعدة وإن كانت تقتضى التعرض للسعر الإلزامي للعملة الورقية وسعرها القانوني، وشرط الدفع بالذهب إلا أننا نميل إلى القول بأن دراسة هذه الأمور تكون عند دراسة "الوفاء" كسبب لانقضاء الالتزام[٣] .

---

(١) د . عبد الودود يحيى – السابق ص ١١٨

(٢) المادة: ١٣٤ مدنى مصرى – السابق ذكرها .

(٣) وهذا هو ما يميل إليه: د/ عبد المنعم الصدة – المصدر السابق ص ٢٦٢ . وقارن في هذا المعنى (عكس ذلك): د . السنهوري – السابق ص ٥٢٢ ، ٥٣٠.

## المطلب الثالث

## المحل قابل للتعامل فيه Dan le commerce

## (شرط المشروعية)

**يجب أن يكون محل الالتزام مشروعا (قابل للتعامل فيه):**

هذا هو الشرط الثالث من شروط المحل، وهى يعنى أن الالتزام لا ينشأ إلا إذا كان محله مشروعا، أى غير مخالف للنظام العام والآداب، وفي هذا تنص المادة ١٣٥ مدنى مصرى على أنه: "إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا".

فالمحل إذا كان غير مشروع بأن كان مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، وليس هنا موضع دراسة فكرة النظام العام أو الآداب، فنحيل فيها إلى مكانها الأصلى وهو الكتب المخصصة لدراسة مدخل العلوم القانونية[١].

ولكن الذي يعنينا هنا هو أن نبين أن شرط المشروعية هو شرط عام أيا كان محل الالتزام، أى سواء كان التزاماً بعمل، أو امتناع عن عمل، أو التزاما بإعطاء شيء.

**ففى الالتزام بعمل أو امتناع:** إذا كان العمل الذي التزم به المدين غير مشروع، كإرتكاب جريمة فى حق آخر، أو إتلاف أموال شخص آخر مقابل مبلغ من المال، أو عمل مخل بالآدا، أو كان الامتناع الذي تعهد به يتضمن فرض قيد غير مشروع على الحرية الشخصية، كالامتناع عن مزاولة مهنة معينة امتناعا مطلقا وهو يجيدها، فلا ينشأ الالتزام ويكون العقد باطلا .

---

(١) انظر في فكرة النظام العام والآداب ، وأساسها والتطور التاريخي لها ، وأمثلة عديدة لما هو مخالف للنظام العام أو الآداب: مؤلفنا – المدخل لدراسة العلوم القانونية – القسم الأول – نظرية القانون ط ٢٠٠٣ ص ١٣١ وما بعدها ، وانظر المراجع والأحكام القضائية المشار إليها فيه

**أما في الالتزام بإعطاء شيء:** فيقال عادة أنه يشترط في الشيء أن يكون "داخلا في دائرة التعامل" وهذا – في رأي البعض[١]، ليس شرطا مستقلا، بل هو إما تطبيق لشرط "الإمكان" وإما تطبيق الشرط "المشروعية"، إلا أن جمهور الفقه[٢] والقضاء المصرى[٣] والأجنبي يرى – بحق – أن محل الالتزام يجب أن يكون "داخلا في دائرة التعامل" كشرط أساسي لقيامه؛ لأن المحل قد يكون مشروعا ولا يدخل في دائرة التعامل كالأموال العامة، والأموال الموقوفة... الخ، فعدم القابلية للتعامل فكرة نسبية، بمعنى أن من الأشياء ما لا يقبل التعامل فيه بالنسبة لبعض أنواع من التعامل ويصح بالنسبة للبعض الآخر كما في المثال السابق.

وخلاصة هذا الشرط أن الشيء محل الالتزام إذا كان غير قابل للتعامل فيه فلا يصلح أن يكون محلا للالتزام، وعدم قابلية الشيء للتعامل فيه ترجع إما لطبيعته، وإما لأن التعامل فيه يتنافى مع الغرض الذي خصص له، وإما لعدم مشروعية التعامل فيه.[٤]

والأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها هي الأشياء التي لا يمكن أن يستأثر أحد بحيازتها، كالهواء، وأشعة الشمس، وماء البحر، ولكن إذا استأثر أحد بكمية من هذا الأشياء، فإنها تصبح محلا للتعامل، كالهواء المضغوط أو كمية من ماء البحر

---

(١) د . إسماعيل غانم – السابق ص ٢٤٣ ، وقرب من هذا المعنى: د . منصور مصطفى منصور – السابق بند ٢٧

(٢) السنهورى – السابق ص ٣١ ، وما بعدها ، عبد المنعم الصدة ص ٢٦٢ وما بعدها ، د . عبد الناصر العطار – السابق ص ٦٨ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ٢٠٢ – ٢٠٥

(٣) نقض مدنى في ٢٧ / ٤ / ١٩٦٧ – مجموعة أحكام النقض سن ١٨ رقم ١٣٥ ص ٩٧ .

(٤) انظر نقض فرنسي في ٢٤ أكتوبر سنة ١٩١٦ – داللوز ١٩١٦ – ١ – ٢٢–٢٤٧ ، سيريه ١٩٢٠– ١ – ١٧ ، وانظر في الفقه الفرنسي: بلانيول وريبير واسمان – الالتزامات ج١ بند ٢٤٨.

دخلت فى حيازة شخص معين، هنا يصح أن يكون الهواء أو ماء البحر محلا لحق مالي.

وقد لا يكون الشيء قابلا للتعامل فيه، لأن التعامل فيه يخرجه عن العرض الذي خصص له، كما في الأموال العامة، فهذه لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم(١)، لأنها مخصصة للنفع العام، وهذا لا يمنع من أن ترخص الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للأفراد باستعمال هذه الأموال بمقتضى ترخيص إدارى مادام ذلك لا يتعارض مع الغرض الذي خصص له المال العام كشغل جزء من الطريق، أو إقامة حمامات على الشواطئ، أو إقامة مقاصف (كافتيريات) في محطات السكك الحديدية وغيرها، وكذلك الشأن في أموال الأوقاف الخيرية، فهذه لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم(٢)، ولكن يجوز إيجارها لعدم مخالفة ذلك للغرض المقصود من الوقف(٣).

وقد يخرج الشيء عن التعامل لعدم المشروعية نتيجة نص في القانون يحرم هذا التعامل، أو لأن التعامل فيه يتنافى مع النظام العام أو الآداب، كالمخدرات، فهذه لا يجوز التعامل فيها إلا في حالات معينة كاستعمالها لأغراض طبية، وتحريم المشرع الوضعى التعامل في التركة المستقبلة(٤)، وشراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين

---

(١) مادة: ٨٧ / ٢ مدنى مصرى .

(٢) المادة: ٩٧٠ / ٢ مدنى مصرى المعدلة بالقانون الصادر سنة ١٩٥٧م .

(٣) انظر فيما سبق: عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٦٣ ، عبد الودود يحيى ص ١١٩، عبد الفتاح عبد الباقي السابق ص ٢٢٧، عبد المنعم البدراوى – السابق – ص ٣٠٠ ، لبيب شنب – السابق ص ١٩٦ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ٢٠٤ ، حسام الدين الأهوانى – السابق ص ٢٠٧ وما بعدها ، سمير تناغو –السابق ص ٧٥ .

(٤) المادة ١٣١ / ٢ مدنى مصرى .

وكتبة المحاكم والمحضرين الحق المتنازع فيه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها[١]، وبيع الوفاء[٢]،

والاتفاق على سعر للفائدة يزيد على٧%[٣] وهكذا.

وخلاصة هذا الشرط أن الفكرة الأساسية في عدم مشروعية المحل ترجع لمخالفته للنظام العام أو الآداب في ضوء مضمونهما المبين في " موضعه

## المبحث الثالث

## السبب - La cause

### التعريف بالسبب:

السبب هو الركن الثالث اللازم توافره لانعقاد العقد بجانب الرضا والمحل، ويمكن تعريف السبب مبدئيا بأنه: الغرض المباشر الذي يقصد إليه الملتزم من وراء التزامه، وإذا كان محل العقد هو جواب من يسأ: بماذا التزم المدين، فإن سبب العقد هو جواب من يسأل: لماذا التزم المدين [٤] .

---

(١)المادة ( ٤٧١ )

(٢)مادة ٤٦٥ مدنى مصرى

(٣) انظر فيما سبق: السنهوري – السابق ص ٤٣١ – ٥٣٥ ، إسماعيل غانم –السابق ص ٢٤٤ ، جميل الشرقاوى – السابق ص ٢٠٤ – ٢٠٥

(٤) انظر في ذلك: السنهورى – السابق ص ٥٥٥ ، إسماعيل غانم – السابق ص ٢٥٢ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٧١ ، لبيب شنب – السابق ص ٢٠٢ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ١٢٣ ، عبد الناصر العطار – السابق ص ٧٥ . جميل الشرقاوى – السابق ص ٢٠٦ ، سمير تناغو – السابق ص ٧٨ ، وانظر في فقه القانون الفرنسي: أوبرى ورو جـ ٤ ص ٥٤٦ هامش ٢ ، بلانيول وريبير وبولابجيه – السابق جـ ٢ فقرة ٢٧٩ ، ومازو – السابق بند ٢٥٥ ، وكابيتان: السبب فى الالتزامات – الطبعة الثالثة ١٩٢٧ ، جوسران في البواعث في الأعمال القانونية ط ١٩٢٨ ص ١٤٠ – ٢١٤ ، ورسالة الأستاذ بوابية في الصلح –دراسة في فكرتي السبب والعمل الكاشف – تولوز ١٩٤٧ ، ريج: دور الإرادة في العمل القانوني في القانون المدنى الفرنسي الألمانى ط ١٩٦١ ص ٢٥٠ –٣٥٢

والسبب بهذا المعنى لا يكون ركنا فى كل التزام، وإنما يقتصر على الالتزام العقدي، أما الالتزام غير العقدى وهو الالتزام الذي ينشأ عن العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب ونص القانون، فلا محل للبحث فيه عن السبب لأن القانون هو مصدر هذه الالتزامات والسبب في العقد هو الباعث الدافع إلى التعاقد، وهذا الباعث يختلف من شخص إلى آخر، فيتغير حتى فى النوع الواحد من العقود، فهناك شخص يبيع ماله بقصد الحصول على ثمن المبيع ليسافر به إلى الخارج أو ليتعيش منه، وذلك يبيع لأنه يريد أن يشتري بالثمن منزلا أو أرضاً زراعية، وفى هذا يختلف سبب العقد عن سبب الالتزام فالسبب فى الالتزام لا يتغير فى النوع الواحد من العقود، ومن ثم لا يختلف من شخص إلى آخر، عكس سبب العقد الذي يتغير من شخص إلى آخر ومن عقد إلى عقد.

**نظرية السبب في القانون المصري** :

تنص المادة ١٣٦ من التقنين المدنى المصرى على أنه: "إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا".

ويستبين من هذا النص أنه يشترط أن يكون للالتزام سبب، ومن ثم يبطل العقد إذا لم يوجد له سبب.

ويرى جانب كبير من الفقه المصرى أن المراد بالسبب هنا هو سبب العقد لا سبب الالتزام، وأنه يراد بسبب العقد الباعث الدافع إلى التعاقد.[١]

بيد أننا نرى أن الرأى الأولى بالقبول هو ما ذهب إليه غالب الفقه المصرى بأن المقصود بالسبب فى القانون المصرى هو: السبب القصدي الذي تأخذ به النظرية

(١) السنهوري – السابق ص ٦٢٥ فقرة ٢٩٠ د . سمير تناغو – السابق ص ٦٥ – ٨٦ د . عبد الفتاح عبد الباقي – السابق ص ٢٤٧ ونفس هذا الاتجاه جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – مجموعة الأعمال التحضيرية جـ ٢ ص ٢٢٧ .

التقليدية (سبب الالتزام) والسبب الباعث الدافع إلى التعاقد، فلكل من السببين وظيفته، ومن ثم يجب الاعتداد بهما معا، ويعمل بأيهما بحسب ظروف كل حالة، وإذا كان القانون المدنى المصرى يعتد بالباعث الدافع إلى التعاقد فإنه لا يستغنى عن السبب بمعناه التقليد، ولا يقدح في صحة هذا القول أن تكون المذكرة الإيضاحية قد ذهبت إلى خلاف ذلك، مادام النص لا يحتمل ما جاء في هذه المذكرة[١] .

**ويتضح من نص المادة ١٣٦ مدنى مصرى أن السبب في القانون المصرى يشترط فيه شرطان:**

**أولهما: أن يكون موجودا، والثاني: أن يكون مشروعا.**

**أ- فيجب أولا أن يكون السبب موجودا:** وهذه الشرط يتعلق بسبب الالتزام وهو الغرض المباشر الذى يرمى إليه الملتزم من وراء التزامه[٢]. والذي يعتبر عنصراً موضوعيا، يدخل في العقد، ولا يتغير في النوع الواحد من العقود، وهذا هو السبب (السبب القصدى) الذي تأخذ به النظرية التقليدية، ومن ثم يكون هذا الشرط غير متعلق بسبب العقد، بمعناه السابق الذي يعنى أن السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد، والذي يعتبر أمرا شخصيا يتعلق بنوايا الملتزم، فيكون خارجا عن العقد، ويتغير من شخص إلى آخر فى النوع الواحد من العقود.

وجدير بالذكر أن سبب الالتزام يكون غير موجود إذا تم التعاقد، وكان المتعاقدان يعلمان – بعدم وجود سبب الالتزام، أو كان السبب صوريا صورية مطلقة[٣].

---

(١) د . عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٨٩ ، إسماعيل غانم – السابق ص ٢٦٨ – ١٢٦٩.

(٢) د . عبد الودود يحيي – السابق ص ١٣١ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٩ عبد الرازق فرج – السابق ص ٢٣٠ ، عبد الناصر العطار – السابق ص ٨٠ .

(٣) راجع في ذلك السنهوري – السابق ص ١٣٥ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٩٠ ، لبيب شنب – السابق ص ٢٠٣ ، سليمان مرقس – السابق ص ١٥٤ ، عبد الفتاح عبد الباقي – السابق ص ٢٥٠ ، ٢٥١

**ب- ويجب ثانيا أن يكون السبب مشروعا:** ويتعلق هذا الشرط بسبب الالتزام وسبب العقد، والباعث غير المشروع الذي يخالف النظام العام أو الآداب لا يؤدى إلى بطلان العقد إلا إذا كان الطرف الآخر – الذي لم يقم لديه هذا الباعث غير المشروع – على علم به حتى لا يفاجأ ببطلان العقد بسبب لم يكن يعلمه وقت إبرام العقد.(١)

وينظر في توافر السبب ومشروعيته إلى وقت العقد، والسبب الذي تتطلب النظرية الحديثة مشروعيته، ليس هو الغرض القريب المباشر الذي تعتد به النظرية التقليدية، بل هو الباعث الدافع إلى التعاقد، وهذا ما يفسر القول ببطلان العقد لعدم مشروعية السبب في حالة ما إذا استأجر شخص منزلا وكان المستأجر يرمى إلى إعداده للدعارة أو مقرا للتأمر على نظام الحكم، فإن هذا الانفاق يعتبر صحيحا إذا وقفنا عند السبب القصدى الذى تأخذ به النظرية التقليدية؛ لأن المؤجر التزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، والتزم المستأجر بدفع الأجرة، فمحل وسبب التزام كل منهما مشروع في ذاته، وبذلك يكون العقد صحيحا، لذلك كان لابد من الاعتداد بالباعث الدافع إلى التعاقد، بمعناه في النظرية الحديثة – ويكون العقد باطلا في مثل هذه الحالات لعدم مشروعية السبب.(٢)

ولما كانت بواعث الإرادة التعاقدية كثيرة ومتنوعة، فلا يكفى أن يكون أحدها غير مشروع للقول ببطلان العقد، بل الذى يعتد به هو الباعث الرئيسي على التعاقد الذي لولاه لما أقدم العاقد على إبرام العقد، ولا يعتد بما قد يوجد بجانبه من بواعث ثانوية، ولو كان منها ما هو غير مشروع، فالعبرة إذن بالباعث الدافع الرئيسي إلى التعاقد،

(١)انظر نقض مدنى في ٢٦/٥/ ١٩٧٤ – مجموعة أحكام النقض – س ٢٥ ص ٩٤٨

(٢)د . إسماعيل غانم – السابق ص ٢٦٩ . د . عبد الودود يحيى – السابق ص ١٣٢

ويشترط فيه أن يكون مشروعا، أي غير مخالف للنظام العام والآداب وإلا كان العقد باطلا [١] .

**إثبات السبب**:

تنص المادة ١٣٧ من التقنين المدنى المصرى على أن: "١- كل التزام لم يذكر له سبب في العقد، يفترض أنه له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك. ٢- ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه".

ويتضح من هذا النص أنه يفرق بين حالتين، حالة عدم ذكر السبب في العقد – أو في السند المثبت للتصرف – وحالة ذكر السبب:

**أ- ففى حالة ما إذا لم يتضمن العقد ذكر السبب:** وهي الحالة التي تناولتها المادة ١/١٣٧، كما لو تضمن السند أن المدين يتعهد بدفع مبلغ معين للدائن دون أن يرد فيه ذكر سبب هذا الالتزام، فلا يقال مثلا أنه قرض، أو ثمن المبيع أو غير ذلك، وفى هذه الحالة يقيم النص قرينة لصالح الدائن مقتضاها: أنه يفترض أن لهذا الالتزام سببا مشروعا [٢]، فلا يكلف الدائن بإثبات هذا السبب، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس؛ حيث يستطيع المدين أن يثبت عدم وجود السبب، أو عدم مشروعيته، وهو يستطيع إثبات ذلك بكل طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن، لأن الإثبات هنا ينصب على واقعة مادية، ولا ينطوى على ما يخالف الكتابة.[٣]

---

(١) انظر: د . إسماعيل غانم ص ٢٧٠ ، وهامش ١ ، ٢ من ذات الصحيفة ، سليمان مرقس – السابق ص ١٥٤ ، جمال الدين زكى – السابق ص ٢١٤.

(٢) انظر نقض مدنى في ١٧/٤ / ١٩٦٩ – مجموعة أحكام النقض س ٢٠ ص ٦٢٧ .

(٣) د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٩٥ ، د/ إسماعيل غانم – السابق ص٢٧٣.

**ب- وفي حالة ذكر السبب في العقد:** وهذا هو الفرض في المادة ٢/١٣٧ وهو الغالب في الحياة العملية، وفى هذا الفرض يقيم النص قرينة لصالح الدائن مقتضاها، أن السبب المذكور في العقد (السند) هو السبب الحقيقي، والقرينة هنا قابلة لإثبات العكس، فإذا كنا بصدد عقد ملزم للجانبين كان سبب التزام كل منهما هو التزام المتعاقد الآخر، ولا يمكن أن يكون المقصود هنا هو الباعث الدافع إلى التعاقد، وإنما هو السبب القصدي وهو الغرض المباشر الذى يقصد المتعاقد تحقيقه من وراء التزامه، ويستطيع المدين أن ينقض دلالة هذه القرينة، ويثبت أن الالتزام ليس له سبب، أي هناك صورية مطلقة، كما يستطيع أن يثبت أن السبب الموجود في العقد ليس هو السبب الحقيقى للالتزام صورية نسبية[١]، ولكنه لا يستطيع إثبات ذلك إلا بالكتابة، حيث لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة [٢].

**التصرف المسبب والتصرف المجرد:**

الأصل في أي تصرف أن يكون له سبب وإلا كان باطلا فلا يكون التصرف مجردا من السبب إلا على سبيل الاستثناء.

**والتصرف المسبب:** هو التصرف الذى لابد من توافر السبب فيه، فإذا لم يكن للالتزام – أو للعقد – سبب مشروع، فإن الالتزام – أو العقد – لا يقوم ويقع التصرف باطلا .

**أما التصرف المجرد:** L'acte abstrait فهو التصرف الذي يتجرد عن سببه ويكون صحيحا وينتج أثره رغم عدم وجود السبب، والقانون المصرى وكل القوانين

---

(١)انظر في ذلك: السنهورى – السابق ص ٦٤٠ ف ٢٩٧ ، عبد المنعم الصدة –السابق ص ٢٩٥ ، عبد الودود يحيى – السابق ص ١٣٤

(٢)انظر: المادة ٢٦١ / ١ من قانون الإثبات ، وانظر نقض مدني في ص ٥٩٢ ٢١/١٢/١٩٧٦ – المجموعة السابقة س ٢٧ ص ١٨٠١ .

اللاتينية توجب في التصرف أن يكون مسببا، لأنها تأخذ بالإرادة الباطنة التي تستوجب وجود سبب للالتزام، بينما القوانين الجرمانية أفسحت مجالاً واسعا للتصرف المجرد إلى جانب التصرف المسبب، لأن هذه القوانين تأخذ بالإرادة الظاهرة تحقيقا لاستقرار التعامل، ومن ثم لا يلزم وجود سبب للالتزام في كل الحالات، والقانون المدنى المصرى لم يأخذ بالتصرف المجرد إلا في حالتين:

**الأولى: التزام المناب قبل المناب لديه:** حيث تقضى المادة ٣٦١ مدنى بأن يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا، أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

**الثانية: التزام الكفيل نحو الدائن:** فهذا التزام مجرد، فلا يجوز للكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة المدين[1]، ويأتى القانون التجارى – لماله من طبيعة خاصة – في مقدمة القوانين المصرية التى تأخذ بقواعد التصرف المجرد، نلمس ذلك في الكمبيالات، والسندات الأذنية، والسندات لحاملها ... الخ .

(١) انظر في ذلك: السنهورى – السابق ص ١٠٨ – ١٢٠ ، د . عبد الودود يحيى – السابق ص ١٣٦ ، جميل الشرقاوى السابق ص ٢٠٤ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٢٩٨ ، لبيب شنب – السابق ص ٢٢٠ ، سليمان مرقس – السابق ص ١٥٧ ، عبد الرازق حسن فرج – السابق ص ٢٣٢ ، سمير تناغو – السابق ص ٨٧

# الفصل الثاني
# جزاء الإخلال بقواعد تكون العقد
# (نظرية البطلان)[1]

## التعريف بالبطلان والتفرقة بينه وبين ما يقاربه من نظم:

بطلان العقد: هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها[2]. فإذا تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من الشرائط الواجب توافرها فى كل ركن، فإن الجزاء الذي يترتب على ذلك هو البطلان.

والبطلان بهذا المعنى يتميز عن:

**أ- عدم النفاذ أو عدم السريان:** الذي يكون العقد فيه منتجا لآثاره فيما بين المتعاقدين، ولكنه لا يسري فى حق الغير، ومثاله العقد الذي يبرمه المريض مرض الموت، فهو عقد صحيح فيما بين المتعاقدين، ولكنه لا يسري فى حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة، وكذلك العقد الذي يبرمه المدين، فهو عقد صحيح ومنتج لآثاره فيما بين المدين ومن تعاقد معه، ولكنه لا يسري فى حق الدائن إذا طعن فيه بالدعوى البوليصية، وكذلك العقد الذي يبرمه النائب خارج حدود نيابته فهو عقد صحيح فيما بين النائب ومن تعقد معه، ولكنه غير نافذ فى مواجهة الأصيل[3].

**ب- كذلك يتميز البطلان عن الفسخ:** فى أن البطلان يرجع إلى خلل فى أركان العقد، أي عيب نشؤ العقد، أما الفسخ فيفترض فيه نشؤ العقد صحيحا مستوفا

---

(1) انظر فى هذا الموضوع بصفة خاصة فى الفقه المصري: رسالة الدكتور / جميل الشرقاوي ، نظرية بطلان التصرف القانوني – رسالة من جامعة القاهرة عام ١٩٥٣ ط ١٩٥٦م .

(2) د. عبد الرزاق السنهوري – الوسيط ج١ ط ١٩٨١ ص ٦٤٣ .

(3) انظر: د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٢٣ ، د/ جميل الشرقاوي – مصادر الالتزام – ط ١٩٧٤ ص ٢١٥.

لكل أركانه وشروط صحته، ثم لا ينفذ أحد المتعاقدين التزامه، فيكون للمتعاقد الآخر أن يتحلل من التزامه بطلب الفسخ، ومن ثم فالفسخ لا يكون إلا فى العقود الملزمة للجانبين[1].

**أنواع البطلان:**

تقوم نظرية البطلان فى القانون المصري والقانون الفرنسي القديم ومن قبله القانون الروماني على اساس تقسيم شروط تكوين العقد إلى شروط انعقاد، وشروط صحة، فإذا تخلف شرط من شروط الانعقاد كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، فلا ينتج أي أثر، لأنه لا وجود له فى نظر القانون، أما إذا وجدت شروط انعقاد العقد وتخلف شرط من شروط الصحة، كان العقد باطلا بطلانا نسبيا أو قابلا للإبطال (فالتعبيران مترادفان قانونا) أي أن العقد ينعقد ويرتب آثاره، إلا أن يكون مهددا بالزوال نظرا لما شابه من عيب، فهو عقد منعقد قابل للإبطال، أي يكون لأحد طرفيه الحق فى طلب إبطاله، على أنه إذا حكم بإبطاله زال بأثر رجعي وكأنه لم يكن، وعلى هذا الاساس يكون العقد باطلا نسبيا كالعقد الصحيح تماما ما دام لم يحكم بإبطاله، ويكون كالعقد الباطل بطلانا مطلقا فلا ينتج أي أثر إذا حكم بإبطاله[2] .

وقد حرص المشرع المصري على إبراز هذه التفرقة بين نوعي البطلان فلم يستخدم لفظ العقد "الباطل" إلا للتعبير عن البطلان المطلق، واستخدام عبارة العقد القابل للإبطال "للتعبير عن البطلان النسبي".

وعليه، سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، وذلك على النحو التالي:

---

(١) د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٢٧٨ ، حسام الدين الأهواني – المرجع السابق ص ٥٢٨ ، د/ جميل الشرقاوي – السابق – الموضع السابق .

(٢) راجع في ذلك : د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٢٩٩ ، د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٢٧٥.

# المبحث الأول
# أحكام العقد الباطل وآثاره
## المطلب الأول
## أحكام البطلان المطلق

### حالات البطلان المطلق: (أسبابه):

يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا فى الحالات الآتية:

أ- إذا أبرمه شخص فاقد الأهلية كالصبي غير المميز، أو إذا أبرم العقد ناقص الأهلية، ولكنه كان عديم الأهلية بالنسبة إلى التصرف الصادر منه كالصبي الميز إذا صدر منه التبرع[1].

ب- إذا انعدمت الإرادة كما فى حالة المجنون والمكره الذي انعدمت إرادته ولم يكن له خيار بين القبول وعدمه.

ج- إذا كان المحل معدوما أو مستحيلا أو كان غير معين أو غير مشروع.

د- إذا كان سبب العقد غير مشروع أو لم تتحقق شروطه الجوهرية كما لو انتفى سبب الالتزام مثلا

هـ- إذا اشترط القانون شكلا معينا لانعقاد التصرف ولم يتوافر هذا الشكل.

و- إذا ورد فى القانون نص خاص على البطلان[٢] كما فى حالة اشتراط المدة لانعقاد الوعد بالتعاقد[٣] .

---

(١) د/ عبد الرازق حسن فرج – السابق ص ٢٤١.

(٢) انظر فيما سبق د. عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٣٠٤ ،د/ لبيب شنب المرجع السابق ص ٢٢٤ ، د/ عبد الرازق فرج – السابق – الموضع السابق .

(٣) المادة ١٠١ /١ من التقنين المدني .

## خصائص البطلان المطلق ( تقرير البطلان):

تخلص خصائص البطلان المطلق فيما يلي:

١- يقع البطلان المطلق من تلقاء نفسه دون حاجة إلى صدور حكم به، فمن له مصلحة فى التمسك بالبطلان ليس بحاجة لا يصدر حكم من القضاء بالبطلان، بل له أن يتصرف باعتبار العقد غير موجود، إلا أن صاحب المصلحة فى البطلان قد يضطر إلى رفع دعوى لتقرير البطلان كما لو كان البائع قد سلم المبيع وأراد أن يسترده لبطلان البيع فرفض المشتري، كذلك قد يضطر المتعاقد لرفع دعوى البطلان إذا كان سبب البطلان غير واضح، كما لو كان مخالفا للنظام العام أو الآداب، حيث يرجع الأمر هنا إلى السلطة التقديرية للقاضي ليتحقق من صحة سبب البطلان، ويلاحظ أن الحكم بالبطلان هنا هو حكم كاشف فقط عن البطلان لا منشئ له.

٢- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، كما أن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وعلى هذا تنص المادة ١/١٤١ مدني بقولها: "إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". ويقصد بالمصلحة فى هذه الصدد: كل حق تؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه وعلى ذلك يعتبر صاحب مصلحة فى البطلان كل من المتعاقدين والخلف العام لهما أو وريثهما، والموصي لهم بحصة شائعة فى التركة الخلف الخاص والدائنون لكل منهما، فورثة كل من المتعاقدين ( الخلف العام) لهم الحق فى التمسك بالبطلان، وذلك لكي يرد المبيع أو الثمن إلى التركة، والمشتري الثاني من البائع ( وهو خلف خاص له) يستطيع أن يطلب بطلان البيع السابق الذي تصرف به البائع فى العين.

٣- يجوز لكل من المتعاقدين، والخلف العام أو الخلف الخاص، التمسك بالبطلان فى أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو كان ذلك لأول مرة أما محكمة

الاستئناف أو محكمة النقض، كما أن للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها، ودون طلب من الخصوم فى أي حالة تكون عليها الدعوى.

٤- العقد الباطل لا تلحقه الإجازة، أي لا يعتبر العقد الباطل صحيحا ولو رضي به كل من المتعاقدين، أو أسقط كل منهما حقه فى طلب بطلانه، ولكن يجوز للمتعاقدين أن يتراضيا على عقد صحيح جديد، فينعقد هذا العقد الجيد منذ إبرامه لا منذ إبرام العقد الباطل،[1] ويترتب على ذلك أن الدفع بالبطلان لا يسقط ولا يزول بالتقادم[2].

٥- تسقط دعوى الإبطال بمضي خمس عشر سنه من وقت إبرام العقد[٣] وفى هذا تنص المادة ٢/١٤١ مدني بقولها: "وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد".

## المطلب الثاني

## آثار العقد الباطل بطلانا مطلقا

**تمهيد:**

العقد الباطل عقد منعدم لا وجود له ولكنه عمل مادي أو واقعة مادية وهو بهذا الوصف قد ينتج أثرا قانونيا، ليس هو الأثر الاصلي الذي يترتب على العمل القانوني باعتباره عقدا، بل هو أثر عرضي يترتب على العمل المادي باعتباره واقعة قانونية، كما أن العقد الباطل قد ينتج عنه آثار أصلية باعتباره عقدا – بصفة

---

(١) د/ عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ١٦٨ –١٦٩ ، د/ عبد الرازق حسن فرج – المرجع السابق ص ٢٤٢ ، البدراوي – السابق ص ٣٤٤.

(٢) نقض مدني في ١١/ ٤/ ١٩٥٧ – مجموعة أحكام النقض المدني س ٨ ص ٢٠٤ .

(٣) نقض مدني في ٢٥ /١٩٧٥/١١ –مجموعة أحكام النقض المدني س ٢٦ ص ١٤٧٧.

استثنائية –لاعتبارات معينة[1] أهمها حماية الوضع الظاهر المقترن بحسن النية حتى تستقر المعاملات بين أفراد ومؤسسات المجتمع.

ونعالج فى هذا المطلب الآثار الأصلية العرضية للعقد الباطل كل فر فرع مستقل.

## الفرع الأول
## الآثار الأصلية للقد الباطل

- **كيف يرتب العقد الباطل آثاره الأصلية:**

يرتب القانون فى بعض الحالات على العقد الباطل آثاره الأصلية، كلها أو بعضها – وهي الآثار التي يولدها العقد لو كان صحيحا، وهو يولدها لا باعتباره عقدًا، ولكن باعتباره واقعة مادية، وفى هذا خروج صريح على القواعد العامة يبرزه حماية القانون للوضع الظاهر الذي يطمئن إليه الغير ويتعامل على أساسه بحسن نية لكي يكفل ما ينبغي للتعامل من أسباب الاستقرار[2].

**أمثلة من عقود باطلة ترتب آثارها الأصلية (الجوهرية):**

من هذه الأمثلة: الشركة الواقعية: وهي الشركة التجارية التي لم تستوف الاجراءات القانونية، فهذه الشركة وبالتطبيق لنص المادة ٥٤ من التقنين التجاري تنتج آثارها فى المدة السابقة على طلب البطلان، كما لو كانت شركة صحيحة، ويصح تبعا – لذلك – كل ما عقدت من تصرفات مع الغير.

---

(١) السنهوري – السابق ص ٦٥٧ ، د/ جميل الشرقاوي – رسالته السابقص ٣٧٢ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٣٢٦ ، د/ سمير تناغو – السابق ص ٩٢.

(٢) د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٣٢٦ ، د/ حشمت أبو ستيت – نظرية الألتزام في القانون المدني الجديد – مصادر الالتزام ط ١٩٥٤ ص ٢٦٩ ، انظر في هذا الشأن ،د، عبد الباسط جميعي – نظرية الأوضاع الظاهرة – رسالة من جامعة القاهرة سنة ١٩٥٦.

ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة ١٠٣٤ مدني من بقاء حق الدائن المرتهن رغم زوال حق الراهن لإبطال سند ملكيته.

ومنها بقاء أعمال الإدارة التي صدرت قبل إبطال العقد، فإنها تبقى رغم زوال حق المتصرف، مثل عقد الإيجار الصادر من مالك زالت ملكيته بعد ذلك بأثر رجعي.

ومنها العقد الصوري الذي هو عقد لا وجود له فيما بين المتعاقدين، ومع ذلك فهو يعتبر عقدا قائما بالنسبة للغير حسن النية، وكالعقد الصوري تصرفات الوارث الظاهر، فإنها تبقى رعاية لاستقرار التعامل[1].

## الفرع الثاني
## الآثار العرضية للعقد الباطل

**- العقد الباطل ينتج آثارا عرضية باعتباره واقعة مادية (أمثلة):**

قد ينتج العقد الباطل – سواء أكان ذلك من وقت انعقاده أو كان عقدا قابلا للإبطال ثم تقرر إبطاله– آثارا عرضية باعتباره واقعة مادية، لا باعتباره تصرفا قانونيا:

ومن أهم الآثار العرضية للعقد الباطل أثران يستخلصان من نظريتين معروفتين، نعرض لهما بإيجاز، وهما نظرية تحول العقد، ونظرية انتقاص العقد:[٢]

**أولًا: نظرية تحول العقد (مضمون النظرية ):**

تنص المادة ١٤٤ من التقنين المدني على أنه: "إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد".

---

(١) د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٢٧٠ ، السنهوري – السابق ص ٦٨٠ د/ عبد الودود يحي – المرجع السابق ص ١٣٨ .

(٢) انظر: فيما سبق: السنهوري – السابق ص ٦٥٨ ، د/ عبد الودود يحي – السابق ص ١٣٩.

وقبل شرح المادة السابقة نود التنويه إلى أن نظرية "تحول العقد" نظرية ألمانية صاغها فقهاء الألمان فى القرن التاسع عشر، وأخذ بها القانون الألماني كقاعدة عامة فى المادة ١٤٠ منه، ونقلها عنه القانون المدني المصري الحالي.

وتتلخص النظرية: فى أنه إذا اشتمل التصرف الباطل على عناصر تصرف آخر فيتحول التصرف الباطل إلى التصرف الذي توافرت عناصره وهو التصرف الصحيح، وبذلك يكون التصرف الباطل قد أنتج بهذا أثرا قانونيا عرضيا لا أصليا[1]، ومن الأمثلة على ذلك: عقد قسمة نهائية بين شركاء أحدهم قاصر، فيكون العقد قابلا للإبطال، فإذا ما حكم بإبطاله تحول إلى قسمة مهايأة إذا كان الشريك القاصر أهلا للقيام بأعمال الإدارة، وثبت أن لدية النية المحتملة للمتقاسمين كانت تتصرف إلى ذلك، وأيضا الكمبيالة التي لم تستوف البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون التجاري، تتحول من كمبيالة باطلة إلى سند أذني صحيح، وكذلك: وصية لاحقه باطله تتحول إلى عدول صحيح عن وصية سابقة.

- **شروط إعمال نظرية تحول العقد:**

لكي يتم تحول العقد – على النحو السابق – لابد من توافر شروط ثلاثة:

**١- أن يكون العقد الأصلي باطلا، أو قابل للإبطال وقضى ببطلانه:** فإذا كان التصرف ( العقد) صحيحا، فإنه لا يتحول إلى تصرف آخر حتى ولو ثبت ان المتعاقدين كانا يؤثران هذا التصرف الأخير، ويجب أن يكون التصرف أو العقد الأصلي باطلا بأكمله، فلو كان باطلا فى شق منه، وكان العقد يقبل الانقسام، فإنه لا يتحول، وإنما قد ينتقص العقد وفقا لنظرية "انتقاص العقد الذي سنتحدث عنها قريبا".

---

(١) د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٢٩٧ ، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣٥٧ ،د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٢٦٦ ، د/ سمير تناغو– السابق ص ٩٥.

**٢- أن يتضمن التصرف الباطل جميع عناصر التصرف الآخر الذي يتحول إليه دون حاجة إلى إضافة عنصر جديد:** فمثلا إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات كمنزل، ثم تبين أن هذا المنزل كان قد هلك قبل إبراء العقد (المحل غير موجود فيكون العقد باطلا) فلا يجوز أن يتحول هذا البيع إلى بيع آخر يرد على منزل آخر مملوك للبائع حتى لو ثبت أن الطرفين كانا يقبلان إحلاله محله، وذلك لأن العقد الأول لم يتضمن كل عناصر العقد الجديد[1].

**٣- أن تنصرف الإرادة المحتملة للمتعاقدين إلى التصرف الآخر:** وليس معنى هذا أن المتعاقدين أرادا التصرف الآخر إرادة حقيقية، بل معناه أنهما كانا يريدانه لو أنهما علما بأن التصرف الأصلي باطل، فإرادتهما الواقعية انصرفت إلى التصرف الأصلي، وانصرفت إرادتهما المحتملة إلى التصرف الآخر [2]، وبذلك يستطيع القاضي أن يستخلص من التصرف الباطل عناصر تصرف آخر انصرفت إليه الإرادة المحتملة للمتعاقدين ورتب على العقد الباطل – باعتباره واقعة مادية – أثراً عرضياً هو التصرف الآخر والصحيح التي اكتملت عناصره، نزولاً على الغاية الفعلية التي أراد المتعاقدان الوصول إليها، فالعبرة إذن بالغاية العملية لا بالإرادة القانونية.

**ثانياً: نظرية انتقاص العقد[٣] مضمون النظرية:**

تنص المادة ١٤٣ مدني على أنه: "إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير

---

([١]) نقض مدني في ١/٢٩/ ١٩٧٠ ، مجموعة المكتب الفني – س ٢١ ص ٣١٢ ، وانظر نقض مدني في ٦/ ١٩٧٢ ، مجموعة أحكام النقض ص ٢٣ رقم ٢٠٨ ص ١٣٣٠.

([٢]) السنهوري – السابق ص ٦٦٦.

([٣]) انظر: د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٢٦٨ ، السنهوري السابق هامش ١ ص ٦٦٧.

الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله".

فهذا النص خاص بحالات البطلان الجزئي، فيجب لإعمال نظرية "انتقاص العقد" أن يكون العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال في شق منه فقط، والشق الآخر صحيح، فإذا كان العقد كله باطلاً فلا مجال للانتقاص، ولا مجال له أيضاً إذا كان العقد كله صحيحاً، ومثال العقد الباطل في شق منه: اتفاق على البقاء في الشيوع لمدة تزيد على خمس سنوات ( م ٨٤٣ مدني مصري ) أو هبة مقترنة بتكليف غير مشروع على الموهوب له، أو بيع يرد على عدة أشياء يقع غلط في صفة جوهرية في أحد هذه الأشياء، أو يكون أحد هذه الأشياء خارج عن دائرة التعامل، ففي هذه الأمثلة يصح عقد البقاء على الشيوع لمدة خمس سنوات، ويكون باطلاً فيما زاد على ذلك، ويبطل التكليف غير المشروع وحده[١] وتصح الهبة، ويبطل البيع أو يكون قابلا للإبطال بالنسبة للشئ الخارج عن دائرة التعامل أو الذي وقع فيه الغلط، ويصح فيما عدا من الأشياء[٢].... الخ على الترتيب الوارد فى الأمثلة وهكذا.

**شروط إعمال نظرية انتقاص العقد**:

**يشترط لإعمال نظرية "انتقاص العقد" توافر الشروط الآتية:**

١- أن يكون العقد باطلا فى جزء منه فقط، فإذا ثبت أن العقد كله باطل فلا ينتقص العقد، بل يمكن أن يتحول إلى عقد آخر، وفقا لنظرية تحول العقد إذا تحققت شروطها السابقة.

٢- أن يكون العقد قابلا للانقسام، وإلا فإن العقد يبطل بأكمله، ولا ينقص، بل يتحول إلى عقد آخر، فإذا اقترن عقد الهبة بشرط غير مشروع، وكان هذا الشرط هو

---

(١) كما لو كانت الهبة بعوض ، والعوض هو علاقة جنسية غير مشروعة ، أو جلب كمية من المخدرات .

(٢) د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٢٩٧ ،د/ جميل الشرقاوي – المرجع السابق ص ٢٤٨ وما بعدها ،د/ سمير تناغو – السابق ص ٩٣ –٩٤.

الباعث على التعاقد، بطل العقد كله، ويمكن أن يتحول إلى عقد آخر إذا توافرت شروط نظرية تحول العقد، إذا لم يكن الشرط غير المشروع هو الباعث على التعاقد فإن العقد يمكن أن ينتقص بطلان هذا الشرط وحدة بطلانا مطلقا[1] ويبقى فيما عداه صحيحا.

٣- ألا يتبين أن المتعاقدين أو أحدهما ما كان ليرضى بالصفقة إذا تمت مع إنقاص العقد، وإلا فإن العقد كله [2] يبطل أي أن المعيار هنا شخصي ينظر فيه إلى قصد المتعاقدين.

بيد أن المشروع الوضعي يلجأ فى بعض الحالات إلى انقاص العقد بنصوص آمره لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مثل نصه فى المادة ٢٢٢ مدني مصري على أن الاتفاق على فوائد تزيد على الحد الأقصى المقرر قانونا وهو ٧% ينقص إلى هذا الحد، ويتعين رد ما دفع زائدا عن هذا القدر، فيتم الإنقاص هنا بقوة القانون بصرف النظر عن إرادة المتعاقدين[3] ومثال ذلك أيضا بطلان الشروط المخالفة لأحكام قانون العمل أو الشروط التعسفية فى عقد الإذعان (م ١٤٦ مدني مصري) أو الشروط التي حظرها القانون المدني فى عقد التأمين (م ٧٥٠ مدني مصري)، فلا يمتد البطلان إلى العقد بأكمله، فيقتصر البطلان على الشروط المخالفة للقانون الآمر، والشروط التعسفية والشروط المحظورة فى عقد التأمين – على الترتيب –

---

(١) د/ عبد الرازق حسن فرج –المرجع السابق ص ٢٦٢ ، د/ جميل الشرقاوي – السابق – الموضع السابق ، د/ أنور سلطان – المرجع السابق ص ٣١٨ ، ٣١٩ .

(٢) انظر: في هذا الشأن نقض مدني في ١٢/٣١ / ١٩٧٥ – مجموعة أحكام النقض ص ٢٦ ص ١٧٥٧ ، نقض مدني في ٤/٢١/ ١٩٧٣ – المجموعة السابقة س ٢٤ ص ٩٤٩ .

(٣) د/ عبد الناصر العطار – السابق ص ١٧٥ ، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣٢٩ ، د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٢٩٥ ، والبدراوي – السابق ص ٣٦٤ .

وذلك دون اعتداد بإرادة رب العمل، أو الطرف القوي فى عقد الإذعان أو شركة التأمين.

## المبحث الثاني

## أحكام العقد القابل للإبطال

- **تمهيد:** سبق أن ذكرنا أن العقد يكون قابلا للإبطال إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية، أو شاب رضاءه عيب كغلط، او تدليس أو إكراه، او استغلال وهناك مسائل يسيرها هذا الموضوع سنعالجها فى هذا المطلب، فنتحدث أولا عن أحكام العقد القابل للإبطال فى مطلب أول، ثم نعالج آثار هذا العقد فى مطلب ثان .

### المطلب الأول

### أحكام العقد القابل للإبطال ( البطلان النسبي )

- **حالات العقد القابل للإبطال (البطلان النسبي):**

يكون العقد قابلا للإبطال فى الحالات الآتية:

١- إذا صدر التصرف من شخص ناقص الأهلية، كالصبي المميز إذا عقد تصرفا دائرا بين النفع والضرر، كالبيع، والشركة، والإيجار.

٢- إذا صدر التصرف من شخص شاب إرادته عيب من عيوب الإرادة، كالغلط أو التدليس أو الإكراه .

٣- إذا ورد فى القانون نص خاص يجعل التصرف قابلا للإبطال[1] كما هو الشأن فى نص القانون على جعل بيع ملك الغير قابل للإبطال فيما بين المتعاقدين،

(١) عبد الرازق حسن فرج – المرجع السابق ص ٣٤٣ ، د/ عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ١٦٩ ، د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٢٧٦.

وغير ناقذ فى حق المالك الحقيقي [1].

**خصائص العقد القابل للإبطال**

**تخلص خصائص العقد القابل للإبطال فيما يلي:**

أ– لا يجوز أن يطلب بطلانه إلا من تقرر البطلان لمصلحته، فهو وحده الذي يستطيع أن يتمسك بإبطال العقد، فإذا كان سبب القابلية للإبطال هي نقص الأهلية، فهو وحده الذي يجوز له – أو وليه أو وصيه – أن يتمسك بالإبطال، بعد بلوغه سن الرشد خاليا من عوارض الأهلية، وإذا كان سبب القابلية للإبطال هو عيب فى الإرادة، فمن شاب إرادته عيب هو وحده الذي يستطيع أن يتمسك بالبطلان، وإن كان سبب القابلية للإبطال: نص فى القانون كان التمسك بالإبطال للعاقد الذي خوله الشارع هذا الحق، كما فى بيع ملك الغير، حيث يكون هذا الحق للمشتري وحدة [2].

وقد نصت على هذه الأحكام المادة ١٣٨ مدني مصري بقولها: "إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر يتمسك بهذا الحق"، ولا يستطيع أن يطلب الإبطال لا الدائن ولا الخلف الخاص بمقتضى حق مباشر لهما، ولكن يستطيعان ذلك باعتبارهما دائنين للمتعاقد، فيستعملون حقه فى طلب إبطال العقد عن طريق الدعوى غير المباشرة [3].

---

(١) انظر المادة ٤٦٦: مدني وانظر في ذلك تفصيلا مؤلفنا – أحكام بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي والقانون المدني – حيث رجحنا الرأي القائل ببطلان بيع ملك الغير بطلانا مطلقا بأسانيد تشريعية وفقهية ص ٩٣ –٩٤ من هذا المؤلف ط ١٩٩٥.

(٢) د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٣٠٨ ، وانظر: السنهوري – المرجع السابق ص ٧٠٤ د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٢٦٠ –٢٦١ ، سليمان مرقس – المرجع السابق – فـ ٢٤٥، أنور سلطان– المرجع السابق فـ ٢٢٦ ، وانظر مجموعة الأعمال التحضيرية جـ ٢ ص ٢٣٥.

(٣) السنهوري– السابق – الموضع السابق ،د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣٠٨ سليمان مرقس – السابق – الموضع السابق .

أما الخلف العام فله أن يتمسك بالإبطال كالسلف تمام؛ إذ أن الحق فى طلب الإبطال ينتقل إلى الورثة.

ب- العقد القابل للإبطال ينتج جميع آثاره كالعقد الصحيح تماما حتى يحكم ببطلانه.

ج- لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما هو الشأن بالنسبة للبطلان المطلق، ولكن يجب أن يتمسك به من له الحق فيه على نحو ما سبق بيانه.

د- يزول هذا البطلان بالإجازة الصريحة أو الضمنية لمن له الحق فيها[1]، كما أنه يزول بالتقادم [2] وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا فى الفرع التالي .

هـ- إذا قضى بإبطال العقد: ترتب على ذلك أن يعود الحال إلى ما كان عليه قبل العقد، فيرد كل متعاقد ما أخذه على أساس دفع غير المستحق، وإذا كان الرد مستحيلا فى بعض الأحوال نتيجة لطبيعة الأداء ذاته كما فى العقود الزمنية ( كعقد العمل وعقد الإيجار) يستبدل بالرد العيني تعويض نقدي يعادله، ويستثنى من ذلك ناقص الأهلية، فلا يلتزم بالرد إلا فى حدود ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد[3]، كما يستثنى فى هذا الشأن، منع الرد للطرف الملوث، ( المصادرة) وهو ما يعبر عنه الفقهاء بـ "البطلان لعدم المشروعية"، ويرجع هذا الاستثناء إلى قاعدة قديمة فى القانون الروماني تقضي بأنه، لا يجوز للشخص الملوث أن تذرع بعمله الشائن أمام القضاء وتقرير هذا الاستثناء محل شك كبير من قبل الفقهاء، والقانون المصري لم يأخذ به، وارتأى انه لا مجال لتطبيق قاعدة التلوث لاعتبارات اجتماعية

---

(١) مادة ١٣٩ /١ (مدني مصري )

(٢) مادة ١٤٦ /١ مدني مصري والتي تنص على أنه " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .

(٣) مادة ١/١٤٢ مدني مصري، وانظر: د/ عبد الرازق فرج: المرجع السابق ص٢٤٤.

واقتصادية[1]، ومن ثم كان الرأي الراجح فى الفقه أن العقد الباطل لعدم المشروعية حكمه حكم العقد الباطل لأي سبب آخر فيلتزم كل من الطرفين برد ما أخذه تطبيقا للقواعد العامة.

و- لابد لتقرير إبطال العقد من اتفاق المتعاقدين أو صدور حكم قضائي بذلك، وإلا وجب على من له الحق فى الإبطال رفع دعوى أمام المحكمة وحصوله على حكم بذلك، ويكون الحكم هنا منشئ للبطلان لا كاشف له، فإذا ما تقرر الإبطال بالاتفاق أو بحكم القضاء أصبح كالعقد الباطل تماما، وتزول كل آثاره بأثر رجعي، ويرد كل من العاقدين ما أخذه تنفيذا للعقد، عدا حالة إبطال العقد لنقص أهلية احد المتعاقدين، فإن المتعاقد الآخر لا يسترد من ناقص الأهلية إلا ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد[2].

## المطلب الثاني

## آثار العقد القابل للإبطال

**العقد القابل للإبطال له وجود قانوني:**

لما كان العقد القابل للإبطال عقد توافرت أركانه، فهو لذلك عقد له وجود قانوني، وينتج جميع آثاره الأصلية، ومن ثم فهو والعقد الصحيح بمنزلة سواء، فيظل ينتج جميع آثاره حتى يقضي ببطلانه، فإذا كان العقد عقد بيع وشاب إرادة أحد المتعاقدين عيب كغلط أو إكراه، فإن البيع – مع ذلك – ينقل الملكية ويكون للمشتري

---

(١) انظر في ذلك تفصيلا د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٢٩٩ – ٣٠١ ، السنهوري – السابق ص ٧١٦ ، الصدة – السابق ص ٣١ ، ٣٢ ، أبو ستيت – السابق ص ٢٥٢ .

(٢) راجع في ذلك : د/ عبد الودود يحي – المرجع السابق ص ١٤٨ ، د/ عبد الفتاح عبد الباقي – السابق ص ٢٧٥ ، د/ البدراوي – السابق ص ٣٦٣ ، د/ محمود جمال الدين زكي – السابق ص ٢٤٠ ، د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٣٦ .

أن يطلب تسليم المبيع إليه، كما يكون للبائع أن يطالب بالثمن، فإذا طلب الإبطال من شابت إرادته عيب، وقضى به زالت آثار هذا العقد بأثر رجعي، وأصبح كالعقد الباطل، وقد يترتب على هذه الإبطال بعض الآثار العرضية التي ينتجها العقد الباطل باعتباره واقعة مادية[1] – على نحو ما رأينا فى آثار العقد الباطل – كما أن عقد يكون هناك مجال لتطبيق نظرية تحول العقد، أو نظرية انتقاص العقد إذا توافرت شروط اي منهما على النحو السالف بيانه فى حينه .

**سقوط الحق فى التمسك بالإبطال بالإجازة والتقادم**:

إذا كان العقد قابلا للإبطال فإن حق التمسك بإبطاله يسقط أو يزول بالإجازة والتقادم، وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا فيما يلي:

## الفرع الأول

## الإجـــــازة

**التعريف بالإجازة**:

الإجازة: تصرف قانوني من جانب واحد يقصد به النزول عن الحق فى التمسك بإبطال العقد ممن تقرر له هذا الحق[2].

فالإجازة تتم بإرادة منفردة، وهي إرادة صاحب الحق فى طلب الإبطال أي إرادة ناقص الأهلية ( بعد بلوغه سن الرشد) أو إرادة من شاب رضاءه عيب أما المتعاقد الآخر فليس له التمسك بقابلية العقد للإبطال، بل إنها – أي الإجازة – تحدث أثرها

---

(١) د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ١٤٥ ،د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٢٥٦، د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص٢٢٦، د/ الصدة – المرجع السابق ص٣٠٧–٣٠٨ .

(٢) د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٢٨ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٣١١ ، د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ١٤٢، د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٢٥٢.

دون حاجة إلى علم الطرف الآخر بها؛ لأن التعبير فيها غير واجب التسليم، كما أنها إذا تمت لا يمكن الرجوع فيها [1]، بحجة أن القبول لم يصدر.

وعلى هذا تنص المادة ١٣٨ مدني بقوله: "إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق"[2]، أي أن الإجازة تفيد التنازل عن الحق فى الإبطال، وبها يستقر العقد ولا يكون مهددا بالزوال فى المستقبل.

**صيغة الإجازة ( وسائل التعبير عنها ):**

الإجازة قد تكون صريحة، وقد تكون ضمنية:

**فالإجازة الصريحة:** تكون بأي عبارة تجيز إجازة العقد القابل للإبطال متى وضحت من خلالها نية المجيز فى إجازة العقد، كعبارة، اسقطت أو نزلت عن حقي، فى طلب إبطال العقد.

**أما الإجازة الضمنية:** فهي تكون بأي فعل يقوم به المجيز بحيث تخلع عليه الظروف دلالة الإجازة، كأن يقوم بتنفيذ العقد، وهو يعلم أنه قابل للإبطال لمصلحته، أو يقوم بعمل مادي آخر يدل على نزوله عن التمسك بالبطلان، أو يتصرف تصرفا فهم منه بوضوح أنه أجاز العقد، كما إذا اشترى قاصر عينا، وبعد بلوغه سن الرشد تصرف فيها باعتباره مالكا وهو يعلم بأن له حق إبطال العقد الذي اشترى به العين، بشرط ألا تضر الإجازة بالغير حسن النية.

---

(١) د/ عبد الرزاق السنهوري – المرجع السابق ص ٦٨٦ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق – الموضع السابق ، والبدراوي – السابق ص ٣٥٠ ،٣٥١ ، الشرقاوي السابق ص ٢٣٨ .

(٢) وانظر في هذا المعنى: نقض مدني في ٢ فبراير سنة ١٩٧٨ طعن رقم ٦٦٥ س ٤٥ ق حيث جاء فيه أن بطلان العقد الذي يبرمه القاصر لا يجوز لغيره ان يتمسك به .

والمقصود بالغير: الشخص الذي يكتسب حقا فى الفترة ما بين إبرام العقد وحصول الإجازة ويكون من شأن الإجازة الإضرار بهذا الحق.[1]

وعبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال يقع على عاتق الطرف غير المميز، وله حق إثبات الإجازة بكل الطرق بما فيه البينة والقرائن.[2]

**شروط صحة الإجارة**:

يجب أن تتوافر فى الإجازة الشروط اللازمة لصحة التصرف القانوني ومن ثم فيشترط فيها:

١- أن يكون المجيز عالما بالعيب الذي لحق العقد.

٢- أن تصدر الإجازة بعد زوال العيب الذي جعل العقد قابلا للإبطال؛ أي بعد كمال الأهلية، أو انكشاف الغلط، أو التدليس، أو زوال الإكراه أو الاستغلال.

٣- أن تتجه إرادته إلى النزول عن حقه فى طلب الإبطال[3].

- **الإجازة لا تلحق إلا العقد القابل للإبطال**:

الإجازة لا تلحق العقد الباطل، لأنه معدوم منذ نشأته، والعدم لا يمكن أن ينقلب وجودا بالإجازة، وفى هذا تنص المادة ١٤١ مدني بقولها: "لا يزول البطلان بالإجازة" أما العقد القابل للإبطال فهو عقد موجود، وينتج كل آثاره الأصلية كالعقد الصحيح، لكن يكون لأحد المتعاقدين الحق فى طلب إبطاله، وهذا الحق لا يزول بالتنازل عنه، وهذه هي "الإجازة" وفى ذلك تقول المادة ١/١٣٩ مدني: "يزول حق الإبطال بالإجازة الصريحة أو الضمنية".

---

(١) انظر: السنهوري – السابق ص ٦٨٧ –٦٨٨ ، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣١١ ، د/ عبد الناصر العطار – السابق ص ١٧٠ .

(٢) د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٣١.

(٣) انظر: د/عبد المنعم البدراوي – السابق – الموضع السابق – د/ جميل الشرقاوي – السابق – الموضع السابق .

- **أثر الإجازة:**

إذا تمت إجازة العقد القابل للإبطال: استقر وجوده، وأصبح العقد نهائيا بعد أن كان مهدا بالزوال، وقد ارتفع هذا التهديد بالإجازة، واعتبر العقد صحيحا من وقت إبرامه، لا من وقت الإجازة، فالإجازة لها أثر رجعي وفى هذا تنص المادة ١/١٣٩ مدني بقولها: "وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير"، ولكن يجب ألا يؤدي هذا إلى الإضرار بالغير[١] فإذا باع قاصر عينا، وبعد أن بلغ سن الرشد رهن العين أو باعها لآخر، فإذا ما أجاز البيع الأول فإن هذه الإجازة لا ينبغي لها أن تضر بحق الدائن المرتهن أو المشتري الثاني.

## الفرع الثاني

## التقـــــادم

**- التقادم بالنسبة للعقد القابل للإبطال:**

تنص المادة ١٤٠ من التقنين المدني المصري على أنه: "١- يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

٢- ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق طلب الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد".

ويستبين من هذه المادة أن الحق فى طلب إبطال العقد كما يزول بالإجازة، يزول بالتقادم، فإذا مضت مدة معينه من وقت زوال السبب الذي جعل العقد قابلا

---

(١) د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ١٤٦ ، د/ جميل الشرقاوي – المرجع السابق ص ٢٣٦ ، د،/ عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ١٧٠ ، د/ إسماعيل غانم – السابق ص ٢٨٣ ، انظر نقض مدني في ١/٢/ ١٩٥٢ مجموعة القواعد س ٣ جـ ٢ رقم ٤٦ ص ٨٣٩ .

للإبطال، ولم يستعمل من تقرير الإبطال لمصلحته حقه فى إبطال العقد، فإن هذا العقد يصير صحيحا، ولا يجوز بعد ذلك إبطاله.

ومدة تقادم دعوى الإبطال – وفقا للنص السابق – هي ثلاث سنوات تبدأ من وقت كمال الأهلية إذا كان العقد قابلا للإبطال لنقص الأهلية، وتبدأ من وقت اكتشاف الغلط والتدليس أو انقطاع حالة الإكراه، إذا كان العقد قابلا للإبطال بسبب أي من هذه العيوب[١]، وسنة واحدة من وقت إبرام العقد الذي كان فيه استغلال.

وقد أضاف القانون المدني المصري إلى هذا الحكم حكما آخر[٢] مؤداه: أن دعوى طلب الإبطال تتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد، فإذا مضت هذه المدة فلا يجوز التمسك بالإبطال حتى ولو لم تكن قد مضت ثلاث سنوات على اكتشاف العيب الذي شاب الإرادة أي أن الحق فى الإبطال يتقادم بأقصر الأجلين، ثلاث سنوات من وقت كمال الأهلية أو اكتشاف العيب، أو خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد، فإذا وقع البائع تحت إكراه، وزال الإكراه بعد أربع عشرة سنة من وقت العقد، فإن حقه فى الإبطال يتقادم هنا بانقضاء خمس عشرة سنة من قت العقد، لا بعد ثلاث سنوات من وقت كمال زوال العيب الذي شاب إرادته[٣]، ويترتب على انقضاء هذه المدة أنه لا يجوز بعد ذلك طلب إبطال العقد، لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع، ومن ثم يستقر العقد نهائيا – بعد أن كان مهددا بالزوال.

---

(١) نقض مدني في ١٩٧٢/٢/١٥ مجموعة أحكام النقض المدني ص ٢٣ ص ١٦٢.

(٢) لاعتبارات معينه أهمها أن انكشاف العيب قد يتأخر إلى ما بعد إبرام العقد بمدة طويلة ن مما يجعل العقد مذبذب ، غير مستقر .

(٣) د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ١٤٧ .

وجدير بالذكر أن نذكر أن للتقادم أثرا رجعيا، أي أن العقد يصبح صحيحا من وقت انعقاده[1]، لا من وقت مضي مدة التقادم.

**التقادم بالنسبة للعقد الباطل**:

تنص المادة ٢/١٤١ مدني مصري على أنه: "وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد".

والقاعدة أن العقد الباطل لا يرد عليه التقادم؛ لأنه عقد معدوم منذ البداية والعدم لا ينقلب وجودا مهما طال عليه الزمن، إلا أن المشرع الوضعي المصري تمشيا مع اتجاه محكمة النقض الفرنسية[2]، وبعض فقهاء فرنسا[3] قرر أن دعوى البطلان تسقط بالتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت العقد؛ وذلك حتى تستقر الأوضاع القانونية والاقتصادية،[4] فإذا مضى على صدور العقد الباطل خمس عشرة سنة من وقت العقد، ثم رفع صاحب المصلحة دعوى البطلان، أمكن دفعها بالتقادم، وذلك لأن الأوضاع القانونية والاقتصادية قد استقرت منذ صدور العقد الباطل وبقيت دهرا طويلا فوجب احترامها عن طريق إسقاط دعوى البطلان، ولكن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم مهما طالت مدته، فإذا باع شخص أرضا، وكان البيع باطلا، ولم يسلم الأرض للمشترى، ومضى على صدور البيع خمس عشرة سنة، فإنه لا يستطيع أن يرفع دعوى البطلان لسقوطها بالتقادم، إلا أنه لما كانت الأرض تحت يده ولم يسلمها للمشتري فهو فى غير حاجة إلى رفع دعوى البطلان، فإذا ما رفع المشتري دعوى

---

(١) د/ عبد الرازق ويح – المرجع السابق ص ٢٤٧ .

(٢) انظر: نقض فرنسي في ٥ مايو سنة ١٨٧٩ – داللوز ١٨٨٠ –١ –١٤٥.

(٣) بلانيول وريبير جـ١ ف ٣١٠.

(٤) انظر مجموعة الأعمال التحضيرية جـ٢ ص ٢٥٠ وما بعدها .

على البائع يطالبه بتسليم الأرض، استطاع البائع أن يدفع الدعوى ببطلان البيع حتى يعد انقضاء خمس عشرة سنة، إذ أن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم[1].

ويراعى أن سقوط دعوى البطلان بالتقادم – فوق أنه لا يعني أن العقد الباطل يصححه التقدم –، لا يؤثر– أيضًا – على ما للطرفين من حق فى أن يطلب كلل منهما رد ما أداه، فإذا كانت دعوى بطلان عقار قد سقطت بالتقادم، فإن البائع يستطيع أن يسترد الأرض بدعوى الاستحقاق، وهذه لا تسقط أبدًا، والبائع يستطيع أن يسترد العقار ما لم يكن المشتري قد كسب ملكية هذا العقار بالتقادم، وهذا شئ آخر يتعلق بالتقادم المكتسب، ويخلف عن سقوط دعوى البطلان بالتقادم المسقط، مع ملاحظ أن دعوى الاستحقاق دعوى عينية صعبة الإثبات، بخلاف دعوى البطلان؛ إذ هي دعوى شخصية إثباتها يسير، كما أن المشتري يستطيع أن يسترد الثمن الذي دفعه بدعوى "استرداد ما دفع بدون حق"، إذا كانت دعوى البطلان سقطت بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت الدفع ببطلان البيع لا من وقت البيع[2].

(١) د/ عبد الرزاق السنهوري – السابق ص ٦٩٤ ، وانظر د/ عبد الفتاح عبد الباقي المرجع السابق ص ٢٧٦ ، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣١٤ .

(٢) د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٣١٤ ، وانظر في ذلك تفصيلا السنهوري – السابق ص ٦٩٥ ، د/ إسماعيل غانم – السابق ص ٢٨٧٢٨٦٠ .

# الفصل الثالث

# آثـــار الـعـقـد

**نسبية الأثر الملزم للعقد من حيث الأشخاص ومن حيث المضمون:**

إذا انعقد العقد وتوافرت أركانه وخلا من كل ما يعيبه: تكون له قوة ملزمة، أي أنه يلزم عاقديه ما تضمنه، وكذلك الأمر بالنسبة لخلفهما العام والخاص، ويعبر عن هذا بنسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، كما أن العقد له قوة ملزمة من ناحية موضوعه، أي أن العاقدان وخلفهما لا يلتزمان إلا بما ورد بمضمون العقد، ويعبر عن هذا بنسبية أثر العقد من حيث الموضوع كل فى مبحث مستقل.

## المبحث الأول

## آثار العقد بالنسبة إلى الأشخاص

## ( القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص )

- **توضيح:** الأصل أن آثار العقد لا تنصرف إلا إلى المتعاقدين، وفقا لمعنى العبارة التي أصبحت شائعة من أن: "العقد شريعة المتعاقدين" والتي أشار إليها القانون المدني المصري فى المادة ١/١٤٧ منه: فالعقد لا تنصرف آثاره إلا إلى المتعاقدين وفقا لمبدأ نسبية الأثر الملزم للعقد؛ أي أن العقد لا ينشئ فى ذمة الغير التزاما، ولا يكسبه حقا، ومن ثم فالأصل أن آثار العقد لا تنصرف إلا إلى العاقدين، ولكن لا يقصد بالمتعاقدين طرفا العقد وحدهما، وإنما قد تنصرف هذه الآثار إلى الخلف العام، أو الخلف الخاص إذا توافرت شروط معينة.

**ويقصد بالخلف العام:** من يخلف شخصا فى ذمته المالية من حقوق والتزامات، أو فى جزء منها باعتبارها مجموعة من المال كالوارث والموصي له بجزء من التركة كالثلث، أو الربع، والخلافة العامة سبيلها الميراث أو الوصية فقط.

**وأما الخلف الخاص:** فهو من يخلف الشخص فى ملكية شئ عين بالذات، أو فى حق عيني عليها، كالمشتري بغير خلفا خاصا للبائع، لأنه يخلفه فى العين، والموصى له بعين معينه فى التركة، يعتبر خلفا خاصا للموصى[1]، والمنتفع يخلف المالك فى حق الانتفاع، ومن ثم نجد أن الخلافة الخاصة تكون بسبب الوفاة كما فى الوصية بمال معين، وقد تكون بين الأحياء كالمشتري [2].

ولا يعتبر الخلف عاما كان أو خاصا من الغير فى العقد، ولذلك تنصرف إليه آثار العقد الذي أبرمه السلف وذلك على النحو الذي سنبينه فيما يلي:

## المطلب الأول

## أثر العقود بالنسبة للخلف العام

- **كيف ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام:**

تنص المادة ١٤٥ مدني مصري على أنه: "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعته التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام".

ويتبين من هذا النص أن أثر العقد – وهو ما يترتب عليه من حقوق والتزامات – ينصرف إلى الخلف العام، فإذا أبرم شخص عقدا من العقود، ثم توفى، فإن الآثار التي تترتب على هذا العقد تنصرف إلى ورثته وإلى من أوصى لهم بحصة من تركته، وذلك دون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية فى هذا الشأن، وهي تقضي بأنه: "لا تركة إلا بعد سداد الديون"، فالخلف العام (الوارث) لا ينصرف إليه من أثر العقد

---

(١) د/ عبد الودود يحي – المرجع السابق ص ١٥٢ ، وانظر السنهوري – السابق ص ٧٢١ ، د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٤٢ ، عبد المنعم الصدة – السابق الموضع السابق – البدراوي – السابق ص ٤٣٤ .

(٢) راجع: إسماعيل غانم – السابق ص ٣٤٣.

الذي أبرمه السلف (المورث) إلا الحقوق[1] أما الالتزامات (الديون) فتقضى من التركة قبل انتقالها إلى الورثة، وهذا هو التحفظ الذي أوردت هذه المادة ١٤٥ بقولها: "دون إخلال بقواعد الميراث" ومعنى ذلك أن الخلف العام لا يخلف مورثه إلا فيما يتبقى من التركة بعد سداد الديون.

ويترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام: أنه يسري فى حقه ما يسري فى حق السلف بشأن هذا العقد، فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه[2].

**حالات عدم انصراف الأثر العقد إلى الخلف العام مع بقائه خلفاً**:

يستثنى من القاعدة السابقة أحوال ثلاثة أشارت إليها المادة ١٤٥ مدني، وفيها لا ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام مع بقائه خلفًا، بالإضافة إلى حالة رابعة يعتبر فيها الخلف العام من الغير:

**الحالة الأولى:** إذا اتفق المتعاقدان على عدم انتقال آثار العقد إلى الخلف العام، إذ أن العقد شريعة المتعاقدين، كالاتفاق فى عقد الإيجار على أن ينتهي العقد بموت المستأجر، فهو شرط جائز وغير مخالف للنظام العام و الآداب، ومن ثم يجب إعماله.

**الحالة الثانية:** إذا كانت طبيعة الحق أو الالتزام الناشئ من العقد تأبى أن ينتقل من المتعاقد إلى خلفه العام (ورثة المتعاقد) كما لو كان التزاما روعيت فيه شخصية المدين، كما فى التعاقد مع رسام أو محام أو طبيب للقيام بعمل يدخل فى نطاق اختصاص أي منهما، أو يكون إيرادا مرتبا مدى الحياة، أو يكون هذا الأثر

---

([1]) د/ السنهوري: السابق، ص٧٢٣، ود/ عبد الودود يحيي: السابق، ص١٥٣.

([2]) نقض مدني في ١١/٥/ ١٩٧٢– مجموعة أحكام النقض المدني ص٢٣، رقم١٣٥، ص٥٨٢.

حق انتفاع، إذ هو ينتهي بموت المنتفع بحكم القانون[١].

**الحالة الثالثة:** إذا كان هناك نص فى القانون يقضي بأن أثر العقد لا ينصرف إلى الخلف العام، كما فى نص القانون على انقضاء الشركة بموت أحد الشركاء[٢]، والنص على أن الوكالة تنقضي بموت الوكيل أو الموكل[٣] .

**الحالة الرابعة**: يعتبر الخلف العام – أحيانا – من الغير، وعلى هذه الاعتبار لا ينصرف إيه أثر التصرف الصادر من السلف، فلا ينفذ التصرف فى حقه، ويتحقق ذلك فى الحالات التي يخول فيها الشارع الوارث حقوقا تكفل حمايته من تصرفات مورثه الضارة به، فمثلا حماية الورثة تقتضي أن تكون الوصية – وهي تصرف قانوني من المورث مضاف لما بعد الموت – غير نافذة فى حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة، فالورثة يعتبرون من الغير بالنسبة لما يجاوز الحد الجائز الإيصاء به، فلا يكون نافذا فى حقهم إلا إذا أجازوه، ويأخذ حكم الوصية كل تصرف يصدر من المورث فى مرض موته، ويكون مقصودا به التبرع فإنه لا ينفذ فى حق الورثة إلا فى حدود ثلث التركة[٤] .

## المطلب الثالث

## أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص

### مدى تأثر الخلف الخاص بعقود سلفه:

سبق أن ذكرنا أن المقصود بالخلف الخاص كل من يتلقى من سلفه مالاً معيناً – أي حقاً مالياً عينياً أو شخصياً – كان قائماً في ذمة السلف كالمشتري والموهوب

---

(١) م٩٩٣ مدني مصري.

(٢) م ٥٢٨ مدني مصري.

(٣) م ٧١٤ مدني مصري.

(٤) راجع فيما سبق: د/ الصدة: السابق ص ٢٩٣ ، د/ عبد الودود يحيي: المرجع السابق ص١٥٤ ، د/ سلمان مرقس – المرجع السابق ص ٢٧٨ –٢٧٩.

له بمال معين، ومن تقرر له حق انتفاع ...إلخ .

وعلى العكس لا يعتبر المستأجر خلفاً خاصاً للمؤجر، لأن عقد الإيجار لا ينقل مالاً من ذمة المستأجر، بل ينشئ حقاً شخصياً للمستأجر، فهو دائن للمؤجر لا خلفاً له، والأمر كذلك بالنسبة للمستأجر من الباطن في علاقته بالمستأجر الأصلي.

وفي هذا الشأن تقرر أن الأصل هو الخلف الخاص يعتبر من الغير بالنسبة للعقود التي يبرمها سلفه، فلا تنصرف إليه آثارها[1]، فإذا اشترى إنسان عيناً من مالكها فلا شأن له بعقد الإيجار الذي سبق للبائع أن أجر به عيناً أخرى يملكها.

ولكن قد يحدث أن يبرم السلف عقداً يتعلق بنفس الشيء الذي انتقل إلى الخلف، فيثور التسأل عن مدى إمكان انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص، كما لو أبرم مالك بناية عقداً لصيانة مصعد هذه البناية، ثم يبيعها، فهل تنصرف آثار عقد الصيانة إلى المشتري، أو أن يؤمن مالك سيارة عليها ضد الأضرار، ثم يبيعها، فهل تنتقل آثار عقد التأمين إلى المشتري[2].

على هذه التساؤلات أجابت المادة ١٤٦ من التقنين المدني المصري بقولها: "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كان من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه".

ويتضح من هذا النص أنه يمكن أن تستخلص شروط انتقال آثار العقد إلى الخلف الخاص وهو ما سنوضحه تفصيلاً في البند التالي:

---

(١) د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٢٦٦ ، د/ عبد المنعم الصدة ، السابق ص ٣٩٧ ، إسماعيل غانم ص ٣٥٠ ، د/ حلمي بدوي – السابق ص ٢٠١ ، وما بعدها.

(٢) د/ لبيب شنب – السابق – الموضع السابق .

**شروط امتداد أثر تصرف السلف إلى الخلف الخاص**:

**يشترط لانتقال آثار العقد إلى الخلف الخاص توافر الشروط التالية:**

**الشرط الأول**: أن تكون الحقوق والالتزامات التي أنشأها العقد الذي أبرمه السلف من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص[1]، ويعتبر الحق من مستلزمات الشيء إذا كان مكملاً له، كحق التأمين فإذا أمن شخص على شيء مملوك له، ثم باعه فإن حقه الناشئ عن عقد التأمين ينتقل إلى المشتري باعتباره من مستلزمات الشيء.

ويعد الالتزام من المستلزمات الضرورية للشيء إذا كان يحد من كيفية الانتفاع بالشيء، كما إذا كان بائع المنزل قد التزم بعد تحويل منزله إلى مقهى، أو فندق، أو التزم نحو جاره بهدم حائط يحجب الضوء عن الجار، أو بعد الارتفاع ببنائه فوق حد معين[٢]، كما يعتبر الالتزام من المستلزمات إذا حد من حرية المالك في استغلال ملكه، كالتزام السلف بعدم مباشرة تجارته في جهة معينة منعاً للمنافسة.

**الشرط الثاني**: أن يكون تصرف السلف متعلقاً بالشيء الذي تلقاه الخلف وسابقاً على عقده مع الخلف الخاص، والأسبقية تستلزم ثبوت تاريخ التصرف أو شهره في الحالات التي يقضي فيها القانون[٣] بضرورة ذلك.

**الشرط الثالث**: أن يكون الخلف الخاص عالماً بالالتزامات والحقوق التي رتبها تصرف سلفه مع الغير وقت انتقال الشيء إليه، وأهمية هذا الشرط تبدو واضحة

---

(١) د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ١٥٥ ، وانظر د/ عبد المنعم الصدة السابق ص ٣٩٨ – ٣٩٩ ، د/ إسماعيل غنيم – المرجع السابق ص ٣٥٣ .

(٢) د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٢٨٠ ، د/إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٥٣ ، د/ جميل الشرقاوي – السابق ص ٣٢٧ ، ٣٢٩ .

(٣) فإذا باع شخص شيئا معينا إلى شخص ما ، ثم قام بتأجيره بعد البيع فإن عقد الإيجار لا تتصرف آثاره إلى المشتري .

بالنسبة للالتزامات؛ لأنها قيود على حقه، ومن ثم وجب أن يعلم بها، ولما كان الغرض من هذا الشرط هو حماية الخلف الخاص، فإنه لا يطالب إلا بالنسبة للالتزامات فقط[١]، وعبء إثبات علم الخلف بالالتزام يقع على عاتق المتعاقد مع السلف إذا ما طالب الخلف بتنفيذ ذلك الالتزام، كما يلاحظ أن المقصود بـ "إثبات العلم" العلم الفعلي لا مجرد استطاعة العلم[٢] .

فإذا توافرت الشروط السابقة انصرفت آثار العقد، وإذا كان العقد مفرغاً في ورقة عرفية، فلا يشترط أن يكون لها تاريخ ثابت؛ لأن العلم من جانب الخلف الخاص يقوم مقام ثبوت التاريخ[٣].

## المطلب الثالث

## أثر العقد بالنسبة للغير

**المقصود بالغير في هذا الشأن:** كل شخص ليس طرفاً في العقد، أو خلفاً عاماً أو خاصاً لأحد المتعاقدين، وهو ما يسمى الغير الأجنبي أصلاً عن العقد، والقاعدة أن أثر العقد ينصرف – فقط – إلى المتعاقدين وخلفهما العام والخاص، طبقاً لمبدأ نسبة أثر العقد، أما بالنسبة إلى الغير فإنه يعتبر أجنبياً عن العقد، ومن ثم لا ينصرف إليه أثره فلا يمكن أن يكسبه حقاً أو يرتب على علاقته التزاماً، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة في شقيها، فهي مطلقة بالنسبة للالتزامات، فلا يجوز أن ينشئ العقد التزاماً في ذمة الغير، أما بالنسبة للحقوق فيرد عليها استثناءً مقتضاه أن

---

(١) د/ عبد الودود يحي – المرجع السابق ص ١٥٦ .

(٢) السنهوري – السابق ص ٧٤٤ .

(٣) د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٦٨ ، وانظر نقض مدني في ١٩٦٦/٢/١ – مجموعة أحكام النقض س ١٧ رقم ٢٩ ص ٢٢١ .

العقد قد يكسب الغير حقاً من العقد[1]، وهو ما نصت عليه المادة ١٥٢ مدني بقولها: "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، لكن يجوز أن يكسبه حقاً".

ويستبين من هذا النص أنه لا يجوز أن يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير أبداً، ويظهر ذلك في حالة "التعهد عن الغير" بينما يجوز للغير أن يكتسب حقاً من العقد، ويكون ذلك في حالة " الاشتراط لمصلحة الغير"

وهذان الاستثناءان هما الذين نصت عليهما المادة ١٥٢ مدني مصري نزولاً على اعتبارات العدالة، واستقرار التعامل التي تقتضي انصراف أثر العقد إلى الغير[2]، وهو أثر مقصود أراده المتعاقدان، بخلاف الأثر غير المقصود والذي يترتب بحكم القانون، وهو أمر يخرج عن نطاق هذا المصنف الموجز، ونبحث الآن هذان الاستثناءان كل في فرع مستقل.

## الفرع الأول

## التعهد عن الغير

### التعريف بالتعهد عن الغير، أمثلة:

التعهد عن الغير: اتفاق بمقتضاه يتعهد فيه أحد الطرفين بأن يجعل شخصاً ثالثاً (أجنبي عن العقد) يلتزم بأمر معين قبل الطرف الثاني.

والتعهد عن الغير – بالمعنى السابق – له أهمية عملية في كثير من الأحيان، حيث يمكن بمقتضاه – غالباً – علاج موقف لا يمكن فيه الحصول على رضاء ذوي الشأن لأسباب معينة، فيلتزم عنه غيره، وأكثر ما يكون التعهد عن الغير في حالة "الملكية الشائعة" فإذا كان الشركاء على الشيوع بينهم شريك قاصر، ويريدون قسمة المال الشائع أو بيعه، ويتعذر الحصول على إذن المحكمة بالنسبة لنصيب

---

(1) د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٥٦ –١٥٧ .

(2) انظر في ذلك: مجموعة الأعمال التحضيرية جـ ٢ ص ٣٠٢ وما بعدها .

القاصر، فيجري الشركاء البالغون القسمة، ويتعهد أحدهم للآخرين بالحصول على موافقة الشريك القاصر عند بلوغه سن الرشد على ما تم من قسمة، أو يبيعون المال الشائع إلى المشتري، ويتعهدون له بالحصول على هذه الموافقة عند بلوغ القاصر سن الرشد، ومثل ذلك أيضاً أن يكون أحد الشركاء غير حاضر وقت البيع وخشي الشركاء الآخرون أن تفوت الفرصة لو انتظروا حضوره فيبيعوا العقار ويتعهد أحدهم بالحصول على إقرار الغائب للبيع عند حضوره[1].

وقد نظمت المادة ١٥٣ من التقنين المدني المصري التعهد عن الغير بقولها: "١- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر، فلا يلزم الغير بتعهده، فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.

٢- أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين له أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد".

ويبين من هذا النص أن التعهد عن الغير لا يتضمن أي استثناء من مبدأ نسبية الأثر الملزم للعقد[2]، فرغم أن غاية التعهد عن الغير هي الحصول على التزام ذلك الغير، إلا أن التعهد بذاته لا ينشيء سوى التزام المتعهد بالحصول على رضاء الغير، أما الغير فهو لا يلتزم بمقتضى ذلك التعهد، بل هو أجنبي عنه، ولا يلتزم إلا برضاه، وله الحرية المطلقة في القبول أو الرفض.

---

(١) انظر في ذلك : السنهوري – السابق ص ٧٥١ ،د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٢٦ ، د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٢٨٢ ، د/ لبيب شنب– المرجع السابق ص ٢٧٠ ، د/ الصدة السابق ص ٤٠٧ .

(٢) د/ اسماعيل غانم – المصدر السابق – الموضع السابق .

**شروط التعهد عن الغير**:

حتى يقوم التعهد عن الغير يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

**الشرط الأول**: **أن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير**: وهذا ما يميز المتعهد عن الوكيل، والفضولي، فالوكيل يعمل لحساب الموكل (الأصيل) ولذلك تنصرف آثار العقد إلى الأصيل لا إليه، والفضولي يعمل باسم رب العمل ومصلحته، فيلزمه بعمله، أما المتعهد عن الغير فيعمل باسمه هو، وينصرف إليه وحده آثار العقد[١].

**الشرط الثاني**: **أن يقصد المتعهد عن الغير إلزام نفسه لا إلزام الغير:** لأن الغير لا يلتزم إلا بقبوله للتعهد، وهذا هو الفرق بين "التعهد عن الغير" و "الاشتراط لمصلحة الغير"، فالمشترط لمصلحة الغير يريد أن يجعل للغير حقاً مباشراً يكسبه من ذات العقد الذي أبرمه المشترط، ومن هنا كان الاشتراط لمصلحة الغير استثناءًا من القاعدة التي تقضي بانصراف أثر العقد إلى الغير، ويجعل التعهد عن الغير ليس فيه أي خروج على القاعدة[٢].

**الشرط الثالث**: **يجب أن يكون محل التزام المتعهد هو القيام بعمل مضمونه أن يجعل الغير يقبل التعهد**: فالتزام المتعهد التزام بتحقيق نتيجة وليس التزاماً ببذل عناية، فلا يكفي أن يبذل المتعهد قصارى جهده لحمل الغير على قبول التعهد، بل يجب أن يصل فعلاً إلى أن يجعل الغير يقبل التعهد، فإذا قبل الغير انتهى التزام المتعهد، ولا يكون على المتعهد بعد ذلك أن يكفل تنفيذ الغير للتعهد[٣].

---

(١) د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٥٩ ، د، لبيب شنب – المرجع السابق ص ٢٧١ ، د/ حسام الأهواني – السابق ص ٣٥٩ ،د/ سمير تناغو – السابق ص ١٢١ ، د/ جميل الشرقاوي – السابق – الموضع السابق .

(٢) السنهوري – السابق ص ٧٥٢ ، د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٣٦٤ وما بعدها د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٤٠٧ .

(٣) د/ عبد المنعم البدراوي – السابق ص ٤٠٨ ، وانظر د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٣٩٤.

## أحكام ( آثار) التعهد عن الغير:

يتضح مما سبق أن الغير يستطيع أن يقبل التعهد أو يرفضه، لأنه أجنبي عن التعهد، وفي الحالتين تترتب أحكام معينة على القبول أو الرفض، نعرضها فيما يلي:

### أولاً: أثر قبول الغير للتعهد:

يجمع الفقه المصري[1] على أنه إذا قبل الغير التعهد فإن المتعهد يكون قد أوفى بالتزامه، ولا يسأل بعد ذلك عن عدم تنفيذ هذا الغير لالتزامه، ولا يستطيع المتعاقد الآخر أن يرجع على المتعهد، لأنه ليس كفيلاً للغير في تنفيذ التزامه.

والغير إذا رأى من مصلحته أن يقبل ما تعهد به المتعهد، فإنه يستطيع أن يفعل ذلك صراحة أو ضمناً[2]، ولا يشترط في القبول شكل خاص، إلا إذا اشترط القانون ذلك، كما في عقدي الهبة والرهن الرسمي.

والفقه يعتبر قبول الغير بمثابة عقد جديد، شقه الأول التعهد المعقود بين المتعهد والمتعاقد الذي يعتبر بمثابة إيجاب معروض على الغير، وهذا العقد الجديد يختلف عن العقد الأول المعقود بين المتعهد والمتعاقد من حيث الأطراف ومن حيث الالتزامات التي يولدها كل منهما، ومن حيث وقت تمام كل من العقدين[3].

١- فأطراف العقد الأول المتعهد والمتعاقد معه، بينما العقد الثاني طرفاه ذلك المتعاقد والغير، فالمتعاقد مع المتعهد مشترك في العقدين.

٢- ومن حيث الالتزامات التي تترتب على كل منهما: ينشيء العقد الأول التزاماً محله "عمل شيء" دائماً هو حمل الغير على قبول التعهد، في حين أن العقد الثاني

---

(١) د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٥٩ السنهوري – السابق ص ٧٥٤ وما بعدها ، د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٧١ .

(٢) مثال القبول الضمني أن يقوم الغير بتنفيذ التعهد .

(٣) انظر في ذلك: د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٢٠٦ ، د/ جميل الشرقاوي – المرجع السابق ص ٣٤٩ ، د/ عبد المنعم البدراوي – المرجع السابق ص ٧٥٥ .

ينشئ التزاماً في جانب الغير قد يكون محله نقل حق عيني أو عمل شيء أو امتناعاً عن عمل شيء.

٣- ومن حيث وقت تمام كل منهما: نجد أن العقد الأول يتم من الوقت الذي تلاقت فيه إرادة المتعهد والمتعاقد، أما وقت تمام العقد الثاني فلا يكون إلا من وقت قبول الغير للتعهد، ومن ثم فليس لقبول الغير أثر رجعي، إلا إذا تبين أن إرادة الغير قد انصرفت إلى ذلك، فإذا تعهد (أ) عن (ب) بأن يبيع الأخير عيناً يملكها إلى (ج)، وقبل أن يقر (ب) ذلك البيع باع هو العين إلى (د) فإن إقرار (ب) للتعهد لا يمكن أن يضر بحق (د) [١].

ويلاحظ مما سبق أن الغير حين يقبل التعهد ويصبح ملتزماً فإن التزامه إنما ينشأ من العقد الثاني، ومن ثم لا نكون بصدد استثناء من القاعدة، وهو ما كان يقع لو أن التزام الغير نشأ من العقد الأول.

**ثانياً: أثر رفض الغير للتعهد:**

سبق أن ذكرنا أن الغير حر في قبول التعهد أو رفضه، ولا يترتب على رفضه أية مسئولية؛ لأنه لم يلتزم بشيء، ولكن رفض الغير يعني إخلال المتعهد بالتزامه؛ لأنه التزم بحمل الغير على قبول التعهد، وهو التزام تحقق نتيجة – كما سبق أن ذكرنا – فإذا لم تتحقق النتيجة يكون قد أخل بالتزامه، ويصبح مسئولاً يجب عليه تعويض من تعاقد معه على ما أصابه من ضرر من جراء رفض الغير للتعهد[٢]، إلا أن يثبت أن رفض الغير للتعهد راجع لسبب أجنبي لا دخل لإرادته فيه، على أنه يجوز للمتعهد بدلاً من دفع التعويض أن يقوم هو بتنفيذ الالتزام عيناً متى كانت

---

(١) د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٢٨٦ –٢٨٧ ، د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ١٥٩ ، د/ الصدة – السابق ص ٤٠٩ ، د/ أنور سلطان – المرجع السابق ص ٣٤٠ .

(٢) د/ عبد الودود يحيي – السابق – الموضع السابق – د/ حشمت أبو شتيت – السابق – الموضع السابق ، د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٧٢ .

طبيعة الالتزام لا تأبى عليه ذلك[1]، إلا أن التنفيذ العيني في هذه الحالة لا يجبر عليه المتعهد؛ لأن التزام المتعهد بالتنفيذ العيني التزام بدلي، أما التزامه الأصلي فهو دفع التعويض، فإذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل الغير يقبل شراء عين مملوكة للثاني بثمن معين، ورفض الغير الشراء، فإن المتعهد يستطيع شراء العين لنفسه بنفس الثمن، ويكون بذلك نفذ ما كان الغير سيلتزم به[2].

## الفرع الثاني

## الاشتراط لمصلحة الغير

**أولاً**: **التعريف بالاشتراط لمصلحة الغير**:

**الاشتراط لمصلحة الغير:** هو تعاقد يتم بين شخصين أحدهما المشترط ويسمى الآخر المتعهد، يشترط فيه الأول على الثاني: أن يلتزم هذا الأخير قبل شخص ثالث ليس طرفاً في العقد يسمى "المنتفع أو المستفيد" بحيث ينشأ عن هذا العقد حق مباشر للمنتفع قبل المتعهد[3].

ويظهر من هذا التعريف أن الاشتراط لمصلحة الغير أطرافه ثلاثة: المشترط، والمتعهد (وهما طرفي العقد) والمنتفع (وهو الأجنبي).

والاشتراط لمصلحة الغير له تطبيقات عملية كثيرة، أشهرها ما نجده في عقد التأمين، وهو العقد الذي يمكن أن يقال في غير مبالغة أنه كان السبب الرئيسي في كل ما حدث لقاعدة "الاشتراط" من تطور وأهم صوره هو التأمين على الحياة، ففي

---

(1) كما لو كان الالتزام غير متصل بشخص الغير وكان التنفيذ ممكنا .

(2) د/ عب الودود – السابق ص ١٦٠ ، د/ حشمت أبو شتيت – السابق ص ٢٨٧ ، وانظر: السنهوري – السابق ص ٧٥٦ – ٧٥٨ ،د/ إسماعيل غانم – السابق ص ٣٦٥ –٣٦٨ ، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٤١٠ .

(3) د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٦٨ ، د/ عبد المنعم اصدة – السابق ص ٤١١ ، د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٦٠ ، د/ حشمت أبو شتيت – السابق ص ٢٩٠.

هذا العقد كثيراً ما يكن المستفيد من التأمين شخصاً آخر غير المستأمن، كما في التأمين على الحياة لصالح الابن أو الزوجة مثلاً، حيث يكون المستأمن (الأب أو الزوج) هو "المشترط" وشركة التأمين هي "المتعهد" والابن أو الزوجة هو "المنتفع" فهنا يكسب الولد أو الزوجة (وهما أجنبيان عن العقد) حقاً مباشراً من عقد التأمين، ومن صوره تأمين صاحب المصنع لمصلحة عماله، تأمين صاحب السيارة لمصلحة المصاب.

**ثانياً: شروط تحقق الاشتراط لمصلحة الغير:**

لكي يتحقق الاشتراط لمصلحة الغير، يجب أن تتوافر ثلاثة شروط، وهي:

**الشرط الأول: أن يكون التعاقد باسم المشترط لا باسم المنتفع:** إذ إن المنتفع ليس طرفاً في العقد، وبهذا يتميز الاشتراط عن النيابة، حيث لا ينوب المشترط عن المنتفع[1]، كما يتميز عن الفضولي، إذ الفضولي نائب عن رب العمل، متى توافرت شروط الفضالة، وإلا فإن رب العمل لا يستفيد ولا يضار من تصرف الغير، إلا إذا أقره، وبإقراره ينقلب الغير وكيلاً، المهم أن يكون المنتفع أجنبياً عن العقد، وفي هذا تنص المادة ١/١٥٤ مدني مصري على أنه: "يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية".

**الشرط الثاني: أن تتجه نية الطرفين إلى أن يكسب الغير حقاً مباشراً من عقد الاشتراط بنفسه:** فلا يمر بذمة المشترط أولاً، ثم ينتقل إلى المنتفع، ومن ثم يجوز للمنتفع أن يطالب المتعهد بالحق الناشئ عن العقد دون حاجة إلى إدخال المشترط في المطالبة، فإذا اتجهت إرادة المتعاقدين إلى إنشاء الحق في ذمة المشترط أولاً ثم نقله إلى المنتفع بعد ذلك، فإننا لا نكون بصدد اشتراط لمصلحة الغير، مثال ذلك أن

---

(1) نقض مدني في ١٩٦٩/٤/٢٤ – مجموعة أحكام النقض – س ٢٠ – ص ٦٩٣ .

يؤمن شخص على منزله ضد الحريق لصالحه هو، ثم يبيع المنزل، فإن حقه لدى شركة التأمين ينتقل إلى المشتري باعتباره خلفاً خاصاً[1]، ومن ثم لا يعتبر التأمين في هذه الصورة من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، كذلك إذا باع شخص شيئاً، وبعد البيع حول حقه في الثمن إلى شخص ثالث، فإننا لا نكون بصدد اشتراط أو تعاقد لمصلحة الغير، لأن الحق في الثمن نشأ أولاً للبائع ثم انتقل إلى الشخص الثالث (المحال إليه) بالحوالة[2]، وفي هذا تنص المادة ٢/١٥٤ من التقنين المصري على أنه: "ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط، يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد".

**الشرط الثالث**: **أن يكون للمشترط مصلحة مشروعة في الاشتراط**: سواء أكانت مصلحة مادية أم أدبية، ومثال المصلحة المادية أن يشترط البائع على المشتري للشيء أن يؤدي الثمن إلى دائن البائع، فمصلحة البائع من هذا الشرط هي انقضاء دينه بالوفاء.

ومثال المصلحة الأدبية أن يشترط المستأمن على شركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى أبنائه عند وفاته[3]، وعلى هذه الأحكام نصت المادة ٣/١٥٤ مدني مصري بقولها: "ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك".

---

(1) د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق – ص ١٦٢ ، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٤١٥ ، د/ جميل الشرقاوي – السابق – الموضع السابق .

(2) د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٢٧٥ ، د/ إسماعيل غانم – السابق ص ٢٧٦ وما بعدها – أنور سلطان السابق ص ٣٤٨ – ٣٤٩ ، د / عبد الحي حجازي – السابق– ف– ٤٨٠ .

(3) د / عبد الودود يحيي – السابق ص ١٦٣ ،د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٧٥ ، د/ سمير تناغو – السابق ص ١٣٢–٢٣٣ ، د/ عبد الناصر العطار السابق ص ١٣٥ .

**تعقيب**:

استبان لنا من عرض شروط الاشتراط لمصلحة الغير، أنه لا يشترط وجود المنتفع أو تعيينه وقت العقد، وإن كان الغالب أن العاقدين يعينان المنتفع وقت إبرام العقد، ومن ثم يجوز أن يكون المنتفع شخصاً حاضراً أو مستقبلاً، معيناً بذاته أو قابلاً للتعيين، مادام أنه يكون معيناً بذاته وقت أن ينتج العقد أثره. وعلى هذا تنص المادة ١٥٦ مدني مصري بقولها: "يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد طبقاً للمشارطة" .

وعلى ذلك إذا لم يوجد المنتفع بذاته وقت إنتاج الاشتراط أثره، وقع الاشتراط باطلا مع ملاحظة أن بطلان الاشتراط لا يبطل عقد الاشتراط، بل تتحول الفائدة التي يحققها العقد إلى المشترط أو ورثته[١] كما هو الشأن فى التأمين لصالح الزوجة أو الأولاد، فهو تأمين صحيح حتى قبل الزواج أو قبل إنجاب الأولاد، فإذا مات المستأمن (المشترط) قبل الزواج، أو بعد الزواج وقبل إنجاب الأولاد، فإن الاشتراط يقع باطلا، ولكن التأمين لا يبطل، وإنما يعتبر مبلغ التأمين تركة تنتقل إلى ورثة المستأمن[٢].

**ثالثاً: آثار الاشتراط لمصلحة الغير**:

آثار الاشتراط لمصلحة الغير تتركز فى العلاقات الثلاث التي تترتب على الاشتراط لمصلحة الغير، وهي:

---

(١) د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٣٩٣ ، د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٧٧ ، د/ عبد الودود يحيي – السابق – الموضع السابق .

(٢) راجع في ذلك : د/ جميل الشرقاوي – السابق ص ٣٣٦ ،د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٨١ –٣٨٢ ، د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٦٣ .

**العلاقة الأولى**: **علاقة المشترط بالمتعهد**:

المشترط والمتعهد هما طرفا عقد الاشتراط، ومن ثم فالعلاقة بينهما يحددها العقد الذي تم بينهما، فيلتزم كل منهما بما أوجبه العقد عليه، ففي عقد التأمين – مثلا – يلتزم المشترط (المستأمن) بأن يدفع للمتعهد (شركة التأمين) أقساط التأمين كاملة فى مواعيدها، وتلتزم شركة التأمين أن تؤدي ما عليها من التزام نحو المشترط – إذا كان المشترط قد اشترط لنفسه إلى جانب اشتراطه للغير – فتدفع للمشترط المبلغ المتفق عليه إذا بقى حيا إلى المدة المتفق عليها، وإذا كان العقد عقد بيع، فإن المشترط (البائع) يلتزم بتسليم المبيع إلى المتعهد وهو المشتري.

فإذا امتنع أحد طرفي العقد عن الوفاء بما عليه من التزام كان للطرف الآخر أن يطالب بالتنفيذ العيني إذا كان ممكنا وفقا للقواعد العامة، كما يجوز له الامتناع عن تنفذ التزاماته المتقابلة، كما أن له فسخ العقد أو وقف تنفيذه، بل والمطالبة بالتعويض إذا كان له محل[1]، كما أن المشتري – فى عقد البيع – يستطيع أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما التزم به نحوه شخصيا، كما أن له – أيضا – أن يطالبه بتنفيذ ما التزم به تجاه المنتفع[2]، وذلك بناء على وجود مصلحة المشترط فى تنفيذ الاشتراط المعقود لصالح المنتفع ويجوز الاتفاق على قصر هذه المطالبة على المنتفع وحده، وهنا لا يجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لصالح المنتفع، وإلى هذا أشارت المادة ٣/١٥٤ مدني مصري بقولها: "ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك".

---

(١) السنهوري – السابق ص ٧٧٩ ، د/ محمد لبيب شنب – المرجع السابق ص ٢٧٧ ، د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٨٣ ، د/ بهجت بدوي – أصول الالتزامات ف ٢٥٦ .

(٢) انظر: د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٢٩٧ ، د/ عبد المنعم البدراوي السابق ص ٤٧٠ ،د/ عبد الناصر العطار – المرجع السابق ص ١٣٦ ، د/ لبيب شنب – السابق – الموضع السابق ، د/ عبد الرازق ويح – السابق ص ٢٩١.

**العلاقة الثانية: علاقة المشترط بالمنتفع:**

العلاقة بين المشترط والمنتفع تختلف من عقد إلى آخر، فقد يقصد المشترط من التعاقد لمصلحة المنتفع التبرع له فتكون العلاقة بينهما تبرعية[1]، فإذا كسب المنتفع عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير تبرعا – كما فى الهبة – وجب أن تستوفي الهبة شروطها الموضوعية دون الشروط الشكلية؛ لأن الهبة تكون عندئذ هبة غير مباشرة، وهذه لا يجب فيها الشكل وعلى ذلك يجب أن تتوافر فى المشترط أهلية التبرع، كما أن الهبة تأخذ حكم الوصية إذا وقع الاشتراط فى مرض الموت، كما لا يلزم سوء النية لإمكان الطعن فيها بالدعوى البوليصية[2]، كما أنه يجوز الرجوع فيها إذا توافرت شروط الرجوع فى الهبة.

أما إذا كان الاشتراط قد تم معاوضة، كأن يكون قد عُقد وفاء لدين على المشترط، أو لإقراض المنتفع بفائدة، فإن القواعد الخاصة بالوفاء هي التي تطبق، وبصفة خاصة عدم براءة ذمة المشترط إلا بعد استيفاء المنتفع لدينه كاملا من المتعهد[3] .

وسواء كانت العلاقة بين المشترط والمنتفع تبرعا أو معارضة، فإن المشترط يستطيع أن ينقض الاشتراط إلى أن يعلن المنتفع رغبته فى الاستفادة من الاشتراط، وفى هذا تنص المادة ١٥٥ مدني على أنه: "يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد".

---

(١) لبيب شنب –السابق ص ٣٧٨ ، د/ سمير تناغو – السابق ص ١٣٥ .

(٢) انظر في ذلك تفصيلا ،د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٢٩٨ ،د/ عبد المنعم البدراوي – السابق ص ٤٧٢ –٤٧٢ ، د/ جميل الشرقاوي – السابق ص ٣٩٣ ٣٤٠ .

(٣) انظر: د/ لبيب شنب – السابق – الموضع السابق ،د/ حشمت أبو ستيت – السابق –الموضع السابق ،د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٤٢٠ ، د/ سمير تناغو – السابق –الموضع السابق .

فالمشترط يستطيع أن ينقض الاشتراط، وهنا يزول حق المنتفع بأثر رجعي، إلا أنه لا يترتب على نقض الاشتراط أن تبرأ ذمة المتعهد مما التزم به إلا إذا اتفق على غير ذلك، وغالبا ما يكون نقض الاشتراط بإحلال منتفع جديد محل المنتفع الأول، أو بأن يستأثر المشترط لنفسه بالمنفعة، وقد عبرت المادة ٢/١٥٥ مدني على هذا المعنى بقولها: "ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما أن له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة".

فهذه المادة تقرر أن نقض حق الاشتراط للمشترط نفسه، فلا ينصرف إلى دائنيه حال حياته ولا إلى ورثته بعد موته، ويظل هذا الحق قائما إلى أن يعلن المنتفع رغبته فى الاستفادة من الاشتراط سواء وجهها إلى المشترط أو إلى المتعهد، فإذا أعلن المنتفع رغبته امتنع على المشترط أن ينقض الاشتراط كما لا يستطيع نقض الاشتراط إذا كان مخالفا لمقتضى العقد حتى ولو لم يعلن المنتفع رغبته، كما لو باع شخص عقارا مرهونا واشترط على المشتري أن يدفع جزءا من الثمن للدائن المرتهن للعقار، هنا لا يستطيع البائع (المشترط) أن ينقض الاشتراط، لأن المشتري (المتعهد)، له مصلحة فى سداد الدين وتخليص العقار الذي اشتراه من الرهن.

كما أن المنتفع يمكنه أن يرفض ما اشترط لصالحه، وهنا ينصرف الحق إلى المشترط، فيجوز أن يستبقيه لنفسه، ويجوز أن يعين منتفعا آخر محل المنتفع الأول، وفى هذه الحالة يثبت الحق للمنتفع الثاني من وقت العقد لا من وقت تعيينه[1].

**العلاقة الثالثة: علاقة المتعهد بالمنتفع:**

هذه العلاقة هي التي تظهر الخاصية المميزة للاشتراط لمصلحة الغير، ذك أن

(1) انظر في ذلك: د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٦٦ ، د/ إسماعيل غانم – السابق ص ٣٨٥ ، وقارن د/ السنهوري – السابق ص ٧٩١ – ٧٩٦ .

المنتفع المستفيد ينشأ له حق مباشر قبل المتعهد، بموجب العقد الذي تم بين المشترط والمتعهد، وهو عقد لم يكن المنتفع طرفا فيه، ومن هنا يبدأ الخروج على قاعدة "نسبية الأثر الملزم للعقد" وإذا لم ينفذ المتعهد ما التزم به، كان للمنتفع أن يرجع عليه طبقًا لقواعد المسئولية العقدية رغم أنه لم يكن طرفا فى العقد[1]، وحق المنتفع حق قابل للنقض[2]، إلى أن يعلن رغبته فى الاستفادة من الاشتراط، وفقا للمادة ١٥٥ سابق الإشارة إليها، وإعلان الرغبة ليس قبولا لإيجاب معروض عليه من المشترط او المتعهد وليست إجازة، وإنما هو يثبت حقه الذي نشأ من عقد الاشتراط من وقت انعقاده [3].

ويترتب على القول بأن المنتفع يكسب حقا مباشرا قبل المتعهد، وأن هذا الحق مصدره عقد الاشتراط النتائج الآتية:

أ- أن حقه يثبت له من وقت العقد لا من وقت إظهار الرغبة، ومن ثم فإن المتعهد إذا فقد أهليته بعد انعقاده العقد، فإن هذا لا يمنع المنتفع من إظهار رغبته والاستفادة من الاشتراط، كما لا يؤثر فيه موته فى الفترة ما بين إبرام العقد وإعلان رغبة المنتفع، كما أن عقد الاشتراط هو الذي يبين حدود هذا الحق وأوصافه وكيفية استعماله[4].

ب- دائنوا المشترط لا شأن لهم بالحق الذي يكسبه المنتفع مباشرة قبل المتعهد، لأنه لا يدخل فى الضمان العام لمدينهم، فلا يستطيعون التنفيذ عليه ولا أن يستعملون الدعوى غير المباشرة بالنسبة له نيابة عن مدينهم، وإذا توفى المشترط لا يعتبر هذا الحق ضمن تركته، ولا يستطيع الدائنون أن ينفذوا عليه، فمثلا إذا كان

---

(١) نقض مدني في ١٩٧٦/٤/١٩ – مجموعة أحكام النقض س ٢٧ ص ٩٨١ .

(٢) من قبل المشترط ، إلا إذا نزل عن هذا الحق .

(٣) د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٦٧ .

(٤) د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٨٨ وما بعدها.

هناك عقد تأمين شخص على حياته لصالح أولاده ثم توفى فإن أولاده يكون لهم حق مباشر قبل شركة التأمين (المتعهد)، أي أنهم لا يتلقون مبلغ التأمين باعتباره تركة لأبيهم، وبالتالي لا يشاركهم فيه دائنوا التركة، ولكن المنتفع يعتبر دائنا للمتعهد (شركة التأمين) بهذا الحق، ومن ثم يكون دائنوا المتعهد مشاركين للمنتفع مشاركة الغرماء فى اقتسام أموال المتعهد، وأولاد المستأمن (المنتفعون) – في المثال السابق – يشتركون مع بقية دائني الشركة في اقتسام أموالها إذا أفلست[1].

ج- المتعهد يستطيع أن يدفع مطالبة المنتفع له بكل دفوع عقد الاشتراط الجائزة، كالدفع بالبطلان، أو بعدم تنفيذ المشترط لالتزامه المقابل[2]، كما أن له أن يطالبه بالفسخ لعدم التنفيذ، وهذا ما أشارت إليه المادة ٢/١٥٤ مدني مصري بقولها: "ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط، يستطيع أن يطالب بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد".

## المبحث الثاني
## آثار العقد من حيث الموضوع

- **تمهيد:**

يترتب على انعقاد العقد الصحيح: الالتزام بتنفيذه؛ أي يصبح كل من المتعاقدين مسئولا عن تنفيذ ما ورد فى العقد، وآثار العقد من حيث الموضوع (القوة الملزمة للعقد) تقتضي دراسة مسائل ثلاث: ١- تحديد مضمون العقد وتحديد نطاقه. ٢- القوة الملزمة للعقد. ٣- جزء القوة الملزمة للعقد لحين معالجة هذا الموضوع من خلال قواعد المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية فى الباب الثالث من هذا المؤلف

(١) د/ عبد الودود يحيي: السابق ص ١٦٧، د/ سليمان مرقس: نظرية العقد ط ٥٦ ف ٣٢٨ .

(٢) د/ أبو ستيت: المرجع السابق، ص٢٩٩، د/ جميل الشرقاوي: السابق، ص٢٣٤-٢٤٤.

(الفعل الضار) منعا للتكرار وهو الموضوع الطبيعي لمعالجة جزاء القوة الملزمة للعقد خلافا لما جرى عليه معظم الفقه المصري .

## المطلب الأول

## تحديد مضمون العقد

**- كيف يتحدد مضمون الرابطة العقدية:**

تحديد الالتزامات التي أنشأها العقد قد تستوجب أولا تفسير العقد لتفهم مدلول العبارات التي عبر بها الطرفان عن مقصدهما، فإذا ما تم للقاضي تفسير العقد باستخلاص إرادة المتعاقدين، وجب بعد ذلك تحديد طبيعته القانونية، أي تكيفه، أي الفئة التي ينتمي إليها، أهو بيع، أم إجارة، أم قرض ....الخ. وهذا سنعالجه فى هذا المطلب ثم يتعين بعد ذلك – وعلى أساس ما سبق – تحديد، القوة الملزمة للعقد، وهو ما سنعالجه فى المطلب الثاني من هذا المبحث.

### الفرع الأول

### تفسير العقد

**ماهية التفسير وحالاته (إجمال):**

تفسير العقد: هو تحديد ما انصرفت إليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين.[1]

وقد بينت المادتان ١٥٠، ١٥١ مدني مصري حالات التفسير وطرقه فنصت المادة ١٥٠ على أنه: "١– إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

٢– أما أذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة

(١) د/ إسماعيل غانم – السابق ص ٣٠٤ ، د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ١٦٩ ، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣٤٣.

التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري فى المعاملات".

وتنص المادة ١٥١ على أنه: "١- يفسر الشك فى مصلحة المدين.

٢- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن".

ويتضح من هذين النصين أن هناك حالات ثلاث للعبارات الواردة في العقد:

**الحالة الأولى**: **حالة وضوح عبارة العقد**:

إذا كانت عبارة العقد واضحة، فالأمر هنا لا يحتاج إلى تفسير، والقاضي ملزم بأن يأخذ بعبارة العاقدين كما هي[1]، ومن ثم لا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى آخر[2]، ما دام لم يثبت أن معناها الظاهر يختلف عما قصد المتعاقدين منها[3]، وهذا هو الأصل إلا أنه إذا ثبت أن العبارات التي استخدمها العاقدان رغم وضوحها في ذاتها[4] لا تعبر عن حقيقة قصدهما، فإنه يجب العدول حينئذ عن معناها الظاهر إلى المعنى الذي قصده المتعاقدان بها، وقد تكون كل عبارة من عبارات العقد واضحة في ذاتها، لكنها تتعارض فيما بينها بحيث يصبح المعنى المستخلص منها في مجموعه غير واضح.

كما أن العبارة الواضحة قد يحيط بها من الملابسات ما يرجح معها القاضي حمل معناها على معنى آخر مخالف لظاهرها، في مثل هذه الحالات يكون للقاضي

---

(١) م ١/١٥٠ سابق الإشارة إليها.

(٢) د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٠٤ ، د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٢٤٤ ، د/ عبد الناصر العار – المرجع السابق ص ١٤١ .

(٣) انظر نقض مدني في ١٩٩٠/١/١٤ ، مجموعة أحكام النقض س ٤١ رقم ٢٨ ص ١٢٨.

(٤) أي أن المراد بالوضوح هو وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ – انظر في ذلك نقض مدني في ٦/١٢/ ١٩٨٤ ، مجموعة أحكام النقض س ٣٥ جـ٢ ص ١٦٢٧.

أن يتدخل لتفسير العقد بما يراه أقرب إلى قصد المتعاقدين وإرادتهما المشتركة[1]، ويتعين على القاضي هنا أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي أدت به إلى استبعاد المعنى الظاهر واعتباره غير متفق وقصد المتعاقدين، وكيف توصل إلى استخلاص المعنى الذي قصده المتعاقدان، ويخضع القاضي في هذا التسبيب لرقابة محكمة النقض[2].

**الحالة الثانية**: **حالة غموض عبارة العقد**:

إذا كانت عبارة العقد غير واضحة، أي يكتنفها الغموض وتحتمل أكثر من معنى، فإنها تصبح في حاجة إلى التفسير، وفي هذه الحالة يجب – كما تنص المادة ١٥٠ / ٢ مدني مصري – "البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات".

والنص حين يشير إلى الاستهداء بالأمانة والثقة – في تفسير العقد – يعني أن القانون المصري يعتد في تفسير العقد لا بالإرادة الباطنة الكامنة في النفس، ولا بالإرادة الظاهرة في الألفاظ وحدها، وإنما يعتد بالإرادة التي يمكن التعرف عليها من جميع الملابسات الموضوعية المحيطة بالتعاقد.

**وهنا يجب مراعاة القواعد الآتية**:

أ– طبيعة التعامل والعرف الجاري هي من الملابسات الموضوعية التي يعتد بها في تفسير العقد عند غموض عبارته، فعبارة العقد التي تحتمل أكثر من معنى تحمل على المعنى الذي يكون أكثر اتفاقاً مع روح العقد وطبيعته وموضوعه والغرض

(١) د/ حشمت أبو ستيت: المرجع السابق ص ٣٠٧ ، د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٢٤٥.

(٢) انظر: نقض مدني في ١٩٧٨/١١/٢٨ –طعن رقم ٨٥٤ السنة ٣ق .

المقصود منه، ومع العرف الجاري في هذا النوع من التعامل[1]، فإذا كنا بصدد عقد بيع ونص فيه على أن عقد البيع يشمل منزلاً معيناً وما به من منقولات، وجب تفسير كلمة "منقولات" على أنها الأثاث والمفروشات الموجودة بالمنزل، ومن ثم فهي لا تشمل النقود أو الذهب أو أية أوراق مالية يحتفظ بها البائع في منزله، لأن العرف الجاري يفسر المنقولات بذلك[2].

ب- هناك ملابسات أخرى لم تنص عليها المادة ٢/١٥٠ مدني مصري تعين في تفسير العقد، منها أن إرادة المتعاقدين قد تتضح من المفاوضات السابقة على إبرام العقد، أو من الطريقة التي اتبعاها في تنفيذ العقد أو مما قد يكون قد تم إبرامه بينهما من عقود، فمثلاً: إذا اعتاد المستأجر أن يدفع الأجرة في محل إقامة المؤجر مدة من الزمن، فإن ذلك يدل على أنهما أرادا مخالفة القاعدة التي تقضي بدفع الأجرة في محل المستأجر.

ج- يمكن الاستعانة في تفسير عبارة العقد غير الواضحة بما نصت عليه بعض التقنينات الأجنبية، حيث نصت هذه التقنينات على بعض القواعد المنطقية في التفسير، ومبنى هذه القواعد: أن إرادة المتعاقدين إرادة متعقلة، أي أنهما قصدا من العقد ما هو معقول، من ذلك ما نص عليه القانون الفرنسي في المادة ١١٥٧ مدني فرنسي على أنه: "إذا كانت عبارة العقد تحتمل أكثر من معنى فإنها تحمل على المعنى الذي يجعلها تنتج أثراً قانونياً"، وهذه هي القاعدة التي يعبر عنها في أصول

---

(١) د/ حشمت ابو ستيت – المرجع السابق ص ٣٠٨ ، د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٠٥ ، د/ عبد المنعم الصدة –المرجع السابق ص ٣٤٧ .

(٢) د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٣٠٥ ، د/ هبد الرازق ويح – السابق ص ٣٠١ ، د/ جميل الشرقاوي – السابق –الموضع السابق ، د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٦٩ .

الفقه الإسلامي بأن "إعمال الكلام خير من إهماله" وفي المادة ١١٦١ من أن (عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً) [1]

وفي المادة ١١٦٤ مدني فرنسي من أن تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها حتماً تنفرد بالحكم[2].

وتجدر الملاحظة أخيراً إلى أن استخلاص القاضي للنية المشتركة للمتعاقدين بالاستعانة بهذه المعايير المختلفة هو: مسألة موضوعية لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض[٣]، لأن ما أراده المتعاقدين هو من مسائل الواقع وليس من مسائل القانون.

**الحالة الثالثة**: **حالة الشك في معنى العبارة**:

إذا كانت عبارة العقد غامضة، أي تحتمل أكثر من معنى ولا يستطيع القاضي بالرغم من استعانته بوسائل التفسير السابقة أن يهتدي إلى معنى يرجحه على غيره من المعاني، وبقي الشك في التعريف على إرادة المتعاقدين قائماً، فالقاعدة أن "الشك يفسر لصالح المدين" وفقاً لنص المادة ١/١٥٢ من القانون المدني المصري، لأن الأصل هو براءة الذمة، والاستثناء شغلها، والاستثناء لا يتوسع فيه، كما أن الدائن – وفقاً للقواعد العامة – هو المكلف بإثبات الالتزام، فإذا قام شك حول مدى الالتزام، وأراد الدائن أن يأخذ بالمدى الواسع ولم يستطع إثباته فلا يبقى إلا الأخذ بالمدى الضيق؛ لأنه هو الذي ثبت بالدليل، كما أن الدائن هو الذي يفرض الالتزام لا

---

(١) انظر في ذلك بوجه خاص: نقض مدني في ١٩٦٦/٣/١٠ – مجموعة أحكام النقض – س ١٧ قاعدة ٧٨ ص ٥٧ ، ونقض مدني في ٣٠ /١١/ ١٩٦٧ – المجموعة السابق س ١٨ ص ١٧٧٩ رقم ٢٧٠.

(٢) انظر في ذلك تفصيلا: السنهوري – السابق ص ٨٢٣ –٨٣١ ، د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق بص ٣٠٦ ، د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٣٠٨ ، الصدة – السابق ص ٣٤٧.

(٣) انظر: نقض مدني في ٢٦/ ١/ ١٩٦٧ – مجموعة أحكام النقض س ١٨ ص ٢١٥ رقم ٣٥.

المدين[1]، فإذا كان هذا الالتزام غير واضح، فإن ذلك يعتبر خطأ منه، ويجب أن يفسر الشك لمصلحة المدين بالالتزام، وتلك قاعدة تبررها المبررات السابقة، وقواعد العدالة، ومن ثم فقد قررتها معظم قوانين العالم، والقانون المدني المصري نص عليها في المادة ١/١٥١ بقوله: "يفسر الشك لمصلحة المدين" ومن تطبيقات هذه القاعدة: إذا ثار شك حول مقدار العين المؤجرة فسر الشك في مصلحة المؤجر؛ لأنه هو المدين بتمكين المستأجر من الانتفاع بها، وإذا ثار شك حول طريقة الوفاء بالأجرة، فسر في مصلحة المستأجر لأنه المدين بها[2] ... إلخ.

على أنه ينبغي مراعاة أنه إذا كان الأصل أن الشك يفسر لمصلحة المدين[3]، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناءً بالنسبة لعقود الإذعان، ففيها يفسر الشك لمصلحة الطرف المذعن، سواء كان دائناً أو مديناً، وفي هذا تنص المادة ٢/١٥١ على أنه: "ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.

## الفرع الثاني
## تحديد نطاق العقد

### الفرق بين تفسير العقد وتحديد نطاق العقد:

تفسير العقد – كما سبق أن ذكرنا – ينصرف إلى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، أما تحديد نطاق العقد فمعناه: بيان الالتزامات التي تترتب على العقد في ذمة كل من المتعاقدين وفقاً لما اتفق عليه المتعاقدان، أو كان من مستلزمات العقد

---

(1) انظر فيما سبق :د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٧٢ ، د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٠٨ ، د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٣٠٩ .

(2) السنهوري – السابق ص ٨٣٢ ، د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٢٤٧.

(3) د/ محمود جمال الدين زكي – السابق ص ٣٠٦ ،د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٤٧ .

طبقاً للتشريع والعرف والعدالة؛[1] لأن المتعاقدين لا يتعرضان دائماً لكل المسائل التي يمكن أن يثيرها العقد.

وتحديد نطاق العقد بينته المادة ١٤٨ من التقنين المدني المصري بقولها: "١- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ٢- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام".

ويستبين من هذه المادة أن القاضي يسترشد بطبيعة الالتزام لإكمال نطاق العقد ووفقاً للقانون والعرف والعدالة، إلا أن تحديد نطاق العقد يستلزم كيف يمكن تحديد ماهية العقد وتحديد نطاقه.

**أولاً: بيان ماهية العقد:**

أي تكييف العقد أو إعطائه الوصف القانوني الذي يتفق وما انصرفت إليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وهذه مسألة قانونية بحتة يقوم بها القاضي غير مقيد بالوصف الذي أسبغه المتعاقدان على العقد، فكثيراً ما يسمى المتعاقدان العقد إيجاراً، ثم يتبين للقاضي أن العقد في حقيقته وديعة أو العكس، كما يمكن إيجار الخزائن الحديدية في البنوك للعملاء، لإيداع أموالهم فيها؛ فالقاضي هنا يعطي العقد الوصف القانون الصحيح له، ويطبق عليه أحكام هذا العقد الصحيح، وهو يقوم بذلك من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه الخصوم ذلك؛ لأن التكييف مسألة قانونية لازمة لمعرفة القواعد القانونية واجبة التطبيق على العقد[2] .

---

(1) د/ اسماعيل غانم –المرجع السابق ص ٣١٠، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣٥٣ ، د/ سليمان مرقص –السابق ص ٣٤٦.

(2) السنهوري – السابق ص ٨٣٧ – ٨٤١ ، د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٧٢ ، شنب السابق ص ٢٤٨ ، د/ سليمان مرقس – السابق – الموضع السابق .

**ثانياً**: **نطاق العقد**:

وإذا ما استطاع القاضي إسباغ الوصف القانوني على العقد استطاع بعد ذلك أن يحدد الالتزامات المترتبة عليه وبيان نوعها ومداها، ذلك أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة[1].

فالقاضي يضيف إلى التزامات المتعاقدين التي وردت بالعقد ما تقضي به القواعد المكملة سواء كانت قواعد تشريعية أم عرفية، فالبائع والمشتري قد يكتفيان عند البيع بذكر الالتزام بنقل الملكية والالتزام بالوفاء بالثمن، ولكن البائع يلتزم فوق ذلك بتسليم المبيع إلى المشتري وضمان انتفاعه به انتفاعاً هادئاً أخذاً من أحكام القواعد القانونية المكملة الواردة ضمن التنظيم الخاص بقواعد عقد البيع في القانون المدني.

كما أن القاضي يستطيع أن يقضي بما تقضي به قواعد العدالة، فمن يبيع متجرا – مثلًا – يلتزم أن يسلم المشتري المستندات الدالة على ما للمتجر من حقوق، وما عليه من ديون، كما يلتزم ألا ينافس المشتري منافسة تؤدي إلى انتزاع عملاء المتجر.

## المطلب الثاني
## القوة الملزمة للعقد

وسوف نقسم هذا الملطلب إلى فرعين على النحو التالي:

### الفرع الأول
### ضوابط المبدأ العام فى الالزام بالعقد

**العقد شريعة المتعاقدين:**

المبدأ العام فى الالزام بالعقد: "العقد شريعة المتعاقدين"؛ إذ تنص المادة ١/١٤٧ من التقنين المدني المصري على أن: "العقد شريعة المتعاقدين،

(1) نقض مدني في ٢٤ /٢/ ١٩٧٩ – مجموعة أحكام النقض س ٤٤ ق طعن رقم ٦٢٩ .

فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون".

ومقتضى هذه المادة أن القاضي عليه أن يطبق شروط العقد كما لو كان يطبق قانونا[1]، لأن العقد يقوم مقام القانون فى تنظيم علاقة المتعاقدين.

والنتيجة المباشرة لمبدأ القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين هي أن العقد لا يجوز نقضه إلا باتفاق الطرفين.

كما لا يجوز للقاضي أن يعدل فى شروط العقد، أو ينقض عقد صحيحا بحجة أن ذلك تقتضيه العدالة؛ فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين، لكن لا تنسخها إلا بناء على حكم القانون.

وإذا كان هذا هو الأصل إلا أن هناك أحوالا ينص فيها القانون على أنه يجوز لأي من المتعاقدين أن يستقل بإنهاء العقد كما هو الحال فى الوكالة ( م ٧١٥ ،٧١٦ مدني مصري ) والوديعة (م ٧٢٢) والعقود الزمنية التي لم تحدد لها مدة كعقد الشركة ( م٥٢٩) وعقد الايجار (م ٥٦٣) وعقد العمل (م ٢/٦٩٤ مدني مصري)

كما أن هناك احوال استثنائية ينص فيها القانون على تخويل القاضي سلطة تعديل العقد[2]، ومن هذا القبيل سلطة القاضي فى تعديل الشرط الجزائي طبقا للمادة ٢/٢٣٤ مدني مصري إذا كان مبالغا فيه ولم يوضع إلا على سبيل التهديد لإكراه المدين على الوفاء، وسلطته طبقا للمادة ٣٤٦ فى منح المدين أجلا للوفاء بالتزامه، ( نظرة الميسرة ) وسلطة القاضي فى تعديل أجرة الوكيل وفقا للمادة ٧٠٩ من القانون المدني المصري [3].

---

(١) انظر فيما سبق :د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٧٣ ،د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٢٥١ ، د/ إسماعيل غانم –المرجع السابق ص ٣١٠ –٣١١.

(٢) انظر: في هذا الموضوع بوجه خاص: رسالة الدكتور / سمير تناغو في الالتزام القضائي – رسالة من باريس ١٩٦٤ طبعة ١٩٦٥.

(٣) انظر: في حق القاضي في تعديل أجر الوكالة المتفق عليها سواء بتخفيضه أو الزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسبا نقض مدني في ٢/٢٦/ ١٩٧٠–مجموعة أحكام النقض–س٢١ – رقم ٥٣ ص ٣٢٩.

**تنفيذ العقد يجب أن يتم بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية**:

يجب على المتعاقد أن ينفذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومبدأ حسن النية عام يسود جميع العقود، وهو يقيد المدين فى طريقة تنفيذ التزاماته، كما يقيد الدائن فى طريقة المطالبة بحقه،[1] ومن تطبيقات هذا المبدأ أنه إذا تعددت الوسائل التي يمكن سلوكها لتنفيذ العقد، وجب اتباع الطريق الأصلح للمتعاقد الآخر، فالمقاول الذي يتعهد بتوصيل أسلاك الكهرباء إلى محل معين، دون أن يتضمن العقد بيان الطريق الذي يجب أن تمد فيه، عليه أن يقوم بتوصيلها من أقرب طريق ممكن، والناقل عليه أن ينقل البضاعة من الطريق الأصلح بالنسبة إلى صاحبها سواء من حيث طوله، أم من حيث مدى الخطر الذي يتعرض له أثناء النقل، كما أن على الدائن أن يراعى حسن النية في المطالبة، فلا يتمسك بحرفية شرط العقد، فإذا التزم مقاول بتركيب أدوات من "ماركة معينة"، وتعذر الحصول عليها، إلا بنفقات باهظة وجهود مضنية، فليس لدائن أن يرفض قبول أدوات من ماركة أخرى إذا كانت لا تقل عنها في الجودة[2] .

**وأخيرا:** يجب التنويه إلى أن حسن النية يقتضي التعاون بين الطرفين في تنفيذ العقد، ويبدو واجب التعاون واضحا بوجه خاص في بعض العقود التي تقوم على الثقة بين الطرفين، أو تقتضي علاقة مستمرة بينهما[3]، كعقد الشركة وعقد التأمين،

---

(١) د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ١٧٤ ، علما بأن سوء النية في تنفيذ العقد ، يعتبر في الواقع من قبيل " الغش " وهو يقابل التدليس عند تكوين العقد فهما في حقيقتهما شئ واحد [د/ عبد المنعم الصدة –السابق ص ٣٥٥].

(٢) انظر في ذلك: السنهوري – السابق ص ٨٤٩ ، د/ عبد الودود يحيي – السابق – الموضع السابق –د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣٥٥.

(٣) انظر: د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣١٣ ،د/ أنور سلطان – السابق ص ٣٧٨ ،د/ عبد الفتاح عبد الباقي – السابق ص ٢٩٨ .

وعقد الوكالة.

وبعد العرض السابق لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب تنفيذه بحسن نية، نود التنبيه على أن أهم الحالات التي خول القانون للقاضي فيها سلطة تعديل العقد حالتان:

**الأولى:** خاصة بعقود الإذعان؛ حيث يجوز للقاضي تعديل الشروط التعسفية التي قد يتضمنها العقد، بل وأن يعفي الطرف المذعن منها وفقا للمادة ١٤٩ مدني مصري.

**الثانية:** هي حالة الحوادث الطارئة حيث يجوز للقاضي أن يعدل العقد فيرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ولما كنا قد تناولنا عقد الإذعان فيما سبق فلا نعود إليه، ونقتصر في هذا الموضوع على دراسة نظرية الظروف الطارئة في الفرع التالي.

## الفرع الثاني
## نظرية الحوادث الطارئة

### أولًا: تعريف بنظرية الحوادث الطارئة:

مقتضى هذه النظرية: أنه إذا ما طرأت بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه حوادث لم تكن متوقعه، ترتب عليها إخلال التعادل بين التزامات المتعاقدين إختلالا فادحا بحيث أصبح التزام أحدهما مرهقا يهدده بخسارة جسيمة، فعندئذ يجوز للقاضي أن يتدخل لتعديل التزامات الطرفين – وليس لإعفاء المدين من التزامه – على الوجه الذي يرد به الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

مثال ذلك: عقد توريد حدد فيه سعر السلعة التي تعهد بتوريدها العاقد على أساسا الأسعار السائدة وقت إبرام العقد، ثم يحدث حادث غير متوقع، كحرب مثلا، أو حدوث كارثة طبيعية كصقيع مفاجئ أهلك معظم المزروعات المنتجة للسلعة

المتفق علي توريدها، وترتب على ذلك ارتفاع فاحش في الأسعار، بحيث يصبح تنفيذ المدين (المورد) لعقد التوريد بالسعر المتفق عليه يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر التجارة[1]، وهنا يجوز للقاضي أن يوزع تبعة الحادث الطارئ أو الكارثة بين طرفي العقد، وذلك برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

**ثانيًا: شروط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة:**

تنص المادة ٢/١٤٧ من التقنين المدني المصري على أنه: "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".

ويستبين من النص السابق أنه يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة توافر الشروط الآتية:

**الشرط الأول: يجب أن تكون بصدد عقد متراخي التنفيذ:**

أي يجب أن يكون التنفيذ واجبا فور إبرام العقد، ويتحقق ذلك في العقود الزمنية دورية التنفيذ، كعقد التوريد الذي يستغرق وقتا من الزمن، كما يتحقق في العقود الفورية التي يستغرق التنفيذ فيها وقتا طويلا كعقد المقاولة، والعقود مؤجلة التنفيذ كعقد بيع أجل فيه دفع الثمن ما دام هناك وقت بين إبرام العقد وتنفيذه.

ويجب ألا يكون تراخي التنفيذ راجعا إلى خطأ المدين، فإذا التزم المدين بالقيام بعمل معين وتأخر في تنفيذ التزامه دون مبرر غلى أن وقع الحادث الطارئ، فلا

---

(١) د/ إسماعيل غانم: مرجع سابق، ص٣١٤، وانظر في مضمون هذه النظرية تفصيلًا: د/ السنهوري: مرجع سابق، ص٨٥١ وما بعدها، ود/ حشمت أبو ستيت: مرجع سابق، ص٣١٦، ود/ عبد الحي حجازي: مرجع سابق، ص٣٠٦-٣١٧.

تطبق النظرية المدين لا يجوز له أن يستفيد من تقصيره ويجب ألا يكون العقد من العقود الاحتمالية كعقد التأمين وعقود المضاربة في البورصة، لأن طبيعة هذه العقود تجعل أحد المتعاقدين متعرضا للخسارة أو الربح[1].

**الشرط الثاني: أن يطرأ حادث استثنائي عام وغير متوقع:**

والمراد بكونه استثنائيا أن يندر وقوعه كالزلازل والحرب وانتشار وباء عام، أو فرض تسعيره جبرية أو إلغائها، أو استيلاء إداري، أو حدوث فيضان كبير غير مألوف، أو غارة لأسراب هائلة من الجراد بأعداد كبيرة على غير المألوف.

ويجب أن يكون الحادث استثنائي عاما، والحادث الطارئ يكون عاما إذا انصرف أثره إلى عدد كبير من الناس وغير معنيين بذواتهم، ومن ثم لا يكون الحادث عاما إذا كان خاصا بالمدين، كإفلاسه أو مرضه أو حرق بضاعته أو هلاك محصوله، فشيء من ذلك لا يكفي لتطبيق النظرية[2] .

**الشرط الثالث: أن يكون الحادث الطارئ غير متوقع الحصول وقت إبرام العقد:**

فإذا كانت الحوادث الاستثنائية متوقعة أو كان يمكن توقعها وقت إبرام العقد، فلا سبيل حينئذ لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة [3]، ففيضان النيل لا يعد حادثا متوقع الحصول إلا إذا كان فيضانا استثنائيا، واختلاف سعر العملة بين وقت وآخر، وانتشار دودة القطن كلها حوادث في الوسع توقعها [4]، ومن ثم فلا أثر لكل ذلك في العقود المبرمة، على أنه يلاحظ – بحق– أن كون الحادث استثنائيا يمكن أن يغني عنه شرط (عدم التوقع)؛ إذ الحادث الذي لا يمكن توقعه يكون في ذات الوقت

---

(١) انظر: السنهوري – السابق ص ٧٨٣ ، ود/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣٦٣ .

(٢) د/ حشمت ابو ستيت – السابق – الموضع السابق ،د/ جميل الشرقاوي – السابق ص ٣١٦.

(٣) نقض مدني في ١٩٧٤/١٢/٣ – مجموعة أحكام النقض – س ٢٥ رقم ٢٢٥ ص ١٣١٥.

(٤) انظر: نقض مدني في ١٩٦٧/١١/٨ – المجموعة السابقة س ١٨ رقم٢٨٢ ص ١٨٦.

حادثا استثنائيا[1]، كما يلاحظ أن الظروف تكون غير متوقعه إذا لم يكن في وسع أي شخص عادي أن يتوقع حصولها.

ومعيار التوقع وعدمه، معيار موضوعي لا شخصي أي يعتد فيه بالشخص العادي لا بشخص المدين[2] وتقرير هذا الأمر مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع[3] متى أقام قضاءه على أسباب سائغة[4] .

**الشرط الرابع: أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة:**

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يترتب على الحادث الطارئ أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحه، ومن ثم فالحادث الطارئ لا يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا بل مرهقا فحسب، وهنا يتجلى الفرق بين الحادث الطارئ، والقوة القاهرة، فهما وإن كانا يشتركان في أن كلا منهما لا يمكن توقعه، ولا يستطاع دفعه، إلا أنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ولذلك يترتب عليها انقضاء الالتزام ولا يتحمل المدين تبعه عدم تنفيذه، أما الحادث الطارئ فهو يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا فقط، ولذلك لا ينقضي الالتزام بل يرد إلى الحد المعقول[5]، فتتوزع الخسارة بين المدين والدائن ويتحمل المدين شئيا من تبعة الحادث.

---

(١) د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٣١٨- ٣١٩.

(٢) د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٦٠ ،د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٧٨.

(٣) نقض مدني في ٣/٤/ ١٩٧٥، مجموعة أحكام النقض س٢٦ ص٥١٥.

(٤) نقض مدني في ١٨/ ٢/١٩٦٥ – المجموعة السابقة – قاعدة رقم ٢٠ ص ١٩١ .

(٥) انظر: السنهوري – السابق ص ٧٨٤-٧٨٥ ،د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٣١٨ ،د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٧٨ ، د/حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٣١٩ ،د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣٦٥ ، د/ سمير تناغو – السابق ص ١٦٢.

ومعيار الخسارة هنا ليس معيارا شخصيا[1]، بل هو معيار موضوعي ينظر فيه إلى الشخص العادي وما يعتبر خساره بالنسبة له، فإذا تحققت الخسارة على هذا النحو طبقت النظرية حتى ولو كان المدين ثريا لا تؤثر فيه هذه الخسارة، بل وحتى ولو كان المدين هو الحكومة نفسها التي لا تؤثر الخسارة في ميزانيتها الضخمة، فلو أن المدين كان يحتفظ في مخازنه بكميات كبيرة من البضائع التي تعهد بتوريدها دون أن يتوقع علو السعر ودون وجود صلة بين هذا التخزين وبين التزامه بتلك الصفقة، ثم علا السعر كثيرا لحادث طارئ فإن هذا الظرف الخاص المواتي للمدين – ظرف التخزين– لا يعتد به في تقدير الخسارة، ويعتبر تنفيذ الالتزام هنا أيضا مرهقا للمدين؛ لأن تخزين كميات كبيرة من السلعة المتعهد بتوريدها لا يعدوا أن يكون ظرفا خاصا لا يعتد به في تقدير الارهاق [2].

**ثالثًا: أثر توافر شروط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة :**

إذا توافرت شروط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة على النحو السابق جاز للقاضي – تبعا للظروف– وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، فكان أثر الحادث ينحصر في أن القانون يخول للقاضي سلطة تعديل العقد[3]، دون أن يسمح له بفسخ العقد، والقاضي له في معالجة الموقف سلطة واسعة فقد يقضي بإنقاص التزامات أحد العاقدين، وقد يقضي بزيادة التزامات المتعاقد

---

(١) انظر مجموعة الأعمال التحضيرية ج٢ ص ٢٨١ وفى هذا المعنى: نقض مدني في ١١/١٠/ ١٩٥٥ ، مجموعة أحكام النقض س ٦ – رقم ١٩٩ ص ١٤٧٣.

(٢) د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٣١٨ ، وانظر في ذلك تفصيلا: السنهوري –السابق ص ٧٨٧ –٧٨٩، د/ لبيب شنب – السابق ص ١٦١ ، د/ سمير تناغو – السابق ص ١٦٣.

(٣) وهي سلطة تجاوز سلطاته العادية ، فهولا يملك في الاصل إلا تفسير عبارات العقد الغامضة دون أن يتناول بالتعديل ما سبق للطرفين الاتفاق عليه .

الآخر، وقد يقضي بإيقاف وتنفيذ العقد، وهو يختار من هذه الوسائل ما يرى أنه يرد الالتزام إلى الحد المعقول.

أ- فقد يرى القاضي إنقاص أو تخفيف الالتزام المرهق، فيقضي مثلا بإنقاص الكمية المتعاقد عليها إلى المقدار الذي يراه مناسبا.

ب- وقد يرى زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق – بزيادة السعر مثلا-، وفى هذه الحالة يجب عليه أن يبقى على عاتق المدين ما يعتبر "زيادة مألوفة " في عبئ الالتزام، فلا يوزع على عاتق الطرفين سوى الزيادة غير المألوفة؛[1] لأن سلطة القاضي في تعديل العقد وفقا لنظرية الظروف الطارئة، تنحصر في أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وليس له حق رفع كل خساره على عاتق المدين؛ إذ لو فعل ذلك لأدى إلى إصابة الدائن بخسارة فادحة والهدف من النظرية هو منع إصابة أي طرف من الطرفين بمثل هذه الخسارة [2].

وتطبيقا لذلك لو فرض أن سعر أردب القمح المتفق عليها هو ١٥٠ مائة وخمسون جنيها، ثم ارتفع إلى ثلاثمائة جنية، فإن الفرق بين السعرين يعد زيادة غير مألوفة، إذ المألوف أن يرفع سعر الأردب إلى ٢٠٠ – مائتي جنيه، فلا تعتبر زيادة غير مألوفة إلا مائة جنية يوزعها القاضي على الطرفين، أي يلتزم المدين بأن يورد القمح المتفق عليه بسعر الأردب ١٥٠ + ٥٠ (نصف الزيادة غير المألوفة) ويكون الدائن بالخيار بين أن يقبل الثمن الجديد أو يطلب فسخ العقد.

ج- وأخيرا قد يرى القاضي أن خير وسيلة هي وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ إذا كان الحادث وقتيا وينتظر زواله[3]، فإذا تعهد مقاول بإقامة

---

(١)د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٣٨٠ ،د/ سمير تناغو – السابق – الموضع السابق – د/ جميل الشرقاوي – السابق ص ٣١٨، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٣٦٧.

(٢) د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٦١، د/ محمود جمال الدين زكي – المرجع السابق ص ٣٢.

(٣) راجع السنهوري- اسابق ص ٨٧٩ ،د/ عبد الفتاح عبد الباقي –السابق ص ٣١٠ -٣١١.

مبنى، ثم ارتفعت أسعار مواد البناء ارتفاعا فاحشا نتيجة لحادث طارئ ولكنه ارتفاع يوشك أن يزول لقرب زوال سببه، فإن القاضي يمكنه أن يحكم بوقف إقامة البناء مؤقتا إذا كان لا يلحق ضررا جسيما بصاحب المبنى[1] .

د- وفى جميع الأحوال ليس للقاضي أن يحكم بفسخ العقد إجابة لطلب المدين وإلا كان في هذا تحميل أثر الحادث الطارئ للدائن وحده، وهذا ما لا يجوز، ولكن يجوز للدائن أن يطلب فسخ العقد دون تعويض إذا لم يشأ أن يقبل تعديله، لأن الدائن إذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدين، حيث يرتفع عن عاتقه كل أثر للحادث الطارئ[2].

هـ- يلاحظ أن سلطة القاضي في تعديل العقد نتيجة للحادث الطارئ هي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق مقدماً على استبعاد سلطة القاضي في التعديل، وإذا حدث ذلك كان الاتفاق باطلاً، حيث نصت المادة ٢/١٤٧ على أنه: "... يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك".

و- أخيراً: يجب ملاحظة أنه إذا كان العقد من العقود المستمرة، أو دورية التنفيذ، وعدل القاضي فيه نظراً لقيام الحادث الطارئ، ثم زال هذا الحادث الذي استوجب التعديل قبل انتهاء مدة العقد: وجب إلغاء التعديل لزوال الحادث الطارئ، والعودة إلى حكم العقد وفقاً لما كان متفقاً عليه بين المتعاقدين[3].

---

(١) د/ عبد الودود يحيي – السابق ص١٨٠.

(٢) د/ إسماعيل غانم – السابق ص ٣١٩ ، د/ الصدة – السابق ص ٣٦٨.

(٣) راجع السنهوري – السابق ص ٨٨١ ، د/ بد الرازق فرج – السابق ص ٣٨٨ .

# الفصل الرابع
# زوال العقد بالفسخ

**التعريف بالفسخ:**

الفسخ هو: حل الرابطة العقدية التبادلية بعد نشوءها صحيحة كحق يعطي لكل من المتعاقدين كي يتحلل من التزامه متى تخلف المتعاقد الآخر عن الوفاء بالتزامه المقابل[1]، وقد نصت على ماهية الفسخ المادة ١/١٥٧ من التقنين المدني المصري بقولها: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض".

وعلى هذا فإن للمتعاقد أن يلجأ – إذا شاء – إلى التنفيذ العيني لاستيفاء حقه عيناً أو بطريق التعويض، ولكن هذه الوسيلة قد تأخذ من الجهد والعناء ما لا طاقة للمتعاقد به، فيلجأ إلى طلب الفسخ ليتحلل من الالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمها، كما أن له أن يلجأ إلى الدفع بعدم التنفيذ، غير أن هذا الإجراء لن يجديه شيئاً مادام قد قام من جانبه بتنفيذ التزامه، ولا زال يشكو من إخلال الطرف الآخر بالتزامه، ومن ثم فلا سبيل أمامه إلا الالتجاء إلى فسخ العقد[2]، ومن ثم فإن الفسخ وسيلة من وسائل انقضاء الرابطة العقدية لاستحالة تنفيذ الالتزام، أو للامتناع عن تنفيذه أو الإخلال بأحكامه، فهو ذو طبيعة مزدوجة، إذ أنه وسيلة من وسائل

---

(١) مؤلفنا – انقضاء العقد بالإلغاء والرجوع – رسالة من جامعة الأزهر عام ١٩٨٣ – على الآلة الكاتبة لنيل درجة الدكتوراه ص ٧٧ ، وانظر في تعريفات الفسخ د/ حشمت أبو ستيت السابق ص ٣٣٩ ، د/ إسماعيل غانم – السابق ص ٣٢٤.

(٢) د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٢٥ – د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٥٦ ، وانظر: رسالتنا السابقة ص ٧٨ .

الضمان بالنسبة للدائن، وفي ذات الوقت يعتبر جزاءً قانونياً يوقع على المدين لعدم قيامه بتنفيذ التزامه[1].

والفسخ يعتبر عملاً من أعمال التصرف، إذا انصب على عقد من عقود التصرف، ويعتبر عملاً من أعمال الإدارة إذا انصب على عمل من أعمال الإدارة، ويلزم من هذا القول أن الأهلية اللازمة لاستعمال حق الفسخ، ورفع الدعوى به هي الأهلية اللازمة لإبرام العقد المراد فسخه[2].

**أنواع الفسخ:** سبق أن ذكرنا أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد ليتحلل من التزامه، والأصل أن الفسخ يكون بحكم القضاء، ولكن قد يتفق المتعاقدان ابتداء – بواسطة شرط فى العقد – على أن يكون العقد مفسوخا إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ التزامه، وهذا هو الفسخ الاتفاقي.

وقد يقع الفسخ بحكم القانون وهذا هو الانفساخ، وسنعالج كل نوع من هذه الأنواع فى مبحث مستقل:

## المبحث الأول

## الفسخ القضائي (الفسخ بحكم القضاء)

### شروط المطالبة بالفسخ:

تنص المادة ١٥٧ من التقنين المدني المصري على أنه: "١- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتض.

---

(١) انظر رسالتنا السابقة ص ٧٨ .

(٢) راجع د/ حسن الزنون في رسالته سابق الإشارة إليها ص ٢٤، ٢٥ .

٢- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته".

ويستبين من هذا النص أن شروط المطالبة بالفسخ هي:

**الشرط الأول: أن يكون العقد ملزماً للجانبين:**

وهذا شرط عام في كل أنواع الفسخ، سواء كان فسخاً قضائياً، أو اتفاقياً أم قانونياً؛ لأن الفسخ بجميع أنواعه يقوم على فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة[1]، أو على فكرة العدالة[2]، والالتزامات المتقابلة لا تكون إلا في العقود الملزمة للجانبين، والفسخ حق يثبت لكلا العاقدين بمقتضى نص القانون، ويعتبر العقد متضمناً له حتى ولو لم يشترطه العاقدان، ومن ثم لا يجوز حرمان المتعاقدين ولا أحدهما من هذا الحق، أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح من المتعاقدين. [3]

أما العقود الملزمة لجانب واحد كعقد الهبة بدون عوض والكفالة والوديعة إذا كانتا بغير أجر، فإن الفسخ لا يرد عليها، لأن الدائن الذي يتضرر من عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه لا يلتزم بشيء، ومن ثم ليست له مصلحة في طلب الفسخ، وإنما يكون له – فقط – أن يطالب بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً إذا كان ذلك ممكناً، وإلا لجأ إلى التنفيذ بمقابل[4].

---

(١) د/ عبد الرزاق السنهوري – السابق ص ٩٥٥ ، د/ أنور سلطان – السابق ص ٤١٢.

(٢) قارن د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٢٧.

(٣) انظر في ذلك د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ٩١ ،د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٢٩٧ ، عبد المنعم الصدة – السابق ص ٤٣٠.

(٤) د/ السنهوري – السابق ص ٦٥٦ ، د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٩٦ ، د، محمود جمال الدين زكي – السابق ص ٣٩٩ ، د/ جلال العدوي –السابق ص ٢٥٠.

ويلاحظ – أخيراً – أن كل العقود الملزمة للجانبين يرد عليها الفسخ بلا استثناء[1]، وإن كان الملاحظ هنا، أن العقد الزمني – كعقد الإيجار – وهو عقد ملزم للجانبين، وإن كان يرد عليه الفسخ، إلا أن أثر الفسخ فيه يختلف عن أثر الفسخ في العقد الفوري[2].

**الشرط الثاني: ألا يقوم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه:**

يشترط للمطالبة بفسخ العقد أن يكون أحد المتعاقدين قد أخل بتنفيذ التزامه كله أو نفذه بطريقة لا تتفق مع ما اتفق عليه المتعاقدان، أو نفذه بعد فوات الوقت المحدد للتنفيذ، ولم يكن ذلك راجعاً إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، هذا يجوز للمتعاقد الآخر أن يطالب بفسخ العقد، كأن يمتنع البائع عن تسليم المبيع أو ملحقاته للمشتري ... إلخ، فإذا كان عدم التنفيذ راجعاً إلى استحالته سبب لا يد للمدين فيه، فإن الالتزام ينقضي وينفسخ العقد بقوة القانون[3]، أي أن المطالبة بالفسخ تستوجب أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ المدين.

**الشرط الثالث: أن يكون المتعاقد الذي يطلب الفسخ قد نفذ التزامه، أو يكون مستعداً لتنفيذه:**

فإذا كان أحد المتعاقدين لم ينفذ التزامه، وليس مستعد لتنفيذه فإنه يعد مقصرا، ولا يجوز له أن يطلب فسخ العقد استنادا إلى عدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه، فمن اشترى شقة ولم يدفع ثمنها للمالك بسبب عدم تسليمها له ومستنداتها وجب أن يكون

---

(1) د/ حشمت أبو ستيت – السابق – الموضع السابق ،د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٣٣٧ ، ولنفس المؤلف الحقوق العينية الأصلية – الطبعة الثانية ١٩٦١ بند ١٢٢ .

(2) السنهوري – السابق –الموضع السابق .

(3) انظر: د،/ اسماعيل غانم – مصادر الالتزام ص ٣٢٧ ،د/ أنور سلطان – السابق ص ٤١٥ ، والبدراوي – السابق ص ٤٩٤.

قد دفع الثمن أو على الأقل مستعدا لدفعه، وإلا لم يكن له حق المطالبة بالفسخ [1].

**الشرط الرابع: أن يكون طالب الفسخ قادرا على إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد:**

**ومؤدي هذا الشرط:** أن طالب الفسخ إذا لم يكن قادرا على رد الشئ إلى أصله، فلا حق له فى طلب الفسخ، فإذا كان قد تسلم شيئا بموجب العقد واستهلكه أو تصرف فيه، فليس له أن يطلب الفسخ، لأنه طبقا لالتزامه بالضمان قبل المشتري (ضمان التعرض والاستحقاق) لا يستطيع أن يسترد الشئ منه لإعادته إلى الطرف الآخر [2] .

**الشرط الخامس: أن يقوم طالب الفسخ بإعذار المدين:**

وذلك قبل رفع دعوي الفسخ، إلا أن هذا لا يعني أن دعوى الفسخ لا تقبل إذا ليسبقها إعذار المدين، فحتى عند عدم الإعذار تقبل الدعوى؛ لأن رفع الدعوى يعتبر إعذارًا، إلا أن الدائن إذا رفع دعوى الفسخ بلا إعذار فإنه يتحمل مصاريفها إذا بادر المدين إلى التنفيذ بمجرد إعلانه بصحيفتها، هذا فضلا عن أن إعذار المدين قبل رفع دعوى الفسخ يجعل القاضي أسرع إلى الاستجابة لطلب الفسخ، والحكم بالتعويض على المدين.[3]

والإعذار يتم بتكليف المدين بالوفاء بما عليه من التزامات فى صورة ثابته بإنذار على يد محضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو المبين فى

---

(١) انظر في ذلك السنهوري – السابق ص ٩٦٢ ، د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٩١.

(٢) د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٤٣٢ ن وانظر :د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٣٢٨ ،د/ سمير تناغو –السابق ص ١٩١ .

(٣) د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ٢٩٨ ، وانظر د/ الصدة –السابق ص ٤٣٢ ، د/ لبيب شنب – السابق ص ٢٩٨.

قانون المرافعات، ويجوز أن يتفق المتعاقدان على أن المدين يعتبر "معذرا" بمجرد حلول الأجل دون أي إجراء آخر[1].

وهذه الشروط كلها جمعتها المادة ١٥٨ مدني مصري السابق ذكرها.

**كيف يتم الفسخ القضائي:**

إلى جانب إعذار المدين على النحو السابق بيانه فإنه لابد من رفع دعوى، وصدور حكم بالفسخ، وهذا ما يفرق بين الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي، والفسخ بحكم القانون؛ إذ أن الفسخ بحكم الاتفاق، وكذلك الانفساخ بحكم القانون، يكون الحكم مقررا للفسخ لا منشأ له أما الفسخ بحكم القضاء، فالحكم فيه منشئ للفسخ.[2]

وإذا رفع المدين دعوى الفسخ فإن الحكم به لا يكون وجوبيا[3]، بل يظل الخيار موجودا بين الفسخ والتنفيذ وهذا الخيار يكون لكل من الدائن، والمدين، والقاضي:[4]

فللدائن بعد رفع دعوى الفسخ أن يعدل عنه ويطلب التنفيذ قبل الحكم، وعندئذ لا يجوز للقاضي أن يحكم به، إلا أنه لا يجوز له الجمع بين طلب الفسخ وطلب التنفيذ.

والمدين إذا رفعت عليه دعوى الفسخ يمكنه أن يتفادى الحكم به إذا قام بتنفيذ التزامه، ومن ثم لا يبقى للقاضي إلا الحكم بالتعويض عن التأخير فى التنفيذ.

كما أن القاضي له سلطة تقديرية فى الحكم بالفسخ فقد يحكم به وقد يرفضه إذا رأى أن الظروف تبرر ذلك، كما لو رأي أن المدين قد نفذ الجزء الأكبر من التزاماته،

---

(١) انظر المادة ٣١٩ مدني مصري .

(٢) د/ عبد الرزاق السنهوري – السابق ص ٩٦٥ ، د/ عبد المنعم الصدة –المرجع السابق ص ٤٧٤ ، د/ سمير تناغو – السابق ص ١٩٠ .

(٣) راجع في ذلك :د/ جميل الشرقاوي – السابق ص ٣٨٠ ، د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٣٢٩ ، الصدة – السابق ص ٤٣٣.

(٤) انظر: نقض مدني في ٣/١٧/ ١٩٧٠ – مجموعة أحكام النقض س ٢١ ص ٤٥٠ .

فيكتفي القاضي بالحكم بتنفيذ الجزء الباقي عينا أو بمقابل[1]، إذا رأى أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه راجع إلى مبرر معقول، وأن الدائن لم يصبه إلا ضرر يسير من جراء عدم التنفيذ[2]، كما أن القاضي يجوز له أن يمنح المدين أجلا للتنفيذ إذا رأى أن الظروف تستلزم ذلك[3]، ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا انقضت هذه المهلة دون تنفيذ، كما أن للقاضي أن يرفض الحكم بالفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته كما يقول النص.

ويجب التنويه أخيرا إلى أن دعوى الفسخ تتقادم طبقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت ثبوت الحق فى الفسخ[4]، كما أن الفسخ ذاته يسقط – طبقا للقواعد العامة بنزول العاقد عنه صراحة أو ضمنا[5].

## المبحث الثاني

## الفسخ الاتفاقي (الفسخ بمقتضى الاتفاق)

### كيف يقع الفسخ بمقتضى الاتفاق:

تنص المادة ١٥٨ من القانون المدني المصري على أنه: "يجوز الاتفاق على أن

---

(١) نقض مدني في ١٢/٢٣ / ١٩٦٩ م –مجموعة أحكام النقض س ٢٠ ص ١٢٩٦ ، نقض مدني في ١٦ / ١٠ / ١٩٧٢ – المجموعة السابقة س ٢٣ ص ١٢٢٠ .

(٢) انظر السنهوري – السابق ص ٩٧١ وما بعدها ، د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ١٩٣، د/ حشمت أبو ستيت – السابق .

(٣) انظر في ذلك: نقض مدني في ٢٦/ ١٠ / ١٩٧٢ – مجموعة أحكام النقض المدني س ٢٣ رقم ١٩٢ ص ١٢٢٠.

(٤) انظر: السنهوري – السابق ص ٩٧٤ ، الصدة – السابق ص ٤٣٤ ،د/ أنور سلطان – السابق ص ٤٠٤ ، د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٣٤٩ .

(٥) ويعتبر من قبيل النزول الضمني عن الفسخ موافقة البائع . مثلاً . على تصرف المشتري في الجميع كأن يقوم بالشهادة على صحة هذه البيع .

يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الالتزام بالوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه".

ويستبين من هذا النص أن المتعاقدين قد يرغبا فى تجنب رقابة القضاء، وما تقتضيه هذه من إعذار، ورفع دعوى، فيتفقان– سواء فى العقد أو فى اتفاق لاحق، أو أثناء إجراءات التقاضي – على أن يقع الفسخ عند إخلال إحداهما بتنفيذ التزامه، فيحل الاتفاق محل الحكم، ويكون له أثره[1] وفقا لتفاوت درجة الشرط وذلك على النحو التالي:

١– إذا اتفق المتعاقدان على أن "العقد يعتبر مفسوخا إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه" فإن الشرط الفاسخ – على هذا النحو – ليس إلا ترديدا للقاعدة العامة فى الفسخ، فلا يغني عن رفع الدعوى، ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية، ولا يحرم المدين من حقه فى تجنب الفسخ بتنفيذ التزامه إلى أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ[2]، بل وللدائن أن يطلب التنفيذ بدلا من طلب الفسخ.

٢– إذا اتفق المتعاقدان على أن "العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه"، هذا الشرط يسلب القاضي سلطته التقديرية، فلا يملك إلا الحكم بالفسخ، ولكن يجب رفع دعوى الفسخ، ويجب الإعذار، والحكم الذي يصدر يكون منشئا للفسخ لا مقررًا له.

٣– إذا اتفق المتعاقدان على أن "العقد يكون مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم" فلا تكون هناك حاجة إلى رفع دعوى للحصول على حكم بالفسخ إلا أنه إذا نازع المدين فى توافر شروط الفسخ، فادعى أنه قام بتنفيذ التزامه، فيرفع النزاع

---

(١) على أن يراعى أن الحكم بالفسخ ينشئ الفسخ في حين أن الفسخ بالاتفاق يقرر الفسخ ولا ينشئه.

(٢) د. إسماعيل غانم . السابق، ص: ٣٣٠، د/ لبيب شنب . السابق ص: ٣٠٤، د/ جميل الشرقاوي . السابق ص ٣٨٩ ، الصدة، السابق: ٤٣٠ .

إلى القضاء، وليس للقاضي فى هذه الحالة إلا أن يتحقق من أن المدين قد أخل بالتزامه، فإن تحقق من ذلك حكم بالفسخ دون أن تكون له أي سلطة تقديرية، والحكم الذي يصدر يكون مقررًا للفسخ لا منشأ له.[1]

على أن هذا الشرط لا يعفي من إعذار المدين حتى يقع الفسخ[٢]، فإذا أراد الدائن إعمال الشرط وجب عليه تكليف المدين بالوفاء، وإذا لم يقم المدين بالوفاء بعد هذه الإعذار انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

٤- أن يتفق المتعاقدان على أن "العقد يكون مفسوحا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إعذار" وهذه العبارة هي: أقصى درجات شرط الفسخ، وبمقتضاها: يفسخ العقد بمجرد عدم التنفيذ فى الموعد المتفق عليه، وإذا اضطر الدائن إلى اللجوء إلى القضاء، فإن الحكم الذي يصدر يكون كاشفا عن الفسخ –فقط – لا منشئًا له.

ويلاحظ أنه حتى فى هذه الحالة يظل الدائن له حق الخيار بين طلب التنفيذ وطلب الفسخ، وإلا لأصبح زمام العلاقة التعاقدية فى يد المدين[٣]، إن شاء نفذ العقد وإن شاء امتنع عن التنفيذ، فيصبح العقد مفسوخا، ولذلك فإن العقد لا يعتبر مفسوخا إلا إذا تمسك الدائن بذلك.

---

(١) د. إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص: ٣٣١، د / عبد الودود يحيى ، السابق، ص: ١٩٥.

(٢) انظر: السنهوري، السابق، ص: ٩٩٠، وما بعدها، د/ عبد الحي حجازي في مقال سابق الإشارة إليه، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الثانية ص: ٢٦.

(٣) د/ عبد المنعم الصدة ، السابق، ص: ٤٣٦، د/ إسماعيل غانم ، السابق، ص: ٣٣٢، د / سمير تناغو، السابق، ص: ١٩٥، د/ لبيب شنب، السابق ص: ٣٠٦.

# المبحث الثالث
# انفساخ العقد وتحمل التبعة

**انفساخ العقد:**

تنص المادة ١٥٩ من التقنين المدني المصري على أنه: "فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه".

وتنص المادة ٣٧٣ مدني مصري على أنه: "ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه".

وتنص المادة ٢١٥ مدني مصري على أنه: "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه".

ويستبين من هذه النصوص أن الالتزام ينقضي إذا استحال تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، ويترتب على استحالة تنفيذ الالتزام انقضاء الالتزام المقابل، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه بقوة القانون[1]، ولذا سمي انفساخا.

**فالانفساخ:** هو انحلال رابطة العقد بقوة القانون بشروط مخصوصة مجملها: استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

ولما كانت الاستحالة لا ترجع إلى خطأ المدين[2]، فلا محل لإعذاره ولا حاجة

---

(١) راجع: السنهوري، السابق ص: ٩٩٨، وما بعدها، د/ سليمان مرقس، مصادر الالتزام، السابق، ص: ٤٤٧.

(٢) د/ إسماعيل غانم، المرجع السابق، الموضع السابق، د/ عبد الناصر العطار، المرجع السابق، ص: ١٦٢، د/ لبيب شنب، المرجع السابق، ص: ٣٠٦ وما بعدها.،

إلى حكم قضائي، ولا مجال لتقدير يمارسه القاضي، أو لخيار بين الفسخ والتنفيذ[1].

ويثور البحث بعد ذلك عمن يتحمل تبعة هذه الاستحالة من المتعاقدين؟ وهو ما سنعالجه فى البند التالي:

- **مبدأ تحمل التبعة:**

سبق أن ذكرنا أنه إذا استحال تنفيذ التزام المدين لسبب أجنبي، وانفسخ العقد تبعا لذلك – بقوة القانون – انقضى الالتزام المقابل، وهذا يعني أن المدين الذي استحال عليه تنفيذ التزامه، لا يستطيع أن يطالب المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه المقابل، ومن ثم فهو الذي يتحمل تبعة استحالة التنفيذ، ولذلك يقال أن تبعة الهلاك فى العقود الملزمة للجانبين تقع على عاتق المدين الذي استحال تنفيذ التزامه، فإذا كنا بصدد عقد بيع وهلك المبيع فى يد البائع بقوة قاهرة، فإن البائع هو الذي يتحمل تبعة هذا الهلاك، لأنه المدين بالتسليم، ويترتب على هذا انقضاء التزام المشتري بدفع الثمن[2] .

وفى العقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة، والهبة بدون عوض – تكون تبعة الهلاك على الدائن؛ إذ ينقضي الالتزام باستحالة تنفيذه، وليس فى ذمة الدائن التزام يتحلل منه فى مقابل تحلل المدين من التزامه، فيتحمل الدائن الخسارة فى النهاية، فإذا كان هناك وديعه بغير أجر، وهلك الشئ المودع، فإن الدائن (المالك) هو الذي يتحمل تبعة الهلاك، فيفقد ما كان له.

**وخلاصة القول**: أنه فى العقود الملزمة للجانبين تقع تبعة الاستحالة على المدين

---

(١) انظر: نقض مدني في ١٩٧٤/١١/١٢ . مجموعة أحكام النقض س ٢٥ رقم ٢٠٥، ص: ١٢١٣، نقض مدني في ١٩٧٧/٤/٥، المجموعة السابقة، س ٢٨ ص: ٩٠٩

(٢) انظر فيما سبق: السنهوري، السابق ص: ١٠٠٣، د / سليمان مرقس . تبعة الهلاك، بحث باللغة الفرنسية، مجلة القانون والاقتصاد، السنة السادسة، ص: ٣٢٧، د/ عبد الودود يحيى، السابق، ص: ١٩٨

بالالتزام الذي استحال تنفيذه لسبب أجنبي، وفى العقود الملزمة لجانب واحد تقع تبعة هذه الاستحالة على الدائن[1].

# المبحث الرابع
# آثار الفسخ

**زوال العقد بأثر رجعي:**

تنص المادة ١٦٠ من القانون المدني المصري على أنه: "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض".

ويستبين من هذا النص أن الفسخ إذا وقع سواء كان ذلك بحكم القاضي، أو بحكم الاتفاق، أو بحكم القانون[2]، فإن العقد يزول بأثر رجعي ويعتبر العقد كأن لم يكن، الأمر الذي يستلزم إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويزول كل أثر للعقد سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير:

**أولا: أثر الفسخ فيما بين المتعاقدين:**

يترتب على الفسخ أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا كان العقد الذي تقرر فسخه لم ينفذ منه شيئا، فلا يلتزم أي من المتعاقدين بشئ قبل الآخر، وإذا كان طالب الفسخ قد نفذ التزامه، والعاقد الآخر لم ينفذ التزامه، فإن الأول يسترد ما أوفى به إذا كان الاسترداد ممكنا، فيرد المشتري – مثلا – المبيع وثمرته، ويرد البائع الثمن وفوائده[3]، وإذا كان الرد عينا أصبح مستحيلا حكم

---

(١) د/ عبد المنعم الصدة، السابق، ص: ٤٤١.

(٢) السنهوري السابق، ص: ١٠٠٤، عبد الودود يحيى ، السابق، ص: ١٩٥، ١٩٨.

(٣) د/ عبد المنعم الصدة، السابق، ص: ٤٣٦، د / جميل الشرقاوي ، السابق، ص: ٣٨٥، د/ عبد الوجود يحيى ، المرجع السابق، ص: ١٩٦– ١٩٧ ، سمير تناغو، السابق ص: ١٩٣.

القاضي بالتعويض، فلو أن المبيع – مثلا– هلك فى يد المشتري بخطأ منه حكم عليه القاضي بتعويض يعادل قيمة المبيع وقت الهلاك وللدائن الذي طلب الفسخ – بالإضافة إلى استرداد ما أداه – أن يطالب المدين بتعويض تكميلي[1] إذا كان قد أصابه ضرر من جراء عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه، وهذا الضرر لا يكفي لإزالته مجرد الفسخ والاسترداد.

فإذا كان العقد بيعا، وفسخ العقد لعدم وفاء المشتري بالثمن، واسترد البائع المبيع، وكان سعر المبيع قد انخفض فى السوق عما كان عليه وقت إبرام العقد فإن الفسخ والاسترداد لا يكفي لإزالة الضرر الذي أصاب البائع، ومن ثم كان له فوق استرداد المبيع أن يطالب بتعويض عن فرق السعر، والتعويض فى هذه الحالة أساسه – وفقا للرأي الغالب فى الفقه القانوني – المسئولية بالمسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية[2]؛ إذ العقد بعد فسخه لا يصلح أن يكون أساسا للتعويض، وإنما أساس التعويض هنا خطأ المدين.

ويلاحظ انه فى عقود المدة – كقد الإيجار – لا يكون للفسخ أثر رجعي؛ لأن طبيعة هذه العقود تأبي أن يكون للفسخ فيها أثر رجعي؛ لأن الزمن فيها مقصود لذاته، فالزمن معقود عليه، وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه، ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار قبل فسخه تظل محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائما طوال هذه المدة، ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم النهائي بفسخه لا قبل ذلك، ومن ثم تكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجر، لا التعويض فيبقى لها ضمان امتياز المؤجر[3].

---

(١) انظر: المادة ١٥٧ / ١ مدني مصري.

(٢) د/ السنهوري، السابق، ص: ٩٧٨–٩٧٩، د/ حشمت أبو ستيت، المرجع السابق، ص: ٣٤٨.

(٣) السنهوري السابق، ص: ٩٧٨ – ٩٨٠.

**ثانيا: أثر الفسخ بالنسبة للغير:**

القاعدة أن أثر الفسخ بالنسبة إلى الغير كأثره فيما بين المتعاقدين، فالعقد الذي تقرر فسخه له أثره الرجعي بالنسبة للغير أيضاً، فإذا كان العقد بيعاً وباع المشتري العين إلى آخر، أو رتب عليها حق ارتفاق، ثم طالب البائع بفسخ البيع الأول، وأجيب إلى طلبه، رجعت العين إلى البائع خالية من كل حق عليها طبقاً لقاعدة قانونية شهيرة مؤداها: "أنه متى زال حق المتصرف زال حق المتلقي".

**على أنه يستثنى مما سبق حالتين:**

**الأولى:** يجب مراعاة القواعد المقررة لحماية الغير حسن النية، فإذا كان الشيء موضوع التعاقد منقولاً، كان للغير حسن النية إذا كان قد تسلم الشيء أن يتمسك بقاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية)، وإذا كان الشيء عقاراً، وجب تسجيل دعوى الفسخ على هامش تسجيل العقد المطلوب فسخه، وإلا لا يحتج بحكم الفسخ على الغير الذي يكون قد كسب حقه وسجله وهو حسن النية قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ[1].

**الثانية:** القاعدة أن الفسخ لا يؤثر في الحقوق التي تلقاها الغير بحسن نية بمقتضى عقد من عقود الإدارة، كالإيجار، فإن حق المستأجر يبقى رغم فسخ العقد[2].

---

(1) انظر: المادتين ١٥، ١٧ من قانون الشهر العقاري اللتين تحميان سائر الحقوق العينية العقارية متى تم شهرها قبل تسجيل دعوى الفسخ أو التأشير بها.

(2) د / إسماعيل غانم . السابق ٣٣٥ .

# الباب الثاني
# الإرادة المنفردة

**تمهيد:**

سبق أن ذكرنا أن مصادر الالتزام هي: العقد، والإرادة المنفردة والفعل غير المشروع، والإثراء بلا سبب والقانون، كما سبق أن بينا أن المصدرين الأولين هما المصدران الإراديان، والمصادر الثلاثة الأخيرة مصادر غير إرادية.

وسوف نتناول في هذا الباب مدى اعتبار الإدارة المنفردة مصدراً عاماً للالتزام وذلك من خلال فصلين:

## الفصل الأول
## الأحكام العامة للإرادة المنفردة

**أولًا: مدى صلاحية الإرادة المنفردة لتكون مصدراً للالتزام:**

اختلف الفقه القانوني حول مدى صلاحية الإرادة المنفردة لتكون مصدراً عاماً للالتزام، فقد ظل العقد حتى القرن التاسع عشر هو المصدر الوحيد للالتزام الإرادي، أما الإرادة المنفردة فهي لا تولد التزاماً، ولا زالت هذه القاعدة المستقرة في القضاء[١] والفقه[٢] الفرنسي، وهي التي كان يسري عليها القضاء المصري في ظل التقنين المدني القديم[٣].

وذهب رأي آخر يؤيده الفقه الألماني وفي مقدمتهم "سبيجل"[٤] إلى أن الإرادة المنفردة تصلح أن تكون مصدراً للالتزام شأنها في هذا شأن العقد بل إن بعضهم

---

(١) نقض فرنسي في ٢٩ / ٤ / ١٩٠٣ سيريه ١٩٠٨ – ١ – ٤٠٤

(٢) ديموج: الالتزامات ج١ ص٣٨ وما بعدها، وبلانيول وريبير وأسمان السابق ج٦ ف٨ وما بعدها.

(٣) نقض مدني في ١٩٦١/٣/٣٠ . مجموعة أحكام النقض س ١٢ رقم ٤٢ ص٢٩٤ .

(٤) انظر في ذلك: سالي في مؤلفه: الالتزامات في القانون الألماني ف ١٣٨ وما بعدها.

غالى في ذلك، فاعتبر الإرادة هي المصدر الوحيد للالتزام الإرادي، والعقد عند هؤلاء ليس إلا اجتماع إرادتين منفردتين، كل منهما مستقلة عن الأخرى، ولم تلق هذه النظرية المتطرفة قبولاً في أي من القوانين الوضعية، ومن ثم فإن الرأي الذي غلب في الفقه وأخذ به القانون الألماني نفسه الصادر سنة ١٩٠٠ لم يجعل من الإرادة المنفردة مصدراً عاماً للالتزام، ونص صراحة على أن إنشاء الالتزام عن طريق التصرف القانوني لا يكون إلا بعقد، فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك[١].

وهذا الرأي الأخير هو الذي أخذت به معظم التقنيات الحديثة كالتقنين المدني الإيطالي الصادر عام ١٩٤٢، والتقنين الليبي، والتقنين السوري.

**ثانيًا: موقف القانون المدني المصري من الإرادة المنفردة:**

نهج القانون المصري في هذا الشأن مسلكاً وسطاً بين نظريتين متطرفتين، النظرية السائدة في القانون الفرنسي، والتي تنكر على الإرادة المنفردة أن تكون مصدراً للالتزام، والنظرية الألماني التي نادى بها بوجه خاص بعض فقهاء الألمان، وذهبوا فيها إلى أن الإرادة المنفردة تصلح أن تكون مصدراً عاماً للالتزام الإرادي، فهو لم يجعل منها مصدراً عاماً للالتزام كالعقد، وإنما اعتبرها مصدراً منشئاً للالتزام في حالات معينة ينص عليها القانون.

وإذا كان القانون المصري الحالي، ويؤيده غالب الفقه،[٢] قد جعل من الإرادة المنفردة مصدراً استثنائياً من مصادر الالتزام، فيجدر بنا التنويه في هذا الصدد إلى ملاحظتين:

---

(١) م ٣٠٥ من التقنين المدني الألماني .

(٢) د/ الصدة: السابق، ص٤٥٣ هامش٢، ود/ إسماعيل غانم، المرجع السابق ص: ٣٥٤.

**الأولى:** أن فكرة الالتزام بالإرادة المنفردة، وثيقة الصلة بالمذهب المادي في الالتزام، ومن ثم فليس من الضروري وجود الدائن عند نشوء الالتزام، اكتفاء بوجوده عند تنفيذ الالتزام.

**الثانية:** مادامت الإرادة المنفردة تعد مصدراً استثنائياً للالتزام فإن ما ذكرناه من أحكام العقد يسري عليها، وذلك من حيث وجود إرادة جدية ووجود الأهلية، وخلو الإرادة من عيوبها المعروفة، وضرورة قيام الالتزام على محل وسبب مستجمعين الشرائط القانونية اللازمة، مع استثناء ما تعقد من ذلك الأحكام بتوافق الإرادتين كأمر بدهي[1].

**ثالثًا: تطبيقات الالتزام بإرادة منفردة في القانون المصري:**

نص القانون المدني المصري على عدة حالات تكون فيها الإرادة المنفردة للمدين مصدراً للالتزام، وهذه الحالات هي:

**أ – حالة الإيجاب الملزم بإرادة منفردة في القانون المصري:**

فقد سبق وأن ذكرنا أن الموجب يظل ملتزماً بالبقاء على إيجابه إذا عين ميعاداً للقبول، فمصدر التزامه هو إرادته المنفردة.

**ب– حالة المؤسسة الخاصة:** وهي شخص اعتباري ينشأ بإرادة منفردة هي إرادة المنشئ أو المؤسس المنفردة طبقاً لأحكام المادتين ٦٩، ٧٠ من التقنين المدني الملغي، والمادتين ٦٩، ٧٠ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته اللاحقة بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وإنشاء المؤسسة يتم بسند رسمي أو بوصية، والسند الرسمي تصرف بإرادة منفردة حال الحياة والوصية تصرف بإرادة منفردة مضاف إلى ما بعد الموت، فإرادة منشيء المؤسسة توجد الشخص المعنوي، وفي

(1) د / حشمت أبو ستيت . السابق، ص: ٣٦٣، انظر: الصدة ، السابق ص: ٤٥٥ .

الوقت ذاته تلزمه بأن ينقل إلى المؤسسة ملكية ما كان قد تعهد بتخصيصه من المال لها[1].

**ج – تطهير العقار المرهون:** ورد فيه نص المادة ١٠٦٦ مدني مصري، ومؤداه أن حائز العقار المرهون يلتزم بإرادته المنفردة أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وذلك بمجرد إظهار رغبته في تطهير العقار بتوجيهه إعلانات إلى الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المرهون والنافذة في حقه على النحو الوارد بالمادة ١٠٦٥ مدني.

**د – الوعد بجائزة الموجه للجمهور:** وهذه هي الحالة التي أفرد لها القانون نصاً خاصاً تحت عنوان: " الإرادة المنفردة " وهي الحالة التي سنعرض لدراستها بالتفصيل في الفصل التالي:

(1) د/ السنهوري ج ١/١٢٩٣ وما بعدها ط: ١٩٥٢، د/ حشمت ابو ستيت: السابق ص٣٦٤.

# الفصل الثاني

# الوعد بجائزة الموجه للجمهور (الجعالة)

## أولًا: تعريف الوعد بجائزة الموجه للجمهور:

الوعد بجائزة: تصرف قانوني بإرادة منفردة هي إرادة الواعد الذي يعلن للجمهور عن جائزة لمن يقوم بعمل معين.[١]

ومثاله الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء ضائع، أو لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن غوامض جريمة، أو القبض على مجرم هارب، أو لمن يقوم باختراع معين، أو لمن يقوم بوضع أحسن تصميم لبناء معين، أو لمن يهتدي إلى اكتشاف دواء معين أو غير ذلك.

والوعد بجائزة الموجه للجمهور هو نفسه "الجعالة" في الفقه الإسلامي وهي: تعني التزام شخص بشيء معين لمن ينجز له عملاً، وهي جائزة شرعاً عند جمهور الفقهاء، ودليلها قوله تعالى **(ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)** [٢]، كما أن السنة وردت بجوازها والإجماع على ذلك[٣].

وقد أوردت المادة ١٦٢ مدني مصري أحكمم الوعد بجائزة؛ حيث نصت على أنه: "١- من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بجائزة أو دون علم بها. ٢- وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد، وتسقط دعوى

---

(١) د / عبد الودود يحيى . السابق ص: ١٧ .

(٢)الآية: ٥٩ من سورة يوسف .

(٣) راجع: الشيخ علي الخفيف . التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة ، ط: ١٩٤ ص: ١٥٢ .

المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور".

**ثانيًا: شروط الوعد بجائزة:**

لما كان الوعد بجائزة تصرف قانوني يتم بإرادة واحدة، إذا وجب أن تتوافر فيه شروط التصرف القانوني الذي سبق أن عرضنا لها في دراسة أحكام العقد، إلا ما تعلق من هذه الشروط بتوافق الإرادتين ومطابقتهما، ووفقاً لنص المادة ١٦٢ مدني مصري، وتطبيقاً للقواعد العامة للتصرف القانوني يلزم لقيام الوعد بجائزة توافر الشروط التالية:

**الشرط الأول:** أن توجد إرادة جدية لدى الواعد تتجه إلى إحداث أثر قانوني، هو إلزام نفسه بالجائزة لمن يقوم بالعمل المطلوب، لا إلى مجرد التفاوض بشأنه، فإذا اتضح من الإعلان الموجه للجمهور أن الواعد لم يقصد أن يلزم نفسه، وإنما قصد الترويج لسلعته فلا يكون هناك وعد منشئ للالتزام.

**الشرط الثاني:** أن تتوافر في الواعد الأهلية الكاملة للالتزام بما وعد وأن مرد الإرادة على محل مستوف لشروطه وأن تتجه إلى سبب مشروع.

**الشرط الثالث:** أن يوجه التعبير إلى الجمهور[١]، فإذا وجه إلى شخص معين، أو أشخاص معينين بذواتهم، فلا يكون هناك وعد موجه للجمهور، وإنما نكون أما إيجاب لابد أن يقترن به قبول، وعندئذ ينعقد عقد آخر هو الذي ينشأ عنه الالتزام، علمًا بان الفقه الإسلامي لا يشترط أن يكون الوعد موجها إلى الجمهور[٢].

---

(١) يمكن أن يحدد الجمهور الذي يوجه إليه الوعد بصفات معينة، كأن يوجه الوعد للأطباء أو المهندسين أو المحاسبين .. إلخ.

(٢) الشيخ على الخفيف . مجلة العلوم القانونية والاقتصادية . العدد الأول ص: ١٢١ ، ١٢٤ .

**الشرط الرابع:** أن يكون توجيه الوعد للجمهور بطريقة تتوافر فيها العلانية إلى الحد الذي يكفي لأن يعلم به عدد كبير من الناس، كالإعلان فى الصحف، أو الإذاعة... إلخ.

**الشرط الخامس:** أن يتضمن الوعد جائزة يلتزم بها الواعد، سواء كانت مادية فى صورة مبلغ من النقود، أو أسهم أو سندات، أو سيارات، أو دفع نفقات علاج، ...إلخ، أو كانت أدبية كوسام او إشارة أو كأس، أو أي شئ آخر من وسائل التقدير الأدبي، إذن أن الواعد هنا يلتزم بإرادته المنفردة.

**الشرط السادس:** يجب أن يتضمن الوعد تحديد العمل الذي يجب أن يقوم به من يريد الحصول على الجائزة، فلا يكفي أن يكون مجرد الوجود فى مركز معين سببا لاستحقاق الجائزة، كما فى حالة الإعلان عن جائزة لمن يولد فى يوم معين دون أي عمل، أو لأول شهيد فى الحرب؛ لأن النص يتطلب القيام بعمل معين، وإنما يمكن أن يكون هناك هبة إذا توافرت شروطها[1]، وبالنسبة لمن وجه إليه الوعد ويسمى شرعا بـ "العامل" فلا يشترط فيه إلا قيامه بالعمل المطلوب، سواء بنفسه أو عن طريق نائبه.

## ثالثًا: أحكام الوعد بجائزة:

لدراسة آثار الوعد بجائزة يجب التمييز بين ما إذا كان الوعد قد حدد مدة يجب إنجاز العمل المطلوب خلالها أو لم يحدد مدة:

**أ- إذا حددت للوعد بجائزة مدة:** فلا يجوز للواعد أن يرجع فى وعده ما دامت المدة لم تنقض بعد، فإذا انقضت المدة المحددة للواعد دون أن يقوم أحد بإنجاز العمل، سقط الوعد حتى ولو تم إنجاز العمل بعد ذلك.

---

(1) انظر فيما سبق د / عبد المنعم البدراوي . السابق ص: ٤٢٨، د/ إسماعيل غانم السابق ص: ٣٩٧ – ٣٩٩ ، د/ لبيب شنب ، السابق ص: ٣١٧ .

أما إذا قام أحد بالعمل المطلوب قبل انقضاء المدة المحددة، فإن من قام به يصبح صاحب حق فى الجائزة، ودائنا للواعد بها، ويستوي بعد ذلك أن يكون قد قام بالعمل رغبة فى الجائزة أم قام به دون وجود هذه الرغبة، كما يستوي أن يكون وقت قيامه بالعمل يعلم بالجائزة أو لا يعلم بها، أو يكون قد أتم العمل المطلوب بعد أو حتى قبل الإعلان عن الجائزة، وهذا هو الذي يجعل التزام الواعد التزاما بإرادته المنفردة؛ إذ لا يتصور أن يكون هناك عقد بينه وبين من قام بالعمل يجهل وجود الوعد أو أنجز العمل قبل الإعلان عن الجائزة.

**ب- إذا لم تحدد للوعد بجائزة مدة:** فإن الواعد يلتزم رغم ذلك بالوعد، ولكن يجوز له الرجوع فى وعده فى أي وقت دون تثريب عليه فى ذلك، ما دام أن أحدا لم يحقق العمل المطلوب، بيد أن الرجوع لابد أن يتم بذات العلانية التي تم بها الوعد أن يرجع فى وعده، ولو كان هناك من بدأ فى القيام بالعمل المطلوب، وفى هذه الحالة يجوز لمن بدأ فى القيام بالعمل المطلوب أن يرجع على الواعد بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بمقتضى أحكام المسئولية التقصيرية، وليس على أساس الوعد الذي سقط بالرجوع فيه.

أما إذا كان العمل قد تم في مدة معقوله يجدى فيها القيام بهذا العمل[1]، فإن من أنجز العمل يستحق الجائزة دون أن يكون لرجوع الواعد أي أثر، ويستحق القائم بالعمل الجائزة ولو لم يكن قد علم بها، أو قد قام بالعمل دون نظر إلى الجائزة.

وأخيرًا إن الواعد إذا رجع في وعده، ولكن العمل المطلوب كان قد تم قبل الرجوع، فإن القائم بالعمل يستحق الجائزة، دون أن يكون لرجوع الواعد أي أثر في استحقاق الجائزة؛ لأن العمل قد تم في وقت كان الواعد فيه ملتزما فيصبح العامل دائنا للواعد بمجرد إنجاز العمل، حتى ولو كان العامل أنجز العمل دون نظر إلى

(1) إذا ثار خلاف حول المدة المعقولة قام القاضي بتحديدها وفقاً لظروف وملابسات الموضوع .

الجائزة، أو كان العمل قد تم دون علم بها، أو حتى قبل الإعلان عنها.

وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة، إذا لم ترفع في خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور، وفقا لنص المادة ٢/١٦٢ مدني مصري، وهذه مدة سقوط لا مدة تقادم، ومن ثم لا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع، قضى بها المشرع رغبة منه في حسم المنازعات التي تنشأ بسبب تقادم العهد على الجائزة وصعوبة الإثبات[1]، أما في غير هذه الحالات فلا تتقادم دعوى المطالبة بالجائزة إلا بمضي خمس عشرة سنة وفقا للقواعد العامة[2]

**ويستبين مما تقدم أن الواعد يلتزم بالجائزة في حالات ثلاث:**

الأولى: إذا حدد ميعادًا للجائزة، وتم إنجاز العمل خلال الميعاد المحدد.

الثانية: إذا لم يحدد ميعادًا لإتمام العمل، ولم يرجع في وعده وتم إنجاز العمل في خلال مدة معقوله.

الثالثة: إذا لم يحدد الواعد ميعادًا لإتمام العمل المطلوب، ورجع في وعده، ولكن كان هناك من أنجز العمل قبل الرجوع.

وفى الحالتين الأوليتين يسقط حق من قام بالعمل في المطالبة بالجائزة وفقا للتقادم العادي، أي بمضي خمس عشرة سنة وفقا للقواعد العامة، وفى الحالة الأخيرة تسقط دعوى المطالبة بالجائزة بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور على النحو السابق تفصيله.

---

(١) انظر: مجموعة الأعمال التحضيرية ٣ / ٣٤٧ .

(٢) السنهوري، السابق ص: ١٣٠٦، د/ حشمت أبو ستيت: السابق ص: ٣٦٧، د/ الصدة، السابق، ص: ٤٥٩ – ٤٦٠، د/ لبيب شنب ، السابق ص: ٣١٩.

# الباب الثالث
# العمل غير المشروع أو الفعل الضار

**تمهيد:**

**التعريف بالمسئولية وأنواعها:**

كلمة المسئولية تعني: "المؤاخذة والتبعة" على فعل ضار أو فعل خاطئ سواء أتاه الإنسان بنفسه أم كان بفعل غيره (التابع – الخاضع للرقابة) وكان مسئولا عنه، وسواء كانت المؤاخذة في صورة تعويض فقط، أم مقترنه بغيرها من الجزاءات الأخرى، على أن كلمة المسئولية "لا يتحدد معناها بدقة إلا بوصفها" أهي مسئولية مدنية، أم جنائية؟ وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا بعد قليل، وما يهمنا بيانه هنا أن كلمة "المسئولية" ككلمة مجردة لم نعثر لها على معنى أكثر تحديدا من أنها تعني "المؤاخذة والتبعية" على فعل غير مشروع، ولكن يغدو معناها أكثر وضوحا تبعا لنوع المسئولية المراد تعريفها أهي مسئولية عقدية أم تقصيرية.

وبعد هذا البيان الموجز لمعنى "المسئولية" ككلمة مجردة نقول – إن المسئولية التقصيرية هي جزاء الإخلال بالواجب الذي يفرض على كل شخص عدم الإضرار بالغير، أو هي الإخلال بالتزام فرضة القانون وهي تقابل المسئولية العقدية التي تنشأ عن الإخلال بالتزام عقدي.

وقبل أن نعرض لأحكام المسئولية التقصيرية يجب أن نبين نطاقها وهذا البيان يستوجب الحديث عن النقاط الآتية:

**أولًا: التمييز بين المسئولية الأدبية والمسئولية القانونية:**

المسئولية الأدبية: هي المسئولية الناشئة عن اقتراف أمر مخالف لقواعد الدين والأخلاق أو العادات الاجتماعية الصحيحة، وهي بهذا المعنى لا يترتب عليها جزاء قانوني من الالتزام بالتعويض أو غير ذلك من الجزاءات القانونية الأخرى، ومن ثم

يسأل مرتكبها أمام الله وأمام ضميره فقط[1]، ومن أمثلتها عدم التزام الصدق، وعدم مساعدة الضعيف، وعدم التصدق على الفقير، وعدم القاء السلام والتحية عند التلاقي، أو عدم تبادل الهدايا في الأعياد والمواسم ...الخ[2].

أما المسئولية القانونية فهي التي تدخل في دائرة القانون، ويترتب عليها جزاء قانوني، سواء أكان ذلك الجزاء مدنيًا أم جنائيًا أم إداريًا تبعا لنوع المسئولية، كما أنها هي التي ينصرف إليها معنى المسئولية عند الإطلاق؛ لأنها هي التي تحمل معنى "المؤاخذه والتبعة" في نطاق الحياة الاجتماعية ببن الأفراد[3]، ومن ثم تتمثل أهم الفروق بين هذين النوعين من المسئولية فيما يلي:

١- نطاق المسئولية الأدبية تحدده الأخلاق، فهي تبين ما ينبغي أن يكون عليه الشخص في سلوكه نحو ربه ونحو نفسه ونحو غيره من الناس، أما نطاق المسئولية القانونية فيحدده القانون؛ حيث يجب على الشخص أن يسلك السلوك الذي يقرره القانون نحو غيره من الناس، ومن ثم كان نطاق المسئولية الأدبية أوسع نطاقا من المسئولية القانونية.

٢- تتحقق المسئولية الأدبية ولو لم يلحق الغير ضر، كما هو الشأن في تأنيب الضمير على ارتكاب فعل غير أخلاقي، هنا تتحقق المسئولية الأدبية مع أنه لا يوجد لها مظهر خارجي، بينما لا تقوم المسئولية القانونية إلا إذا وجد ضرر، ولحق هذا الضرر بشخص آخر غير المسئول.

---

(١) انظر د / حسام الدين الأهواني . المرجع السابق، ص: ٤٨٣ ، د / جميل الشرقاوي ، النظرية العامة للالتزام ( المصادر غير الإرادية ) هامش ١ ص: ٢٣ .

(٢) انظر في ذلك: مؤلفنا: المدخل لدراسة العلوم القانونية . القسم الأول . نظرية القانون ط: ٢٠٦ ص: ٥٨.

(٣) راجع: رسالتنا لنيل درجة الماجستير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني . دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي . من جامعة الأزهر على الآلة الضاربة عام ١٩٧٨م، ص: ٣٨، والمراجع المشار إليها فيها.

٣- تقوم المسئولية الأدبية على أساس ذاتي محض؛ حيث يسأل الشخص أمام الله وأمام ضميره فقط، أما المسئولية القانونية فتقوم أمام شخص آخر هو المضرور[1].

٤- المسئولية الأدبية لا يترتب عليها جزاء قانوني، أما المسئولية القانونية فهي التي يترتب عليها جزاء قانوني[2] يتمثل في العقوبة المقررة على الفعل غير المشروع [3]، سواء أكانت عقوبة جنائية أم مدنية أم إدارية.

**ثانياً: التمييز بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية:**

الفارق الجوهري بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية هي أن الأولى جزاء فعل أضر بشخص معين، ويترتب على هذا الفارق عدة نتائج:

١- الجزاء في المسئولية الجنائية عقوبة توقع على الجاني، أما الجزاء في المسئولية المدنية فهو إلزام المسئول بتعويض الضرر، كما أن الذي يباشر الدعوى ويطالب بالجزاء في الأولى هو المجتمع ممثلًا في النيابة العامة، بينما الذي يفعل ذلك في الثانية هو المضرور ذاته.

٢- القاعدة في القانون الجنائي أنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، ومن ثم لا تتحقق المسئولية الجنائية إلا إذا ارتكب الشخص عملًا تحرمه القوانين الجنائية، خلافا للمسئولية المدنية التي لا يمكن حصر الأعمال الموجبة لها، وإنما تحدد هذه الأفعال وفقا لضوابط محدده أهمها ما تنص عليه القوانين المدنية "أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

---

(١) انظر د/ عبد الرزاق السنهوري . السابق ص: ٨٤٢، د/ سليمان مرقس . المرجع السابق ص: ٤٦٢ ف ٣٥٩، د/ حسام الدين الأهواني . المرجع السابق ص: ٤٨٤.

(٢) حيث يقتصر الجزاء فيها على تأنيب الضمير واستهجان الناس لمن يخرج على القاعدة الخلقية.

(٣) د / عبد المنعم الصدة . المرجع السابق ص: ٤٦٣ ، وانظر: المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء لكل من: المستشار / عز الدين الديناصوري، المستشار: عبد الحميد الشواربي ط: ١٩٨٨م ص: ٦.

٣- لا يجوز الصلح ولا التنازل في المسئولية الجنائية لأنها حق المجتمع، خلافا للمسئولية المدنية حيث يجوز للمضرور أن يصالح أو ينزل عما هو حق له[1].

٤- يختلف نطاق المسئولية الجنائية عن نطاق المسئولية المدنية، فقد تتحقق المسئولية الجنائية دون المسئولية المدنية، وذلك إذا ارتكب الشخص فعلا يجرمه القانون الجنائي دون أن ينتج عنه ضرر للغير، كما في جرائم حمل السلاح، والشروع والتشرد، ومخالفات المرور والاتفاق الجنائي، وقد تتحقق المسئولية المدنية دو المسئولية الجنائية، كما لو ارتكب شخص خطأ سبب للغير ضررا دون أن يكون من الأفعال التي نهت عنها القوانين الجنائية، كإتلاف مال بغير قصد، وكالمنافسة غير المشروعة، وتطبيقات التعسف في استعمال الحق.

وقد تنتج المسئوليتان معًا عن فعل واحد، كما في جرائم القتل والضرب والجرح والسرقة والسب والقذف والغضب ...الخ، وفى هذه الأحوال تؤثر المسؤلية الجنائية – وهي الأقوى إذ يتمثل فيها حق المجتمع – على المسئولية المدنية التي يتمثل فيها حق الفرد[2]، وذلك في نواح عديدة نعالجها تفصيلا في البند التالي.

**أثر اجتماع المسئولين معا يناء على فعل واحد**:

إذ ترتب على الفعل الواحد مسئولية مدنية ومسئولية جنائية في وقت واحد فإن الأخيرة – وهي الأقوى لأنها حق المجتمع – تؤثر في الثانية وذلك من عدة وجوه:

**١- من حيث الاختصاص:** يجوز رفع الدعوى المدنية – وهي دعوى التعويض – أمام المحكمة الجنائية على أساس أنها تابعة للدعوى الجنائية فتفصل فيها من الدعوى الجنائية، ولكن لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية، ففي

(١) د / عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ص: ٨٤٣، د / إسماعيل غانم ، المرجع السابق ص: ٤٠٤ د/ حشمت أبو ستيت ، المرجع السابق ص: ٣٧٢.

(٢) راجع في ذلك د/ إسماعيل غانم، المرجع السابق ، ص: ٤٠٥، د / عبد المنعم الصدة، المرجع السابق ص: ٤٦٤ .

جريمة القتل يجوز لورثة القتيل أن يطالبوا بالتعويض أمام محكمة الجنايات التي يحاكم أمامها الجاني بناء على طلب النيابة العامة فتفصل هذه المحكمة في طلب توقيع عقوبة القتل، وتفصل في طلب التعويض في ذات الوقت[١].

**٢- من حيث التقادم:** تقضي المادة ١٧٢ مدني بأن دعوى التعويض المدنية لا تسقط – بالتقادم- إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا لم تتقادم الدعوى الجنائية، فإن هذا يحول دون تقادم الدعوى المدنية حتى لو كانت مدة تقادم هذه الدعوى الأخيرة قد انقضت، والعكس غير صحيح، إذ أن بقاء الدعوى المدنية قائمة لا يمنع من سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم[٢].

**٣- من حيث وقف الدعوى المدنية:** إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية، فإنه يتعين وقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يصدر الحكم في الدعوى الجنائية، وتعرف هذه القاعدة بأن "الجنائي يوقف المدني"، والغرض من ذلك منع صدور حكمين متعارضين، كأن تقرر المحكمة الجنائية تبرئة المتهم على أساس أنه لم يرتكب الفعل الذي يحاكم من أجله في حين تقرر المحكمة المدنية أنه ارتكب الفعل ومن ثم تلزمه بالتعويض بناء على ذلك[3].

**٤- من حيث حجية الحكم:** يتصل بالمبدأ السابق مبدأ آخر مقتضاه أن المحكمة المدنية تتقيد بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية بالنسبة للوقائع، دون أن تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، وبيان ذلك أنه إذا حكمت المحكمة الجنائية

---

(١) د/ لبيب شنب: المرجع السابق ص: ٣٢٥، د/ حسام الأهواني: المرجع السابق، ص: ٤٨٥ .

(٢) د/ السنهوري، السابق ص: ٨٤٥، د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق ص: ٤٦٦.

(٣) د/ لبيب شنب، السابق، ص: ٣٢٥، وانظر: د/ حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص: ٤٥٦، د/ عبد الناصر العطار، السابق الموضع السابق، د/ سمير تناغو . السابق، الموضع السابق.

بإدانة المتهم لارتكابه الفعل المنسوب إليه، فلا تستطيع المحكمة المدنية أن ترفض دعوى التعويض بحجة أن الفعل (واقعة) لم يقع من المتهم، أما إذا صدر حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم، فإن ذلك لا يمنع المحكمة المدنية من أن تحكم بالتعويض على أساس أن ما نسب إليه من إهمال يكفي لاعتباره خطأ مدنيا، وأظهر من ذلك أن تكون المسئولية المدنية مبنية على خطأ مفروض، فإذا حكم القاضي بعدم مسئولية قائد السيارة جنائيا، فإن ذلك لا يمنع من اعتباره مسئولا مدنيا باعتباره حارسا لها، كذلك فى حالة ما إذا قضت المحكمة الجنائية بسقوط الدعوى الجنائية لموت المتهم، أو بعدم العقاب لقيام مانع من توقيعه كما لو كان السارق ابنا أو زوجا، أو لأن عفوا شاملا قد صدر، فإن شيئا من ذلك لا يمنع القاضي المدني من النظر في دعوى التعويض[1]، وقد عبرت عن هذا المادة ١٠٢ من قانون الإثبات [2] بقولها: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضروريا".

**ثالثا: التميز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية:**

سبق أن ذكرنا أن المسئولية المدنية تنقسم إلى مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية، والأولى: هي جزاء الاخلاء بالتزام عقدي، والثانية هي جزاء الإخلال[3] بالواجب العام الذي يلزم كل شخص بعدم الإضرار بالغير، ومع أن كلا من المسئوليتين تشتركان في كثير من الأحكام، إلا أن بعض هذه الأحكام تختلف بحسب ما إذا كانت المسئولية عقدية أم تقصيرية وذلك من خلال الصياغة الفنية لأحكام كل منهما وذلك على النحو التالي:

---

(١) د / أحمد حشمت أبو ستيت، المرجع السابق ص: ٣٧٤، ٣٧٥، د / عبد الودود يحيى . المرجع السابق ص: ٢٢٣.

(٢) وهو القانون رقم ١٩٨٦ المعدل.

(٣) د/ الصدة، السابق، ص: ٣٨٣، د/ لبيب شنب ص: ٢٩١.

**١- من حيث الإعفاء الاتفاقي في المسئولية:** لما كانت المسئولية العقدية منشؤها العقد، فإنه يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية أو التخفيف منها، فيما عدا حالتي الغش[١] (الخطأ العمدي والخطأ الجسيم)، وعلى العكس لا يجوز ذلك في المسئولية التقصيرية، فلا يجوز الاتفاق على تعديل أحكامها أو الإعفاء منها.

**٢- من حيث مدى التعويض:** التعويض في المسئولية العقدية لا يشمل إلا الضرر المباشر والمتوقع الحصول دون الضرر غير المتوقع، إلا أن يكون قد وقع من المدين غش أو خطأ جسيم، أما في المسئولية التقصيرية فالمدين يسأل عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع (م ٢/٢٢١ مدني).

**٣- من حيث التضامن:** إذا تعدد المسئولون فى المسئولية التعاقدية كانوا غير متضامنين، لأن التضامن لا يفترض بينهم، وليس هذا إلا تطبيقا للمادة ٢٧٩ مدني التي تقضي بأن التضامن لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون أما في المسئولية التقصيرية فإن التضامن بين المسئولين مقرر بنص القانون وفقا للمادة ١٦٩ مدني مصري.

**٤- من حيث التقادم:** تتقادم دعوى المسئولية العقدية بمضي خمس عشرة سنة طبقا للقاعدة العامة في التقادم[٢]، أما دعوى المسئولية التقصيرية فتتقادم بمضي ثلاث سنوات من يوم العلم بوقوع الفعل الضار ومعرفة مرتكبه، أو خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل حسب الأحوال[٣].

---

(١) المادة: ٢١٧ / ٢ مدني مصري.

(٢) المادة ٣٧٤ مدني مصري.

(٣) انظر المادة ١/١٧٢ مدني مصري، والتي تنص على أنه: "وتسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل غير المشروع".

٥- **من حيث الإثبات:** في المسئولية العقدية يجب على المدين إثبات الوفاء بالتزامه التعاقدي بعد أن يثبت الدائن وجود العقد، أو يثبت السبب الأجنبي الذب حال بينه وبين الوفاء بهذا الالتزام، بينما يقع عبء الإثبات في المسئولية التقصيرية على الدائن، وهو المضرور؛ حيث يجب عليه أن يقيم الدليل على خطأ المدين[1] .

٦- **من حيث الأهلية:** في المسئولية العقدية تشترط أهلية الرشد في أكثر العقود أو أن يكون المتعاقد أهلًا لإبرام العقد، بينما يكفي التمييز في المسئولية التقصيرية.

٧- **من حيث الإعذار:** في المسئولية العقدية يشترط إعذار المدين إلا في حالات استثنائية[2] بينما لا يشترط إعذار المدين في المسئولية التقصيرية.[3]

**عدم جواز الجمع أو الخيرة بين المسئولية التعاقدية والمسئولية التقصيرية**:

إذا ما توافرت في العمل الواحد شروط المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية في وقت واحد، كما لو تسلم ناقل بضاعة، بضاعة لنقلها فيختلسها لنفسه؛ فالناقل هنا يعتبر قد أخل بالتزامه العقدي هو توصيل البضاعة إلى المكان المتفق عليه، فيكون مسئولا عقديا عن الضرر الذي أصاب مالك البضاعة، ويعتبر مسئولًا مسئولية تقصيرية – كذلك – لخطأه (فعل الاختلاس) الذي سبب ضررًا للغير (مالك البضاعة) [4].

---

(١) راجع فيما سبق: السنهوري . السابق ص: ٨٤٨ ، د / عبد الودود يحيى . المرجع السابق ص: ٢٦٦، د/ إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص: ٤٠٧، د/ لبيب شنب . السابق ص: ٣٢٧.

(٢) مادة ٢١٨ مدني مصري والتي تقضي بأنه: "لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص غير ذلك".

(٣) نقض مدني في ١٩٤٩/١٢/١٠، مجموعة أحكام النقض السنة الأولى ص: ٩٨.

(٤) راجع في ذلك: د / لبيب شنب، المرجع السابق ص: ٣٢٨، د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص: ٤٧٧، د/ حشمت أبو ستيت، المرجع السابق ص: ٣٩٠ .

فهل يجوز للمضرور أن يتمسك بالمسئولية التقصيرية؛ لأنها الأكثر نفعا له، أو لأنه وجد نفسه عاجزا عن التمسك بالمسئولية العقدية لوجود شرط في العقد يعفي المدين منها؟ هذه فحوى مسألة الجمع بين المسئوليتين وإن كان الأدق أن يقال " الخيرة بين المسئوليتين".

وبيان ذلك: أن جمهور الفقه المصري[1] والأجنبي[2] يجمع على أن الدائن لا يجوز له الجمع بين المسئوليتين في الرجوع على المدين، أيًّا كان المعنى الذي يفهم من لفظ الجمع:

فلا يجوز الجمع بمعنى أن المضرور يطالب بتعويضين، تعويض عن المسئولية العقدية وآخر عن المسئولية التقصيرية؛ لأن الضرر الواحد لا يجوز التعويض عنه مرتين.[3]

ولا يجوز الجمع بين المسئوليتين بمعنى أنه يجمع بين المزايا في كليهما، فيأخذ من كل منهما ما يتفق وصالحه في الدعوى، يرفع مثلًا دعوى المسئولية التقصيرية بعد أن تقادمت، مستندًا إلى عدم تقادم دعوى المسئولية العقدية بعد، ويرفع دعوى المسئولية العقدية متمسكا بتضامن المسئولين المقرر في المسئولية التقصيرية، فهو لا يستطيع أن يرفع سوى دعوى واحدة تقوم كلها على إحدى المسئوليتين، أما الدعوى التي تأخذ من هذه وتلك فهي دعوى لا يعرفها القانون.

ولا يجوز الجمع بين المسئوليتين بمعنى أنه إذا رفع دعوى على أساس إحداهما فخسرها يستطيع أن يرفع الدعوى الأخرى؛ لأن هذا يتعارض مع حجية الأمر

---

(١) انظر: السنهوري، المرجع السابق ص: ٨٥٧ ، وما بعدها، د / عبد الودود يحيى، المرجع السابق ص: ٢٢٦.

(٢) انظر في الفقه الفرنسي: مازو . دروس في الالتزامات ص: ٤٢٦ وما بعدها.

(٣) نقض مدني في ٢٩ / ٤ / ١٩٨١، مجموعة أحكام النقض س ٣٢، ص: ١٣٢٨.

المقضي[1] وهذا ما تأخذ به الدائرة المدنية بمحكمة النقض المصرية[2]، أما الدائرة الجنائية فتذهب إلى عكس ذلك [3]، ويسير القضاء الفرنسي في مجموعه على هذا الرأي المخالف، إلا أن هذا القضاء منتقد من أغلب الفقه الفرنسي[4].

ويستبين مما سبق أن التعبير بلفظ "الجمع بين المسئوليتين" تعوزها الدقة، إذ الجمع قطعا لا يجوز، ومحل البحث هو: هل تجوز الخيرة بين المسئوليتين فيختار تلك التي تكون أكثر نفعا له؟ للجواب عن هذا السؤال، انقسم الفقه والقضاء في هذه المسألة إلى رأيين:

**أ – الرأي الأول: يقول بجواز الخيرة بين المسئوليين:** فيقول أن للدائن ان يختار بين الدعويين، وأهم حجج هذا الرأي: أن المسئولية التقصيرية من النظام العام، ومن ثم فلا يجوز للأفراد أن يتفقوا على استبعادها والحد منها، فهي تقوم دائمًا إلى جانب المسئولية العقدية، وفى وسع المتعاقد أن يجاوز هذه إليها، كما أن شروط كل من الدعويين قد توافرت، والمنطق القانوني يقضي بأن الدعوى متى توافرت شروطها جاز رفعها، فلا شئ يمنع الدائن من رفع أيهما إذا آثرها على الأخرى؟

---

(١) فوفقاً لقاعدة حجية الأمر المقضي تكون الدعوتان متحدتين في الخصوم والمحل والسبب، ومن ثم لا تكون الدعوى الأخرى مقبولة.

(٢)انظر: نقض مدني في ١٩٣٩/١/٥ . مجموعة عمر ، ص: ٤٥٢، رقم ١٥٤.

(٣)انظر: نقض جنائي في ١٩٤٣/٣/٨، المحاماة س ٢٥، ص: ١٣٢، رقم ٤٥، ونقض جنائي في ١٩٤٣/٥/٣١، المحاماة س ٢٦ رقم ٣٧، ونقض جنائي في ١٩٤٥/٢/١٧، المحاماة س ٢٧ ص: ١٠٠٦، رقم ٣٩٤.

(٤) انظر في الفقه الفرنسي: بلانيول وريبيير وبولانجي ج ٢ ف ١٦٦٩ ومازو السابق ج ٣ ف ٢٠٩١ وما بعدها.

وهذا الرأي يقول به بعض الفقه المصري[1]، والأجنبي[2].

**الرأي الثاني: وهو لمنكري حق الخيرة بين المسئولين:** وهم جمهور الفقه المصري[٣]، ويقول أنصار هذا الرأي أن الدائن لا يعرف المدين إلا عن طريق العقد، فكل علاقة تقوم بينهما بسبب هذا العقد يجل أن يحكمها العقد وحده، كما أن المسئوليتين وضعان متعارضان لا يمكن أن يجتمعا، إذ المسئولية العقدية إنما تقوم بين المتعاقدين، في حين تكون المسئولية التقصيرية بين أشخاص لا تربطهم في خصوص العمل غير المشروع الذي وقع أي رابطة عقدية، ولا يمكن أن يجتمع لشخص في آن واحد وصفين، وصف كونه متعاقدا ووصف كونه من الغير، ولا مناص من الاختيار، والاختيار بالطبع لا يكون إلا للمسئولية العقدية؛ لأنها هي التي تحكم العلاقة بين المتعاقدين، فالمسئولية العقدية تطرد بحكم القانون المسئولية التقصيرية، وإذا ما اعترض بأن في رفض الخيرة معنى إباحة الاتفاق على استبعاد نص آمر هو نص المادة ١٦٣ مدني فإنه يمكن الرد على ذلك بأن "استبعاد المسئولية التقصيرية لم يكن وليد اتفاق الطرفين بل كان نتيجة تحديد منطقة كل من المسئولتين[٤] .

---

([1]) لا نعلم – على قدر ما وسعنا الجهد – من يجيز الخيرة بين المسئوليتين في الفقه المصري، سوى الدكتور/ مصطفى مرعي في مؤلفه "المسئولية المدنية" ف ٢٢، وما بعدها، الأستاذ/ حسين عامر، القوة الملزمة للعقد، ف ٢٦٠، وما بعدها، والدكتور/ عبد الرزاق السنهوري في رأي قديم له مذكور في الموجز للنظرية العامة للالتزامات ف ٣٠١ .

([2]) انظر: جوسران ج ٢ ف ٤٨٢، وبلانيول وريبير وبولانجي . السابق ف ٩٣٣ وما بعدها.

([3]) انظر: السنهوري . السابق ص: ٨٦١، ٨٦٢، د/ حشمت أبو ستيت . المرجع السابق ص: ٣٩٢، د / لبيب شنب . السابق ٣٣٠ – ٣٣١ .

([4]) انظر: د/ حشمت أبو ستيت . السابق . الموضع السابق .

وهذا الرأي الذي يقول به جمهور الفقه المصري هو الرأي الأول بالقبول في نظرنا، وهو الذي يستبعد الخيرة في كل الفروض؛ ولذا فنحن لا نقر رأي من ذهب إلى جواز الخيرة في ما يكون الفعل جريمة جنائية – كما لو سرق البضاعة ناقله – ولا في حالة الغش الصادر من العاقد في تنفيذ العقد ولو لم يرق فعله إلى حد الجريمة الجنائية؛ لأننا ما دمنا بصدد الإخلال بالتزام عقدي وتوافرت شروط المسئولية العقدية، فلا يمكن الالتجاء إلى المسئولية التقصيرية .

اما القضاء فلا زال منقسما حول مبدأ الخيرة بين المسئوليتين وإن كان القضاء المصري قديمًا[1] كان يميل إلى إباحة الخيرة، إلا أنه عاد وأخذ في أحكامه – حديثا بما استقر عليه الفقه المصري من عدم جواز الخيرة بين المسئوليتين عند توافر شروطهما، وهو نفس التردد الموجود في القضاء في فرنسا على نطاق ضيق.

(1) نقض مدني في ١٩٦٩/٦/٤، مجموعة أحكام النقض س ٢٠، ص: ٨٦٨ ، وانظر: نقض مدني في ١٩٦٥/١١/٣٠ المجموعة السابقة س: ١٦، ص: ١١٦٠.

# الفصل الأول

# المسئولية عن الأعمال الشخصية

- **تمهيد في المبدأ العام في المسئولية التقصيرية وأركانها:**

تقوم المسئولية عن الأعمال الشخصية – أي عن عمل شخصي يصدر من المسئول نفسه – على خطأ واجب الإثبات؛ أي أن الدائن يكلف بإثبات الخطأ في جانب المدين، ومن ثم فهو خطأ غير مفترض، فإذا أثبت المضرور خطأ المسئول وكان الضرر نتيجة لهذا الخطأ، التزم المخطئ بالتعويض، وفى هذ تنص المادة ١٦٣ مدني على أن: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

ويستبين من هذا النص أن أركان المسئولية التقصيرية – كالمسئولية العقدية – ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وسنعرض لكل من هذه الأركان في مبحث مستقل، ثم نتبع ذلك بالحديث عن آثار توافر أركان هذه المسئولية في مبحث رابع:

## المبحث الأول

## الخطـأ

**التعريف بالخطأ:** لم يضع المشرع المصري معيارًا للخطأ، وحسنا فعل؛ لأن وضع معيار هو من المسائل العملية التي تترك للفقه والقضاء يكيفانها بما يجعلها أكثر مسايرة للحاجات العملية. وقد اختلف الرأي في تحديد معنى الخطأ:

فذهب رأي إلى أن الخطأ: هو العمل الضار غير المشروع.[1] وهذا الرأي منتقد – من قبل الفقهاء– تأسيسًا على أن: "الأعمال الضارة ليست هي وحدها التي نها عنها القانون".

(1) رسالة: ديليانس عن فكرة العمل غير المشروع – باريس ١٩٥١، رسالة نظرة عامة في عدم المشروعية ١٩٥٥، وانظر في نقد هذا الرأي مارتي ورينو– السابق جـ٢ ص ٣٨٨، دي باج– السابق ص٨٧٩ .

وذهب رأي ثان قال به الأستاذ بلانيول مضمونه: أن الخطأ هو الإخلال بالتزام سابق[1]، وهذا الرأي – أيضا – منتقد من حيث أنه يجب أن نعرف متى يكون هناك إخلال بالتزام سابق حتى يقوم الخطأ، الأمر الذي جعل بلانيول يحاول أن يحصر الالتزامات السابقة فى أربعة: الامتناع عن العنف، الكف عن الغش، والامتناع عن مزاولة كل عمل لم تتهيأ له أسباب المهارة لدى القائم به، واليقظة فى مراقبة الأشياء لدى القائم به، واليقظة فى مراقبة الأشياء أو الأشخاص الذي قد يسأل عنهم الشخص، إلا هذه المحاولات أيضا منتقدة[2]، على أساس أن هذا تقسيم لأنواع الخطأ وليس تعريفا له.

وذهب رأي ثالث نادى به الاستاذ إيمانويل ليفي[3] إلى أن الخطأ: هو الإخلال بالثقة المشروعة فى النفس وثقة الغير فيه، ولكن هذا الرأي منتقد أيضا من ناحية صعوبة التفرقة بين هذين النوعين من الثقة، وهو ما لم يبينه هذا الرأي.

وذهب رأي رابع وهو للأستاذ جوسران [4]إلى أن الخطأ: هو الإضرار بحق للغير دون أن يكون قادرًا على الاستناد إلى باعث مشروع، وهذا الرأي منتقد أيضا على أساس أن ما ورد به ألفاظ عامة لا تحدد معنى الخطأ [5].

---

(١) بلانيول – السابق ج ٢ ف ٨٦٣ ، وانظر د/ سليمان مرقس – مصادر الالتزام – ط ١٩٦٠ – ف ٢٩١ –٣٩٣ ، وانظر في نقدا هذا التعريف: دي باج – السابق الموضع السابق ، ومالاتي ورينو – السابق ص ٣٩٠ –٣٩٣ .

(٢) انظر :جوسران – في السابق ج ٢ فقرة ٤٢٢.

(٣)انظر مقالة في المجلة الاقتصادية للتشريع والقضاء ١٨٩٩ ص ٣٦١ وا بعدها .

(٤) جوسران – السابق ج ٢ ف ٤٢٣ –٤٢٥.

(٥) انظر في ذلك تفصيلا وفى تعريفات الخطأ المنتقدة: السنهوري – السابق ص ٨٧٩ – ٨٨١ ، د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٤٠٧ –٤٠٩ ، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٤٨٧ ، د/ سليمان مرقس – في دراسة الدكتوراه هامش ص ٢٤٠ ، د/ أنور سلطان – المصدر السابق ص ٤٨٥ ، وانظر مجموعة الأعمال التحضيرية ج٢ ص ٣٥٤ –٣٥٥.

وإزاء هذه الانتقادات السابقة فإن أفضل تعريف للخطأ فى المسئولية التقصيرية هو: الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي الموجود فى نفس الظروف الخارجية لمرتكب الضرر مع إدراكه لهذا الانحراف.

## المطلب الأول

## عناصر الخطأ

استبان لنا من تعريف الخطأ أنه يقوم على عنصرين:

الأول: العنصر المادي: وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد.

والثاني: العنصر المعنوي (أو النفسي) وهو الإدراك أو التمييز:

**أولاً: العنصر المادي: فى الخطأ (التعدي):**

التعدي هو: كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي لو وجد – وقت إحداث الضرر– فى نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر؛ فالخطأ يتحقق إذا انحرف الشخص فى سلوكه فأضر بالغير، سواء جاء هذا الانحراف عمدا فأضر بالغير كما فى الجرائم، أم جاء فى صورة إهمال أو تقصير.

وهذا الانحراف الذي يضر بالغير يجب أن يكون المعيار فيه موضوعيًا لا شخصيا؛ لأن المعيار الشخصي يقتضي أن ننظر إلى شخص من وقع منه الانحراف، فإذا كان شديد اليقظة، كان أقل انحراف من جانبه يعتبر خطأ، وإذا كان الشخص مهملا فلن يعتبر سلوكه انحراف إلا إذا كان على درجة كبيرة من الجسامة.[1]

(1) انظر في عرض هذا المعيار :د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٣٢ – وانظر :د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤١٠ ،د/ لبيب أبو ستيت – المرجع السابق ص ٣٤٣ .

وهذا المعيار يقتضي ضرورة الرجوع إلى كل ما يتعلق بالشخص ذاته[1]، حالته النفسية والعقلية والبدنية، وقوة أو ضعف بصره، ومستوى ذكائه وثقافته فالمقارنة تتم بين ما قام به الشخص من سلوك وبين ما كان يجب أن يقوم به وفقا لظروفه هو وليس بالمقارنة مع سلوك شخص آخر.

وهذا المعيار يتميز بأنه واقعي من حيث أنه يأخذ كل شخص بجريرته ويقيس مسئوليته بمعيار من قدراته ومُكناته[2].

**ولكن يؤخذ على هذا المعيار**: أنه لا يتفق مع قواعد العدالة التي يهدف إليها القانون، وخاصة العدل الاجتماعي، ويترتب عليه أن نشدد فى المسئولية على الشخص الحريص اليقظ، وإلى تخفيفها بالنسبة للشخص المهمل غير المكترث، وما ذنب المضرور إذا كان الضرر قد وقع من شخص مهمل لا يعتبر سلوكه انحرافا إلا إذا بلغ درجة كبيرة من الجسامة. [3]

إزاء هذا النقد كان الرأي الراجح فقها وقضاء[4] هو الأخذ بالمعيار الموضوعي (أو المعيار المجرد) فقياس فعل المسئول بمسلك شخص مجرد هو الشخص المعتاد، وهو شخص يمثل الوسائط بين جمهور الناس، شخص متوسط الفطنة واليقظة، حتى

---

(١) انظر: السنهوري – السابق ص ٨٨٣ ، وأنور سلطان – المرجع السابق ص ٤٨٥ ، وانظر: توفيق فرج – المرجع السابق ص ٣٧٠ ، وانظر: في الفقه الأجنبي: مازو في المسئولية المدنية ج١ فقرة ٤١٧ ،وأبرى ورو ج٥ بند ٤٤٤ ، د / يمولومب ج١٦ ف ٤٧٩ ، ومارتي ورينو ج٢ ص ٤٠٠ .

(٢) يأخذ بهذا المعيار قلة من فقهاء القانون المدني منهم: ليجال في رسالته عن الإهمال وعدم التبصر كمصور للمسئولية التقصيرية – باريس ١٩٢٢ ص ٧ وما بعدها .

(٣) السنهوري – المرجع السابق ص ٨٨٣ ،د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٣٣ ، د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٣٤٤ ، د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤١٠.

(٤) السنهوري – السابق –ص ٨٨٤ ، أبو ستيت السابق – الموضع السابق د/ جميل الشرقاوي – السابق ص ٤٧٠ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٤٩١.

إذا تمثلناه فى خاطرنا تساءلنا عما كان يفعله ذلك الشخص لو وجد فى مكان المسئول.

**ويترتب على الأخذ بهذا المعيار:** أنه يجب الاعتداء بالظروف الخارجية للمعتدي دون الظروف الشخصية الداخلية، بل نجرده من هذه الظروف ككونه ضعيف البصر مثلا، أو ثائر الأعصاب أو مريضا، وألا عدنا إلى المقياس الشخصي الذاتي، فإذا قاد شخص سيارته ليلا فى مدينة وصدم أحد المارة، فلا عبرة بكونه صغير السن، أو ضعيف البصر، أو مريضا، أو لم يتعود قيادة السيارات ليلا داخل المدينة؛ لأن هذه كلها ظروف داخلية خاصة به، ومن ثم فيعتبر أنه ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته إذا كان قد انحرف فى سلوكه عما كان يسلكه الشخص العادي التي لا تقوم بالنسبة له هذه الظروف، إذ أن ظروف الزمان والمكان تعتبر – كذلك – ظروفا خارجية مثل وقوع الحادث ليلا، أو نهارا فى طريق وعر أو ممهد ... الخ .

وعلى العكس من ذلك: يجب الاعتداد بالظروف الخارجية الذي وجد فيها من ارتكب الفعل الضار، لأنها ظروف عامة لجميع الناس، ففي المثال السابق يقاس سلوك مرتكب الفعل الضار بسلوك الشخص العادي الذي يقود السيارة ليلا فى المدينة، فإذا كان الحادث قد وقع أثناء قيادة السيارة فى طريق غير ممهد، أو فى شارع شديد الازدحام، تحت وابل من المطر أو فى جو مشرق، أخذت هذه الظروف فى الاعتبار[1]، ومن ثم يجب النظر – عند تحديد المسئولية – إلى سلوك الشخص المعتاد لو أنه كان يقود السيارة فى نفس الظروف .

(1) د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ٣٣ ، وانظر :د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤٢١ ، د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص٤١١ ، د/ الصدة – المرجع السابق ص ٤٩٣.

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن معيار التعدي ينظر فيه إلى سلوك الشخص العادي فى الظروف الخارجية للشخص المعتدي: فإن هذا المعيار ذاته ينطبق على الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي، كما أن هذا المعيار ذاته ينطبق على الخطأ العمدي – أي الذي قع بقصد الإضرار بالغير –، والخطأ بإهمال وهو الخطأ الذي يقع بدون قصد؛ إذ النية فى الخطأ العمدي ليست سوى ظرفا شخصيا لا يصح أن يعتد فى التقدير، كما ينطبق المعيار على الخطأ الجسيم، أي الخطأ الذي لا يرتكبه إلا شخص غبي، والخطأ اليسير، وهو الخطأ الذي لا يرتكبه شخص متوسط العناية والذكاء[1]، ولا يقدح فى هذا أن المحاكم تميل من الناحية العملية إلى زيادة التعويض عن الخطأ الجسيم عنه فى الخطأ اليسير، بل إن المشرع نفسه يعتد بدرجة جسامة الخطأ فى بعض الحالات [2].

وخلاصة القول أن معيار التعدي الخطأ واحدا لا يتغير أيا كان نوع الخطأ وأيا كانت درجة جسامته[3] .

**ثانيًا: العنصر المعنوي فى الخطأ (الإدراك):**

الإدراك هو الركن المعنوي فى الخطأ؛ إذ أن مناط المسئولية التمييز، وبالتالي لا مسئولية دون تمييز، ويتوافر التمييز– فى القانون المصري – ببلوغ الصغير سن السابعة دون أن يعرض له ما يفقده العقل، وكان القانون المدني صريحا فى اشتراط

---

([1]) د/ عبد المنعم الصدة: السابق ص ٤٩٥ ، وانظر: السنهوري– السابق – الموضع السابق ، حشمت أبوستيت – السابق ص ٤١٢ .

([2]) كما في حالة الغرامة التهديدية (٢٤٢ مدني ) وحالة توزيع المسئولية عند تعدد المسئولين عن عمل ضار ( م١٦٩ مدني) .

([3]) انظر في ذلك : نقض مدني في ٣/٢٢/ ١٩٦٦ مجموعة المكتب الفني – س ١٧، ص ٦٣٦ رقم ١٩٨٨ ، ونقض جنائي في ٢/١١/ ١٩٧٣ م ، مجموعة أحكام النقض الجنائي س ١٤ ص ١٨٠ .

التمييز حتى يمكن مساءلة مرتكب الفعل الضار، فنص فى المادة ١/١٦٤على أن: "يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز".

وعلى ذلك فإن من بلغ السابعة من عمره دون أن يعرض له ما يفقده العقل، يسأل مسئولية كامله عن أفعاله غير المشروعة، ويأخذ حكم الصغير المميز كل من فى السفيه وذو الغفلة ومن أصيب بعجز جسماني شديد، وذو العاهتين ( أصم وأبكم ...) حتى ولو فرضت له المساعدة القضائية .

أما الصبي غير المميز، والمجنون، والمعتوه عتها تاما، ومن فقد رشده لسبب عارض كالسكر والغيبوبة، والمنوم تنويما مغناطيسيا والمصاب بمرض النوم ...الخ، كل هؤلاء لا يمكن أن ينسب إليهم خطأ لأنهم غير مدركين لأعمالهم[١]، غير أن فقد التمييز إذا كان راجعا إلى خطأ الشخص كما فى حالة السكر عمدا، فإن من وقع منه الفعل الضار يكون مسئولا عما وقع منه، إلا إذا أثبت أنه كان مضطرا لذلك لسبب مشروع كالعلاج مثلا، أو ثبت أنه لم يعهد فى نفسه من قبل أن يفقد الوعي[٢].

كما أنه يجب لانتفاء المسئولية عن عديم التمييز أن يكون فى مكان المسئول، فإذا كان فى مكان المضرور ونسب إليه إهمال ساعد فى وقوع الضرر اللاحق به، فإن القضاء المصري فى بعض أحكامه يأخذ عديم التمييز بإهماله، كما أن عديم التمييز فى حالات الخطأ المفروض يعتبر مسئولا، فيسأل عن فعل تابعه وعن فعل الشئ الذي هو فى حراسته.

---

(١) د/ السنهوري – السابق ص ٩٠٣ وانظر: د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤٢٥ ، د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٤٢٥ ،د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص٢٣٤.

(٢) انظر: د/ عبد المنعم الصدة – السابق – الموضع السابق ، د/ حشمت أبو ستيت السابق ص ٩٠٩ ، د/ مصطفى مرعي – السابق ف ٦١.

**مسئولية عديم التمييز فى حالات استثنائية:**

انعدام مسئولية التمييز قد تصطدم فى بعض الفروض مع اعتبارات العدالة، من أجل ذلك أجاز القانون المدني المصري مسئولية عديم التمييز فى حالات معينة، إذا قضى فى المادة ٢/١٦٤ مدني على أنه: "ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز، ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .

ويستبين من النص السابق أن مسئولية عديم التمييز تقوم إذا لم يوجد شخص مسئول عنه، أو وجد من هو مسئول عنه ولكن تعذر الحصول على تفويض منه لسبب أو لآخر كسفره أو موته ...الخ، ومن ثم يجوز للقاضي أن يحكم بتعويض عادل على من وقع منه الضرر (الصبي غير المميز) مراعيا فى ذلك مركز الخصوم من يسار وإعسار فى جانب الطرفين وظروف ارتكاب الفعل الضار...الخ، ومسئولية عدم التمييز على النحو السابق تتميز بخصائص أربع:

١- **فهي مسئولية احتياطية أو مشروطه:** أي لا يلجأ إليها إلا إذا لم يجد المضرور سبيلا للحصول على التعويض من شخص آخر غير عديم التمييز الذي أحدث الضرر، كما لو لم يوجد شخص مكلف برقابة عديم التمييز الذي أحدث الضرر، أو وجد ولكن المصاب لم يستطع أن يرجع عليه، إما لأنه استطاع أن ينفي الخطأ عن نفسه أو ظهر – رغم ثبوته مسئوليته – أنه شخص معسر، حينئذ يستطيع المضرور أن يرجع على عدم التمييز طبقا للمادة ٢/١٦٤

٢- **وهي مسئولية استثنائية:** قررت استثناء من القاعدة العامة فى إقامة المسئولية عن الأعمال الشخصية على الخطأ، وفى اشتراط التمييز ركنا أساسيا فى

الخطأ، فهي مسئولية موضوعية لا تقوم على الخطأ، إنما أساسها تحمل التبعية أو "التضامن الاجتماعي".

**٣- وهي مسئولية جوازية:** إذا الحكم بالتعويض على عديم التمييز جوازي للقاضي متروك لتقديره؛ حيث يجب على القاضي أن يراعي مركز الخصوم، فيستطيع أن يلزم عديم التمييز بالتعويض، إذا وجد أنه حالته المالية تسمح بذلك، وله ألا يحكم بالتعويض إذا رأى أن حالة عديم التمييز لا تسمح بذلك .

**٤- وهي مسئولية مخففة:** فإذا رأى القاضي إلزام عديم التمييز بالتعويض[1]، فليس حتما أن يقدر القاضي التعويض بقدر الضرر، بل يقتضي بتعويض "عادل" مراعيا فى ذلك مركز الخصوم.

**مسئولية الشخص المعنوي[٢]:**

الشخص المعنوي ( الوزارة – الشركة- الجامعة ) ليس له إدراك أو تمييز، ولكنه يمارس نشاطه بواسطة ممثلية من الأشخاص الطبيعيين، والمبدأ الذي استقر عليه الفقه والقضاء فى مصر هو جواز مسألة الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي، وهو كما يسأل مسئولية عقدية، يسأل مسئولية تقصيرية؛ لأن المسئولية إنما تقع على ذمة الشخص المعنوي، وإذا كانت المسئولية الجنائية للشخص المعنوي لا يمكن تصورها إلا إذا كانت العقوبة هي الغرامة أو المصادرة أو الحل، فإن المسئولية المدنية بنوعيها (العقدية والتقصيرية) يمكن تصورها تماما؛ لأنها تقع على مال الشخص المعنوي، ومن أمثلة ذلك: مدير شركة يفصل عاملا فى وقت غير لائق، فتكون

---

(١) انظر فيما سبق: د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤٢٦ ، د/ حشمت بو ستيت – المرجع السابق ص ٤٢٢ ، د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٣٥ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٠٠.

(٢) د/ عبد الرزاق السنهوري – المصدر السابق ص ٩١٥ ، د/ محمد كامل مرسي – المرجع السابق ج٢ بند ٢٤ ، د/ أنور سلطان – المرجع السابق ص ٤٣٤ .

الشركة مسئوله عن هذا الفصل، وزارة الصحة تستورد دواء معينا لعلاج مرض معين عند الآدميين ثم يتبين أنه انتهت مدة صلاحيته...الخ، فتكون الوزارة مسئوله عما يحدث من ضرر لأي شخص عن استعمال هذا الدواء، وتتحقق مسئولية الشخص المعنوي فى مصر على النحو الذي تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة، وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين.

فالقضايا التي تقوم على هذه المسئولية بالنسبة إليهما معا تدخل فى اختصاص القضاء العادي؛ أي أن القضاء العادي فى مصر يطبق على مسئولية الدولة والسلطات العامة قواعد المسئولية التقصيرية التي يطبقها على الأفراد والهيئات الخاصة، حتى إن هناك اتجاها قضائيا[1]، يجعل الدولة مسئوله عن الخطأ مسئولية شخصية، وليست مسئولية متبوع عن أعمال تابعه، خلافا لما هو سائد فى فرنسا؛ حيث إن مجلس الدولة هناك هو صاحب الولاية العامة فى جميع التبعة[2]، وهو اتجاه محمود يؤيده بعض الفقه والقضاء المصري[3] .

## رقابة محكمة النقض على ركن الخطأ:

التعدي – وهو العنصر المادي فى ركن الخطأ – يعتبر من مسائل الواقع وتستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض[4]، إلا أن وصف سلوك الشخص بأنه خطأ أو لا، وما إذا كان هذا السلوك أو الوقائع تعتبر تعديا أم لا، يعتبر من مسائل القانون، كذلك ركن "الإدراك" والحدود التي يسأل فيها عديم التمييز مما يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، كما

---

(١) نقض مدني في ١٥/ ٣/ ١٩٥٦ – مجموعة أحكام النقض المدني س ٧ ص ٣١٠ رقم ٤٦ .

(٢) انظر بلانيول وريبير وبولانجيه –السابق بند ٩٧٢، ٩٧٣ ، وكولان وكابيتان ج ٢ فقرة ٣١٤ .

(٣) انظر في ذلك تفصيلا: رسالتنا لني درجة الماجستير – مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة – دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ط ١٩٧٨ والمراجع المشار إليها فيها .

(٤) نقض مدني في ٦/١٢/ ١٩٧٣ – مجموعة أحكام النقض س ٢٤ ص ٨٩٤ رقم ١٥٧ .

أن الحالات الاستثنائية التي يتطلب فيها القانون درجة معينه من الجسامة فى الخطأ، هي من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.[1]

## المطلب الثاني
## أهم تطبيقات الخطأ

هناك تطبيقات كثيرة ومتنوعة للخطأ فى الحياة العملية، ولا يتسع المقام لذكر هذه التطبيقات كلها، ومن ثم فإننا سنقتصر على عرض موجز لأهم هذه التطبيقات وأكثرها وقوعًا فى الحياة العملية:

**١ – حوادث النقل:**

النقل قد يكون بأجر، وقد يكون بغير أجر، والنقل بأجر قد يكون نقلا للأشياء، أو نقلا للأشخاص [2]، وفيما يتعلق بنقل الأشياء بأجر يقع على عاتق الناقل التزام بنقل الأشياء سليمة إلى مكان الوصول، فإذا تلفت هذه الأشياء أثناء النقل، كان الناقل مسئولا مسئولية عقدية لقيامها على التزام يترتب على عقد النقل، وفى نقل الأشخاص بأجر استقر الرأي الحديث – والراجح – على أن عقد النقل يرتب التزاما بضمان سلامة المسافر، ومن ثم تكون مسئولية الناقل عما يصيب المسافر مسئولية عقدية[3] .

---

(١) انظر: نقض مدني في ٢٠/٥/ ١٩٦٥ – مجموعة أحكام النقض ص ١٦ ص ٦١٤ رقم ٩٩ ، نقض مدني في ٢٠/٦/١٩٦٦ – المجموعة السابقة س ١٧ ص ١٤٦٧ رقم ٢٠٨ ، وانظر في الفقه المصري – السنهوري – الساب ص ٩١٧ ، د/ سليمان مرقس – الفعل الضار ص ٥٤ ، د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤٢٥ ، د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٣٥٨ ، وانظر في الفقه الأجنبي بلانيول – السابق وريبير ، يند ٥٩٦ .

(٢) انظر: السنهوري – السابق ص ٩٢١ .

(٣) راجع في ذلك: د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٠٢ ، د/ مصطفى مرعي – المسئولية المدنية بند ٦٦ –٦٩ .

وإذا كان النقل بغير أجر – كانت المسئولية تقصيرية سواء كان نقلا للأشياء أو للأشخاص – كما يصطحب شخص صديقا له فى سيارته للنزهة، فإذا أصيب الصديق بحادث من جراء ركوب السيارة، فإن مسئولية الناقل لا تكون إلا تقصيرية؛ لأنه لا يوجد عقد أصلا، وحتى تتحقق مسئولية الناقل التقصيرية: ذهب رأي إلى أن الناقل لا يسال إلا عن خطئة الجسيم، تأسيسا على المنقول – وإزاء تبرع الناقل – قد قبل النقل– لشخصية أو لأمتعة – محتملا لتبعة الأخطاء التي تحدث من الناقل، وخاصة إذا كانت أخطاء يسيرة، وهذا الرأي أيدته بعض المحاكم الفرنسية[1]، ومحكمة الاستئناف المصرية المختلطة[2]، بيد أن محكمة النقض الفرنسية رفضت هذا الرأي دون تردد على أساس أنه ما دام لم ينسب للمصاب أي خطأ[3]، فكل خطأ من الناقل لا يصدر من الرجل المعتاد يكفي لقيام مسئوليته[4].

**٢– مسئولية الأطباء والجراحين وغيرهم من أصحاب المهن الفنية الأخرى:**

هذه المسئولية وفقا للاتجاه الحديث – مسئولية عقدية ما دام يوجد اتفاق بين المريض والطبيب، وتكون المسئولية تقصيرية إذا لم يكن هناك اتفاق وسواء كانت المسئولية عقدية أم تقصيريه، فإن المعيار الذي يقاس به خطؤه المهني واحد؛ ذلك لأن الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب بمقتضى العقد التزام ببذل عناية، وهي العناية الفنية التي تقرضها أصول المهنة، وهذا هو نفس ما يطلب منه فى المسئولية

---

(١) انظر: سقاتيبة – المرجع السابق ج١ بند ١٢٣ والأحكام الفرنسية المشار إليها فيه .

(٢) استئناف مختلط في ١٣ / ١١/ ١٩٣٠ م ٤٣ ص ١٢ ، وفى ٢ إبريل ١٩٣١ م ٤٣ ص ٣٢٧ ، وفى ١٩ مايو سنة١٩٤٣ م ص ١٦٣ .

(٣) إذ لا يمكن أن يعتبر مجرد قبوله للنقل مجانا: خطأ ، أو انحراف عن السلوك المعتاد .

(٤) نقض فرنسي في ٢٧ مارس ١٩٢٨ – داللوز ١٩٢٨ – ١– ١٤٦ مع تعليق ربيير وسيرية ١٩٢٨ –١– ١٥٣ وفى ٥ مايو سنة ١٩٢٥ سيرية ١٩٤٢ –١ ٢٥ ، ومن الفقهاء الذين أيدوا هذا الرأس ، بلانيول وريبير واسمان – السابق ج١ بند ٦٢٢ ، مازو – السابق ج١ بند ١٢٧٨

التقصيرية، ومن ثم يتعين عليه فى الحالتين أن يبذل القدر من العناية الذي يبذله طبيب عادي وسط من طبقته فإذا لم يبذل تلك العناية اعتبر منحرفا عن السلوك المعتاد وتوفر الخطأ المهني فى جانبه[1].

وقد ذهب بعض الفقه إلى وجوب التمييز فى مزاولة المهنة بين الخطأ العادي والخطأ المهني: ففيما يتعلق بالخطأ المهني لا تجوز مساءلة الأطباء وأصحاب المهن الأخرى ( كالمحامين والمهندسين والمحاسبين ...الخ) إلا إذا كان الخطأ الصادر من أي منهم جسيما، أو كان بحيث لا يمكن اغتفاره، فإذا كان الخطأ يسير فلا يسأل عنه الطبيب.

أما فيما يتعلق بالخطأ العادي – الذي لا يتصل بالمهنة – فإن الطبيب يعامل بشأنه كما يعامل أي شخص آخر، فيتحقق خطؤه لو أنه أجرى عملية جراحية وهو فى حالة سكر، أو كانت يده مصابة بما أعجزها عن الحركة، وعلة هذا التخفيف عن كاهل الأطباء هي الرغبة فى ترك قدر مناسب لهم من الحرية فى العمل حتى يتمكنوا من القيام بعملهم الإنساني وإلا امتنعوا عن مزاولة عملهم وهذا فيه ما فيه من الاضرار بمصلحة المرضى أنفسهم [2] .

ولكن الرأي الراجح فقها وقضاء[3]، هو انه لا محل لتلك التفرقة، ويخضع الطبيب فى كل ما يصدر عنه من خطأ للمعيار المعتاد، فيسأل الطبيب كلما كان الفعل الذي آتاه لا يأتيه طبيب من مرتبته وجد فى ذات الظروف التي أحاطت بالمسئول، ومبررات تخفيف مسئولية الأطباء مرفوضه؛ لأن الأفراد أيضا فى حاجة

---

(١) د/ الصدة – المرجع السابق ص ٥٠٦ ، د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤١٢.

(٢) انظؤ: د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٤١٣.

(٣) انظر: : السنهوري – السابق ص ٩٣٢ – ٩٣٤ ، د/ سليمان مرقس – مسئولية الطبيب ومسئوليه إدارة المستشفى ، بحث في مجلى القانون والاقتصاد السنة السابغ=عة ص ١٥٥ ، ولنفس المؤلف: الفعل الضار – بند ٤٢ ، ٤٤ .

إلى الحماية وعدم تعريضهم لإهمال أو سوء تصرف الأطباء، ومن ثم فالطبيب يسأل عن كل خطأ يصدر منه بلا تفرقه بين خطأ فني وخطأ عادي، ولا بين خطأ جسيم او خطأ بسيط، ومن ثم فهو – فى رأينا – يخضع للمعيار العام فى ضوابط الخطأ على النحو السالف بيانه .

**٣- حالات أخرى للخطأ:**

توجد بعض الحالات الأخرى للخطأ أقل وقوعا فى الحياة العملية وتوجب المسئولية التقصيرية منها مسئولية شركات المياه، والغاز، والنور، ومنها المنافسة التجارية غير المشروعة، ومنها الإجراءات القضائية الكيدية كالدعاوى والدفوع الكيدية، ومنها المضار الفاحشة للجوار (تجاوز المالك فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار– م٨٠٢مدني) ومنها السب والقذف وإذاعة أخبار غير صحيحة تمس السمعة، ومنها فسخ اخطبة، أو الإخلال بالوعد بالزواج الذي يستوجب المسئولية التقصيرية إذا اقترن بأفعال أخرى الحقت ضررا بأحد الطرفين [1]..الخ.

## المطلب الثالث

## حالات انعدام الخطأ

**حالات ثلاث ينعدم فيها الخطأ:**

اهتم القانون المدني بتنظيم حالات محددة يتسبب فيها الشخص بأحداث ضرر للغير، ومع ذلك لا يعتبر فعله خطأ يستوجب مسئوليته ويتحقق ذلك فى حالات ثلاث هي:

---

(١) انظر في ذلك تفصيلا: السنهوري – السابق ص ٩٣٤ – ٩٤٥ ، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٥٠٧ . سمير تناغو – السابق ص ٢٣٩ ،٢٤٠.

**أولاً: حالة الدفاع الشرعي:**

تنص المادة ١٦٦ من التقنين المدني المصري على أنه: "من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله، أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول، على ألا يتجاوز فى دفاعة القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة".

ويستبين من هذا النص أن الدفاع الشرعي عن النفس أو المال لا يعتبر خطأ لأنه السلوك المألوف الذي سيسلكه الشخص العادي لو وجد فى نفس الظروف، وقد قضت محكمة النقض بأن: "العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته، هي بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة بشرط أن يكون تقديره مبنيا على أسباب معقوله تبرره". [1]

**ولكي يتحقق ذلك يجب توافر شروط الدفاع الشرعي وهي:**

**١- أن يكون هناك خطر حال لا يستطيع المعتدي عليه أن يدفعه إلا بإيقاع الأذى بالمعتدي:** يستوي أن يكون الخطر واردا على نفس المدافع أو ماله، أو على نفس الغير أو ماله بشرط أن يكون لهذا الغير من المكانة فى نفس المدافع ما يسوغ قيامه بالدفاع عنه[2]، ولا يشترط وقوع الاعتداء بالفعل، بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع الاعتداء، وللمدافع أن يقدر ذلك متى كان تقديره مبنيا على أسباب معقوله.

---

(١) نقض جنائي في ١٠/ ٥ ١٩٧٦ – مجموعة المكتب الفني س ٢٧ ص ٤٨٢ ، وانظر ى هذا المعنى ايضا نقض جنائي في ١٩٧٦/١٠/٤ – لمجموعة السابقة ص ٢٧ ص ٦٩٨ .

(٢) نقض جنائي في ١٢/٢٨/ ٤٨ – المحاماة ٢٤ص ٢٢١ رقم ٩٨ ، وفى ١٩٣٤/١/١٨ المحاماة ٢٤ ص ٤٦٠ رقم ١٤٩.

٢- **أن يكون إيقاع هذا الخطر عملا غير مشروع:** كالضرب والشرقة، ومن ثم فليس لمن ألقى القبض عليه بطريق قانوني أن يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعي[1].

٣- **أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم لدفع الخطر دون مجاوزة أو إفراط:** فإذا جاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي تحقق خطؤه، ولكنه لا يسأله مسئولية كاملة عن تعويض الضرر الذي أحدثه، إذ يكون خطأ المعتدي قد اشترك فى إحداث الضرر، فتكون مسئولية المدافع مسئولية مخففه[2]، وهذا هو ما أشارت إليه المادة ١٦٦ حين قررت إن المدافع يلتزم بتعويض "تراعى فيه مقتضيات العدالة".

**ثانيا: حالة تنفيذ أمر صادر من رئيس:**

تنص المادة ١٦٧ من التقنين المدني على أنه: "لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقوله، وأنه راعى فى عمله جانب الحيطة".

ويستبين من النص السابق أن تنفيذ أمر صادر من الرئيس ينفي الخطأ عن فعل المرؤوس حتى ولو سبب ضررا للغير، ولكن يجب أن تتوافر الشروط الأربعة الآتية حتى ترفع المسئولية عن رفع الضرر:

١- أن يكون من صدر منه الفعل موظفا عاما.

٢- أن يكون العمل الذي قام به الموظف تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس مباشر، أو غير مباشر، طاعته واجبة أو كان الموظف يعتقد أنها واجبة.

---

(١) السنهوري – المرجع السابق ص ٨٩٤ ،د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٠٩ .

(٢) د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤٢٢ ، ٤٢٣ . ٢

٣- يجب أن يثبت الموظف أنه كان يعتقد مشروعيته الأمر الذي صدر إليه وقام بتنفيذه بحيث يكون هذا الاعتقاد مبنيا على اسباب معقوله، فإذا كان الموظف يعلم أن العمل الذي يقوم به غير مشروع كان مسئولا، ولا يعفيه من المسئولية أن يكون رئيسة قد أمره بذلك، مثال ذلك أن يصدر مأمور القسم أمرا لأحد الضباط بالقبض على شخص أو تفتيش مسكنه دون أن يحصل بذلك على إذن من السلطة التي تملك إصدار الأمر بالقبض أو التفتيش، والضابط يعلم – بحكم ثقافته القانونية – أن هذا الفعل غير مشروع، ورغم ذلك قام بتنفيذ أمر الرئيس [1].

٤- يجب على الموظف أن يثبت أنه راعي فى عمله جانب الحيطة، وذلك بالقياس إلى ما كان يسلكه الموظف العادي إذا ما وجد فى مثل ظروفه.[2]

فإذا توافرت هذه الشروط، انتفت المسئولية عن الموظف الذي نفذ أمر رئيسه، وتثبت المسئولية فى الرئيس الآمر.

هذا فيما يتعلق بإطاعة الرئيس، وهو ما يقال أيضا بالنسبة لإطاعة أمر القانون، فيكفي أن يكون الموظف العام قد اعتقد بحسن نية أنه قام بالعمل تنفيذا لما أمرت به القوانين، أو أن القيام به يدخل فى اختصاصه، وأن اعتقاده هذا كان مبنيا على أسباب معقوله، وأنه لم يأت العمل إلا بعد أن تثبت وتحرى.

**ثالثا: حالة الضرورة:**

تنص المادة ١٦٨ من التقنين المدني على أن: "من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره، لا يكون ملزمًا إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.

---

(١) انظر: في ذلك نقض جنائي في ١٩/١١/ ١٩٧٢ – مجموعة المكتب الفني س ٢٣ ص ١٢١٦ .

(٢) د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٣٩ ، انظر د، عبد المنعم الصدة السابق ص ٥١٠ ، أبو ستيت – السابق ص ٤١٨ ،د/ لبيب شنب –السابق ص ٣٥٢ .

ويستبين من هذا النص أن من أحدث ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره – ليس مصدره الشخص المضرور كما فى حالة الدفاع الشرعي[1] – كما لو أتلف شخص شيئا مملوكا لغيره حتى يتمكن من إطفاء حريق شب فى منزله، ينتفي عن هذا الخطأ الموجب للمسئولية، وهو ما يعبر عنه بـ "حالة الضرورة " ويجب توافر حالة الضرورة الشروط الآتية:

١- أن يكون من تسبب فى الضرر مهددا بخطر حال محدق بنفسه أو بماله، أو بنفس شخص عزيز عليه أو بماله، كسائق السيارة الذي يتفادى الاصطدام بأحد المارة فيصدم سيارة واقفه على جانب الطريق ويحدث بها بعض التلفيات [2].

٢- أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا، لا يد فيه لمن سبب الضرر أو لمن وقع عليه الضرر، كفعل الطبيعة أو فعل الغير، فإذا كان مصدر الخطر هو الشخص الذي أوقع الضرر، كانت مسئوليته كاملة، وإذا كان مصدر الخطر هو من وقع عليه الضرر فى حالة دفاع شرعي ولا يلتزم بأي تعويض [3].

٣- أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر من الضرر الذي أصاب الغير كما لو أتلف شخص كمية من مواد البناء قيمتها ألف جنية فى سبيل إطفاء حريق شب فى سيارة قيمتها ١٠٠٠٠٠ مائة ألف جنية، فإذا كان الخطر المراد تفاديه، أقل من الضرر الذي وقع أو مساويا له، فإن حالة الضرورة لا تقوم ويلتزم من تسبب فى الضرر بالتعويض.

---

(١) أي الفرق بين حالة الضرورة ، وحالة الدفاع الشرعي ، انه في الأولى لا يوجد تدخل من المضرور، خلافا لما يحدث في حالة الدفاع الشرعي ، كما أن المضرور في حالة الضرورة لا سأن له بالحادث الذي أنشأ تلك الحالة.

(٢) تجري محكمة النقض على أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذ وجد خطر يهدد النفس ولا يتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب ( انظر: حكمي النقض السابقين ) .

(٣) انظر: السنهوري – السابق ص ٩٠٠ ،د/ لبيب شنب – السابق ص ٣٥٠ .

وإذا ما قامت حالة الضرورة بالمعنى المذكور، فإن المسئول لا يعفى من التعويض بصفة مطلقه، بل يكون ملزما بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا، والغالب أن يخرج القاضي فى هذه الحالة من نطاق المسئولية التقصيرية، إلى نطاق الإثراء بلا سبب؛ إذ أن هناك افتقار فى جانب من وقع عليه الضرر، وإثراء فى جانب الشخص الآخر بقدر الفائدة التي حصل عليها من دفع هذا الضرر، والتعويض الذي يحكم به القاضي هنا هو أقل القيمتين: الإثراء أو الافتقار، أما إذا لم تتوافر شروط الإثراء بلا سبب بأن لم يحصل أي إثراء لمن قام بالفعل الذي سبب الضرر للغير، فإن التعويض الذي يحكم به القاضي يقوم على أساس فكرة العدالة[1] مجرد عن أي وسيلة أخرى من وسائل الصياغة الفنية كالإثراء بلا سبب أو المسئولية التقصيرية.

# المبحث الثاني

# الضـــرر

**تعريف الضرر وأهميته في المسئولية المدنية**:

الضرر في المسئولية المدنية هو: الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له[٢]، فالضرر هو الركن الثاني للمسئولية، وجوهرها عموماً.

وبدونه لا تنجح دعوى المسئولية تطبيقاً لمبدأ "لا دعوى بغير مصلحة"، فإذا أخطأ محضر في إعلان صحيفة الدعوى، فلا مسئولية عليه إذا ما حكم برفض

---

(١) انظر: فيما سبق تفصيلا د/ السنهوري – السابق ص ٩٠١ –٩٠٢ ، د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٤١ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥١١.

(٢) د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٢٨ ، وانظر د/ سليمان مرقس – السابق (الفعل الضار) ص ١٣٣ ، د/ جمال الدين زكي – المرجع السابق ص ٥٤٦ .

الاستئناف شكلاً متى استبان أن الاستئناف كان واجب الرفض موضوعاً، وإذا شرع شخص في سرقة أو قتل شخص آخر، فإن الجاني يسأل جنائياً عن ذلك الشروع، ولكنه لا يلتزم بأي تعويض تجاه من شرع في سرقته أو قتله إذا كان هذا أو ذلك لم يتأثر بالمحاولة التي كانت موجهة ضده، ولم يلحقه منها أي ضرر[1].

**أنواع الضرر**:

الضرر نوعان: مادي، وأدبي، ولا يقصد من تعبيرنا أن يكون الضرر مادياً إذا وقع تحت الحواس، ويكون أدبياً إن لم يقع تحتها، وإنما يقصد بالضرر المادي، الضرر الذي يصيب الشخص من الناحية المالية، وبالضرر الأدبي الضرر الذي لا يصيبه من تلك الناحية، وسنعالج هذين النوعين بشيء من التفصيل فيما يلي:

## المطلب الأول

## الضرر المادي

**تعريف الضرر المادي وأمثلته:**

**الضرر المادي هو:** كل إخلال بحق أو بمصلحة مشروعة للضرر ذات قيمة مالية[2]، ويشمل في الحالتين ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، ومن أوضح صوره: الاعتداء على حق مالي أيا كان نوعه، سواء أكان حقا عينياً كإتلاف الأموال باختلاف أنواعها، أو سرقة منقول أو اغتصابه، أو كان حقاً شخصياً، كالتواطؤ مع المدين في عدم الوفاء بالتزامه، والاعتداء على حق المؤلف والمخترع إلا إذا لم يترتب على هذا الاعتداء انتقاص للمزايا المالية التي تخولها هذه الحقوق

(1) د/ سليمان مرقس: المرجع السابق ص١٣٥، ود/ اسماعيل غانم: المرجع السابق ص٥١٤.

(2) قرب من ذلك د/ عبد الرزاق السنهوري – المرجع السابق ص ٩٧٠ .

لأصحابها، إذ يكون الضرر هنا أدبياً[1].

وكذلك يعد ضرراً مادياً كل مساس بصحة الإنسان وسلامة جسمه إذا كان يترتب عليه خسارة مالية، كالإصابة التي تعجز الإنسان عجزاً كلياً أو جزئياً، أو تقتضي علاجاً يكلف نفقا، وكذلك المساس بكل حق من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان كالحرية الشخصية، وحرية العمل وحرية الرأي إذا كان يترتب عليه خسارة مالية كحبس شخص دون وجه حق أو منعه من السفر إلى جهة معينة له فيها مصلحة .. إلخ.

على أنه يلاحظ أن الضرر قد يصيب شخصاً آخر نتيجة لإصابة المضرور، ومثال ذلك: القتل، فهو يحدث ضرراً يصيب المقتول في حياته ثم هو بالتبعية يصيب ذويه الذين يعولهم، حيث ينقطع مورد رزقهم، ومن ثم يعد هذا الضرر ضرراً مستقلاً عن الضرر الذي أصاب المقتول، ولهذا إذا ثبت أن المقتول لم يكن يعولهم فلا ينشأ لهم حق شخصي في التعويض عن أي ضرر مادي، وإنما يقتصر حقهم في المطالبة بتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب المقتول ذاته، لأن حق المقتول في التعويض ينتقل إلى ورثته[2].

وقد يكون الضرر إخلالاً بمصلحة مالية للمضرور، حيث يكون الشخص عائلاً لقريب له لا تجب عليه نفقته، ثم يقتل هذا الشخص فإن القريب يضار من ذلك، حيث أضير في مصلحة ماليه له[3]، فإذا ثبت أن المقتول كان يعوله بصفة مستمرة، وأن فرصة الاستمرار في الإنفاق على هذا القريب في المستقبل كانت محققة، فإذا

---

(1) د/ سليمان مرقس – السابق ص ١٣٧ ، وراجع د/ لبيب شنب – الموضع السابق ص ٣٣٩ ، رمضان أبو السعود – السابق – الموضع السابق .

(2) انظر: السنهوري – السابق ص ٩٧٢ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٢٩ .

(3) د/ رمضان أبو السعود – المرجع السابق ص ٣٦٢ ، د/ عبد الرازق فرج – السابق ص ٦٣ .

نجح في هذا الإثبات قضي له بالتعويض بشرط أن تكون المصلحة هنا مشروعة[١]، إذ الخليلة لا يجوز لها أن تطالب بتعويض عن ضرر أصابها بقتل خليلها، لأن مصلحتها في بقاء خليلها غير مشروعة.

**شروط الضرر المادي الموجب للتعويض (شرطان):**

سبق أن ذكرنا أن الضرر المادي هو الإخلال بحق أو بمصلحة مشروعة ذات قيمة مالية للمضرور، إلا أنه يجب أن يكون هذا الإخلال محققا وأن يتضمن المساس بمصلحة مشروعة.

**الشرط الأول: أن يكون الضرر محققاً:**

يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع، بأن يكون قد وقع فعلاً، أو سيقع حتماً في المستقبل.[٢]

ومثال الضرر محقق الوقوع: أن يكون المضرور قد مات، أو أصابه جرح في جسمه، آو حصل تلف في ماله.

ومثال الضرر محقق الوقوع في المستقبل: أن يصاب عامل بإصابة تعجزه عن العمل في الحال، ويكون من المحقق أنها ستؤثر في قدرته على العمل في المستقبل، هذا يتم تعويضه عن كل من الضرر الذي وقع فعلاً نتيجة العجز، والضرر الذي سيقـــع حتماً من جــراء عجزه عن العمل في المستقبل[٣]، وكالحروق الحادثة عن

---

(١) د/ الصدة – المرجع السابق ص ٥٢٩ ، د/ محمود جمال الدين زكي – السابق ص ٥٥٥ .

(٢) انظر: د/ عبد الرزاق السنهوري – المرجع السابق ص ٩٧٥ ، اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤١٥ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٣٠ .

(٣) د/ سليمان مرقس – المرجع السابق ص ١٣٩ ، د/ حسام الدين الأهواني – المرجع السابق ص ٥٠٦ ، د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٣٣٩ ، د/ سمير تناغو – السابق ص ٢٤٧ .

الأشعة، والتي تبدو أول الأمر هينة، ثم تتمخض عن ضرر جسيم في المستقبل[١].

فإذا أصيب شخص بضرر لم تعرف بعد درجة خطورته، فإن القاضي يحكم بالتعويض عما وقع فعلاً من الضرر، ويحفظ للمضرور حقه في الرجوع إلى القضاء فيما لو ساءت حالته مستقبلاً، كما يستطيع أن يؤجل الحكم بالتعويض حتى يستبين الضرر كله، كأن يكون المصاب تحت العلاج، ولم يعرف بعد ما إذا كان الخطأ سيؤدي إلى الشفاء، أو إلى تخلف عاهة مستديمة، أو الوفاة، ولكل ما يناسبه من تعويض، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك[٢]، كما أن القضاء يستطيع إذا رأى أن المصاب سيظل عاجزاً عن العمل أن يحكم له بتعويض في صورة مرتب مدى الحياة[٣]، وإلى هذه الفروض تشير المادة ١٧٠ من التقنين المدني المصري بقولها: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ٢٢١، ٢٢٢ مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً[٤] نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير".[٥]

---

(١) د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤٣٦ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٣٠ ، د/ جميل الشرقاوي – المرجع السابق ص ٤٥ ،د/ رمضان أبو السعود السابق ص ٣٦٣ .

(٢) انظر في هذا المعني نقض مدني ٢ فبراير سنة ١٩٧٧ ، مجموعة أحكام النقض المدني س ٢٨ ص ٣٩٥نقض مدني في ١٠ / ٦ / ١٩٦٥ المجموعة السابق س ١٦ ص ٧٣٦ رقم ١١٧ .

(٣) انظر: نقض مدني في ٦/٧/ ١٩٣٤ – مجموعة أحكام النقض جـ ١ ص ٤١٥ رقم ١٩٠ ، نقض مدني في ١٩٢٤/٣/٢٦ – المجموعة السابقة جـ٣ ص ٤٢٢ رقم ١٥ .

(٤) انظر :د/ حشمت – المرجع السابق ص ٤٣٦ ، د/ محمود جمال الدين زكي – المرجع السابق ص٤٥٩ -٥٥٠

(٥) انظر: مجموعة الاعمال التحضيرية جـ٢ ص ٢٩٢.

كما تنص المادة ١٧١ على أن "يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطاً، كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين أن يقدم تأمينا".

وإذا كان الضرر قد تفاقم عما كان عليه وقت تقدير القاضي له كأن كف بصر العامل الذي بدت إصابته طفيفة عند تقدير التعويض، هنا لا مانع يمنع المضرور من أن يرفع دعوى جديدة يطالب فيها بتعويض جديد عن الضرر الذي لم يكون القاضي توقعه، ولا يحول دون ذلك قوة الشيء المقضي، وذلك لاختلاف موضوع الدعويين[١]، أما لو كان الضرر قد تناقص عما كان قدره القاضي وأقام عليه حكمه – كأن يعافي المصاب من الشلل الذي كان قد أصابه عند وقوع الخطأ –، فإن معاودة النظر في التعويض بغية إنقاصه غير ممكنة، لأن تقدير القاضي للتعويض قد حاز قوة الشيء المقضي[٢].

وتأسيساً على ما تقدم فإنه لا يكفي أن يكون الضرر محتملاً، وهو الضرر الذي لم يقع بعد، وليس من المؤكد أنه سيقع في المستقبل، بل هو قد يقع وقد لا يقع، مثال ذلك إصابة سيدة حامل إصابة لم يترتب عليها إجهاضها، وليس من المؤكد أن الإجهاض سيقع، فيكون الإجهاض ضررًا احتمالياً لا يجوز المطالبة بتعويض عنه إلا إذا تحقق بالفعل[٣]، كما لا يجوز لجيران المحلات التي تتاجر في مواد خطرة أو مخازن المواد المتفجرة أن يطالبوا بالتعويض عن الإضرار التي قد تلحقهم نتيجة انفجارات محتملة لم تقع بعد.

---

(١) انظر في ذلك: د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤٣٧ .

(٢)انظر: في الفقه الفرنسي: مازو – السابق – فقرة٢٢٨ ، ٢٣٠ ، وبلاينول وريبير جـ٦ فقرة ٥٤٣ ، ونقض فرنسي في ١٩٣٩/٢/٨ – سيري ١٩٣٩ –١– ٢٩ .

(٣) د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤١٥ ، وانظر: محمود جمال الدين زكي – المرجع السابق ص ٥٥٠

**التعويض عن الفرصة الفائتة**:

يجب التمييز بين الضرر المحتمل، والذي لا محل للتعويض عنه، وبين تفويت الفرصة الذي يجب التعويض عنه، لأن الفرصة إذا كانت أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يترتب عليه ضرر حال، ومثالها أن يصدر من شخص خطأ يفوت على طالب فرصة دخول الامتحان، أو فرصة الدخول في مسابقة لشغل وظيفة (بأن يحجب عنه موعد الامتحان مثلاً) أو فرصة الدخول في سباق للسيارات أو الخيل، أو فرصة الترقي إلى درجة أعلى فهذه كلها أمور محتملة قد تحقق وقد لا تتحقق، إلا أن تفويت فرصة الوصول إليها يقضي على ذلك الاحتمال، ومن ثم فإن الضرر المتمثل في تفويت الفرصة يعد ضرراً محققاً يجب التعويض عنه[1]، ويقدر القاضي التعويض على أساس مدى احتمال نجاح تلك الفرصة الفائتة.

وقد أخذ القضاء المصري بوجوب التعويض عن تفويت الفرصة، حيث قضت المحاكم المصرية بالتعويض لطالب حرم من دخول الامتحان دون حق[2]، وقضت لموظف بالتعويض عن فصله دون حق، وتفويت الفرصة عليه في الترقي إلى درجة أعلى[3]، وللمعول عن قتل عائله وحرمانه بذلك من فرصة استمرار ذلك العائل في إعالته[4].

---

(1) انظر: السنهوري – السابق ص ٩٧٩ ، د/ سليمان مرقس – المصدر السابق ص ١٤٦ ، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٣٢ ، د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٥١٦.

(2) حكم محكمة القضاء الإداري في ٢٧/ ١٩٤٨/٤ – مجلة التشريع والقضاء ١-٢٥-٢٣

(3) نقض مدني في ١٣ / ١١ /١٩٥٨ – المحاماة –٣٩ ١٠٢٥ –٣٢٩ .

(4) نقض مدني في ١٣ / ٢ /١٩٥٦ ، مجموعة أحكام النقض المدني في ص ٧ رقم ١٥٢ ، وانظر نقض مدني في ١٩٧٦/٣/١٥ – المجموعة السابقة – س ٢٧ ص ٦٤٦ ، نقض مدني في ٢٧ / ٣ / ١٩٨٠ المجموعة السابقة س ٣١ ص ٩٣٧ ، نقض مدني في ١٦٦/ ٥ / ١٩٧٩ – المجموعة السابقة س ٣٠ ص٣٦١.

**الشرط الثاني: أن يتضمن الضرر المساس بمصلحة مالية مشروعة:**

سبق أن ذكرنا أن المساس بحق للمضرور يمثل ضرراً يستوجب التعويض، وذكرنا أمثلة عديدة لذلك المساس، فإصابة شخص في جسمه، أو إتلاف ماله ضرر بغير شك، على أن الضرر قد يكون إخلالا لمجرد مصلحة لا ترقى إلى مرتب الحق[1]، كقتل الخاطب بعد أن قامت المخطوبة بإعداد منزل الزوجية، فإنه كان من مصلحتها – وإن كان ليس من حقها – أن تتزوجه وهي مصلحة يقرها القانون وقتله أدى إلى ضياع كثير من النفقات التي بذلتها لإعداد منزل الزوجية، ومن ثم فقد أصيبت بخسارة مالية، أي بضرر مادي يعطيها الحق في طلب التعويض وكالشخص الذي يعول أحداً من أقاربه أو ممن يلوذ به دون أن يلزمه القانون بالنفقة عليه، فإذا قتل العائل في حادث، فإن القريب يضار بفقد عائله، والضرر هنا لا يتضمن المساس بحق، فالفرض أنه لم يكن صاحب حق في النفقة، وإنما يتضمن المساس بمصلحة فحسب، بشرط أن يثبت طالب التعويض أن المتوفى كان يعوله على نحو مستمر، وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة.

على أنه يراعى أن المصلحة المالية التي يعد الإخلال بها ضرراً هي المصلحة المشروعة، فلا محل لتعويض الخليلة عن ضرر يصيبها بفقد خليلها، حتى ولو كان قائماً بالإنفاق عليها، لأن مصلحتها من بقاء خليلها موالياً للإنفاق عليها مصلحة غير مشروعة، على أنه من نافلة القول التذكير بأن المصلحة تكون غير مشروعة إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

---

([1]) د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق – ص ٤١٦.

# المطلب الثاني
# الضرر الأدبي أو المعنوي

**ماهية الضرر الأدبي:**

**الضرر الأدبي هو:** الضرر الذي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية، وقد رأينا أن الضرر الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مالية مشروعة هو ضرر مادي، وإذا كان الضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله، فهو بذلك المعنى يشمل كل ألم يصيب الشخص سواء كان ألماً جثمانيا أو ألماً نفسياً ترتب على المساس بكرامته أو عاطفته أو شعوره أو بأي معنى من المعاني الأدبية التي يحرص عليها الناس.

وتوضيحاً لذلك يمكن إرجاع الضرر الأدبي إلى أحد الأنواع الآتية:

أ- الضرر الذي يصيب الشرف أو الاعتبار أو العرض، كالقذف والسب، وهتك العرض، وإيذاء السمعة وإطلاق الشائعات الكاذبة على شخص ما، كل هذه أفعال تحدث ضرراً أدبياًح إذ هي تضر بسمعة المصاب وكرامته، وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس[1].

ب- الضرر الذي يصيب الجسم من جروح أو ألم أو تشويه في الوجه أو الأعضاء أو في الجسم بوجه عام.

ج- الضرر الذي يصيب الشخص في عاطفته أو شعوره، كخطف طفل من حضن أمه، أو قتل عزيز على الشخص أو الاعتداء على الأم والأب أو الزوج أو

---

(1) انظر: السنهوري، السابق ص: ٩٨١، د / إسماعيل غانم ، المرجع السابق، ص: ٤١٧، د/ عبد المنعم الصدة . المرجع السابق، ص: ٥٣٣.

الأولاد، ويتصل بذلك كل عمل يصيب الشخص في معتقداته الدينية وشعوره الأدبي[١].

د- الضرر الذي يقع على الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، كدخول شخص عنوة في أرض مملوكة للغير.

كل هذه أضرار أدبية، وإن أمكن أن نميز فيما بينها بين ضرر أدبي محض، أي لا يقترن به ضرر مادي، كالضرر الذي يصيب الشخص في عاطفة المحبة والحنان، وضرر أدبي يمكن أن يقترن به ضرر مادي، كضرر يصيب الجسم (جرح مثلاً) وينجم عنه نقص في القدرة على الكسب، وكضرر يقع على الشرف إذا كان المضرور صاحب حرفة يؤذيها سوء القالة[٢].

ويجب في كل الأحوال أن يكون الضرر الأدبي محققاً[٣]، غير احتمالي، كما هو الشأن في الضرر المادي تماما.

**الضرر الأدبي كالضرر المادي يخول الحق في التعويض**:

الضرر الأدبي يجعل للمضرور حقاً في طلب التعويض كالضرر المادي تماماً[٤]، وقد كان التعويض عن الضرر الأدبي مثار خلاف بين الفقهاء في مصر[٥]

---

(١) د / سليمان مرقس، المرجع السابق، ص: ١٥٨، وما بعدها، د/ حشمت أبو ستيت المرجع السابق، ص: ٤٤٠.

(٢) انظر: السنهوري . السابق، ص: ٩٨٢، د / حشمت أبو ستيت، السابق، ص: ٤٤٠.

(٣) د/ السنهوري السابق، الموضع السابق، وانظر: إسماعيل غانم ، السابق، ص: ٤١٧، وفقرة ٢٨٤، ص: ٤٩٠، وما بعدها من هذا المؤلف.

(٤) انظر في ذلك: نقض في ١٩٧٦/٦/٢١ مجموعة أحكام النقض المدني س ٢٧، ص: ٦٧ .

(٥) انظر في عرض هذه الآراء تفصيلاً: د / إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص: ٤١٨، د / حشمت أبو ستيت، المرجع السابق، ص: ٤٤٠، وهامش (١) بذات الصحيفة، د / عبد الرزاق السنهوري . المرجع السابق، ص: ٩٨٤.

وفرنسا[١] بيد أن هذا الخلاف لم يعد موجوداً الآن، حيث إن الفقه والقضاء المصري[٢] والفرنسي[٣] مستقران منذ أوائل القرن الماضي على جواز التعويض عن الضرر الأدبي سواء في المسئولية العقدية أو في المسئولية التقصيرية، وقد أقر القانون المدني ذلك في المادة ٢٢٢ التي تنص على أنه: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا...".

**متى ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة بعد وفاة المضرور**:

تنص المادة ٢٢٢ من التقنين المدني المصري على أنه: "١- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير، إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.

٢- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب".

ويتبين من نص الفقرة الأولى من المادة السابقة أنه وإن كان قد قرر مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي إلا أنه احتفظ له بطابعه الشخصي، فلا يجوز في الأصل أن ينتقل إلى الورثة بعد وفاة المضرور، وإذا كان المضرور لم يطالب به أثناء حياته، أي أن الحق في التعويض عن الضرر ينقضي بوفاة المضرور، ولا ينتقل التعويض – أياً كان سبب الانتقال – إلى الورثة إلا بإحدى طريقتين:

---

(١) انظر: بلانيول وروبير . المرجع السابق، ج٦، فقرة ٥٤٦.

(٢) انظر: السنهوري السابق، ص: ٩٨٥، د / سليمان مرقس، المرجع الساب، ص: ١٥٨ وما بعدها، د / لبيب شنب، المرجع السابق، ص: ٣٤٠ .

(٣) انظر في الفقه الفرنسي منيال في مقال له في المجلة القانونية ١٨٨٤ ، أسمان في مقال له في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة ١٩١٣.

١- أن يكون قد تم اتفاق بين المضرور وبين المسئول بشأن التعويض ومقداره على أساس أن التعويض أثر للعقد الذي تنصرف آثاره إلى الخلف العام الذي فصلناه في حينه.

٢- أن يكون المضرور قد رفع دعوى للمطالبة بالتعويض أمام القضاء حتى ولو لم يكن قد صدر فيها حكم بعد؛ لأنه برفع الدعوى يكون قد أكد عدم تنازله عن الحق في التعويض.[١]

وعلى ذلك إذا مات المضرور دون أن يتفق أو أن يطالب قضاء بتعويض عما أصابه من ضرر، فلا ينتقل الحق في التعويض إلى ورثته بل يزول الحق فيه بموته.

**أسباب الحق في التعويض عن الضرر الأدبي:**

التعويض – كقاعدة عامة – يثبت لكل من أصابه ضرر ذاتي، وقد حددت المادة ٢/٢٢٢ الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بتعويض عن الضرر الأدبي – الالم الذي أصابهم من جراء موت عزيز عليهم –، فنصت على أنه: "لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب".

وعلى ضوء هذا النص يكون الحق في المطالبة بالتعويض مقصورا على الأبوين، والجدين والجدتين والأولاد، وأولاد الأولاد، والإخوة، والأخوات، بشرط أن يثبت كل منهم ما أصابه من ألم، ولا يتحتم الحكم لكل من هؤلاء لمجرد صلته بالميت، إذ لا يحكم بالتعويض إلا لمن يثبت من هؤلاء أنه قد أصابه ألم حقيقي من

---

(١) د/ عبد الودود يحيى . المرجع السابق، ص: ٢٥٥، وانظر: د/ حشمت أبو ستيت ، المرجع السابق، ص: ٤٤٣، د / إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص: ٤١٩، د / محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص: ٥٥٧

موت المصاب[1]، وقد أراد المشرع بتحديد نطاق الادعاء بوقوع ضرر أدبي على هذا الوجه منع المغالاة، واحتمالات الاستغلال من ذوي قرابة الميت البعيدين، بل ومن أصدقائه ومريديه في بعض الأحيان.

## المبحث الثالث
## علاقة السببية بين الخطأ والضرر

**تمهيد:**

المسئولية المدنية تستوجب توافر أركان ثلاثة: الخطأ، الضرر، علاقة السببية، فلا يكفي لقيام المسئولية أن يرتكب شخص خطأ، ويصاب آخر بضرر، بل يجب أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في الضرر[2]، وهذه هي علاقة السببية التي تعتبر الركن الثالث للمسئولية التقصيرية، وتتفق مع المسئولية العقدية، ومن المسلم به به فقهاء وقضاء أن السببية بين الخطأ والضرر يجب أن تكون محققة، ومباشرة، فقد يقع الخطأ والضرر، ولكن لا توجد بينهما رابطة السببية، فلا تقوم المسئولية، كما إذا قاد شخص سيارة بدون رخصة ثم دهس شخصاً ظهر فجأ في طريقه فأصابه إصابة أدت إلى موته، فإن السائق لا يكون مسئولاً عن هذا الحادث بالرغم من خطئه في القيادة دون ترخيص، وبالرغم من الضرر الذي أصاب المجني عليه وذويه، وذلك لانعدام السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر، أي أن القيادة بدون رخصة ليست هي السبب في وقوع الضرر، وإنما خطأ المصاب هو الذي أحدث

---

(1) انظر فيما سبق، السنهوري ، المرجع السابق، ص: ٩٨٨، د / إسماعيل غانم . المرجع السابق، ص: ٤١٨، د / حشمت أبو ستيت ، المرجع السابق، ص: ٤٤٢.

(2) انظر في ذلك: السنهوري، المرجع السابق، ص ٩٩٠، ٩٩٢، د / سليمان مرقس، المرجع السابق، ص: ٤٥٦، د / جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص: ٥٦٣، د/ عبد الودود يحيى . المرجع السابق، ص: ٢٥٦.

الضرر[1]، ومثل أن يدس شخص لآخر سما في شرابه، وقبل أن يسري السم في جسم المسموم يقوم شخص ثالث بقتل من شرب السم بإطلاق عيار ناري عليه، فهنا وقع الخطأ ممن دس السم، وحصل ضرر هو موت المصاب، إلا أنه لا سببية؛ لأن الموت كان بسبب إطلاق العيار الناري على المجني عليه، وليس دس السم، فقد وجد الخطأ[2] والضرر، ولم توجد علاقة السببية، ومن ثم انعدمت المسئولية، ويلاحظ أن معرفة ما إذا قامت السببية بين الخطأ والضرر أم لا مسألة دقيقة، ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين:

**الأول:** أن الضرر قد يقع نتيجة لعدة أسباب وليس لسبب واحد، كما لو حدث الضرر نتيجة خطأ المدعي أو قوة قاهرة ... إلخ، وهنا يجب معرفة ما إذا كانت السببية متوفرة بالنسبة إليها جميعًا أم بالنسبة إلى بعضها فقط، وإن قبل بتوافرها، فما أثر ذلك التعدد على مسئولية المسئول عن واحد منها؟ ومن ثم يجب البحث عن السبب الحقيقي للضرر[3].

**الثاني:** أنه كثيراً ما يسبب السبب الواحد أضرارا متلاحقة، فهل يسأل المخطئ عن هذه الأضرار كلها أم عن بعضها فقط؟ والعامل الأول هو ما يسمى "تعدد الأسباب" والعامل الثاني هو ما يسمى بـ "تسلسل الأضرار"، حيث يوجد إلى جانب الضرر المباشر ضرر آخر غير مباشر وهذا ما سنعالجه تفصيلا في المطلبين الآتيين:

---

(1) انظر: د/ سليمان مرقس، المرجع السابق، ص: ٤٥٦، د / عبد الودود يحيى ، المرجع السابق، ص: ٢٥٦ .

(2) د / عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: ٩٩١.

(3) د/ حشمت أبو ستيت . المرجع السابق، ص: ٤٤٤، د / محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، الموضع السابق، د / سمير تناغو ، السابق، ص: ٢٥١.

# المطلب الأول
# تعدد الأسباب

**نظريتان أساسيتان:**

إذا تعددت الأسباب التي اشتركت في إحداث الضرر، فإن البحث يدور عن السبب الحقيقي للضرر، هل نأخذ بها جميعا طبقا لنظرية تعادل أو تكافؤ الأسباب؟ أم نأخذ منها فقط بالأسباب المنتجة طبقاً لنظرية "السبب المنتج" أو الفعال؟ ظهر في هذا الصدد نظريتان ألمانيتان كان لهما أثرهما الهام أو الفعال في الفقه والقضاء:

**أولا**: **نظرية تعادل أو تكافؤ الأسباب**:

صاحب هذه النظرية الفقيه الألماني فون بيري، ومضمونها أن كل سبب له دخل في إحداث الضرر بحيث لولاه لما وقع الضرر يعتبر من الأسباب التي أحدثت الضرر[1]، فجميع الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر تكون متكافئة أو متعادلة.

**وتطبيقاً لهذه النظرية:** إذا أهمل شخص وترك مفتاح سيارته فيها أثناء وقوفها في الشارع، فسرقها آخر وقادها بسرعة كبيرة، فأصاب أحد المارة، فإن خطأ كل من هذين الشخصين (صاحب السيارة والسارق) يعتبر سببا للضرر، والسببان متكافئان، ومن ثم يسأل كل منهما عن الضرر الذي أصاب الغير.

**ثانياً**: **نظرية السبب المنتج (الفعال) أو السبب المباشر**:

هذه النظرية قال بها الفقيه الألماني فون كريسي ومضمونها إنه إذا تعددت الأسباب التي لها دخل في إحداث الضرر، فلا يعتبر سبباً للضرر إلا الأسباب التي تؤدي عادة إلى الضرر، أما تلك التي تنتج الضرر بصفة عارضة فلا تفيد أسباباً

---

(1) انظر في ذلك: السنهوري، المرجع السابق، ص: ١٠٢٦، د / محمود جمال الدين زكي . المرجع السابق، ص: ٥٦٤، د/ عبد الودود يحيى ، المرجع السابق، ص: ٢٦٤.

للضرر، فالسبب العارض غير السبب المنتج، والأخير هو السبب المألوف الذي يحدث الضرر في العادة، بينما السبب العارض هو السبب غير المألوف الذي لا يحدث الضرر عادة، ولكن أحدثه عرضاً [١].

وتقول النظرية إن الذي يجب الاعتداد به هو السبب المنتج دون السبب العارض، ففي المثال السابق يعتبر خطأ صاحب السيارة الذي ترك مفتاحها فيها وهي في الشارع سبباً عارضاً، لا يحدث الضرر عادة، أما خطأ من أخذ السيارة وقادها بسرعة فهو سبب منتج؛ لأنه هو الذي يحدث الضرر في العادة، ولذلك لا يجب الاعتداد إلا به، ومن ثم يعتبر من أخذ السيارة هو المسئول الوحيد عن الضرر، وهذه النظرية (نظرية السبب المنتج) هي النظرية السائدة في الفقه الأجنبي[٢]، والمصري[٣] والقضاء المصري[٤] والفرنسي[٥]؛ لأنها هي التي تتفق مع الواقع ومن ثم فهي الأحرى بالاتباع؛ لأنها صالحة بمنطقها لتكون أساسا صالحاً لتأصيل كثير من أحكام القضاء، وإن كانت نظرية تكافؤ الأسباب أيسر وأبعد عن التحكم التي لابد من مصادفته عند استقصاء الأسباب التي أنتجت الضرر[٦].

---

(١) السنهوري ، السابق، ص: ١٠٢٧، د / أنور سلطان، السابق، ص: ٤٦٢، وانظر: د/ لبيب شنب، المرجع السابق، ص: ٣٦١.

(٢) مازو . المسئولية ط: ٦، ج٢ ف ١٤٤٢، ومارتي ورينو ، السابق، ج٢ ف ٤٨٠ وروبير ، المرجع السابق، ( المسئولية ) ص: ٦١٧ وما بعدها.

(٣) د/ عبد الرزاق السنهوري . السابق ص: ١٠٢٨ د/ الصدة ، المرجع السابق، ص: ٣٩ .

(٤) قضت محكمة النقض المصرية بأنه " يجب عند تحديد المسئولية الوقوف عند السبب المنتج في إحداث الضرر دون السبب العارض " نقض مدني في ٢٦/ ١٩٦٧/١٠، مجموعة أحكام النقض المدني س ١٨، ص١٥٦٠.

(٥) انظر نقض فرنسي في ١٩٤٣/٥/٧ ، دالوز التحليلي ١٩٤٢ ص ٥١، نقض فرنسي في ١٩٦٥/٢/٥، دالوز ١٩٦٥، قضاء ، ص ٣٣٧، ونقض فرنسي ١٩٥٩/١/٢١ ، داللوز . قضاء ص: ٢٠٨.

(٦) د / حشمت أبو ستيت ، المرجع السابق، ص: ٤٤٥.

## المطلب الثاني

## انعدام السببية عند الضرر غير المباشر أو لقيام السبب الأجنبي

**تمهيد:** يمكن للمدعي عليه بالمسئولية أن ينفي رابطة السببية بين خطأه والضرر الذي أصاب المدعي عليه بأحد طريقين:

**أولهما:** أن يثبت أن خطأه ليس هو السبب المنتج للضرر، أو بمعنى آخر أن يثبت أن الضرر ليس مباشراً[1]، وهو ما يعرف في كتب الفقه بـ "تسلسل النتائج أو تعاقب الأضرار.

**ثانيهما:** أن يثبت أن الضرر نشأ عن "سبب أجنبي" وهذا ما سنبحثه تفصلاً في البندين الآتيين:

**أولاً: انعدام المسئولية عند الضرر غير المباشر (تسلسل النتائج أو تعاقب الأضرار)**

في هذا الفرض لا تتعدد أسباب الضرر، بل يكون السبب واحداً والأضرار هي التي تتعاقب عن السبب الواحد، فصارت أضراراً متعددة،[2] وهنا يثور التساؤل: ما هي الأضرار التي يسأل عنها من ارتكب الخطأ، وتلك التي لا يسأل عنها لانعدام علاقة السببية بينهما وبين الخطأ؟

وللإجابة على هذا التساؤل نقول: أن المستقر عليه قانوناً أن المسئولية لا تكون إلا عن الضرر المباشر وحده، فلا يسأل الشخص عن الأضرار غير المباشرة عن خطئه، سواء في ذلك المسئولية العقدية أم المسئولية التقصيرية.

وهناك مثال تقليدي مشهور في هذا الصدد نقلاً عن الفقيه الفرنسي (بوتييه) وهو خاص بالمسئولية العقدية، ولكنه ينطبق أيضاً على المسئولية التقصيرية، ويتعلق

---

(1) د/ لبيب شنب ، المرجع السابق، ص: ٣٦٤.

(2) انظر في التمييز بين تعدد الأسباب وتسلسل النتائج تفصيلاً: السنهوري، السابق، ص: ١٠٢٩، د / عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص: ٥٥٣، د / رمضان أبو السعود ، المرجع السابق، الموضع السابق.

المثال بتاجر مواشي يبيع بقرة موبوءة (مصابة بالطاعون) فنقلت العدوى إلى مواشي المشتري، فتموت ويموت معها سائر المواشي، ونشأ عن ذلك عجز المشتري عن زراعة أرضه، فيعوزه المال، فلا يستطيع الوفاء بديونه، فيحجز الدائنون على أرضه ويبيعونها عليه بثمن بخس، فهذه أضرار متعاقبة يجر بعضها بعضاً: موت البقرة الموبوءة، وعدوى مواشي المشتري وموتها، العجز عن زراعة الأرض، العجز عن وفاء الديون، الحجز على الأرض وبيعها بثمن بخس، فأي الأضرار يعتبر نتيجة مباشرة لبيع البقرة المريضة يسأل عنها المخطئ، وأيها لا يعتبر نتيجة مباشرة، ومن ثم لا يسأل عنها؟

يرى بوتيه[1] – بحق – أن الأضرار المباشرة التي يجب التعويض عنها هي موت البقرة الموبوءة، وعدوى المواشي وموتها، أما عجز المشتري عن زراعة أرضه، وعن وفاء ديونه ... إلخ، فهي أضرار غير مباشرة لا يستحق التعويض عنها؛ لأن المشتري كان يستطيع توقيها وأن يتجنب تلك الأضرار ببذل جهد معقول.

وهناك مثال آخر من القضاء المصري إذ قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأنه: "إذا تلفت آلات وابور ري بسبب حادث حصل لقطار كانت مشحونة فيه، فلا تسأل مصلحة السكك الحديدية عن الضرر غير المتسبب مباشرة من الحادث كالضرر الذي ينشأ عن عدم تركيب الوابور الذي تلف (نتيجة حادث القطار) على بئر ارتوازية وتعذر الانتفاع بها، وتلف زراعة صاحب البئر، وزراعة الأطيان المجاورة التي كان متعهداً بريها، والتزامه بتعويض أصحاب هذه الأطيان.[2]

---

(1) السنهوري، السابق، ص: ١٠٣٠، وانظر: سليمان مرقس، المرجع السابق، ص: ٤٦٨، د / عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص: ٥٥٣، د / لبيب شنب، المرجع السابق، ص: ٣٦٥.

(2) استئناف في وطني ١٩١٤/١٠/٢٢ ، الشرائع، ص: ٢٤٧ – ٥١ / ٢.

وقد أخذ القضاء المصري حديثا بهذا الاتجاه حين قرر أن التعويض لا يكون إلا عن الأضرار المباشرة فقط[1]، لأن الأضرار غير المباشرة يمكن توقيها ببذل جهد معقول.

وإذا كان الفقه والقضاء مستقران على أن المسئولية لا تكون إلا عن الضرر المباشر فقط، على النحو السابق ذكره، إلا أ نه يجب وضع معيار دقيق لهذا الضرر، حتى يمكن بعد ذلك معرفة الأضرار غير المباشرة التي لا يعوض عنها لانقطاع السببية بينها وبين الخطأ، بيد أن تحديد هذا المعيار أمر في منتهى الصعوبة والدقة، إلا أنه باستقراء أحكام المحاكم يمكن أن يستنبط فيها المعيار الذي يمكن الاهتداء به في اعتبار الضرر مباشراً، فقد عرفت محكمة الاستئناف المختلطة الضرر المباشر بأنه: "الضرر الذي لم يكن في وضع المصاب أن يتوقاه ببذل جهد معقول".

وقد حددت المادة ٢٢١ /١ مدني معيار الضرر المباشر فقالت إنه: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخير في الوفاء، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول"[2].

فالضرر المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي حدث، والضرر يعتبر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

---

(1) نقض مدني في ٨ يونية ١٩٨٢، طعن رقم ٢٠٧٥ لسنة ٥١ ق، ونقض مدني في ٥ يناير سنة ١٩٨٤ ، الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٥٠ ق.

(2) استئناف مختلط في ٧ يونية ١٩٢٨ – ٤٠ ص ٤١٨ .

وإذا طبقنا هذا المعيار على المثالين المذكورين أمكننا القول أن موت البقرة المريضة في المثال الأول وموت المواشي التي انتقلت إليها العدوى نتيجة طبيعية أو مباشرة لخطأ البائع، أما ما أعقب ذلك من أضرار متلاحقة فيعتبر أضرارا غير مباشرة أو نتيجة غير طبيعية؛ لأن المشتري كان يستطيع أن يتوقاه ببذل جهد معقول، ومن ثم لا محل للتعويض عنها[1] .

وفي المثال الثاني نجد أن تلف آلات الوابور بسبب الحادث يعتبر ضرراً مباشراً يجب التعويض عنه، لأن صاحبها ما كان يمكنه أن يتلاقى هذا الضرر أما ما تلى ذلك من عدم الانتفاع بالبئر الذي حفرها، وعدم زراعة الأرض والعجز عن ري الأرض المجاورة، ودفع تعويض للمزارعين ... إلخ فهذه أضرار غير مباشرة لا يعوض عنها؛ لأنه كان يستطيع أن يتلافاها ببذل جهد معقول، وهو الالتجاء إلى وسيلة أخرى للري، مع ملاحظة أن الفرق بين تكلفة الري[2] بالوسائل الأخرى التي يلجأ إليها، وتكاليفه لو أن آلات الوابور لم تتلف يعتبر ضررا مباشرا يستحق عنه التعويض.

**ثانياً: انعدام المسئولية لقيام السبب أجنبي:**

السبب الأجنبي هو كل حادث ليس من فعل المدعي عليه يكون هو سبب الضرر، وعند توافر هذا السبب: تنتفي مسئولية المدعي عليه كلا أو جزءا [3]

---

(1) انظر: السنهوري السابق، ص: ١٠٣٤، د / لبيب شنب ، المرجع السابق، ص٣٦٦، د/ جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص: ٥٨٢، د/ عبد المنعم الصدة ، المرجع السابق، ص: ٥٥٣، د / جميل الشرقاوي المرجع السابق، ص ٥٩ .

(2) د / عبد الودود يحيى ، المرجع السابق، ص: ٢٦٧، د / حشمت أبو ستيت، المرجع السابق، ص: ٤٥٢.

(3) انظر د/ حشمت أبو ستيت، المرجع السابق، ص: ٤٤٥، د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص: ٥٣٩، د/ لبيب شنب، المرجع السابق، ص: ٣٦٧.

والسبب الأجنبي – على هذا النحو – قد يكون القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، وقد يكون خطأ المضرور، وقد يكون خطأ الغير، وفي السبب الأجنبي وأثره في المسئولية جاءت المادة ١٦٥ مدني مصري تقول: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك".

ويتضح من النص السابق أن الأسباب التي جاءت فيه لم ترد على سبيل الحصر، إذ قد يكون السبب الأجنبي أمرا غير هذه الأسباب، كما لو كان عيباً في الشيء الذي أتلف أو مرضاً لدى المضرور[١] .... إلخ .

وسنقتصر على معالجة الأسباب التي ذكرها النص باعتبارها أهم صور السبب الأجنبي الذي ينفي المسئولية عن المدعي عليه.

## الفرع الأول
## القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

**لا فرق بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ:**

ذهب بعض الفقهاء إلى التفرقة بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، ويختلفون فيما بينهم في الأساس الذي تقوم عليه تلك التفرقة، إلا أن غالب الفقه[٢] والقضاء المصري[٣] يذهب إلى عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، فهما اسمان

---

(١) د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص: ٥٤، وانظر المذكرة الإيضاحية في مجموعة الأعمال التحضيرية ج٢، ص: ٣٧٨.

(٢) د/ عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق، ص: ٩٩٢، وما بعدها، د/ سليمان مرقس ، المرجع السابق ص: ٤٨٦، وما بعدها، د/ حشمت أبو ستيت ، المرجع السابق، ص: ٣٣٥ د/ جمال زكي، المرجع السابق، ص: ٢٨٩.

(٣) انظر: نقض مدني مصري في ١٧ مايو ١٩٦٦، مجموعة أحكام النقض س: ١٧ ص: ١١٢٩، قاعدة رقم ١٥٣، ونقض مدني في ٢٧ مارس سنة ١٩٨٠، المجموعة السابق، س: ٣١ ص ٩٣٠ قاعدة رقم ١٨٣.

مختلفان لمعنى واحد، فإذا نظر إليه من حيث إنه غير متوقع الحدوث فهو حادث مفاجئ، وإذا نظر إليه من حيث إنه لا يمكن دفعه فهو قوة قاهرة، فإذا ثبت أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي امتنع قيام المسئولية التقصيرية على الوجه الذي ذكرناه في المسئولية العقدية.

**الشروط الواجب توافرها في الحادث الفجائي أو القوة القاهرة:**

يجب لاعتبار الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً يؤدي إلى انعدام رابطة السببية توافر الشروط الآتية:

١- **أن يكون الحادث أمراً لا يمكن توقعه:** فإذا كان من الممكن توقعه فلا نكون بصدد قوة قاهرة أو حادث فجائي حتى ولو استحال دفعه، ومن ثم فإذا كان الحادث ممكن توقعه ولم يتخذ الشخص الاحتياطيات اللازمة لتلافي ما يمكن أن يترتب عليه من آثار فإن الشخص يعتبر مقصراً[١] إلا أنه لا يشترط أن يكون الحادث لم يسبق وقوعه أصلاً، فالزلازل، والبراكين والفيضانات غير العادية والحروب، كلها حوادث سبق وقوعها، ومع ذلك تعتبر قوة قاهرة طالما لم تكن متوقعة في الوقت الذي حدثت فيه مرة ثانية، والمعيار هنا موضوعي، بمعنى ألا يكون في الوسع توقعه عادة من جانب أشد الناس حرصاً ويقظة وبصرا بالأمور، بحيث يكون عدم التوقع مطلقاً لا نسبيا.

٢- **يجب أن يكون الحادث مستحيل الدفع:** فإذا كان باستطاعة المدعي عليه أن يتجنب الحادث، ولم يفعل يكون مسئولاً[٢].

---

(١) د/ عبد الودود يحيى . المرجع السابق ، ص: ٢٢٨، وانظر: السنهوري . المرجع السابق ص: ٩٩٦ د / عبد المنعم الصدة . المرجع السابق، ص: ٥٤١.

(٢) انظر: نقض مدني في ١٩٦٦/٥/١٧ مجموعة أحكام النفض المدني س ١٧ ص ١١٢٩.

فإذا كان دفع الحادث مستطاعاً فلا يكون قوة قاهرة، حتى لو استحال توقعه، والاستحالة هنا يجب أن تكون مطلقة، أي بالنسبة لكل شخص يوجد في مركز المدعي عليه فلا تكون بالنسبة إلى المدين فحسب، بل تكون بالنسبة لأي شخص يكون في موقف المدين، والمعيار هنا موضوعي أيضاً وليس ذاتيا على نحو ما ذكرنا سابقاً.

**٣- يجب أن يجعل الحادث الفجائي أو القوة القاهرة تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة:** أي بالنسبة لكل شخص يوجد في مركز المدين (المدعي عليه) يستوي أن تكون هذه الاستحالة مادية أو معنوية، فإذا تعهد شخص بالغناء في حفلة معينة، ثم توفى شخص عزيز عليه في اليوم المحدد للحفلة، فاستحال عليه معنوياً أن يغني، فإن الحادث يعتبر قوة قاهرة، إذ يصح أن يكون لهذا الموت أثره في نفس المدين فلا يمكنه الغناء في هذه الظروف[١]، وهذه مسألة يقدرها قاضي الموضوع وفقا لظروف كل حالة، وعليه أن يحتاط في تقدير ذلك[٢].

هذا ويجب أن يلاحظ أن استحالة التنفيذ هي التي تفرق بين القوة القاهرة، والحادث الطارئ، فقد رأينا أن الحادث الطارئ – في نظرية الظروف الطارئة – لا يؤدي إلى أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وإنما يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا فحسب، بينما تجعل القوة القاهرة تنفيذ الالتزام مستحيلا[٣].

---

(١) راجع فيما سبق، د / عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: ٩٩٧، د/ سليمان مرقس، المرجع السابق، ص: ٤٨٧، د/ أنور سلطان ، المرجع السابق ص: ٤٧١، د/ توفيق فرج، المرجع السابق، ص: ١٦٦.

(٢) د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص: ٣٧٠، وانظر: د/ جميل الشرقاوي . السابق، الموضع السابق، د / هشام الفاسي، المرجع السابق، ص: ١٣٤، د/ سمير تناغو . السابق، ص: ٢٥٢.

(٣) انظر نقض مدني في ١٩٧٦/١/٢٩، مجموعة أحكام النقض المدني س ٢٧، ص: ٢٤٣، وانظر: د/ عبد الودود يحيى ، المرجع السابق، ص: ٢٥٨.

ومن الأمثلة على القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، الحرب بما ينجم عنها من تدمير أو تخريب، وتؤدي إلى تقلب سعر العملة، وغلاء الحاجيات والمواد الأولية[١]، وكذلك صدور تشريع أو أمر إداري واجب التنفيذ، أو وقوع زلزال أو حريق، أو فيضان غير عادي، أو هبوب عاصفة، أو تفشي داء طارئ، أو إضراب غير متوقع، أو سرقة ونحو ذلك، ما دام الحادث يستحيل توقعه أو دفعه، كما أن حوادث السيارات قد تنطوي على قوة قاهرة أو حادث فجائي، كما لو انفجر إطار السيارة فجأة، أو انزلقت السيارة في أرض زلجة أو بهر بصر السائق نور خاطف، كما قد يكون ذعر حيوان على إثر وقوع صاعقة، وانسعار كلب قوة قاهرة، أو حادثاً فجائيا إذا كان غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع[٢].

**أثر القوة القاهرة**:

إذا كانت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هي السبب الوحيد في وقوع الضرر، فإن المدين يبرأ من التزامه نهائياً لانعدام علاقة السببية[٣]، وإذا كانت القوة القاهرة مانعة من تنفيذ الالتزام بصفة مؤقتة – لا بصيفة نهائية – فإنها توقف تنفيذ الالتزام حتى يزول الحادث، فيصبح الالتزام واجب التنفيذ[٤].

ويجوز للطرفين أن يعدلا باتفاقهما من أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، فيصح أن يتفقا على أن يتحمل المدين مسئولية عدم تنفيذ التزامه حتى ولو كان ذلك

---

(١) نقض مدني في ١٩٥٩/١١/١٩، مجموعة أحكام النقض المدني س١٠ ص٦٧٧، رقم ١٠٣.

(٢) د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: ٩٩٨ – ٩٩٩ د / سليمان مرقس، الموضع السابق، ص: ٤٨٨ د/ جمال زكي، المرجع السابق، ص: ٥١٠، د/ حسام الأهواني . المرجع السابق، ص: ٥٧٦.

(٣) السنهوري، المرجع السابق، ص: ٩٩٩، د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص: ٥٤٣، د/ أنور سلطان . المرجع السابق، فقرة ٤٧٢، د/ حسام الأهواني ، المرجع السابق ص ٥٧٧.

(٤) د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، الموضع السابق، د / عبد الرزاق فرج، المرجع السابق، ص: ٨٠، د/جميل الشرقاوي ، المرجع السابق، المصادر غير الإرادية، ط١٩٧٤، ص: ٥٢.

راجعاً إلى القوة القاهرة أو الحادث الفجائي[1]، وهذا ما تحدثنا عنه عند الحديث عن الاتفاقات المعدلة للمسئولية، وهو ما عبرت عنه المادة ٢٥٩ من التقنين المدني العراقي بقولها " يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة " .

**ويجب التنويه أخيراً إلى أنه إذا اشترك خطأ المدعي عليه مع القوة القاهرة أو الحادث الفجائي في إحداث الضرر:** فإن المدعي عليه يسأل مسئولية كاملة عن الضرر[2]، لأن القوة القاهرة لا يمكن نسبتها إلى شخص آخر حتى يشترك مع المدعي عليه في تحمل المسئولية، فلو أن سائقاً قاد سيارته بسرعة فائقة، ثم هبت رياح شديدة، فاقتلعت شجرة وألقت بها أمام السيارة فترتب على ذلك أن انقلبت السيارة على أحد المارة فقتلته، فالسائق هنا يسأل مسئولية كاملة، ويلزم بكامل التعويض عن كل الضرر[3].

## الفرع الثاني
## خطأ المضرور

**تمهيد وتوضيح:**

قد يحدث أن يرتكب المضرور فعلا يساهم مع فعل المدعي عليه في إيقاع الضرر عليه شخصياً، ومثال ذلك إذا فرض أن شخص كان يعبر الشارع وهو يقرأ كتاباً أو صحيفة وصدمته سيارة تسير بسرعة كبيرة، فإن خطأه يكون له دخل في إيقاع الضرر، ومن ثم وجب علينا أولا أن نعرف إلى أي حد يؤثر خطأ المضرور

---

(1) السنهوري . السابق . الموضع السابق ، والصدة . السابق . الموضع السابق.

(2) د/هشام القاسمي . المرجع السابق ، ص: ١٣٥ د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص: ٣٧١.

(3) انظر فيما سبق د/ السنهوري، السابق، ص: ٩٩٩، د/ حشمت أبو ستيت، السابق، ص: ٤٥٠، د/ جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص: ٥٩٠، وما بعدها.

في المسئولية التي نشأت نتيجة خطأ المسئول[1] (وهو صاحب السيارة فى مثالنا المذكور) هذا يقتضي الأمر أن نميز بين فرضين:

الأول: أن يكون أحد الخطأين قد استغرق الخطأ الآخر.

الثاني: أن يكون كلا من الخطأين مستقلا عن الآخر، أي أن يكون هناك خطأ مشترك .

وسنعالج كلا من هذه الفرضين فى بند مستقل

**أولًا: استغراق أحد الخطأين للآخر:**

إذا استغرق أحد الخطأين الخطأ الآخر، فإن الخطأ المستغرق لا يكون له أثر[2]، ومثال ذلك: إذا كان خطأ المدعي عليه يستغرق خطأ المضرور، فإنه يكون مسئول مسئولية كاملة عن الضرر الذي لحق بالمضرور، ولا يخفف منها خطأ الأخير، ولكن إذا كان خطأ المضرور هو الذي استغرق خطأ المدعي عليه تنتفي لانعدام علاقة السببية .

ويستغرق أحد الخطأين الخطأ الآخر فى حالتين:

**الحالة الأولى: أحد الخطأين يفوق كثيرا في جسامته الخطأ الأخر:**

فإن الخطأ الأشد لا يستغرق الخطأ الأخف إلا فى صورتين:

**الصورة الأولى: أذا كان أحد الخطأين عمديا:** فى هذه الصورة يكون أحد الطرفين المدعي عليه أو المضرور أراد إحداث الضرر متعمدا، أما الآخر فقد صدر منه خطأ غير معتمد، فإذا كان المدعي عليه هو الذي تعمد إحداث الضرر قامت

---

(1) انظر د/ محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص: ٥٩٠، د/ لبيب شنب، المرجع السابق، ص: ٣٦٩، د/ محمد كامل مرسي، المرجع السابق ج٢ فقرة ٦.

(2) انظر نقض جنائي في ١٩٧٤/١١/٣، المجموعة الجنائية س ٢٥ ، ص: ٧٠٨ نقض جنائي في ١٩٦٦/٤/٢٥، المجموعة السابقة س ١٧ ص: ٤٧٥ ونقض جنائي في ١٩٦٦/١١/١٧ . المجموعة السابقة س ٢٠ ص ١٢٧ .

مسئوليته كاملة، ولا يعتد بخطأ المضرور، ومثال ذلك أن يرى سائق سيارة غريما له يعبر الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة فيتعمد دهسة، إذ تقع المسئولية كاملة على السائق، ولا يجوز له أن يحتج بخطأ المضرور لتخفيف مسئوليته؛ لأن خطأ المضرور هنا لم يكن إلا ظرفا استغله السائق لإحداث الضرر [1].

واما إذا كان الخطأ المعتمد هو خطأ المضرور نفسه ( أي أن المضرور تعمد الحاق الضرر بنفسه ) فإن خطأه يستغرق خطأ المدعي عليه وتنتفي مسئولية المدعي عليه لانعدام رابطة السببية، ومثاله: لو أن شخصا أراد الانتحار، فألقى بنفسه أمام سيارة تسير بسرعة تجاوز السرعة المطلوبة، ولقى حتفه؛ فهو وحدة الجاني على نفسه، ولا يكون السائق مسئولا، ولا يجوز ان يحتج – هو لو نجا أو ورثته لو مات – بالادعاء بأن السائق أخطأ، لأنه كان يسير بسرعة كبيرة، لأن ذلك لم يكن إلا ظرفا استغله المضرور لتنفيذ قصده [2].

**الصورة الثانية: رضاء المضرور بما وقع عليه من ضرر:** القاعدة أن رضاء المضرور بالضرر لا ينفي مسئولية المدعي عليه من فعله الخاطئ الذي أحدث الضرر، وتبقى مسئوليته كامله، فالطبيب الذي يجري عملية جراحية خطرة لا تتطلبها ضرورة، يكون مخطئا، ولا يعفيه من المسئولية أن يكون المريض قد رضى بإجراء العملية، والمهندس إذا نفذ تصميما معينا يكون مخطئا حتى لو رضي عمليه بهذا التصميم، إلا أن رضاء المضرور بوقوع الضرر قد يمثل خطأ منه.[3]

---

(١) د/ السنهوري، المرجع السابق ، ص: ١٠٠٣ ، د/ الصدة ، المرجع السابق، ص: ٥٤٥.

(٢) السنهوري . السابق، ص: ١٠٠٦، وانظر: د/ عبد الودود يحيى . المرجع السابق ، ص: ٢٥٩، د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، الموضع السابق.

(٣) انظر: د/ توفيق فرج، المرجع السابق، ص: ٣٩٩ – ٤٠٠، د/ أنور سلطان، المرجع السابق، فقرة ٤٧٧، د/ جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص: ٥٥.

وفى هذه الحالة يقضي المنطق بأن هذا الخطأ يخفف عن مسئولية المدعي عليه إذ نصبح حينئذ بصدد خطأ مشترك، يستوجب توزيع المسئولية على عاتق الطرفين، ومثال ذلك أن يركب شخص سيارة وهو يعلم أنها غير سليمة، أو يعلم أن سائقها فى حالة سكر، أو يستحث السائق لأن يقود السيارة بسرعة كبيرة فى طريق وعر أو مظلم فتقع حادثة تؤدي إلى إصابته، فى هذه الفروض وأمثالها، يخفف خطأ المضرور من مسئولية السائق، (المدعى عليه).

**الحالة الثانية: أن يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر:**

إذا كان أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر فإن العبرة تكون بالخطأ الذي وقع أولا لأنه حينئذ يستغرق الخطأ الثاني فإن كان خطأ المضرور هو نتيجة خطأ المدعي عليه، استغرق الخطأ الثاني الخطأ الأول، وتتحقق مسئولية المدعي عليه كاملة، باعتبار أن خطأه هو وحده الذي أحدث الضرر، ومثال ذلك أن يركب شخص مع صديق له فى سيارة يقودها هذا الصديق مسرعا فى سيره بها، وترتب على ذلك ظهر للراكب خطرا فزعه، مما دفعه أن ياتي بحركة خاطئة التماسا للنجاة ( القى بنفسه مثلا خارج السيارة ) فأضر بنفسه، هنا نجد أن خطأ المضرور كان نتيجة خطأ المدعى عليه [1] فاستغرق خطأ الصديق خطأ الراكب، وتحققت مسئولية الصديق كاملة [2]، وإذا كان خطأ المدعي عليه هو نتيجة خطأ المضرور، فإن خطأ المضرور هو الذي يستغرق خطأ المدعي عليه، وتنتفي مسئولية الأخير لانعدام رابطة السببية [3]، كما إذا أخاف شخص سائقا بفعل خاطئ منه، فأدى هذا إلى قيام

---

(١) د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: ١٠٠٧، د/ عبد الودود يحيى ، المرجع السابق، ص: ٢٩٠، د/ جميل الشرقاوي . المرجع السابق، ص: ٥٤.

(٢) انظر: نقض مدني في ١٩٦٨/٤/٢، مجموعة أحكام النقض المدني س ١٩ ص: ٦٨٩.

(٣) د/ السنهوري . السابق . الموضع السابق ، د/ عبد الودود يحيى ، المرجع السابق، ص: ٢٦١.

السائق بحركة خاطئة ( انحراف مفاجئ بالسيارة ) أحدثت ضررا بذلك الشخص كان اصطدمت رأسه بزجاج السيارة، فخطا السائق هنا يكون نتيجة لخطأ المضرور[1] .

**ثانيًا: استقلال كامل من الخطأين عن الآخر ( الخطأ المشترك) :**

إذا لم يستغرق أحد الخطأين الآخر على النحو السابق، بل ساهم كل من خطأ المضرور، خطأ المدعي عليه فى أحداث الضرر مستقلا، فقد صرنا أمام ما يسمى بـ "الخطأ المشترك"[2] وتوافرت السببية بين الضرر وكل من الخطأين، إذ لولا أيهما ما وقع الضرر، كما لو قاد شخص سيارة بسرعة تزيد على الحد الأقصى المسموح به قانونا، فدهس شخصا كان يعبر الطريق من مكان ليس مخصصا لعبور المشاة، ولما كان كل من المدعي عليه والمضرور مسئولا بقدر ما أحدث من ضرر، وكان خطأ كل منهما كان سببا لوقوع الضرر كله، فإن المسئولية تكون بالتساوي بينهما، ومن ثم لا يرجع المضرور على المدعي عليه إلا بنصف التعويض[3]، ولو أن المدعي عليه شخصان لا شخص واحد، وكانا هما والمضرور مسئولين بالتساوي[4] فإن المضرور يرجع على أي منهما بثلثي الضرر لأنه يتحمل قيمة ثلث الضرر، والمدعي عليهما متضامنان فى الثلثين.

---

(١) انظر في ذلك نقض جنائي في ٢٩/ ١٩٦٨/١، مجموعة أحكام النقض الجنائي

(٢) وهو تعبير غير دقيق في رأينا؛ لأنه يوحى بأن يشترك اثنان في خطأ واحد، وهذا ليس مقصوداً، بل المقصود هو أن يوجد خطأن مستقلان وقعا من شخصين مختلفين، أو أكثر، المدعي عليه أو عليهما ، والمضرور وأحدثا الضرر.

(٣) السنهوري . المرجع السابق ، ص: ١٠٠٩.

(٤) نقض مدني في ١٩٦٦/٥/١٧، مجموعة أحكام النقض المدني ص: ١٨ ص: ٦١٦، رقم ٨٤.

إلا أن القاضي – وهو الرأي السائد فيها وقضاء[1] – يستطيع أن يوزع المسئولية – وبالتالي التعويض – بحسب جسامة الخطأ الذي صدر من كل هؤلاء بدلا من توزيع المسئولية بالتساوي، إلا إذا لم يستطيع القاضي تحديد جسامة الخطأ؛ لأن خطأ أحدهم قد يكون جسيما – بينما يكون خطأ الآخرين – أو الآخر – تافها وليس من مقتضيات العدالة أن يتساوى الخطأ الجسيم مع الخطأ التافه، كما أنه ليس مقبولا أن يحصل المضرور على تعويض كامل بالرغم من أنه قد ساهم بخطئه فى إحداث الضرر .

فإذا رأى القاضي أن مساهمة أحد الخطأين فى إحداث الضرر أكبر من مساهمة الخطأ الآخر، قام بتوزيع التعويض على هذا الأساس، وفى هذا تقول المادة ٢١٦ من القانون المدني المصري: "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه".

وبمقتضى هذا النص يكون للقاضي حق فى عدم انقاص شئ من التعويض – وهذا أمر جوازي له – وذلك فى حالة ما إذا كان خطأ المدعي عليه قد استغرق خطأ المضرور وقد ينقض القاضي التعويض وذلك فى حالة ما إذا كان المضرور قد صدر منه خطأ مستقل اشترك فى إحداث الضرر، كما يجوز للقاضي أيضا ألا يحكم بأي تعويض، وذلك فى حالة ما إذا كان خطأ المضرور قد استغرق خطأ المدعي عليه[٢]، وذلك على النحو الذي بيناه فى حينه .

ومن أهم تطبيقات الخطأ المشترك: خطأ الصبي الذي تعلق بالسيارة لحظة ابطائها وفى غير محطة من محطات الركاب، والخطأ المشترك بين عامل المصعد

(١) قرب من ذلك د/ عبد الودود يحيى، السابق، ص: ٢٦١، السابق، ص: ٢٦١، الصدة، السابق، ص: ١٧٨، د/ عبد الناصر العطار، المرجع السابق، ص: ٢٧٩.

(٢) د/ عبد المنعم الصدة . المرجع السابق . ص: ٥٤٨، د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص: ٣٧٨– ٣٧٩، د/ هشام القاسمي، المرجع السابق ، ص: ١٣٨.

والراكب فيه، وخطأ عمال السكك الحديدية الذين نزعوا بعض أجزاء السور لتقصير الطريق إلى مساكنهم[1] ....الخ .

## الفرع الثالث

## خطأ الغير

**المقصود بخطأ الغير:**

يقصد بالغير هنا كل شخص غير المضرور، وغير المدعي عليه، وغير الأشخاص الذين يسأل عنهم المدعى عليه وهم تابعية والأشخاص المشمولين برعايته،[2] كابنه، أو شخصا وضع فى كنفه وتحت رعايته.

وعلى ذلك إذا كان فعل الغير هو السبب الوحيد فى إحداث الضرر، فلا مسئولية على المدعي عليه إطلاقا، وإذا كان هذا الفعل خطأ كان الغير وحده هو المسئول، إلا أن هذه الحالة ليست هي المقصود فى هذا المقام.

والذي يعنينا هنا هو: أن المدعي عليه قد وقع منه خطأ، وفى ذات الوقت وقع معه خطأ من الغير بحيث يكون لكل من الخطأين دور فى إحداث الضرر، فى هذه الحالة يثور التساؤل عن أثر فعل الغير فى مسئولية المدعي عليه؟

والإجابة: أن فعل الغير إذا لم يكن خطأ له شأن فى إحداث الضرر: فليس له من أثر فى مسئولية المدعي عليه، وكان هذا الأخير هو المسول وحده، وتكون مسئوليته كامله عن كل الضرر، ومن ثم يجب أن يكون فعل الغير خطأ، ويقاس الخطأ بمعياره المعروف وهو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد، ولابد أن

---

(1) د/ عبد الرزاق حسن، المرجع السابق، ص: ٨٤، د/ سمير تناغو، السابق، ص:٢٥٥.

(2) د/ لبيب شنب، المرجع السابق، ص: ٣٧٠، وانظر في هذا المعنى د/ عبد الناصر العطار، المرجع السابق، ص: ٢٧٨، د/ رمضان أبو السعود، السابق، ص: ٣٨٠.

يكون خطأ الغير له شأن فى إحداث الضرر، وإلا لما جاز للمدعي عليه أن يحتج به، إذا لا علاقة له بالضرر.

ويجب ألا يكون الغير قد ارتكب الخطأ من الأشخاص الذي يسأل عنهم المدعى عليه، فلو كان هذا التغيير ابنا للمدعي عليه، أو تلميذا أو تابعا له، فلا يكون للخطأ الصادر منه أثر فى مسئولية المدعي عليه نحو المضرور، ولا يشترط أن يكون الغير معروفا، فلو ثبت أن خطأ ما صدر من الغير، وكان له شأن فى إحداث الضرر، فإن ذلك يؤثر فى مسئولية المدعي عليه، كما لو وقع حادث وكان من بين أسبابه خطأ صدر من شخص ثالث وقد هرب دون أن يعرف شخصه[1]، إذ يجوز أن يستغرق خطأ هذا الغير المجهول خطأ المدعي عليه[2]

**أثر خطأ الغير فى مسئولية المدعي عليه:**

إذا أسهم خطأ الغير مع خطأ المدعي عليه فى إحداث الضرر – على النحو السابق– فإن أثر خطا الغير فى مسئولية المدعي تختلف بحسب ما إذا كان أحد الخطأين قد استغرق الآخر، أم كان كل منهما مستقلا عن الآخر .

**أولًا: استغراق أحد الخطأين للخطأ الآخر:**

إذا اشترك خطأ الغير مع خطأ المدعي عليه فى إحداث الضرر، وكان أحد الخطأين يستغرق الآخر، اعتبر الخطأ المستغرق هو وحده السبب فى إحداث الضرر، فإذا استغرق خطأ المدعي عليه خطأ الغير، كان المدعي عليه وحده هو المسئول مسئوليه كامله، ولا أثر لخطأ الغير فى هذه المسئولية، كما إذا قتل شخص آخر بمسدس غير مرخص كان يحمله الغير، هنا يكون القاتل وحده هو المسئول

---

([1]) انظر فيما سبق، د/ عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: ١٠١٧.

([2]) انظر: نقض مدني في ١٩٦٨/٤/٢، مجموعة أحكام النقض المدني س ٩، ص: ٦٨٩.

عن جريمة القتل، لأن خطأه استغرق واستوعب خطأ صاحب المسدس الذي حمله دون ترخيص.

أما إذا استغرق خطا الغير خطأ المدعي عليه، فالغير وحده يكون هو المسئول مسئولية كاملة عن الضرر ولا أثر لخطأ المدعي عليه فى هذه المسئولية، كما لو حفر المدعي عليه حفرة فى الطريق، فوقع بها شخص، وثبت أن خصمه هو الذي دفعه فيها، إذ يكون الغريم هو وحده المسئول عما يحدث لهذا الشخص من ضرر[1] .

**ثانيًا: تعدد المسئوليتين:**

إذا لم يستغرق أحد الخطأين الآخر على النحو السابق بأن قام كل واحد منهما على استقلال بقى كل من الخطأين قائما، واعتبر سببا فى إحداث الضرر، وهذه هي حالة تعدد المسئولين، حيث اشترك مع المدعي عليه شخص آخر فى إحداث الضرر، فأصبح المسئول أكثر من شخص واحد، وعلى ذلك تتحقق مسئولية المدعي عليه والغير، ويكون كل منهما مسئولا فى مواجهة المضرور عن الضرر فى مجموعة، فينقسم التعويض بينهما بالتساوي، إلا إذا حدد القاضي نصيب كل منهم فى التعويض بقدر جسامة الخطأ الذي وقع منه.[2]

---

(1) انظر: السنهوري، المرجع السابق، ص: ١٠١٨، د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص: ٥٥٠، د/ حشمت أبو ستيت، المرجع السابق، ص: ٤٥١.

(2) د/ عبد الودود يحيى ، المرجع السابق، س: ٦٢، وانظر: د/ سليمان مرقس، المرجع السابق، ص: ٤٩٩، د/ أحمد سلامة، السابق، ص: ٢٩٠، د/ الصدة، المرجع السابق، ص: ٥٥١.

وفى هذا تنص المادة ١٦٣ من التقنين المدني المصري على أنه: "إذ تعدد المسئولون عن عمل صار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية بينهم إلا إذا حدد القاضي نصيب كلا نهم فى التعويض".

ويستبين من هذ النص أن الغير والمدعي عليه يكونان مسئولين عن التعويض بالتضامن، فيستطيع المضرور أن يرجع على أي منهما {الغير والمدعي عليه} بكل التعويض، ويكون لمن دفع أن يرجع على الآخر بنصيبه.

**ثالثًا: اشتراك خطأ المدعي عليه، وخطأ الغير وخطأ المضرور:**

إذا اشترك خطأ المدعي عليه، وخطأ الغير، وخطأ المضرور فى إحداث الضرر، وثبت الخطأ في جانبهم جميعا تحمل المضرور ثلث التعويض ويكون المدعي عليه والغير مسئولين بالتضامن عن الثلثين الباقيين فيرجع المضرور بثلثي التعويض على أي منهما، ويرجع من دفع منهما على الآخر بثلث التعويض[1]، هذا ما لم يحدد القاضي نصيب كل منهم فى التعويض وفقا لجسامة الخطأ الذي صدر منه [2].

**إثبات السبب الأجنبي:**

يقع على المدعي وهو المضرور عبء إثبات توافر السببية بين الخطأ والضرر[3]، ولكن هذه السببية يفترض توافرها إذا أقام المدعي الدليل على الخطأ والضرر، وهذا لا يعني إعفاء المضرور من إثبات السببية، وإنما بعني أن إثبات الخطأ والضرر يعد كافيا لافتراض ثبوت السببية بينهما، وذلك طبقا للقواعد العامة فى الإثبات، وذلك أن المدعي فى الإثبات لا يتحتم عليه أن يقيم الدليل على جميع

---

(١) د/ رمضان أبو السعود . السابق، ص ٣٨٢.

(٢) انظر: نقض جنائي في ١٩١٨/١/٢٢، مجموعة أحكام النقض الجنائي ، س: ١٩، ص: ٩٤.

(٣) انظر: نقض مدني فرنسي، الدائرة الثانية في ١٩٧٦/١١/٨، داللوز، ١٩٧٧– ١.

عناصر الواقعة التي يدعيها، وإنما حسبه أن يبرهن على قدر معقول من هذه العناصر يكفي لافتراض ثبوت الباقي منها. [1]

فإذا أقام المدعي الدليل على الخطأ والضرر، افترضت علاقة السببية بينهما، وانتقل عبء الإثبات إلى المدعي عليه بجميع شروطه، فإذا ادعى المدعي عليه أن سبب الضرر هو القوة القاهرة، أو خطأ المضرور، أو خطأ الغير، وأثبت أن ذلك هو السبب الوحيد والمباشر للضرر الذي أصاب المدعي، انتفت مسئوليته ولا يلزم بأي تعويض (المادة ١٦٥ مدني سابق الإشارة إليها)

وتجدر الملاحظة أخيرا إلى أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أو انقطاعهما، هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ[2].

وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى عكس ذلك، حيث استقر على أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض[3].

أما محكمة النقض المصرية فقد ذهبت – على غرار ما فعلته محكمة النقض الفرنسية – إلى تخويل نفسها حق مراقبة محكمة الموضوع فى استخلاص تلك العلاقة، لكنها عادت – وهو الرأي الأصح لدينا – واستقرت على أن علاقة السببية بين الخطأ والضرر هي من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون استخلاصه فيه غير سائغ[4].

---

(١) د/ الصدة، السابق، ص: ٥٥٢، د/ حشمت أبو ستيت، السابق، ص: ٤٥٣.

(٢) نقض مدني في ١٩٨٣/١/١٣، طعن ٢٢، ق س ٤٥ ق .

(٣) انظر في ذلك نقض مدني: روديبير ، المسئولية المدنية . فقرة ١٦٢٠ ص: ٣٨ ط: ١٩٥٢.

(٤) نقض مدني في ١٩٩٠/٢/١٨، مجموعة أحكام النقض س ٤١، ج ١، ص ٥٣٣.

# الفصل الثاني
# المسئولية عن عمل الغير

تتحقق مسئولية الشخص عن عمل الغير فى حالتين:

الأولى: حالة من تجب عليه مراقبة شخص فى حاجة إلى الرقابة، كالأولاد بالنسبة لوالدهم، والتلاميذ بالنسبة للمعلم، والصبية الذين يعملون فى حرفة بالنسبة للمشرف عليهم .

الثانية: حالة المتبوع، إذ لا يكون مسئولا عن أعمال تابعة، كمسئولية رب العمل عن الأعمال .

ونعالج هاتين الحالتين كل فى مبحث مستقل على النحو التالي:

## المبحث الأول
## مسئولية متولي الرقابة

**مفهوم فكرة متولي الرقابة:**

موضوع هذه المسئولية يفترض أن شخصا ما يتولى قانونا، أو بمقتضى اتفاق، رقابة شخص يحتاج لهذه الرقابة، نظرا لصغر سنة، أو مرضه، وان هذا الصغير أو المريض صدر منه فعلا أضر بالغير، فى هذه الحالة يلتزم متولي الرقابة بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر بسبب خطأ الصغير أو المريض، ولا يستطيع التخلص من هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، وأن الضرر كان سيقع حتما حتى لو قام بما يجب عليه من رقابة [1]، وقد عرضت لأحكام هذه المسئولية المادة ١٧٣ من القانون المدني المصري بقولها: "١- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة بسبب قصره، أو بسبب حالته

(1) د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٦٩.

العقلية أو الجسمية ن يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

٢- ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان فى كنف القائم على ترتيبه، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمة فى المدرسة، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها إو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

٣- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية".

وسنعرض لأحكام مسئولية مسئولي الرقابة فى مطلبين، نخصص أولهما لشروط تحقيق هذه المسئولية، ونخصص ثانيهما لبيان أساس هذه المسئولية .

## المطلب الأول

## شروط تحقيق مسئولية مسئولي الرقابة

تتحقق هذه المسئولية إذا تولى شخص الرقابة على شخص آخر وصدر ممن هو تحت الرقابة عمل غير مشروع ثبت فى جانبه فأوجب مسئوليته، ومن ثم فيجب لكي تتحقق مسئولية متولى الرقابة أن يتوافر شرطان:

**الشرط الأول: تولي شخص الرقابة على آخر:**

لا يكفي لتحقيق هذه المسئولية أن يتولى شخص بالفعل رقابة شخص آخر، وإنما لابد أن يكون هناك التزام بالرقابة، ومصدر هذا الالتزام قد يكون القانون، كما هو الشأن للأب، فهو ملزم برقابة ابنه، وقد يكن مصدر الالتزام هو الاتفاق، كما هو الشأن بالنسبة لمدير مستشفى الأمراض العقلية، فهو ملتزم برقابة مرضاه،

واضطلاعه بهذه الرقابة واجب يقع عليه بمقتضى الاتفاق المبرم بينه وبين المريض أو من يمثله[1]، وعلة هذا الالتزام – كما هو واضح من النص – حاجة الشخص إلى الرقابة بسبب سنة، كالقصر أو بسبب حالته العقلية، كالمجنون والمعتوه، وذو الغفلة، أو بسبب حالته الجسمية كالأعمى والمشلول، وأما الرقابة التي تقوم بسبب – غير هذه الأسباب الثلاثة، كرقابة السجان على المسجونين، ورقابة رئيس الحزب السياسي على أعضاء حزبه، فلا يترتب عليها هذه المسئولية .

ويلاحظ أن القانون المدني لم يحصر الحالات التي تقوم فيها الرقابة، وإنما أورد مبدأ عاما تتحدد فى ضوئه هذه الحالات، وذلك حيث يكون هناك التزام قانوني أو اتفاقي يتولى هذه الرقابة .

**الشرط الثاني: صدور عمل غير مشروع من الخاضع للرقابة:**

يشترط لقيام مسئولية متولي الرقابة أن يصدر من الشخص الخاضع للرقابة عمل غير مشروع يصيب الغير بضرر، فإذا قامت مسئولية الخاضع للرقابة قامت بجوارها مسئولية متولي الرقابة، على أساس افتراض خطأ فى جانبه هو أنه لم ينهض بواجبه فى رعاية الخاضع لرقابته[2]، أو أنه فى حالة ما يكون وليا على النفس –لم يحسن تأديبه، فتقوم حينئذ مسئوليتان: مسئولية أصلية، وهي مسئولية الخاضع للرقابة، ومسئولية تبعية هي مسئولية المكلف بالرقابة[3] .

---

(١) راجع في ذلك د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٨٤، د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٧٠ .

(٢)انظر: في ذلك السنهوري – السابق ص ١١٣٢، د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤٧٥، د/ اسماعيل انم – المرجع السابق ص ٤٧٣.

(٣) راجع د/ حشمت أبو ستيت – المرع السابق ص ٤٧٦، د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٣٧٦ .

وقد تتحقق مسئولية الشخص الخاضع للرقابة على أساس غير الخطأ بوصفه حارسا، كأن يقود سيارة فيصطدم بها أحد المارة، فتتحقق تبعا لذلك مسئولية المكلف بالرقابة، بجوار مسئولية الخاضع للرقابة بوصفه حارسا على السيارة .

وإذا كان الخاضع للرقابة شخصا غير مميز، كما لو كان صبيا دون السابعة أو مجنونا أو معتوها، فإن الفعل الضار الصادر منه، يرتب مسئولية متولي الرقابة، وتكون مسئوليته مسئولية أصلية ن وليست تابعة لمسئولية غير الميز، لأن هذا الأخير لا يمكن نسبة الخطأ إليه، فهو غير مسئول[1]، ومسئوليته المكلف بالرقابة هنا يغلفها وجه العدالة التي تقتضي تعويض المضرور، ولو لم تقم مساءلة المكلف بالرقابة لضاعت الحقوق عند ارتكاب الخاضع للرقابة غير المميز عملا غير مشروع أضر بالغير، وفى هذا تقول المادة ١٧٣ مددني ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز، وتصبح مسئولية المكلف بالرقابة فى هذه الحالة مسئولية أصلية، ويكتفي فى الفعل الضار الصادر من غير المميز على هذا النحو بعنصر " التعدي " دون عنصر الإدراك[2]، لتحقق مسئولية المكلف بالرقابة، وإذا استوفى المضرور التعويض من المكلف بالرقابة فليس للأخير أن يرجع على من ارتكب الفعل الضار، لأن المفروض أن عديم التمييز غير مسئول .

وتجدر الملاحظة أخيرا إلى أن مسئولية متولي الرقابة لا تقوم إلا إذا كان العمل غير المشروع قد وقع من الخاضع للرقابة، فإذا كان هذا الأخير هو الذي أصابه الضرر من شخص آخر، فلا تقوم المسئولية المفترضة فى جانب متولي الرقابة،

---

(١) انظر: د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٥٨٦، د/ اسماعيل غانم – السابق ص ٤٢٥، د/ رمضان أبو السعود –السابق ص ٤٠٨ .

(٢) د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٤٧٤، الصدة – السابق – الموضع السابق .

يستوى أن يكون الخاضع للرقابة هو الذي أوقع الضرر بنفسه أم وقع عليه الضرر بفعل شخص أجنبي .

فإذا ألحق أجنبي ضررا بتلميذ أصناء قيام رقابة المدرسة، أو إذا التحق التلميذ ضررا بنفسه في تلك الفترة، فلا تتحقق مسئولية المدرسة في الحالتين.

## المطلب الثاني

## أساس مسئولية متولي الرقابة وكيفية دفعها

تقوم مسئولية المكلف بالرقابة على أساسا " الخطأ المفترض فى جانبه، أي على أساسا افتراض أنه أخطأ فى القيام بواجب الرقابة بما ينبغي من عناية، وأن تقصيره هذا كان هو السبب فى ارتكاب الخاضع للرقابة للفعل غير المشروع الذي أضر بالغير، أي افترض قيام الخطأ فى جانبه، وافترض الخطأ فى جانب المكلف بالرقابة يستتبع بالضرورة افتراض وجود علاقة سببية بين الخطأ المفروض والضرر الواقع، ومن ثم يعفى المضرور من إثبات الخطأ ومن إثبات السببية، وإلا لكانت قرينة الخطأ ضربا من العبث، إذ يكون معنى ذلك أن نطالب المضرور بأن يثبت خطأ معينا للمسئول عن غيره حتى يمكن أن تقوم السببية بينه وبين المضرور مع أن القانون قد اعفى المضرور من إثبات أي خطأ فى جانبه[1].

والخطأ المفترض فى جانب متولي الرقابة خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس، فيستطيع أن يتخلص من المسئولية إذا استطاع أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بالعناية اللازمة، وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة فى سبيل تجنب الغير مثل العمل الذي وقع، وأنه قد أحسن أدب الخاضع لرقابته حالة كونه وليا للنفس عليه، وأما نفي علاقة السببية بين خطأ المكلف بالرقابة والضرر الواقع فيمكن للمكلف

(1) د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٤٧٧، انظر: السنهوري – السابق ص ١١٣٧، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٨٧، د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤٣٤ .

بالرقابة نفيها بأن يثبت – كما تقول المادة ١٧٣ مدني: "... أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية" فالسببية تنتفي متى أثبت المكلف بالرقابة أن خطأه لم يكن سببا فى وقع العمل غير المشروع، أو متى أثبت أن سببا أجنبيا حال بينه وبين قيامه بالتزامه بالرقابة على الوجه الصحيح [1] .

وخلاصة القول: إن مسئولية متولي الرقابة تنتفي بأحد أمرين:

**أولهما:** أن ينفي الخطأ المفترض فى جانبه، فينعدم ركن الخطأ .

**ثانيهما:** أن يثبت السبب الأجنبي فينعدم ركن السببية .

وفى الحالتين يبقى الخاضع للرقابة مسئولا عن العمل غير المشروع الذي صدر منه، وفقا للقواعد العامة فى المسئولية حتى لا يضيع حق المضرور من جراء خطأ الغير الذي أصابه بالضرر [2].

**حق المكلف بالرقابة فى الرجوع على لخاضع للرقابة بما أداه من تعويض إذا كان مميزا:**

لا شك ان قيام مسئولية متولي الرقابة على النحو الذي بيناه، لا يمنع من أن تقوم إلى جانبها مسئولية الشخص الخاضع لها فى حدود القواعد العامة عن الفعل غير المشروع الذي صدر منه، فيستطيع المضرور أن يرجع على أيهما شاء، أو عليهما معا لأنهما متضامنان أمامه، وإن كان الغالب يرجع على متولي الرقابة لأنه الأكثر يسارا عادة، فإذا رجع المضرور على متولي الرقابة واستوفى منه حقه فى التعويض فلا رجوع له بعد ذلك على الخاضع للرقابة بما دفعه من تعويض إذا كان

---

(١) انظر فيما سبق: د/ عبد الرازق السنهوري – المرجع السابق ص ١١٣٧ – ١١٤٠، د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤٧٧، د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٧٣.

(٢)انظر: في ذلك نقض مدني في ٢٣/ ١٢ /١٩٦٩ مجموعة أحكام النقض المدني س ٢٠ ص ٣٠٣ .

الخاضع مميزا، أما إذا كان غير مميز فلا يرجع عليه متولي الرقابة بشئ، لأن مسئولية الأخير مسئولية أصلية كما سبق أن بينا .

وإذا رجع المضرور على الخاضع للرقابة واستوفى منه كل التعويض، فلا رجوع له بعد ذلك على متولي الرقابة[1]، أي أن المضرور لن يتقاضى إلا تعويضا واحدا من هذا أو ذاك أو منهما معا على سبيل التضامن فى حدود القواعد العامة.

## المبحث الثاني

## مسئولية المتبرع عن أعمال تابعه

**توضيح مضمون فكرة هذه المسئولية :**

تفترض هذه المسئولية وجود علاقة تبعية بين شخصين، بمقتضاها يكون لأحدهما ( المتبوع) سلطة تخوله رقابة وتوجيه الآخر(التابع)، فإذا وقع ممن التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها عمل غير مشروع أضر بالغير، كان المتبوع مسئولا عن تعويض الضرر الذي أحدثه عمل التابع، وفى هذا تنص المادة ١٧٤ من التقنين المدني المصري على أنه: "١- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية ووظيفة أو بسببها.

٢- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه" .

وهذه المسئولية أكثر وقوعا فى العمل من مسئولية المكلف بالرقابة ومن ثم اكتسبت أهمية بالغة فى الحياة العملية[1] " لأنها تيسر للمضرور الحصول على حقه

---

([1]) راجع في ذلك السنهوري – السابق ص ١١٤٢،د/ لبيب شنب – المرجع السابق – ص ٣٧٩، د/ محمود جمال الدين زكي السابق ص ٦١٧ .

المشروع فى التعويض فى حالات كثيرة لا يتسنى له بغيرها الحصول عليه، نظرا لإعسار المسئول فى الأصل عنه، فالتابع فى أغلب الأحيان لا ثروة عنده حتى إن المتبرع يكون فى العادة قادرا على تعويض المضرور، ويكفي أن نتمثل مسئولية الأشخاص المعنوية، وشركات المساهمة على وجه الخصوص عن الأعمال غير المشروعة التي تنسب إلى مستخدميها وعمالها فى شتى نواحي النشاط الذي تقوم به على تعدده واتساعه " [٢].

## شروط تحقق مسئولية المتبع

لكي تتوافر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة يجب أن يتوافر شرطان :

**الشرط الأول: علاقة التبعية:**

يجب لقيام هذه المسئولية أن تتوافر علاقة تبعية بين التابع والمتبوع بحيث يكون أحدهما خاضعا للآخر، ويتحقق ذلك إذا كان للمتبوع على تابعة سلطة فعليه فى رقابته وتوجيه. فعلاقة التبعية تقوم على عنصرين: عنصر السلطة الفعلية، وعنصر الرقابة والتوجيه:

أ- **عنصر السلطة الفعلية:** تقوم التبعية على سلطة فعلية للمتبرع على التابع، ومن ثم لا يشترط وجود علاقة عقدية بينهما، وإن كان الغالب أنه يوجد عقد بين التابع والمتبوع، ويكون هذا العقد عقد عمل، كما هو الحال بالنسبة للعامل، والخادم والطاهي، والسائق، والموظف، كل هؤلاء تابعون، ومتبوعهم هو رب العمل أو سيد البيت أو الحكومة [3]، غير أنه فى مثل هذه الحالات قد يكون العقد باطلا، ومع

---

([١]) انظر: د/ يحيي عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٧٤، وراجع د/ عبد الرازق السنهوري – المرجع السابق ص ١١٤٤ وما بعدها .

([٢]) د/ محمود جمال الدين زكي – المرجع السابق ص ٦١٧

([٣]) انظر في ذلك: د/ عيد الرازق السنهوري – المرجع السابق ص ١١٤٧، د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤٧٩،د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٥٩٣ .

ذلك تقوم علاقة التبعية، ما دام هناك سلطة فعلية للمتبرع على تابعة، بل إنه ليس من الضروري أن تكون سلطة المتبوع على تابعة سلطة شرعية، بل يكفي أن يكون للمتبوع سلطة فعليه حتى ولو كانت غير شرعية يزاولها المتبوع غصبا فى علاقة رئيس عصابة لصوص بأعضائها[1]، كما أن السلطة الفعلية تقوم ولو لم يوجد عقد أصلا، كما لو كلف أب ابنه، أو زوج زوجته بعمل معين بحيث يكون له عليه سلطة فعليه فى الرقابة والتوجيه، وليس من الضروري – أيضا أن يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعة بل قد يكون التابع مفروضا على المتبوع كما هو الشأن فى موظفي المجالس البلدية والمحلية [ موظفي الوحدات المحلية فى مصر ] التي تعينهم الحكومة لدية ن فلا يد له فى اختيارهم[2]، ومع ذلك تسأل هذه المجالس عن أعمالهم كما لا يهم أن يكون قيام علاقة التبعية بأجر أو بدون أجر، مؤقته أو لها صفة الاستمرار، بل إن مجرد وجود تبعية أدبية يكفي لقيام علاقة التبعية على الوجه الذي نعنيه هنا، فمن الممكن أن تقوم علاقة التبعية بين الزوج وزوجته، والصديق وصديقه، والأب والابن ما دامت توجد سلطة من ناحية وخضوع من ناحية أخرى.

**ب- عنصر الرقابة والتوجيه:**

يقصد بهذا العنصر أن يكون للمتبوع سلطة إصدار الأوامر إلى تابعة لتوجيهه

---

(١) د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤٣٧، د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٧٦، وانظر في ذلك نقض مدني في ٢٤/ ١٠ /١٩٦٣ مجموعة أكام النقض المدني ص ١٤ ص ٩٧٤.

(٢) انظر في ذلك: السنهوري – السابق ص ١١٤٨، د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق – الموضع السابق – وانظر في هذا الشأن بوجه خاص نقض مدني في ١٩٧٨/١١/٢٣ – طعن رقم ٤١٨ لسنة ٤٣ ق .

فى عمله ولو توجيها عاما[1]، وأن تكون له الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر، ومن ثم يعتبر تابعا: الخادم فى علاقته بمخدومه، والعامل فى علاقته برب العمل، والسائق فى علاقته بصاحب السيارة، والممرضة فى علاقتها بالطبيب الذي تعمل فى خدمته، والبواب فى علاقته بصاحب العمارة [2]، وهكذا وعلى العكس إذا لم تتوافر سلطة الرقابة والتوجيه، فلا تقوم علاقة التبعية، كما فى علاقة رب العمل بالمقارب، حيث يباشر المقاول عمله مستقلا عن رب العمل، والأطباء الذين يعملون فى مستشفى لحسابهم الخاص ليسوا تابعين لصاحب المستشفى، وسائق التاكسي ليس تابعا للراكب، وهكذا ....

وتأسيسا على ما تقدم لا يشترط لقيام علاقة التبعية أن يكون المتبوع ملما بأصول عمل التابع أو غير ملم به، فمالك السيارة يسأل عن خطأ السائق ولو كان يجهل قيادة السيارات، وصاحب المستشفى يسأل عن خطأ الطبيب الذي يعمل لديه فى مستشفاه، ولو لم يكن صاحب المستشفى نفسه طبيبا، إذ يكفي أن يكون للمتبوع الرقابة الإدارية والتنظيمية على التابع، بل حتى هذه يمكن ألا تكون له، كما لو كان المتبرع صبيا غير مميز، أو مجنونا، ومع ذلك يكون مسئولا عن أعمال تابعة باعتبار أن نائبه أو وليه، أو القيم عليه يتولى الرقابة عنه[3] .

---

(١) وبذلك يكون الجندي في الجيش تابعا لوزارة الدفاع، لأنه يتلقى منها التوجيه العام نحو ما ينبغي عليه القيام به

( استئناف مصر الوطنية في ٢٩ / ١٠ / ١٩٥٤ – المحاماة " ٢٦ رقم ٢٤٥ ص ٦٥٢ ) .

(٢) وبذلك يكون البواب تابعا لصاحب العمارة، ولا يكون تابعا للسكان ن حتى ولو كان يتقاضى منهم أجرا نظير خدمات بسيطة يؤديها، ومن ثم يكون صاحب العمارة مسئولا عن البواب إذا أحدث ضررا بالسكان أو بالغير، أو إذا سرق أحد السكان بإهمال من البواب ( السنهوري هامش ٣ ص ١١٣٩)،د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤١٦.

(٣)د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤٨٠، وانظر في هذا المعنى: السنهوري – السابق ص ١١٤٩ وما بعدها، د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤٣٧ .

ويجب أن تكون هذه الرقابة فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، وهذا ما يفرق بين مسئولية المتبوع (١٧٤ مدني ) ومسئولية متولي الرقابة (١٧٣مدني) فللأب وللمعلم فى المدرسة سلطة الرقابة والتوجيه على الولد أو التلميذ، ولكنها رقابة عامة لا تنصب على عمل معين، ومعلم الحرفة له الرقابة على الصبية فى عمل معين، حتى ولو كامن هذا العمل – وهو الغالب – لا يقوم به الصبية لحساب صاحب الحرفة بل ليتدربوا على العمل[1] .

وأخيرا: يجب التنويه إلى أن التابع إذا كان يؤدي عملا لمصلحة شخص آخر غير المتبوع بإذن من هذا المتبوع، فإن الأصل أن يظل المتبوع مسئولا عن عمل تابعة، إذ الفرض أن يستبقي لنفسه السلطة فى رقابة تابعة وتوجيهه، ومن ثم فإنه يسأل إذا وقع من التابع خطأ أثناء تأديته عملا لمصلحة ذلك الآخر، كما إذا استأجر شخص السيارة، وسائقها لنقله إلى جهة معينة، لكن إذا اتضح من ظروف الحال أن المتبوع قد تخلى عن سلطته على التابع إلى الشخص الآخر، كما إذا كان هذا قد استأجر السيارة وسائقها مشاهرة مثلا فإن السلطة تنتقل إلى هذا الآخر وفى هذه الحالة يصبح هذا الشخص الآخر هو المتبوع الذي يسأل عن خطأ التابع[2] ما يقال له المتبوع العرضي[3] – والمسألة هنا خاضعة لتقدير القاضي الموضع بلا رقابة عليه من محكمة النقض فى هذا الشأن.

---

(١) د/ إسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤٣٨، د/ عبد المنعم الصدة – السابق ص ٥٩٦، د/ عبد الودود يحيي – السابق ص ٢٨٨، د/ سمير تناغو – السابق ص ٢٨١ .

(٢) د/ عبد المنعم الصدة – السابق – الموضع السابق، وانظر د/ حشمت أبو ستيت – السابق ص ٤٨١.

(٣) انظر في ذلك: نقض مدني في ١٩٨٨/٣/١٦ مجموعة أحكام النقض المدني طعن ٢١٥٠ س ٥٤ ق .

**الشرط الثاني: خطأ التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها:**

لكي تتحقق مسئولية المتبوع يجب أولا أن تتحقق مسئولية التابع، ولكي تتحقق مسئولية التابع يجب أن يقع منه خطأ يسبب ضررا للغير، وذلك بأن تتوافر فى جانبه أركان المسئولية الثلاثة الخطأ، الضرر، علاقة السببية، فإذا انتفى خطأ التابع فلا مسئولية على التابع [1]، كما لو كان التابع غير مميز، أو كان مميزا ولكنه كان فى حالة دفاع شرعي، وإذا وقع الخطأ من التابع وجب أن يكون ذلك الخطأ قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، مع ملاحظة ان المضرور يقع عليه عبء إثبات خطا التابع ما لم يكن مفترضا فى جانبه[2]، كما لو كان مدرسا فى مدرسة، فتقوم مسئوليته على أساس الخطأ المفترض فى جانب متولى الرقابة، كما يجب أن يكون خطأ التابع قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، فهذا هو الذي يستساغ معه قيام مسئولية المتبوع، أما إذا وقع الخطأ بمناسبة الوظيفة، أو كان خطأ التابع أجنبيا عن الوظيفة، فلا تقوم مسئولية المتبوع[3] من مسئولية المتبوع أن يعلم المضرور، أو ان يكون فى استطاعته أن يعلم بمجاوزة التابع لحدود الوظيفة، كما إذا اتفق سائق سيارة مع صديق له على اختلاس سيارة متبوعة لتنزه بها معا، ثم وقع من السائق ( التابع) خطأ أدي إلى إصابة صديقه، فإن المتبوع – صاحب السيارة – لا يسأل عن

---

(١) انظر في ذلك نقض مدني – المجموعة السابقة في ١٦ / ٥/ ١٩٦٣ س ١٤ ص ٦٨٩ .

(٢) انظر: د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤٨٢،د/ محمد كامل مرسي – المرجع السابق ج٢ ف ١٤٤، د/ توفيق فرج – السابق ص ٤١٢.

(٣) انظر: د/ عبد الودود يحيي – المرجع السابق ص ٢٧٨، انظر بوجه خاص نقض مدني في ١٩٦٣/٥/١٦ مجموعة أحكام النقض المدني ص ١٤ ص ٦٨٩ .

خطأ التابع، لأن المضرور (الصديق) كان يدرك أن التابع – فى هذه الحالة – يعمل لحساب نفسه لا لحساب متبوعه[1].

(1) د/ عبد المنعم الصدة – المرجع السابق ص ٦٠١ –، د/ حشمت أبو ستيت – المرجع السابق ص ٤٨٦، د/ محمود جمال الدين زكي – المرجع السابق ص ٦٢٨، د/ لبيب شنب – المرجع السابق ص ٣٩١، د/ اسماعيل غانم – المرجع السابق ص ٤٤٣ .

# الباب الرابع
# الإثراء بلا سبب

**تمهيد**:

يقصد بالإثراء بلا سبب أن كلا من أثرى على حساب الغير دون سبب قانوني يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثرى به في حدود ما لحق الغير من خسارة، فإذا استولى شخص على شيء مملوك لغيره دون سبب قانوني فيلتزم برد أقل القيمتين، ما أثرى به هو، أو قيمة ما افتقر به الغير(١).

ولا شك أن هذه قاعدة تفرضها قواعد العدالة، ومبادئ القانون الطبيعي التي تتنافى مع احتفاظ المثرى بما أثرى به على حساب المفتقر نتيجة لإثرائه، ولذلك نادى بهذا المبدأ فقهاء الرومان بمناسبة بعد تطبيقاته، وتبعهم في ذلك فقهاء القانون الفرنسي القديم، وواضعوا قانون نابليون الحالي ١٨٠٤، الذين لم يضمنوه المبدأ وإن أوردوا بعض تطبيقات له، إلاأن القضاء الفرنسي اتترف بالمبدأ على فترات متعاقبة ووضع ضوابطه وحدوده وعني بتحديد أركانه وأحكامه.

(١) انظر: السنهوري السابق، ص: ١٢٤٨، د/ عبد الودود يحيى ، السابق، ص: ٣١٠، د/ الصدة، السابق، ص: ٦٣١.

# الفصل الأول
# أركان قاعدة البحث الإثراء بلا سبب

**أركان ثلاثة**:

سبق أن ذكرنا أن أُراء بلا سبب كما عرفته المادة ١٧٩ له أركان ثلاثة:

١-إثراء المدين .

٢-افتقار الدائن

٣-انعدام السبب القانوني لهذا الإثراء

فإذا توافرت هذه الأركان قامت دعوى الإثراء دون أهمية لأن تكون دعوى الإثراء دعوى احتياطية أو ضرورة أن يظل الإثراء باقياً إلى وقت رفع الدعوى(١).

**وسنعالج كل ركن من هذه الأركان في بند مستقل:**

**الركن الأول**: **وجوب تحقق الإثراء**:

يجب أن يتحقق إثراء المدين بلا سبب قانوني لأن هذا الإثراء هو مصدر الالتزام الذي يترتب في ذمته ومقصود بالإثراء كل منعة مادية أو أدبية لها قيمة مالية يحصل عليها المثري، سواء كان ذلك في صورة مال يكسبه أو في صورة خسارة يجنبها، وإذا لم يتحقق الإثراء بمعناه المذكور، فلا التزام حتى ولو كان هناك افتقار قد تحقق في جانب آخر، ومثاله أن يوفى شخص ديناً على آخر، ثم يتبين أن هذا الدين لم يوجد أو أنه كان موجوداً ثم حصل وفاة له، في هذه الحالة لم يتحقق إثراء، وم ثم لا يجوز للموفى الرجوع إلا على من دفع له إذا توافرت شروط دفع غير المستحق(٢).

---

(١) انظر في ذلك: السنهوري، المرجع السابق ١٢٦٨، د/ حشمت أبو ستيت، المرجع السابق، ص: ٥٢٣، د/ عبد الودود يحيى ، المرجع السابق ص ٣١٣.

(٢) د / عبد الودود يحيى، المرجع السابق، ص: ٣١٣، وانظر:د/ حسام الأهواني ،. المرجع السابق،

**الركن الثاني: افتقار الدائن ( المدعي )**

يجب أن يكون المدعي قد افتقر افتقاراً ترتب عليه إثراء المدعي عليه، ومن ثم فيجب هنا البحث في مسألتين في وجوب تعحقق افتقار الدائن ( المدعي ) وفي علاقة السببية ما بين افتقار المدعي وإثراء المدعي عليه.

**(أ) وجوب تحقق افتقار الدائن:**

يجب أن يتحقق افتقار الدائن[1] ( المدعي ) إذ إن افتقار المدعي هو الوجه المقابل لإثراء المدعي عليه، فإذا حصل إثراء من جانب شخص ولم يقابله افتقار في جانب شخص آخر، فلا تنطبق القاعدة، ومن ثم لا يجب التعويض، ولا يلتزم المثري برد أي شيء، لأنه يلتزم برد أقل القيمتين قيمة ما أثرى به، وقيمة ما افتقر به الشخص الآخر، فإذا لم يتحقق افتقار هذا الأخير فلا التزام في جانب المثري[2]، ومثاله: أن يقيم مالك في أرضه سداً يحفظها من مياه الفيضان، فاستفاد جار له من عملاه، وكمن يجمل حديقة منزله فترتفع قيمة منزل الجار لذلك، وكما إذا أمدت شركة مترو الأنفاق خطا في جهة معينة، فارتفعت قيمة الأرض في تلك الجهة .. إلخ.

**(ب) علاقة السببية المباشرة بين الافتقار والإثراء:**

يجب أن يكون افتقار الدائن هو السبب المباشر في إثراء المدني، ويتحقق ذلك عندما تكون هناك واقعة واحدة هي السبب المباشر لكل من الإثراء والافتقار، ومثال

---

ص: ٦٦٤، د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص: ٦٣٥.

(١) انظر: نقض مدني في ١٩٥٦/٦/٧، مجموعة أحكام النقض المدني س ٧، ص: ٦٧٢، ونقض مدني في ١٩٦١/١٢/٢٠، المجموعة السابقة س ١٢/، ص ١١٥٩

(٢) وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن "شرط افتقار المدعي هو شرط جوهري لدعوى الرجوع استناداً لقاعدة الإثراء بلا سبب، ونقض مدني في ١٩٦١/١٢/٢٠، المشار إليها سابقاً ص١١٥٩.

ذلك أن يوفى شخص ديناً على غيره، إذ إن واقعة الوفاء هنا هي التي أدت إلى افتقار سبب مباشر لكل منهما، ومثال ذلك أيضاً: قيام المستأجر بعمل ترميمات في العين المؤجرة هي في الأصل واجبة على المؤجر، إذ إن افتقار الأول وإثراء الثاني سببه واقعة واحدة هي قيام المستأجر بالترميمات ومن ثم توم السببية بين الإثراء والافتقار[١].

**الركن الثالث: انعدام السبب:**

لكي تكون بصدد إثراء على حساب الغير يلزم المثري بالرد: يجب أن يكون الإثراء المتحقق والافتقار المقابل مجردين عن سبب قانوني، ولا يقصد بالسبب هنا: السبب كركن من أركان العقد، وإنما يقصد به المصدر القانوني الذي يكسب المثري الإثراء، فيجعل له الحق في استبقائه، فالسبب إذن له معنى قانوني بحت، هو أن يكون للمثري حق في كسب الإثراء الذي حصل عليه، وهذا الحق قد يكون مصدره العقد، ومثال: حق الموهوب له، فلا يجوز للواهب أن يرجع على الموهوب له بدعوى الإثراء بلا سبب، لأن بين العاقدين تصرفاً قانونياً هو عقد الهبة الذي يبرر افتقار أحدهما وإثراء الآخر[٢]، ومن ثم مكحل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب عند وجود عقد يحكم علاقة الطرفين[٣].

---

(١) د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص: ٦٣٧، وانظر: د/، عبدالودود يحيى، المرجع السابق، ص: ٣١٦، د/ سمير تناغو، السابق ص: ٣٠٩.

(٢) انظر: مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٢ص ٤٤١، حيث جاء فيها: الشرط الثالث ألا يكون للإثراء الحادث أو افتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما، فلا يجوز للواهب مثلاً أن يرجع على الموهوب له بدعوى الإثراء بلا سبب لأن بين العاقدين تصرفاً قانونياً هو عقد التبرع يبرر افتقار أحدهما وإثراء الآخر.

(٣) انظر في ذلك نقض مدني في ١٩٧٧/١١/١٥، مجموعةو أحكام النقض المدني س٢٨، ص: ١٧٠٣ حيث جاء فيه: إذا كان الثابت أن علاقة الطاعن والمطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية، وتكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد

# الفصل الثاني

# الفضالة

## التعريف بالفضالة ـ طبيعتها القانونية

عرفت المادة ١٨٨ مدني الفضالة بقولها " الفضالة هي أن يتولى شخص عن قص القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك، ومثال: أن ينهض جار في غيبة جاره بأن يقيم جداراً يكاد أن ينقض في منزل الأخير، ويسمى المتدخل في شأن غيره فضولياً[١]، والمستفيد من التدخل " رب العمل "

والفضالة بهذا المعنى تعد . طبقاً للرأي السائد، تطبيقاً من تطبيقات القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب، إذ إن الفضولي يعمل لتحقيق منفعة للغير دون أن يكون لهذه المنفعة سبب في علاقة قانونية سابقة، وهذه هي مقومات الإثراء بلا سبب، ومع ذلك يظل هناك فارقاً جوهرياً بين الفضاللة والإثراء بلا سبب، حيث إنه في الإثراء بلا سبب لا يطلب عند المفتقر أي قصد إلى تحقيق منفعة الغير، بينما في الفضالة يفتقر الفضولي طوعاً بقصد خدمة مصلحة رب العمل، ويترتب على ذلك نتيجة هامة هي أن مبدأ الإثراء إذا كان يقضي بتعويض الفضولي عما تكبده، فإن القصد الذي صاحب عمله يقتضي له تعويضاً أكمل[٢].

---

حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر.

(١) أي أنه لابد أن يحصل ذلك على معنى التفضل لا على معنى التطفل.

(٢) د/ محمود جمال الدين زكي ، المصدر السابق، ص: ٧١٦، وانظر: د/ عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص: ٦٧١، د/ حشمت أبو ستيت المرجع السابق ص: ٥٥٧.

## المطلب الأول

## أركان الفضالة

**النصوص القانونية: أركان الفضالة ثلاثة:**

تنص المادة ١٨٩ مدني على أنه: " تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.

وتنص المادة ١٩٠ مدني على أنه: تشري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

**ويتضح من هذه النصوص أن الفضالة تتحقق بقيام أركان ثلاثة:**

١-ركن مادي: وهو قيام الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر.

٢-ركن معنوي: وهو أن يقصد الفضولي في قيامه بهذا الشأن مصلحة رب العمل.

٣-ركن قانوني: وهو ألا يكون الفضولي قد قام بالعمل تنفيذاً لالتزام عليه.

## المطلب الثاني

## أحكام الفضالة

**الفضالة ترتب التزامات في جانب الفضولي والتزامات في جانب رب العمل:**

**أولاً: التزامات الفضولي** :

**يلتزم الفضولي بأربعة التزامات هي :**

١-مضى الفضولي في العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه .

٢-أن يخطر الفضولي رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك .

٣-بذل عناية الشخص المعتاد في القيام بالعمل .

٤-تقديم حساب لرب العمل قام له ورد ما استولى عليه الفضولى بسبب الفضالة

**ثانياً: التزامات رب العمل** :

التزامات رب العمل تضمنتها المادة ١٩٥ مدني التى تنص على أنه: " يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته .

**ويستبين من هذا النص أن رب العمل يلتزم بالتزامات أربعة :**

١-تنفيذ التعهدات التى عقدها الفضولي بالنيابة عن رب العمل .

٢-تعويض الفضولي عن التعهدات التى عقدها باسمه شخصياً .

٣-رد النفقات الضرورية والنافعة، ودفع أجر الفضولي متى كان العمل الذي به يدخل في أعمال مهنته .

٤-تعويض الفضولي عما يمكن أن يكون قد أصابه من ضرر بسبب قيامه بالعمل (1).

---

( ١) يلاحظ أن مصدر هذه الالتزامات فيما عدا أولها – هو الإثراء بلا سبب ،وإن كان ما يعوض به الفضولي أكبر مما يعوض به المفتقر أما الالتزام الأول فمصدره النيابة كما أن الفضولي يستحق التعويض ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة من العمل .

# الباب الخامس

# القانون مصدر غير مباشر لجميع الالتزامات

لا شك أن القانون هو مصدر جميع الالتزامات لأن كل مصادر الالتزام تستمد قوتها من القانون، فالقانون هو الذي جعل العقد مصدراً للالتزامات والقانون هو الذى جعل الإرادة المنفردة مصدراً للالتزام والقانون هو الذي جعل العمل غير المشروع مصدراً للالتزام والقانون هو الذي جعل الإثراء بلا سبب مصدراً للالتزام، والقانون هو الذي حدد أحكام وأركان وآثار هذه المصادر المباشر للالتزام، ولكن طبقاً لقانون السببية وتدرج المصدر المباشر هو العقد، أو الإرادة المنفردة، أو الفعل في المشروع (١)، أو الإثراء بلا سبب أما القانون فهو المصدر غير المباشر لهذه الالتزامات، أي المصدر التى تستند إليه المصادر الأخرى وتستمد منه وجودها وأحكامها (٢).

**القانون مصدره مباشرة الالتزامات في حالات خاصة** :

تنص المادة ١٩٨ مدني على أن " الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص التى أنشأها (٣).

ويستبين من هذا النص أن القانون إذا كان يعتبر مصدراً لجميع الالتزامات – إلا أنه قد يكون مصدراً مباشراً بالنسبة لبعضها، ومصدراً غير مباشر بالنسبة للبعض الآخر .

---

( ١) د. سمير عبد السيد تناغو ، المصدر السابق – ص ٣٥١ ، وانظر في هذا المعنى: السنهوري – السابق ص ١٤٨٣ وما بعدها .

( ٢) جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني " كل الالتزامات أيا كان مصدره المباشر تصرفاً قانونياً أو عملاً غير مشروع " . مجموعة الأعمال التحضيرية ٢ / ٤٩٢.

( ٣) انظر المادة ٢٠٧ من مشروع القانون المدني المصري طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

فالالتزامات الناشئة عن العقد، والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب: مصدرها القانون، كل ما هنالك أن القانون يعتبر مصدراً غير مباشر بالنسبة لها، على ما سبق تفصيله، إلا أن هناك التزامات تنشأ عن القانون مباشرة، بحيث لا يكون لها مصدراً آخر غير حكم القانون الذي أنشأه أي أن القانون لا يعتبر مصدراً مباشراً للالتزام إلا إذا أنشأه بنص خاص، وهذا النص هو الذي يحدد أركان هذا الالتزام، وشروطه، وأحكامه، وآثاره (١).

**تطبيقات مختلفة للقانون كمصدر مباشر لبعض الالتزامات** :

هناك تطبيقات مختلفة للقانون كمصدر مباشر لبعض الالتزامات القانونية وهي منتشرة في شتى فروع القانون، إذ هي ليست قاصرة على نطاق قانون بعينه، وإليك بعض الأمثلة في أهم فروع القانون :

**أ – في التقنين المدني:** التزامات الفضولي والتزامات الجوار والالتزامات الناشئة عن الحائط المشترك، والحائط الملاصق، والالتزامات الناشئة عن الشيوع في الملك .

**ب – في قوانين الأحوال الشخصية:** التزامات الأسرة، حيث يدخل الالتزام بالنفقة الى رتبه القانون على قيام علاقة القرابة أو الزوجية والتزامات الأولياء والأوصياء والقوم .

**ج– في القوانين المالية:** الالتزام بدفع الضرائب .

---

( ١) انظر: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ٢ / ٤٩٠ التى ذكرت في هذا الصدد: أوجز المشروع إيجازا بينا فيما يتعلق بالالتزامات التى صدر عن نص القانون مباشرة ، وقد حداه على ذلك ما هو ملحوظ في ترتيب هذه الالتزامات وتنظيمها فكل التزام منها يتكفل ذات النص المنشئ له بتعيين مضمونه وتحديد مداه . السنهوري – السابق ص ١٤٤١ وما بعدها ، د . حشمت أبو ستيت – السابق ص ٥٧٨ ، د سمير تناغو – السابق ص ٣٥١ . د . عبد الودود يحيى – المرجع السابق ص ٣٦١ .

**د- في قانون الإثبات:** جواز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده تكون منتجة في الدعوى وذلك في الأحوال المنصوص عليها .

**هـ . في القانون التجاري:** جواز إلزام التاجر بتقديم دفاتره إلى المحكمة أو بتوصيلها إلى خصمه للاطلاع عليها(١) .

إلى غير ذلك من الالتزامات الواردة بنصوص خاصة في القوانين المختلفة(٢)

---

( ١) د . عبد المنعم الصدة – المرجع السابق – ص ٦٩٦ ، انظر في ذلك تفصيلاً: د. عبد الرزاق السنهوري – المصدر السابق – ص ١٤٦١ ، د. حشمت أبو ستيت – المرجع السابق – ص ٥٨٠ .

( ٢) انظر في ذلك نقض مدني فيس ١٩٧٧/٤/٢٧ مجموعة أحكام النقض المدي ص ٢٧ ص ١٠٧٦ الذي قضى بأن نص القانون هو مصدر الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون اتابع الإجراءات القانونية ، وانظر كذلك في أن نص القانون هو مصدر الالتزام: نقض مدني في ١٩٦٩/٦/١٢ . المجموعة السابقة س ٢٠ ص ٩١٤ .

## فهرس الموضوعات


| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| المقدمة | ٣ |
| الباب الأول: العقد وأحكامه | ٦ |
| الفصل الأول: انعقاد العقد (أركان العقد) | ٧ |
| المبحث الأول: التراضي | ٨ |
| المطلب الأول: وجود التراضي | ٨ |
| الفرع الأول: التعبير عن الإرادة | ٩ |
| الفرع الثاني: تطابق الإرادتين في القانون المدني | ١٦ |
| المطلب الثاني: صور خاصة من التراضي | ٣٦ |
| الفرع الأول: التعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة | ٣٦ |
| الفرع الثاني: عقود الإذعان | ٣٨ |
| الفرع الثالث: الوعد بالتعاقد | ٤٣ |
| الفرع الرابع: التعاقد بالعربون | ٤٨ |
| الفرع الخامس: النيابة في التعاقد | ٥١ |
| المطلب الثاني: صحة التراضي | ٦٣ |
| الفرع الأول: الغلط | ٦٤ |
| الفرع الثاني: التدليس | ٧٤ |
| الفرع الثالث: الإكراه | ٨٢ |
| الفرع الرابع: الاستغلال ( الغبن) | ٩٢ |
| المبحث الثاني: المحل | ١٠١ |

| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| المطلب الأول: المحل موجود أو ممكن الوجود | ١٠٢ |
| المطلب الثاني: شرط التعيين (المحل معين أو قابل للتعيين ) | ١٠٩ |
| المطلب الثالث: المحل قابل للتعامل فيه (شرط المشروعية) | ١١٢ |
| المبحث الثالث: السبب | ١١٥ |
| الفصل الثاني: جزاء الإخلال بقواعد تكون العقد (نظرية البطلان) | ١٢٢ |
| المبحث الأول: أحكام العقد الباطل وآثاره | ١٢٤ |
| المطلب الأول: أحكام البطلان المطلق | ١٢٤ |
| المطلب الثاني: آثار العقد الباطل بطلانا مطلقا | ١٢٦ |
| الفرع الأول: الآثار الأصلية للقد الباطل | ١٢٧ |
| الفرع الثاني: الآثار العرضية للعقد الباطل | ١٢٨ |
| المبحث الثاني: أحكام العقد القابل للإبطال | ١٣٣ |
| المطلب الأول: أحكام العقد القابل للإبطال ( البطلان النسبي ) | ١٣٣ |
| المطلب الثاني: آثار العقد القابل للإبطال | ١٣٦ |
| الفرع الأول: الإجـازة | ١٣٧ |
| الفرع الثاني: التقـادم | ١٤٠ |
| الفصل الثالث: آثـار العقد | ١٤٤ |
| المبحث الأول: آثار العقد بالنسبة إلى الأشخاص ( القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص ) | ١٤٤ |
| المطلب الأول: أثر العقود بالنسبة للخلف العام | ١٤٥ |
| المطلب الثالث : أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص | ١٤٧ |

| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| المطلب الثالث : أثر العقد بالنسبة للغير | ١٥٠ |
| الفرع الأول: التعهد عن الغير | ١٥١ |
| الفرع الثاني : الاشتراط لمصلحة الغير | ١٥٦ |
| المبحث الثاني: آثار العقد من حيث الموضوع | ١٦٤ |
| المطلب الأول : تحديد مضمون العقد | ١٦٥ |
| الفرع الأول: تفسير العقد | ١٦٥ |
| الفرع الثاني : تحديد نطاق العقد | ١٧٠ |
| المطلب الثاني: القوة الملزمة للعقد | ١٧٢ |
| الفرع الأول: ضوابط المبدأ العام فى الالزام بالعقد | ١٧٢ |
| الفرع الثاني: نظرية الحوادث الطارئة | ١٧٥ |
| الفصل الرابع: زوال العقد بالفسخ | ١٨٢ |
| المبحث الأول: الفسخ القضائي (الفسخ بحكم القضاء) | ١٨٣ |
| المبحث الثاني: الفسخ الاتفاقي (الفسخ بمقتضى الاتفاق) | ١٨٨ |
| المبحث الثالث: انفساخ العقد وتحمل التبعة | ١٩١ |
| المبحث الرابع: آثار الفسخ | ١٩٣ |
| الباب الثاني: الإرادة المنفردة | ١٩٦ |
| الفصل الأول : الأحكام العامة للإرادة المنفردة | ١٩٦ |
| الفصل الثاني: الوعد بجائزة الموجه للجمهور (الجعالة) | ٢٠٠ |
| الباب الثالث: العمل غير المشروع أو الفعل الضار | ٢٠٥ |
| الفصل الأول: المسئولية عن الأعمال الشخصية | ٢١٧ |

| الموضوع | الصفحة |
|---|---|
| المبحث الأول: الخطأ | ٢١٧ |
| المطلب الأول: عناصر الخطأ | ٢١٩ |
| المطلب الثاني: أهم تطبيقات الخطأ | ٢٢٧ |
| المطلب الثالث: حالات انعدام الخطأ | ٢٣٠ |
| المبحث الثاني: الضرر | ٢٣٥ |
| المطلب الأول : الضرر المادي | ٢٣٦ |
| المطلب الثاني : الضرر الأدبي أو المعنوي | ٢٤٣ |
| المبحث الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر | ٢٤٧ |
| المطلب الأول : تعدد الأسباب | ٢٤٩ |
| المطلب الثاني : انعدام السببية عند الضرر غير المباشر أو لقيام السبب الأجنبي | ٢٥١ |
| الفرع الأول : القوة القاهرة أو الحادث الفجائي | ٢٥٥ |
| الفرع الثاني: خطأ المضرور | ٢٥٩ |
| الفرع الثالث: خطأ الغير | ٢٦٥ |
| الفصل الثاني: المسئولية عن عمل الغير | ٢٧٠ |
| المبحث الأول: مسئولية متولي الرقابة | ٢٧٠ |
| المطلب الأول : شروط تحقيق مسئولية مسئولي الرقابة | ٢٧١ |
| المطلب الثاني: أساس مسئولية متولي الرقابة وكيفية دفعها | ٢٧٤ |
| المبحث الثاني : مسئولية المتبرع عن أعمال تابعه | ٢٧٦ |
| الباب الرابع: الإثراء بلا سبب | ٢٨٣ |

| الموضوع | الصفحة |
| --- | --- |
| الفصل الأول: أركان قاعدة البحث الإثراء بلا سبب | ٢٨٤ |
| الفصل الثاني: الفضالة | ٢٨٧ |
| المطلب الأول: أركان الفضالة | ٢٨٨ |
| المطلب الثاني: أحكام الفضالة | ٢٨٨ |
| الباب الخامس: القانون مصدر غير مباشر لجميع الالتزامات | ٢٩٠ |